المدخل للعلوم القانونية

أ.د/شحاتة غريب شلقامي

أستاذ القانون المدني ونائب رئيس الجامعة

لشئون التعليم والطلاب

أ.د/ خالد جمال أحمد حسن

أستاذ القانون المني

بكلية الحقوق جامعة أسيوط

طبعة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠م

الجزء الأول

نظرية القانون

أ.د/ شحاتة غريب شلقامي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

كما هو واضح من التسمية المدخل لدراسة القانون أو مبادئ القانون تعنى دراسة مجموعة من المبادئ الأولية والأسس القانونية العامة التي لا نستطيع الاستغناء عنها عند دراسة فروع القانون المختلفة ، فمبادئ القانون تنير لنا السبل لتفهم الموضوعات القانونية المفصلة ، فالقانون كسائر العلوم الأخرى له مصطلحاته الفنية التي يجب الإلمام بها ومعرفتها ، ولا نتمكن من معرفة هذه المصطلحات إلا من خلال هذا الكتاب عن المدخل لدراسة القانون .

وكتاب المدخل لدراسة القانون يهدف إلى تمكين طلاب الفرقة الأولى بكليات الحقوق من أخذ فكرة واضحة ومبسطة عن المبادئ الأساسية والمعلومات الأولية التي لا غنى عنها في دراسة فروع القانون المختلفة.

ويمكننا القول أن مادة مبادئ القانون تعتبر من أهم المواد المقررة على طلاب الفرقة الأولى بكليات الحقوق لأنها تنير لهم الطريق لفهم فروع القانون المختلفة وأساس هام لبناء وتكوين العقلية القانونية التي تستطيع دراسة وتحليل الموضوعات القانونية المتعمقة .

والقانون ضرورة اجتماعية ، ومما يؤكد ذلك أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يميل إلى الدخول في علاقات مع باقي أفراد المجتمع ، فلن يستطيع الإنسان أن يعيش في عزلة عن المجتمع بل يسعى دائما إلى الدخول في روابط وعلاقات مع معظم أفراد المجتمع، وإذا كان الإنسان اجتماعي الطبع فهو أناني الطبع أيضا يميل إلى إشباع رغباته وحاجاته دون النظر إلى رغبات وحاجات الآخرين من حوله .

من هنا يمكننا القول أن اجتماعية الإنسان وأنانيته في نفس الوقت قد تؤدى إلى وجود بعض التعارض بين المصالح المختلفة وإلى حدوث منازعات ، محاولا كل إنسان أن ينتصر تحقيقا لرغباته واحتياجاته ضاربا بعرض الحائط رغبات ومصالح الآخرين .

وإذا تركنا مسألة تسوية المنازعات إلى الأفراد لسادت الفوضى ولعم الظلم ولأضحت المساواة ضحية لأنانية الإنسان ، ولأصبح العدل مصطلحا يُعرّفه كل إنسان طبقا لرغباته وميوله !

لذلك كان لابد من وجود القانون للقضاء على شريعة الغاب وتحقيق الاستقرار في المجتمع ، فمن خلال مجموعة من القواعد القانونية نتمكن من تنظيم

العلاقات بين الأفراد في شتى المجالات لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ، فالقانون إذن لازمة من لوازم الحياة في المجتمع ، فهو الذي يكفل تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ، ويوفر الحد الأدنى من الأمن والنظام اللازمين لبقاء المجتمع وتطوره[1].

والقانون كما سنعرف يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ، وبيان ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات والتزامات ، فالقانون يرجح من بين المصالح المتعارضة بين الأفراد مصلحة أحدهم ويقرر له حقا ما في مواجهة الطرف الآخر ، وعلى هذا الأخير أن يحترم هذا الحكم وينفذ ما عليه من التزامات ، فالحق لا يوجد ولا يتقرر إلا من خلال القانون ، لذلك نرى أنه من المناسب في هذا الكتاب أن ندرس نظرية القانون ونظرية الحق ، ومن خلال نظرية القانون سنوضح ماهية القانون وأقسامه ومصادره وتطبيقه وتفسيره ، أما من خلال نظرية الحق سنوضح ما هو الحق وتقسيمات الحقوق وأنواعها ومصادرها وأصحاب الحق ومحل الحق وحمايته .

خطة الدراسة :

سنقسم هذه الدراسة إلى جزئين :

الجزء الأول : نظرية القانون .

الجزء الثاني : نظرية الحق .

---

[1] د. محمود سلام زناتى ، مدخل إلى العلوم القانونية ، ١٩٨٦ ، ص ٦ وما بعدها .



الجزء الأول

نظريـــــة القانـــــون

الباب الأول : ماهيـــــــة القانـــــــون .

الباب الثاني : أقسام القانــون وفروعه .

الباب الثالث : مصـــــــادر القانـــــــون .

الباب الرابع : تطبيق القانون وتفسيره .

الباب الأول

ماهيـة القانــون

القواعد القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار وهي مصحوبة بجزاء لإلزام المخاطبين بأحكامها أن ينصاعوا إلى مفهومها ، وهي في ذلك تختلف عن قواعد اجتماعية أخرى غير مقترنة بجزاء ، فمن يخالفها يواجه استنكار المجتمع أو يكتفي بتأنيب الضمير ، لكل ما سبق نرى أن ندرس هذه الموضوعات كى نوضح ماهية القانون في الفصول التالية :

الفصل الأول : التعريف بالقاعدة القانونية وبيان خصائصها .

الفصل الثانى : التمييز بين القانون والقواعد الاجتماعية الأخرى .

الفصل الثالث : دور القانون ووظيفته .

الفصل الأول

تعريف القاعدة القانونية وبيان خصائصها

سوف نتناول في هذا الفصل تعريف القاعدة القانونية وخصائصها لنوضح ما تتمتع به من عمومية والزام وأنها قاعدة سلوك من خلال المبحثين التاليين :

المبحث الأول : تعريف القاعدة القانونية من الناحية اللغوية والاصطلاحية.

المبحث الثانى : خصائص القاعدة القانونية .

المبحث الأول

تعريف القاعدة القانونية

لتعريف القانون لابد من تناول التعريف اللغوى ثم التعريف الاصطلاحي .

التعريف اللغوى للقانون :

يستخدم لفظ القانون للدلالة على كل قاعدة ثابتة ومستقرة وتؤدى إلى نتائج معينة ، ومن هذا المنطلق العام يستخدم لفظ القانون في مجالات شتى كمجال

العلوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى ، فعلى سبيل المثال نقول قانون الكون والذي يعنى النظام الفريد الذي وضعه المولى . سبحانه وتعالى . والمتصف بالثبات والانتظام كدوران الأرض حول الشمس ، وكتعاقب الليل والنهار ، ويمكننا أيضا أن نقول قانون الجاذبية الأرضية ، وقانون العرض والطلب في مجال علم الاقتصاد .

وكلمة قانون استخدمها العرب بمعنى القواعد التنظيمية على الرغم من أن هذه الكلمة ليست عربية الأصل بل هي مشتقة من أصل لاتينى والكلمة في اللاتينية هي KANON ومعناها القاعدة أو التنظيم ، وقد استخدم اليونانيون هذه الكلمة بمعنى العصا المستقيمة وهو المعنى الحرفي لكلمة KANON باليونانية[1].

التعريف الاصطلاحي للقانون :

أساتذة القانون يستخدمون مصطلح القانون للدلالة على معاني متعددة ، فعلى سبيل المثال يقصد بالقانون هو مجموعة القواعد التي تنظم بصورة ملزمة سلوك الأفراد في المجتمع وهذا هو المعنى الواسع لمصطلح القانون.

أما المعنى الضيق لمصطلح القانون يمكن أن يدل على عدة معاني :

١ . القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم على سبيل الإلزام سلوك الأفراد في بلد معين أو زمن معين فيقال مثلا القانون المصري ، أو القانون الفرنسي للدلالة على مجموعة القواعد القانونية السائدة في مصر أو في فرنسا .

٢ . قد يستخدم مصطلح القانون للدلالة على فرع معين من فروع القانون ، كالقانون المدني ، والقانون التجاري ، والقانون الدولي ، وغيرهم من

---

[1] انظر أ.د محمد حسام لطفي ، المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ، الكتاب الأول ، نظرية القانون ، القاهرة ٩٣ . ١٩٩٤م ، ص ٩ وما بعدها .

فروع القانون لتنظيم سلوك الأفراد ونشاطهم في مجال معين[١] .

٣ . قد يستخدم لفظ القانون للدلالة على القواعد القانونية التي تنظم مسألة معينة ، فيقال مثلا قانون المرور أو قانون تنظيم الجامعات وقانون الشهر العقاري ، وقانون الجوازات ، وقانون المحاماة وقانون الإصلاح الزراعي وغير ذلك

ويمكننا أن نشير إلى أن مصطلح القانون قد يستخدم للدلالة على القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية وبالتالي يعبر القانون عن التشريع بالرغم من أن هذا الأخير يعتبر أحد مصادر القانون وليس المصدر الرسمي الوحيد للقانون ، ولكن كما قال البعض هذا يعد من باب إطلاق الكل على الجزء ونظرا للأهمية العظمى التي يتمتع بها التشريع كأحد مصادر القانون[٢] .

ويجب التنويه إلى أن القاعدة القانونية تختلف عن الحق ، فالحق عبارة عن سلطة لشخص معين تخول له القيام بأعمال معينة لتحقيق مصلحة يحميها القانون ، أما القاعدة القانونية هي التي تمنح هذه السلطة ، فالقاعدة القانونية تقوم بتنظيم الروابط الاجتماعية عن طريق إنشاء الحقوق وفرض الواجبات ، فالقاعدة القانونية التي تقضى بأن "لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله ، واستغلاله والتصرف فيه" ، هذه القاعدة تعطى للمالك عدة حقوق في حدود القانون وعلى الغير احترام هذه الحقوق ، فالقاعدة القانونية إذن تنشأ الحق .

---

[١] انظر أ.د محمد حسام لطفي ، المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، الكتاب الأول ، نظرية القانون ، القاهرة ٩٣ . ١٩٩٤م ، ص ٩ وما بعدها.

[٢] انظر أ.د . أحمد سلامة ، المدخل لدراسة القانون ، نظرية القاعدة القانونية ، الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ ، ص ١٦ .



المبحث الثانى

خصائص القاعدة القانونية

من التعريف السابق للقانون يمكننا القول بأن القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتعلق بالسلوك الخارجي للأفراد في المجتمع والمنظمة لهذا السلوك على وجه من الإلزام .

لذلك القاعدة القانونية تتمتع بالخصائص الآتية :

١ . القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي .

٢ . القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة .

٣ . القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية .

٤ . القاعدة القانونية قاعدة ملزمة .

وفيما يلي نتناول كل خاصية من الخصائص آنفة الذكر في مطلب مستقل :

المطلب الأول

القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي

كما سبق الذكر عن تعريف القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع ، فالقانون عبارة عن مجموعة قواعد تتعلق بالسلوك فهو يهدف أولا وأخيرا إلى تنظيم هذا السلوك سواء بين الأفراد بعضهم البعض أو فيما بين الدول بعضها البعض ، فالقاعدة القانونية تخاطب الأشخاص الطبيعية وهم الأفراد والأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات والهيئات والنقابات والجمعيات .

وبذلك يمكننا القول بأن القاعدة القانونية لا تخاطب إلا هؤلاء الأشخاص ، فهي لا تخاطب الحيوانات أو الطيور والحشرات ، ولا يعنى ذلك أن القانون يتجاهل تماما وجود هذه الكائنات أو ما قد تحتاجه من حماية ورعاية ، فالقانون ينظم على سبيل المثال ملكية الإنسان للحيوانات ، وينظم أيضا المسئولية عن الأضرار التي قد تسببها الحيوانات للإنسان أو لحيوانات أخرى ، والقاعدة القانونية هنا لا تخاطب الحيوان بل تخاطب الشخص الذي يملكه[١] .

وفي شأن الأشخاص الاعتباريين يجب التنويه إلى أن القانون استوجب ضرورة وجود شخص طبيعى يمثل الشخص الاعتبارى ويوجه إليه خطاب المشرع الوارد في القاعدة القانونية كمدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة ما أو هيئة ما ، ولا شك أن هذا يعتبر نتيجة حتمية ومنطقية لعدم قدرة الشخص الاعتبارى على فهم أو إدراك خطاب المشرع[٢] .

والقانون عندما يخاطب الأشخاص يهدف إلى تنظيم السلوك ببيان الحقوق والالتزامات ، فعند قيام أ ببيع شيئا من الأشياء إلى ب ، فإن القانون يحدد حقوق كل من الطرفين والتزاماتهم وعلى كل طرف أن يحترم تنفيذ الالتزامات المفروضة على عاتقه كما أن لكل طرف المطالبة بحقوقه التي حددها له القانون.

والقانون لا يهتم إلا بالسلوك الخارجى للأفراد ، فالقانون ينظم العلاقات بين الأفراد لتوفيق المصالح بينهم وإزالة ما بينهم من تعارض ، أما النواحى والمسائل الداخلية فلا يهتم بها القانون إنما هي أمور باطنية لا يعلمها إلا المولى . سبحانه

---

[١] أ.د. محمد حسين عبد العال ، مبادئ القانون ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٨ ، ص ٢٤

[٢] أ.د. محمد سعد خليفة ، د. حمدى محمد عطيفي ، المدخل لدراسة القانون ، ٢٠٠٢ ، ص ١٣ .

وتعالى . وبالتالى قد تهتم بهذه الأمور الداخلية قواعد الدين أو الأخلاق وليس القانون.

لكن هذا لا يعنى أن القانون يستبعد النوايا تماما بل قد يدخل القانون نوايا وبواعث الأفراد الداخلية في الاعتبار وذلك إذا اقترنت بسلوك خارجى يدل عليها ، فالقانون يعتد بالنية في تكييف الجريمة الجنائية فلو أن شخصا عقد النية على قتل إنسان آخر وظلت هذه النية حبيسة في صدره لم تخرج للوجود فإن القانون لا يعاقب عليها ، وفي حالة قيام هذا الشخص بقتل إنسان بناء على هذه النية الكامنة في داخله فإن القانون يعامل الجانى عندئذ معاملة شديدة وتختلف عن الذي قتل بدون قصد .

وقد نصت المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات المصري على أن "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالاعدام".فهذا النص يوضح لنا مدى اعتداد المشرع بالنية ، ففي حالة قتل شخص بدون قصد وبدون نية كامنة بالقتل العقوبة ستكون أخف بلا شك من الاعدام .

وإذا كانت النية لها أهميتها كما سبق في مجال قانون العقوبات فإن لها أهمية أيضا في مجال المعاملات المدنية،فالقانون المدني ينص في المادة١/١٤٨على ضرورة تنفيذ العقود بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية،كما أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير طبقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني .

المطلب الثانى

القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

تتميز القاعدة القانونية بأنها عامة ومجردة بمعنى أن يكون الخطاب موجها إلى جميع الأشخاص وإلى جميع الوقائع التي يمكن أن ينطبق عليها ، فيجب أن

يكون الخطاب موجها إلى الكافة لا إلى شخص بعينه أو أشخاص بذواتهم ويجب إلا يخص القانون واقعة بعينها أو وقائع محددة بالذات ، فالعمومية تعنى أن يتوجه خطاب المشرع إلى الكافة ، والتجريد يعنى عدم أخذ في الاعتبار الظروف الخاصة أو الداخلية للأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية أو الوقائع المقصودة بها

فالقاعدة القانونية تتكون من فرض وحكم والمقصود بالفرض هو المشكلة أو الواقعة التي تعالجها القاعدة القانونية ، أما الحكم فهو الحل الذي تضعه القاعدة القانونية للمشكلة ، والقاعدة القانونية تكون دائما مجردة من حيث الفرض أو المشكلة التي تعالجها ، وتكون عامة من حيث الحكم أو الحل الذي تضعه للمشكلة ، فالحكم ينطبق على الجميع وليس على أشخاص معينين بذواتهم[١] .

وفي الواقع عمومية الحكم يعتبر النتيجة المنطقية لتجريد الفرض لأن التجريد يعنى عدم مخاطبة القاعدة القانونية لشخص معين بالذات أو مواجهة واقعة محددة بعينها .

وعمومية وتجريد القاعدة القانونية يعنى أن القاعدة تتجه بخطابها إلى كل من تتوافر منهم شروط تطبيقها ، فالقاعدة القانونية تتوجه بالخطاب إلى جميع المواطنين أو إلى طائفة منهم كالتجار أو الأطباء ، كما أن القاعدة القانونية يمكن أن تتوجه إلى شخص واحد بصفته وليس بذاته كشخص رئيس الدولة ، أو رئيس

---

[١] أ.د/محمد حسين عبد العال،المرجع السابق ، ص ٢٨ ، على سبيل المثال تنص المادة ١٦٣ على أن"كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"فالفرض هنا هو ارتكاب خطأ يسبب ضررا للغير أما==الحكم فهو التزام مرتكب الخطأ بالتعويض ، فالفرض في هذه الحالة مجرد لا يخص شخص معين بالذات منى أو محمد أو على،وبالتالى الحكم عاما وهو دفع التعويض والذي يكون على عاتق مرتكب الخطأ .

الوزراء ، فصفة العمومية والتجريد التي تتميز بها القاعدة القانونية تختلف عن الأوامر والقرارات الفردية الخاصة بفرد معين كقرار تعيين موظف أو قرار منح الجنسية لشخص معين لتوافر شروط اكتسابها ، كل هذه القرارات ينتفي عنها صفة العمومية والتجريد .

ويجب التأكيد على أن خاصية العمومية والتجريد التي تتمتع بها القاعدة القانونية لا تقتصر في عموميتها وتجريدها على الأشخاص الذين تتوجه بالخطاب إليهم بل يجب أن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة بالنسبة لموضوعها وهذا يعنى أنها تنطبق على عدد لا متناه من العلاقات المتماثلة التي تتوافر فيها شروط ومحددات معينة كالقواعد الخاصة بالبيع أو الإيجار أو المقاولة ، فكل علاقة من هذه العلاقات تقوم بين الأشخاص بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة تسرى عليها القواعد القانونية الخاصة بها مرتبة آثارها[1] .وصفة العمومية التي تتمتع بها القاعدة القانونية لا تعنى وجوب وضع القاعدة لزمن غير محدد أو أنها واجبة التطبيق في كل إقليم الدولة ، فالقواعد القانونية التي توضع لتطبق خلال مدة معينة كالقوانين الخاصة بالأحكام العرفية تعتبر عامة ، وأيضا القوانين الخاصة بجزء معين من إقليم الدولة لتعويض سكان في حالة الكوارث تعتبر عامة ولا ينفي عنها صفة العمومية كونها خاص بجزء معين من إقليم الدولة .

وقد ذهب البعض إلى أن صفة العمومية والتجريد والتي تتمتع بها القاعدة القانونية تعتبر عاملا جوهريا من عوامل المساواة السياسية بين أفراد المجتمع ، فتوجيه خطاب المشرع إلى عامة الناس دون تحديد شخص ما يؤكد مبدأ المساواة بين الجميع ويساعد على تحقيق مبدأ سيادة القانون ، ولا شك أن كل هذا سيؤدى

---

[1] د. عبد الرازق يس ، الوجيز في مبادئ القانون ، ٢٠٠٠ . ٢٠٠١ ، ص ١١ وما بعدها .

حتما إلى تحقيق العدل ، فيمكننا القول حينئذ أن صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية هي وسيلة تحقيق العدل ودعم مبدأ سيادة القانون وضمان للأفراد ضد جميع أشكال التمييز والتفرقة[1] .

المطلب الثالث

القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

الإنسان بطبعه كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده ، ولا يستطيع أن يكون في عزلة تامة عن أفراد المجتمع ، بل نجد الإنسان يرغب دائما في الدخول في علاقات مع باقي أفراد المجتمع ، وهذه العلاقات لابد وأن تكون منظمة ومحكومة بقواعد معينة ، والقانون هو الذي ينظم هذه العلاقات من أجل تحقيق الاستقرار للمجتمع وتوفير الأمن ومنعا لتفشى الفوضى والاستبداد .

لذلك يمكننا القول أن المجتمع لا غنى له عن القانون وإلا سادت الفوضى جميع ربوع المجتمع ، ويمكننا أيضا القول بأن القانون لا غنى له عن المجتمع ، فما الفائدة من القانون إذا لم يوجد مجتمع ، فبدون وجود المجتمع لا يوجد القانون.

وفي غيبة القانون تسود المجتمع وتسيطر عليه ما يطلق عليه شريعة الغابة ، أى أن القوى يأكل الضعيف والبقاء دائما له ، وأن الغنى يسلب حقوق الفقير ويستخدمه في أعمال السخرية دون مقابل ودون مراعاة لآدميته وحقوقه ، من هنا كان لابد من وجود نظام قانونى عادل يحقق التوازن في المجتمع.

ومما يؤكد غلبة الطبيعة الاجتماعية على القواعد القانونية نجد دائما أن القانون يعبر عن ظروف المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

---

[1] أ.د. محمد حسين عبد العال ، المرجع السابق ، ص ٣٣ .

كما نجد القانون يتطور بتطور المجتمع حتى لا يفقد مصداقيته ، فعلى سبيل المثال في هذا العصر المتقدم تقدما هائلا في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا برامج الحاسب الآلى وجدنا واضعى القانون يتدخلون لتعديل بعض قواعد القانون لمسايرة هذا التطور التكنولوجى العظيم ولا أدل على ذلك من قانون الملكية الفكرية الجديد[١] والذي يحمى مبتكرى برامج الحاسب الآلى ضد الاعتداءات القاتلة لإبداعهم الفكرى كنسخ البرامج مثلا[٢] .

ويمكننا أن نضيف أيضا لبيان غلبة الصفة الاجتماعية على القاعدة القانونية أن القانون في مجتمع ما قد تختلف قواعده عن قواعد القانون في مجتمع آخر لأن لكل مجتمع عاداته وقيمه وتقاليده والتي لابد من احترامها وأخذها في الاعتبار عند وضع القانون .

وقد ذهب البعض وبحق إلى أن القانون أصبح أحد العلوم الاجتماعية الهامة نظرا لصلته الوثيقة بالمجتمع ، فالقانون يهتم بالسياسة وذلك من خلال تنظيمه للدولة وبيان سلطاتها وأنظمة الحكم فيها وبيان أفضل طرق الحكم ، كما أن القانون يهتم بالاقتصاد وذلك من خلال تنظيمه لكيفية تداول الأموال وتوزيع الثروات ، والقانون يهتم أيضا ببواعث السلوك الاجتماعي ومظاهره ، ومن هنا نستطيع القول بأن القانون وثيق الصلة بعلوم النفس والاجتماع والأخلاق .

المطلب الرابع

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

---

[١] أنظر : القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية .

[٢] د. شحاته غريب شلقامى ، برامج الحاسب الآلى والقانون ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٣م ، ص ٨٤ وما بعدها .

كما نعرف القانون هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلوك الخارجى للأفراد على سبيل الإلزام ، فالقاعدة القانونية تعتبر قاعدة ملزمة بمعنى أن الأفراد إذا لم ينصاعوا إلى العمل وفقا لمضمون هذه القاعدة اختيارا ، أكرهوا على ذلك جبرا ، ولإحترام قواعد القانون لابد من وجود جزاء رادع يحمل الأفراد المخاطبين بأحكام القواعد القانونية على تنفيذها والعمل وفقا لمضمونها ، وبالطبع السلطة العامة في الدولة هي التي تتولى توقيع وتنفيذ الجزاءات بما لها من وسائل تساعدها على ملاحقة الخارجين والمخالفين لقواعد القانون .

ولا شك أن اقتران القواعد القانونية بجزاءات يعتبر أمر ضرورى وحتمى لحمل الأفراد المخاطبين بأحكامها على احترام هذه القواعد ضمانا لتحقيق الاستقرار في المجتمع وتتويجا لمبدأ سيادة القانون ، ذلك أن ترك القواعد القانونية دون جزاء يكفل احترام مضمونها سيؤدى بالضرورة إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار وضياع الحقوق ، ومن هنا يؤكد الجميع أن احترام قواعد القانون هي سمة من سمات المجتمعات المتقدمة والراقية لأن الأفراد كلما ازداد تقدمهم ورقيهم الفكرى كلما ازداد الاحساس بالحاجة إلى احترام قواعد القانون لتحقيق غاية أسمى ألا وهي إقامة النظام .

ويجب التنويه إلى أنه رغم رقى بعض الأفراد وسعيهم نحو احترام قواعد القانون من أجل إقامة النظام يوجد العديد من أفراد المجتمع الذين يميلون إلى خرق هذه القواعد ، وعدم احترام أحكامها ، فكان لابد من اقتران هذه القواعد بجزاءات رادعة ضمانا لاحترامها وتحقيق العدل في المجتمع ، فالجزاء أمر ضرورى تقتضيه صفة الإلزام في القاعدة القانونية ، وفيما يلى سنوضح ماهية الجزاء والمقصود به وخصائصه وأنواعه .

في الواقع الجزاء هو عبارة عن النتيجة المترتبة على عدم احترام ومخالفة

القاعدة القانونية ، ويتضح لنا من هذا التعريف أن الجزاء يتمتع بالخصائص التالية :

خصائص الجزاء في القاعدة القانونية وتطوره :

من خلال التعريف السابق للجزاء نجد أنه يتمتع بالخصائص التالية :

- الجزاء حال غير مؤجل ، ومعنى ذلك هو وجوب أن يكون الجزاء فوريا ومباشرا بحيث يوقع على المخالف في الحال ، عند ثبوت مخالفته لمضمون وأحكام القاعدة القانونية ، وهذه الخاصية تميز القواعد القانونية عن قواعد الأخلاق أو القواعد الدينية والتي يؤجل فيها الجزاء للآخرة .

- الجزاء مادى ومحسوس ، ومعنى ذلك هو ضرورة أن يتخذ الجزاء مظهرا خارجيا ملموسا يتمثل في الاجبار الذي تباشره السلطة العامة بالقوة المادية ، فالجزاء يوقع على المخالف لأحكام القاعدة القانونية في نفسه أو في ماله حسب الأحوال ، فالجزاء المقترن بالقاعدة القانونية يختلف عن الجزاء الأخلاقى المتمثل في تأنيب الضمير أو استنكار الناس لسلوك المخالف للقواعد الأخلاقية .

- الجزاء منظم قانونا بحيث تتولى السلطة العامة في الدولة مهمة تنفيذه وتطبيقه على كل من يخالف أو يخترق أحكام القاعدة القانونية ، فلا يجوز للأفراد من غير السلطة العامة القيام بتنفيذ الجزاء أو تطبيقه تحاشيا ومنعا لانتشار الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع .

وقد مر الجزاء من حيث تنظيمه وتطوره بمراحل مختلفة ، ففي المجتمعات القديمة كان توقيع الجزاء موكولا إلى الفرد الذي وقع عليه الاعتداء ، فقد كان هذا الفرد هو الذي يتولى بنفسه توقيع الجزاء أو تتولاه عائلته أو قبيلته ، فقد كان أقارب القتيل أو عائلته يقتصون من القاتل على مرأى ومسمع من جميع أفراد القبيلة على

أساس أن هذا القصاص هو الجزاء المناسب لما أقترفه القاتل في حق أهل القتيل بصفة خاصة وفي حق المجتمع بصفة عامة .

وقد عرفت المجتمعات القديمة نظاما آخر بديلا للقصاص وهو نظام الدية ، حيث يتحمل القاتل دفع مبلغ من المال كدية عن القتل بمفرده أو بالاشتراك مع أقاربه ، ودفع هذه الدية كان يتم في حضور البعض من أفراد القبيلة ، وفي حالة عدم قبول المعتدى عليه للدية كان يلجأ إلى القوة للحصول على حقه .

وفي المعاملات المدنية نجد أن القانون الرومانى كان يعطى للدائن الحق في المساس بحرية المدين كحبسه أو بيعه استيفاء لدينه ، فقد كان الجزاء بدنيا ، وتطور حتى أصبح يتعلق بأموال المدين[1] .

ومع تطور المجتمعات وظهور الدولة الحديثة انتهي عصر القصاص أو القضاء الخاص والذي كان يتولى فيه الفرد توقيع الجزاء بنفسه ، فقد ظهرت الدولة الحديثة بمقوماتها وسلطاتها المختلفة بما لها من نفوذ وسلطان وصلاحيات ، لتوقيع الجزاء على المخالف لأحكام القانون تحقيقا للعدل ، وبالتالى أصبحت الدولة هي المحتكرة لسلطة توقيع الجزاءات ولم يبق في عصر الدولة الحديثة من آثار القضاء الخاص إلا بعض الحالات الاستثنائية كحالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال ، فيجوز للأفراد الدفاع عن أنفسهم وعن أموالهم في حالة الاعتداء عليهم ولكن بالقوة المناسبة وبشروط معينة ، وإلا تعرضوا للعقوبة وفقا لأحكام القانون .

صـــور الـجزاء :

---

[1] لقد ظل الجزاء البدنى سارى العمل بـه في القانون االفرنسي على أن تم إلغائه بقانون ٢٢ يوليو ، ١٨٦٧ والذي بدوره ألغى الاكراه البدنى في المعاملات المدنية إلا في أحوال استثنائية .



الجزاء الذي تقوم بتوقيعه السلطة العامة في الدولة لا يتخذ شكلا واحدا وإنما يختلف باختلاف فروع القانون التي وقعت المخالفة بشأنها ، لذلك يمكننا القول أن الجزاء يتنوع إلى عدة صور منها :

١ ـ الجزاء الجنائـى .

٢ ـ الجزاء المدني .

٣ ـ الجزاء الإدارى .

٤ ـ الجزاء السياسى .

وفيمـا يلـى سنوضـح المقصـود بكـل صـورة مـن صـور الجـزاء آنفة الذكر .

١ ـ الجزاء الجنائى :

يعتبر الجزاء الجنائى أشد صور الجزاء المقرر عند مخالفة القاعدة القانونية وهو عبارة عن العقوبة المقررة عند ارتكاب جريمة معينة مكتملة الأوصاف ومستوفية الشروط كما حدد ذلك قانون العقوبات ، فالجزاء الجنائى يعتبر عقوبة وهذه العقوبة قد تمس الشخص في نفسه وحياته كالإعدام ، أو في حريته الشخصية كالسجن المؤبد أو المشدد والسجن والحبس أو في ذمته المالية كالغرامة والمصادرة .

وكما قلنا منذ قليل الجزاء الجنائى يعتبر أشد صور الجزاء خاصة وأن العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع العام والردع الخاص ، فمن حيث الردع العام ، العقوبة تهدد كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ، أما من حيث الردع الخاص نجد أن العقوبة تهدد مرتكب الفعل المحظور من العودة لإرتكاب مثل هذا الفعل مرة أخرى

والعقوبة تختلف من حيث جسامتها وشدتها تبعا لاختلاف طبيعة الجريمة

المرتكبة وما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، فالقانون قد قسم الجرائم إلى صور مختلفة كما سبق ونجد أن أشدها وأبشعها هي الجنايات .

والجنايات طبقا لنص المادة ١٠ من قانون العقوبات المصري هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

الإعدام : هي أقصى العقوبات المقررة في القانون الجنائى لأنها تنطوى على حرمان الجانى من حياته ، وهذه العقوبة تنفذ عن طريق الشنق وفقا للمادة ١٣ من قانون العقوبات المصري ، وهذه العقوبة لا تطبق إلا على نوعية خاصة من الجرائم التي تمثل إخلالا فادحا بأمن المجتمع ونظامه وحياة أفراده .

السجن المؤبد : هذه العقوبة تستغرق حياة المحكومة عليه كلها ، ويجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعد مضى ٢٠ سنة إذا أثبت خلالها أنه حسن السيرة والسلوك .

السجن المشدد : هذه العقوبة لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة .

السجن : هذه العقوبة لا تنقص عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة وطبقا لهذه العقوبة يودع المحكوم عليه أحد السجون العمومية ويتم تشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة طوال المدة المحكوم بها عليه (مادة ١٦ عقوبات)

مما سبق يتضح لنا أن الجنايات وهي أشد الجرائم خطورة يعاقب مرتكبها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو السجن حسب الأحوال .

أما الجنح فهي الجرائم التي يعاقب عليها بالعقوبات الآتية (مادة ١١ عقوبات):

الحبس : لا يجوز أن تنقص مدته عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد

على ثلاث سنوات بحسب الأصل (مادة ١٨ عقوبات) ، ويتم تنفيذ الحبس بوضع المحكوم عليه أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم عليه بها ، وعقوبة الحبس نوعان الحبس البسيط ، والحبس مع الشغل ، والحبس البسيط عبارة عن أن المحكوم عليه يقضيه دون أن يكلف بشغل داخل السجن ، أما الحبس مع الشغل هو تشغيل المحكوم عليه داخل السجن أو خارجه طبقا لما تقتضيه المادة ١٩ عقوبات .

ويجب التنويه إلى أن كل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر له الحق في أن يطلب تشغيله خارج السجن طبقا لما هو مقرر بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه ، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إذا نص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار (مادة ١٨ عقوبات) .

الغرامة : تتمثل في الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ معين من المال إلى خزينة المحكمة.وإذا كانت الجنح معاقب عليها بالحبس أو الغرامة ، نجد أن المخالفات معاقب عليها بالغرامة .

وجدير بالذكر أنه نظرا لخطورة التجريم والعقاب نجد معظم الدساتير تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وإذا كانت العقوبات سالفة الذكر هي العقوبات الأصلية نجد أن هناك عقوبات تبعية تطبق بقوة القانون إلى جانب العقوبات الأصلية ، كما أن هناك عقوبات أخرى تكميلية لا تطبق إلا إذا قررها القاضى في حكمه .

٢ ـ الجزاء المدني :

هو الجزاء الذي يوقع عند الاعتداء على حق خاص أو إنكاره أو هو الأثر الذي يرتبه القانون على مخالفة قاعدة تحمى مصلحة خاصة أو حقا خاصا ، ويمكننا أيضا القول بأن الجزاء المدني هو الجزاء الذي يوقع عند ثبوت المسئولية

المدنية . والجزاء المدني يأخذ صور متعددة :

البطلان : الذي يترتب في حالة إبرام التصرفات القانونية بطريقة مخالفة لما ينص عليه القانون كبطلان تصرفات الصبى غير المميز واعتبارها في حكم العدم طبقا لنص المادة ١١٠ من القانون المدني المصري ، كما أن العقد يكون باطلا وفي حكم العدم إذا كان محله مخالفا للنظام العام والآداب العامة ، وبالإضافة إلى البطلان يوجد القابلية للإبطال في حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد مثلا كتوافر عيوب الرضا من غلط أو تدليس أو اكراه أو استغلال ، ويكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب إرادته عيب من العيوب السابقة ، ويجوز له وحده التمسك ببطلان العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد .

إجبار الشخص على القيام بما لم يقم به طواعية واختيارا :كإلزام المؤجر بتمكين المستأجر من العين المؤجرة طالما أنه وفي بكل التزاماته

الفسـخ : والذي يترتب عليه أيضا إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، والفسخ يفترض أن العقد المبرم بين الطرفين نشأ صحيحا لكن هناك استحالة في تنفيذه كعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ ما عليه من التزامات أو تأخر في تنفيذه أو نفذه بطريقة معيبة ، هنا يجوز طلب الفسخ لحل الرابطة التعاقدية .

التعويض : الجزاء المدني قد يتخذ صورة التعويض وذلك لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور ، وكما ورد في المادة ١٦٣ مدنى "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" .

والتعويض قد يكون هو الجزاء الأصلى للمخالفة كالتعويض الذي يلتزم به

صاحب سيارة عن الإصابة التي تسبب فيها للغير ، وقد يكون التعويض ليس أصليا للمخالفة ولكن لتعذر واستحالة تطبيق الجزاء الأصلى يكون التعويض ، وذلك في حالة تعذر تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا لما فيه من مساس بحرية المدين الشخصية ، كتعهد رسام برسم لوحة أو فنان بإحياء حفلة ، هنا نلزمه بالتعويض في حالة عدم تنفيذ التزامه لأن اجباره على تنفيذ التزامه عينيا فيه مساس بحريته الشخصية .

والتعويض ثلاثة أنواع : إتفاقى وقضائى وقانونى ، الاتفاقى يكون نتيجة اتفاق الأطراف مقدما على مقداره وشروطه ، أما التعويض القضائى يحكم به القاضى ويقدره بحسب ما لحق الشخص من خسارة وما فاته من كسب ، وأخيرا التعويض القانونى وهو عبارة عن الفوائد الربوية وهي ٤% في المسائل المدنية ، و ٥% في المسائل التجارية ، ويجوز الاتفاق على سعر آخر للفوائد لا يزيد على ٧% وفقا للمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدني المصري .

٣ ـ الجـزاء الإدارى :

هو الجزاء الذي يوقع على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالوظيفة العامة .

وصور الجزاء الإدارى متعددة فمنها الإنذار أو لفت النظر أو اللوم ، أو تأجيل منح العلاوة ، وقد يصل الجزاء إلى حد الفصل من الوظيفة العامة .

٤ ـ الجـزاء السياسى :

هو الجزاء الذي يوقع عند الإخلال وانتهاك أحكام الدستور ، كإعمال المسئولية الوزارية للحكومة أمام البرلمان ، وحق رئيس الدولة في حل مجلس النواب ، وللجزاء السياسى صورة أخرى تتمثل في ثورة الرأى العام وإثارة الاضطرابات والتظاهرات .

الفصل الثانى

التمييز بين القانون والقواعد الاجتماعية الأخرى

من خلال ما سبق دراسته تبين لنا أن القواعد القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع على سبيل الإلزام تحقيقا للإستقرار وترسيخا لمبدأ سيادة القانون ، لكن ليس معنى ذلك أن القواعد القانونية هي القواعد الوحيدة الموجودة بالمجتمع والتي تنظم سلوك أفراده ، فالواقع يوضح لنا ويكشف عن وجود قواعد أخرى اجتماعية تنظم أيضا سلوك الأفراد في المجتمع ، فعلى سبيل المثال نجد قواعد الأخلاق والقواعد الدينية وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد ، فكل هذه القواعد تحتوى على مبادئ ومثل عليا وتدعو الأفراد إلى إتباعها والعمل بمقتضاها ، وفي الحقيقة هذه القواعد وإن كانت تنظم سلوك الأفراد كالقواعد القانونية إلا أنها تختلف عنها من حيث المصدر والغاية والنطاق .

لذلك نرى دراسة التفرقة بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى في المباحث التالية :

المبحث الأول : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الدين .

المبحث الثانى : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق .

المبحث الثالث : التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد المجاملات .

وفيما يلى سنتناول بالشرح كل مبحث من المباحث آنفة الذكر .

المبحث الأول

التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الدين

القواعد الدينية هي عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي التي يؤمن بها الناس نظرا لأنها منزلة من الله . سبحانه وتعالى . عن طريق رسله ، وهذه الأوامر والنواهي تنظم سلوك الأفراد في الحياة ، وتدعوا الجميع إلى الامتثال لتعاليم الله . سبحانه وتعالى . تحقيقا للعدل والمساواة بين جميع الناس .

والقواعد الدينية تتفق مع القواعد القانونية في أنها :

- تنظم سلوك الأفراد في المجتمع .
- عامة ومجردة لأنها لا تخاطب شخص معين بالذات إنما هي موجهة لجميع الناس ، وتدعوهم إلى اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه .

والقواعد الدينية تنظم سلوك الإنسان في تعامله مع غيره من أفراد المجتمع ، وأيضا علاقة الإنسان بنفسه ، كما أن هذه القواعد تنظم علاقة الإنسان بربه من حيث الإيمان به وعبادته ، وفي هذا تختلف القواعد الدينية عن القواعد القانونية ، وقبل أن نوضح هذا الاختلاف يجب التنويه إلى أن قواعد الدين لها صلة وثيقة بالقانون خاصة وأنها تعتبر مصدرا احتياطيا وتاريخيا للقاعدة القانونية ، وحتى في البلاد الإسلامية والتي تأخذ بالقوانين الوضعية نجد أنها تطبق أحكام الدين في مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقات[١] .

ويمكننا التأكيد على أن الدستور المصري لسنة ٢٠١٤ نص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع ، وبالتالى أية قوانين تصدر لابد وأن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وينبغى على السلطة التشريعية مراجعة كافة القوانين التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية لأنها

---

[١] يجب معرفة أن قواعد الدين في هذه المسائل "مسائل الأحوال الشخصية" تعتبراً مصدراً أصلياً للقانون .

في هذه الحالة ستكون قوانين غير دستورية .

ورغم الصلات بين القواعد الدينية والقواعد القانونية كما ذكرنا ، إلا أنه يوجد اختلاف بينهم من عدة وجوه :

من حيث المصــدر :

القواعد الدينية مصدرها المولى سبحانه وتعالى ، فهي منزلة من عنده عن طريق رسله لتنظيم الحياة ، أما القواعد القانونية قام بوضعها البشر (البرلمان) ويترتب على هذه التفرقة نقطة هامة وهي أن القواعد الدينية لا تتغير فهي صالحة لكل زمان ومكان لأنها منزلة من الله سبحانه وتعالى ، أما القواعد القانونية قابلة دائما للتعديل والتغيير لأن واضعها هم البشر لا حول لهم ولا قوة .

من حيث المضمـون :

القواعد الدينية أوسع نطاقا من القواعد القانونية لأنها تنظم علاقة الفرد بنفسه وبغيره من الأفراد ، وأيضا علاقته بربه سبحانه وتعالى ، كما أن القواعد الدينية تضع تنظيما للدنيا والآخرة أيضا ، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن القواعد الدينية تهتم بالبواعث والنوايا في حين أن القواعد القانونية لا تهتم إلا بالسلوك الخارجى للأفراد

من حيث الغايــة :

في الواقع كل من القواعد الدينية والقانونية تهدف إلى تحقيق الخير والسلام في المجتمع ، لكن نجد أن غاية القواعد الدينية هي المثالية والسمو بالنفس البشرية تحقيقا للاستقرار وتدعيما للروابط الاجتماعية ، في حين نجد القواعد القانونية هدفها وغايتها نفعية فقط من أجل الرقى بالمجتمع وتتغاضى بعض الأحيان عن المثل والقيم ، وعلى سبيل المثال نجد القواعد القانونية تقر الغاصب على ما أغتصبه دون وجه حق إذا وضع يده عليه مدة معينة .

من حيث الجــزاء :

القواعد القانونية لها جزاء دنيوى فقط ، فمن يخالف أحكامها يعاقب حسب ما اقترفه من مخالفة ، أما القواعد الدينية نجد أن الجزاء المقترن بها دنيوى وأخروى ، فهناك عقوبة في الدنيا وجزاء في الآخرة حيث يحاسب المولى سبحانه كل غير متبع لأوامره وكل منفذ لنواهيه .

المبحث الثانى

التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الاخلاق

يقصد بقواعد الأخلاق مجموع المبادئ والأنماط السلوكية المقرة من قبل غالبية الناس والمستقرة في وجدانهم بهدف تحقيق المثل العليا والعمل على نشر الخير والفضيلة كمساعدة الضعفاء واجتناب الشر وعدم الاعتداء على النفس أو على المال.

ومن خلال هذا التعريف آنف البيان يتضح لنا أن قواعد الأخلاق مثلها مثل القواعد القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، وأنها عامة وموجهة لكافة الناس ، فهي لا تخاطب شخص معين بذاته إنما تخاطب جميع أفراد المجتمع ، ورغم هذا الاتفاق يمكننا القول أن قواعد الأخلاق تفترق عن القواعد القانونية من عدة وجوه :

من حيث الغايــة :

تهدف القواعد القانونية إلى حفظ النظام في المجتمع وتحقيق الاستقرار ، لكن قواعد الأخلاق نجد أن غايتها مثالية ، فهي تهدف إلى تحقيق الكمال ، وتأخذ من الشخص الكامل نموذجا لها بينما القواعد القانونية تأخذ من الشخص العادى نموذجا لها ، فيمكننا القول أن قواعد الأخلاق تحاول خلق مجتمع من الملائكة ، أما القانون فلا ينشد سوى إقرار النظام داخل المجتمع .

من حيث الجــزاء :

كما سبق الحديث وجدنا أن القاعدة القانونية تكون مقترنة بجزاء ومن يخالفها يقع تحت طائلة القانون ، وقد بينا آنفا أن الجزاءات متعددة فمنها مدنى أو جنائى أو إدارى ، أما فيما يتعلق بقواعد الأخلاق فهي لا تقترن بجزاء مادى ملموس كالحبس أو الغرامة عند مخالفتها إنما تكون مقترنة بتأنيب الضمير أو استنكار الناس لمن يخالفها ، فلا توجد سلطة عليا تجبر الأفراد على احترام القواعد الخلقية بعكس الحال عند انتهاك القواعد القانونية حيث توجد سلطة عليا تعاقب من يخالف القاعدة القانونية .

من حيث الوضوح والتحديد :

القاعدة القانونية تصاغ في عبارات واضحة ومحددة قبل أن تصبح نصوصا في تشريع معين ، لذلك تتسم القواعد القانونية بالدقة والوضوح والتحديد ، وعند التعرف على حكم قاعدة قانونية نجد أنه يكفي مطابقة النص لفهم الحكم الذي تنطوى عليه هذه القاعدة ، أما قواعد الأخلاق نجدها غامضة وغير منضبطة لأنها أحاسيس داخلية موجودة في وجدان الأفراد وقد تتفاوت هذه الأحاسيس من جهة وقد تتعارض مع شعور الجماعة من جهة أخرى .

وجدير بالذكر أن هذا الاختلاف يرجع إلى أن المصدر مختلف ، فمصدر القاعدة القانونية هو التشريع والعرف ، أما مصدر قواعد الأخلاق متعدد كالتاريخ والتراث والمعتقدات الدينية السائدة والأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في مجتمع ما .

من حيث المجال :

قواعد الأخلاق أوسع نطاقا ومجالا من القواعد القانونية لأنها لا تهتم فقط بالسلوك الخارجى للأفراد إنما تهتم بالبواعث والنوايا الداخلية ، فقواعد الأخلاق لا تكتفي بالحكم على التصرفات الظاهرة فقط إنما تهتم بالمقاصد خاصة وأنها تبتغى

تحقيق الكمال .

أما القواعد القانونية لا تهتم إلا بالسلوك الخارجى للأفراد ، وإذا أخذت أحيانا بالنوايا فهي لا تهتم بها إلا من أجل الحكم على السلوك الخارجى للأفراد .

الصلة بين القانون والأخلاق :

لقد أوضحنا أن هناك اختلافات بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق ، لكن هذه الفروق لا تعنى انعدام الصلة بينهم ، فكثير من قواعد القانون تعتبر قواعد أخلاقية أو تطبيقا لمبادئ ومثل عليا ، فالقواعد القانونية التي تحرم الاعتداء على جسم الإنسان وعلى ماله تعتبر قواعد أخلاقية ، والقواعد القانونية التي تمنع التعسف في استعمال الحق تعتبر أيضا قواعد خلقية .

ورغم هذه الصلة بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق إلا أنه توجد اختلافات بينهم ، فنجد أن هناك العديد من المبادئ الأخلاقية كالدعوة إلى الخير ونبذ الحقد والكراهية تكون بعيدة عن التنظيم القانونى ، وبالإضافة إلى ذلك نجد بعض القواعد القانونية التي تتعارض مع المثل العليا والمبادئ الأخلاقية وعلى سبيل المثال القاعدة القانونية التي تحمى الحائز سيئ النية إذا وضع يده على أرض ما مدة طويلة تكون متناقضة مع مبادئ الأخلاق والمثل العليا .

المبحث الثالث

التمييـز بين القاعدة القانونية وقواعد المجاملات

يقصد بقواعد المجاملات هي القواعد التي يستقر الناس في المجتمع على اتباعها من عادات وتقاليد ، وهذه القواعد لا يفرضها قانون أو دين معين ، إنما هي نابعة من عادات وتقاليد الشعب ، ومن أمثلة هذه القواعد زيارة المريض ، والتهنئة في المناسبات السعيدة كالزواج والأعياد ، والعزاء في المآتم والكوارث .

وقواعد المجاملات تتفق مع القواعد القانونية في أنها تنظم سلوك الأفراد ، وأنها عامة مجردة ، ولكنها غير مقترنة بجزاء فمن يخالفها لا يجد سوى جزاء معنوى يوقع على المخالف كاستنكار الناس له .

ويجب التنويه إلى أن قواعد المجاملات قد تتحول إلى قواعد قانونية عند تزايد قيمتها الاجتماعية ، فالقواعد الخاصة بمعاملة السلك الدبلوماسى هي في الأصل قواعد مجاملات ، لكن نظرا لتزايد أهميتها أصبحت قواعد قانونية معترف بها في القانون الدولي العام .



البـاب الثانـى

أقسام القانون وفروعه

هناك تقسيمات عدة للقانون بحسب الزاوية المنظور منها ، فقد قسم الفقهاء القواعد القانونية إلى قواعد قانون عام ، وقواعد قانون خاص ، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المخاطبين بهذه القواعد ، ويقسم البعض قواعد القانون إلى قواعد موضوعية ، وقواعد اجرائية ، موضوعية لأنها تحدد الحقوق والواجبات ، واجرائية لأنها تبين الاجراءات المتبعة للحصول على هذه الحقوق .

وهناك فريق آخر قد قسم قواعد القانون إلى قواعد خارجية تهتم بالعلاقات بين الدول أو الهيئات الدولية ، وأخرى داخلية تختص بتنظيم العلاقات في الداخل ، أما بالنظر إلى إمكانية مخالفة القواعد القانونية أو عدم إمكانية مخالفتها ، قد قسم الفقهاء القواعد القانونية إلى قواعد قانونية آمره لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ، وقواعد قانونية مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها .ولعل أكثر هذه التقسيمات ذيوعا هو التقسيم الرومانى لقواعد القانون ، وهذا التقسيم يشمل نوعين من القواعد هي قواعد القانون العام ، وقواعد القانون الخاص ، والتقسيم الآخر الذي له أيضا الغلبة هو تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمره وقواعد مكملة ، وبناء على ما سبق ، تكون الدراسة في هذا الباب منصبة على فصلين :

الفصل الأول : تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص .

الفصل الثانى : القواعد القانونية الآمرة ، والقواعد القانونية المكملة .

الفصل الأول

تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص

يعد تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص أقدم التقسيمات ، فقد نادى به الفقهاء في ظل القانون الرومانى ، ولا يزال له الغلبة حتى عصرنا هذا ، ومعظم فقهاء القانون في هذا العصر تتبنى هذا التقسيم .

هذا التقسيم من قبل فقهاء الرومان اعتمد على التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، وساد الاعتقاد بأن القانون العام هو الذي يهدف إلى المصلحة العامة ، أما القانون الخاص يهدف إلى حماية المصلحة الخاصة ، لذلك يجب علينا أن نوضح المقصود بكل من القانون العام والقانون الخاص ، ومعايير التفرقة بينهما ، والفروع المختلفة لكل قسم من هذين القسمين الأساسيين لقواعد القانون .

ولتناول كل هذه المسائل آنفة البيان ، سنقسم الدراسة في هذا الفصل إلى المبحثين التاليين :

المبحث الأول :التعريف بالقانون العام والقانون الخاص والتفرقة بينهما.

المبحث الثانى : فروع القانون العام والقانون الخاص .

المبحث الأول

التعريف بالقانون العام والقانون الخاص والتفرقة بينهما

القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة أو سيادة ، ويهتم القانون العام أيضا بتنظيم العلاقات التي يكون أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .

والمقصود بالقانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض ، أو بين الأفراد والدولة ، أو أحد أشخاصها الاعتبارية لا بوصفهم أشخاص معنوية عامة ذات سيادة أو سلطة ولكن بوصفهم أشخاص معنوية خاصة .

معايير التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص :

لقد عرفنا آنفا القانون العام والقانون الخاص ، لكن هذا التعريف اعتمد على معيار معين من المعايير المختلفة للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص ، فما هو المعيار الذي تم التعويل عليه حتى وصلنا إلى التعريف سابق الذكر لكل من قواعد القانون العام ، وقواعد القانون الخاص؟

معيار القهر والسيطرة :

أنصار هذا المعيار يرون أن القانون العام مرادف للخضوع والقهر ، وقدرة السلطة العامة على تنفيذ قراراتها بالقوة الجبرية[1] ، فالقانون العام قانون سيطرة ويضع تنظيما آمرا لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفه ، أما فيما يتعلق بالقانون الخاص فهو قانون الحرية وسلطان الإرادة لأن قواعده مكملة ويجوز الاتفاق بحرية

---

[1] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٤٣ .

تامة على ما يخالفها .

ولكن قد تعرض هذا المعيار للنقد على أساس أن كل قواعد القانون العام أو الخاص تشتمل على قواعد آمره ومكملة في نفس الوقت ، فالقواعد التي تتطلب أشكالاً معينة للعقود أو القواعد المتعلقة بالأهلية كلها آمره رغم أنها من قواعد القانون الخاص

معيار المصلحة المبتغـــاة :

أساس هذا المعيار هو الغاية من القواعد القانونية ، فإذا كانت القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة تكون من قواعد القانون العام ، أما إذا كانت المصلحة المبتغاة هي المصلحة الخاصة فإن القواعد القانونية تكون قواعد القانون الخاص ، فطبيعة المصلحة المحمية هي التي تحدد قواعد القانون العام من قواعد القانون الخاص .

ولكن قد وجهت سهام النقد إلى هذا المعيار على أساس أن جميع قواعد القانون تهدف إلى المصلحة العامة ، فقواعد القانون الخاص لا تهدف إلى المصلحة الخاصة فقط ، ولكنها أيضا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ، وعلى سبيل المثال البطلان المقرر للعقود عند مخالفة النظام العام والآداب العامة يكون محققا للمصلحة العامة ، فقواعد القانون كلها عبارة عن مزيج من الرغبة في التوفيق بين الصالح العام والصالح الخاص .

معيـــار أطراف العلاقة :

مضمون هذا المعيار يتمثل في اعتبار قواعد القانون من القانون العام إذا كانت تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها ، أما إذا كانت العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض تكون القواعد المطبقة من قواعد القانون الخاص .

وقد تعرض هذا المعيار كغيره من المعايير السابقة إلى النقد لأن الدولة قد تدخل العلاقات بوصفها شخص عادى لا بوصفها شخص معنوى عام ذات سلطة أو سيادة ، فأحيانا الدولة قد تبيع عقارا من أموالها أو إجرائها لعقد الإيجار بوصفها شخص معنوى خاص ، فهنا ليس من المنطقى تطبيق قواعد القانون العام ، فقواعد القانون الخاص هي الأحرى بالتطبيق .

ولما كانت كل هذه المعايير آنفة الذكر معرضة لسهام النقد ، عارية من الحجج والأسانيد التي تدعمها ، أصبحت في رأينا خليقة بالرفض وعدم الاتباع ، وكان حتما البحث عن معيار آخر لتوضيح التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص

معيار صفة أطراف العلاقة :

المعول عليه في هذا المعيار ليس مسألة أن الدولة طرف في العلاقة أم لا ، ولكن المعول عليه الصفة التي تتصف بها الدولة عند دخولها هذه العلاقة ، فهل الدولة تدخل العلاقة بصفتها شخص معنوى عام ذات سيادة أم أنها تدخل العلاقة بصفتها شخص معنوى خاص غير صاحب سلطة ؟

فللدولة حينما تدخل في العلاقات القانونية صفتين طبقا لهذا المعيار ، إما أنها تدخل العلاقة باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان ، وإما أنها تدخل العلاقة بوصفها شخصا عاديا لا سيادة له ولا سلطان ، وخير مثال على ذلك أنه إذا قامت الدولة بنزع ملكية أرض للمنفعة العامة أو قامت بفرض ضريبة ستخضع العلاقة هنا والتي تكون الدولة طرفا فيها لقواعد القانون العام لأن الدولة في هذه العلاقة صاحبة سيادة وسلطان ، أما إذا أجرت الدولة قطعة أرض تملكها أو قامت بإستئجار منزلا لاستخدامه كمدرسة ، هنا ستدخل العلاقة في نطاق قواعد القانون الخاص لأن الدولة دخلت العلاقة بوصفها شخصا معنويا خاصا[1] .

---

[1] د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية

ويعد وبحق هذا المعيار هو أقرب المعايير إلى المنطق والصواب لأنه فصل العلاقات التي تدخل الدولة فيها ، وبيّن النتيجة التي تترتب على دخول الدولة هذه العلاقات بصفة شخص معنوى عام ، وعند دخولها بصفة شخص معنوى خاص ، فالقانون العام طبقا لهذا المعيار هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان ، أما القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها بوصفها شخصا معنويا خاصا.

وجدير بالذكر أن للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص أهمية قصوى في العديد من المجالات .

أهمية التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص :

نظرا لاختلاف نوع وطبيعة العلاقات التي تنظمها كل من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ، نجد أن التفرقة بينهم ذات أهمية بالغة القيمة في العديد من المجالات .

فيما يخص المنازعات : مما لا ريب فيه أن المنازعات التي تقوم بين الأفراد بعضهم البعض لا يختص بها سوى القضاء العادى ، أما المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها شخص معنوى عام ذات سيادة ، يكون الاختصاص القضائى لمحاكم القضاء الإدارى "محاكم مجلس الدولة"[1] .

فيما يخص انشاء العلاقة القانونية أو تنظيمها : في الحقيقة قواعد

، ١٩٩٢ ، ص ٣٠ .

[1] مجلس الدولة هو الذي يمثل جهة القضاء الإدراى في مصر ، وهو لا يشتمل على القسم القضائى فقط ، بل يشمل أيضا قسمى الفتوى والتشريع .

القانون العام تخول الدولة بوصفها شخص معنوى عام سلطات واسعة عند الدخول في علاقات تعاقدية ، ففي العقود الإدارية نجد الدولة تستطيع تعديل بنود العقد بإرادتها المنفردة مع تعويض الطرف الآخر ، فالدولة لا تقف موقف المساواة مع الأفراد العاديين ، فهؤلاء الأفراد تحكمهم قواعد القانون الخاص لا قواعد القانون العام .

ومن السلطات المخولة للدولة أيضا باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام نزع ملكية الأفراد للمصلحة العامة ، وهذا يختلف عن قواعد القانون الخاص التي لا يتيح للأفراد الاستيلاء على ممتلكات الآخرين بدون اتفاق معهم .

حتى في مجالات العمل ، نجد أن علاقة الدولة مع موظفيها تختلف عن علاقة الأفراد بعضهم ببعض في نطاق القانون الخاص ، فالموظف العام يخضع لما يكلف به من قبل الدولة دون إرادة منه ، ولا يجوز له التوقف عن العمل أو الإضراب عنه لأن ذلك فيه تعطيل لسير المرفق العام بانتظام واضطراد ، أما علاقة الشخص العادى كصاحب العمل مع شخص آخر كالعامل نجد أن هناك قدر من الحرية عند التعاقد مكفول للعامل حتى ولو كان يمثل الطرف الضعيف في عقد العمل .

فيما يخص الملكية : الأموال التي تملكها الدولة تعتبر أموالا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عيها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم المكسب ، فهي لا تسقط مهما طال الزمن ، أما الملكية الخاصة وهي ملكية الأفراد يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو كسبها بالتقادم .

فيما يخص طبيعة قواعد القانون العام والقانون الخاص : معظم قواعد القانون العام تعتبر قواعد آمره لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ، أما قواعد القانون الخاص تشتمل على النوعيين القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها ،



والقواعد المكملة التي يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفتها .وهكذا التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص لها أهميتها في العديد من المجالات .وبالإضافة إلى ذلك نجد أن مسئولية الدولة عند انتهاكها لأحد قواعد القانون العام تختلف عن مسئولية الأفراد عند مخالفة قواعد القانون الخاص ، فمسئولية الدولة أو أحد أشخاصها تخضع لاعتبارات وأسس مغايرة عن تلك التي يخضع لها الأفراد العاديين .

وبعد أن درسنا التعريف بالقانون العام والقانون الخاص ، ومعايير التفرقة بينهما ، ثم أهمية التمييز بين كل من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ، يجب علينا حتى نكون نسيجا متكاملا عن هذا الموضوع أن نبين فروع كل من القانون العام والقانون الخاص .

المبحث الثانى

فروع القانون العام والقانون الخاص

أوضحنا فيما سبق أن القانون العام يختلف عن القانون الخاص ، ولكل قسم من هذين القسمين فروعه المستقلة ، فما هي فروع القانون العام وفروع القانون الخاص؟

للإجابة على هذا التساؤل نقسم الدراسة هنا إلى مطلبين :

المطلــب الأول : فروع القانون العام .

المطلب الثانى : فروع القانون الخاص .

المطلب الأول

فروع القانون العام

المقصود بفروع القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد أشخاصها العامة طرفا فيها بإعتبارهم ذات سيادة أو سلطان ، والقانون العام يتفرع إلى قانون عام خارجى وهو القانون الدولي العام ، وإلى قانون عام داخلى ويشمل القانون الجنائى ، القانون الدستوى ، القانون الإدارى ، والقانون المالى .

وسنعرض فميا يلى المقصود بالقانون العام الخارجى (القانون الدولي العام) ، ثم القانون العام الداخلى .

الفرع الأول : القانون العام الخارجى (القانون الدولي العام) :

يقصد بقواعد القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم

العلاقات بين الدول بعضها البعض ، أو بين المنظمات الدولية ، أو بين الدول وهذه المنظمات الدولية . طبقا لهذا التعريف نجد أن القانون الدولي العام يعالج موضوعات مختلفة ، وهو لا يقتصر على زمن السلم فقط ، بل أيضا وقت الحرب ، ولكن قد شكك البعض في توافر الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام ، لذلك يجب علينا معالجة المسائل الآتية :

أولا : موضوعات القانون الدولي العام .

ثانيا : مصادر القانون الدولي العام .

ثالثا : مدى توافر الصفة القانونية في قواعد القانون الدولي العام .

أولا : موضوعات القانون الدولي العام :

تتباين موضوعات القانون الدولي العام في وقت السلم عنها في وقت الحرب ، بالإضافة إلى أن نطاق قواعد القانون الدولي العام قد اتسع ليشمل تحديد مراكز المنظمات الدولية وعلاقاتها الدولية .

في زمن السلم :

يهتم القانون الدولي العام بتحديد أشخاص المجتمع الدولي ، وما هي الشروط الواجب توافرها لنشأة الدولة ، وحقوقها وواجباتها في مواجهة الدول الأخرى ، كما تختص قواعد القانون الدولي العام بتحديد طرق إبرام المعاهدات الدولية والآثار المترتبة عليها ، كما أنها تهتم بتنظيم طرق التمثيل الدبلوماسى والقنصلى بين الدول ، وتعتنى أيضا قواعد القانون الدولي العام ببيان الطرق السلمية التي يجب اللجوء إليها لفض المنازعات بين الدول ، سواء عن طريق المفاوضات أو التحكيم أو الوساطة الدولية .

في زمن الحرب :

يقوم القانون الدولي العام بدور هام في زمن الحرب ، حيث أن قواعد

القانون الدولي العام هي التي تحدد متى تبدأ الحرب ومتى تنتهي ، والأسلحة التي يجوز استخدامها في الحرب ، والأخرى التي لا تجوز ، ومن الموضوعات الهامة أيضا في زمن الحرب كيفية معاملة أسرى الحرب وما هي حقوقهم وواجباتهم ، وفيما يخص الدول المحايدة ، تحدد أيضا قواعد القانون الدولي العام حقوقها وواجباتها في زمن الحرب وموقفها بالنسبة للدولة المتحاربة ، وضرورة عدم تقديم المساعدات لأى من أطراف النزاع ، لأن ذلك قد يخرجها عن حيادها[١] .

مراكز المنظمات الدولية وعلاقاتهـا :

لقد اتسع نطاق القانون الدولي العام ليشمل تحديد مراكز المنظمات الدولية واختصاصاتها وأجهزتها ، كما يهتم القانون الدولي العام ببيان علاقات هذه المنظمات ببعضها البعض ، وعلاقاتها بالدول ، ومن المنظمات الدولية نجد منظمة الأمم المتحدة وهي منظمة عامة ، وجامعة الدول العربية وهي منظمة إقليمية خاصة بالدول العربية فقط[٢] .

ثانيا : مصادر القانون الدولي العام :

قواعد القانون الدولي العام مستقاة ومستمدة من ثلاث مصادر رئيسية: العرف الدولي ، المعاهدات الدولية ، والمبادئ العامة للقانون .

العرف الدولي : يكتسب العرف الدولي أهمية قصوى كمصدر من مصادر القانون الدولي العام ، لأن القانون الدولي العام يفتقر إلى وجود سلطة عليا تملك إصدار أوامر أو تشريعات تلتزم بها الدول ، والعرف الدولي يكون كالعرف الداخلى

---

[١] د. توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ٣٢ .

[٢] يوجد منظمات إقليمية أخرى ، كمنظمة الوحدة الافريقية ، ومنظمة السوق الأوربية المشتركة ، وتوجد منظمات تقتصر عضويتها على دول معينة يجمعها رباط واحد كمنظمة الدول الإسلامية



، فهو عبارة عن اعتياد الدول في علاقاتها على سلوك معين لمدة طويلة مع الاعتقاد بإلزامية هذا السلوك وسريانه واجبا لدول المجتمع الدولي ، فمع مرور مدة طويلة من الزمن ، واعتقاد الدول بوجوبية القاعدة العرفية ، تصبح الأخيرة جزءا من قواعد القانون الدولي العام .

وجدير بالذكر أن ننوه إلى أن العرف الدولي قد يكون عاما ، وقد يكون إقليميا ، والعرف الإقليمى يختص بجماعة معينة من الدول ، كالعرف السائد في المنطقة العربية فقط ، أما العرف العام يقصد به العرف الذي يخص الدول جميعها[١] .

المعاهدات الدولية : يقصد بالمعاهدات الدولية بصفة عامة الاتفاقات التي تبرم بين الدول في شأن من الشئون الدولية ، والمعاهدات الدولية تعد المصدر الثانى لقواعد القانون الدولي العام بعد العرف الدولي .ويوجد نوعين من المعاهدات الدولية : المعاهدات الدولية العامة والمعاهدات الدولية الخاصة ، ويقصد بالمعاهدات العام الاتفاقات التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول في مسألة تهم الدول جميعها ، وينتج من هذه المعاهدات قواعد عامة مجردة تلزم الدول جميعها ، وخير مثال على ذلك هو معاهدة سان فرنسيسكو عام ١٩٤٥م والتي صدر بمقتضاها ميثاق الأمم المتحدة ، أما المقصود بالمعاهدات الخاصة هي الاتفاقات التي تبرم بين دولتين أو بين عدد محدود من الدول لتنظيم مسألة معينة ، فهذا النوع من المعاهدات لا يلزم إلا الدول الأطراف في المعاهدة فقط ، فهو لا يعد مصدرا من مصادر القانون الدولي العام ، ولكن قد تصبح هذه المعاهدات مصدرا للقانون الدولي العام إذا أقرت قواعد واستقر المجتمع الدولي على اتباعها ، والاعتقاد بإلزاميتها ، ففي هذه الحالة ستكون عرفا دوليا واجب الاتباع ، ويصبح

---

[١] د. محمد حسين عبد العال ، المرجع السابق ، ص ٧٠ .

جزءا من قواعد القانون الدولي العام .

المبادئ العامة للقانون : عند عدم وجود قاعدة عرفية دولية أصبحت جزء من قواعد القانون الدولي العام ، أو عند غياب معاهدة عامة للفصل في مسألة معينة ، يكون الاحتكام إلى المصدر الثالث من مصادر القانون الدولي العام ، وهو المبادئ العامة للقانون .

ويقصد بالمبادئ العامة للقانون مجموعة المبادئ الأساسية التي تقررها النظم القانونية المختلفة ، فمبدأ المسئولية عن الفعل الضار ، وقاعدة احترام الأطراف لما يبرمونه من عقود ، كلها مبادئ عامة تحترمها كل القوانين الوضعية في الأمم المتمدينة ، ويجب على المجتمع الدولي احترام هذه المبادئ الأساسية المقررة في القوانين الداخلية للأمم المختلفة .

ثالثا : مدى توافر الصفة القانونية في قواعد القانون الدولي العام :

لقد أنكر البعض توافر الصفة القانونية في قواعد القانون الدولي العام ، وأيد البعض الآخر توافر هذه الصفة في قواعد القانون الدولي العام ، وسنعرض فيما يلى للحجج والأسانيد التي قال بها كل اتجاه .

الاتجاه الأول: انكار الصفة القانونية في قواعد القانون الدولي العام :

لقد ذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن قواعد القانون الدولي العام ليس لها صفة القواعد القانونية وذلك للأسباب التالية :

١ . عدم وجود هيئة تشريعية عليا تكون مختصة باصدار قواعد القانون الدولي العام ، وتسهر على احترام هذه القواعد من قبل المخاطبين بها.

٢ . عدم وجود سلطة عليا تراقب مدى تطبيق قواعد القانون الدولي العام، وتوقيع الجزاء على من يخالف أو ينتهك هذه القواعد ، لذلك كل من يخالف أحكام القانون الدولي العام لا يخشى الوقوع تحت طائلة العقاب لعدم وجود من يوقع الجزاء .

الاتجاه الثانى: توافر الصفة القانونية في قواعد القانون الدولي العام:

غالبية الفقه تتجه إلى عكس ونقيض الاتجاه الأول وتؤكد توافر الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام ، وقد فند أنصار هذا الاتجاه حجج الاتجاه الأول ، وقاموا بدحضها وهدمها كالآتى :

١ . فيما يخص حجة عدم وجود سلطة عليا تقوم بإصدار قواعد القانون الدولي العام ، تعتبر حجة واهية ومن السهل هدمها لأنه ليس من الضرورى وجود هيئة تشريعية عليا لإصدار قواعد القانون الدولي العام ، وأن القواعد القانونية الداخلية لا يكون مصدرها التشريع فقط بل أيضا العرف ، وهذا الأخير لا تضعه هيئة عليا ، ولكنه نتيجة اعتياد الناس على سلوك معين لمدة طويلة واعتقادهم بإلزامية هذا السلوك ، فهناك من القواعد القانونية ما ينشأ دون الحاجة إلى سلطة عليا تضعها ، كما هو الشأن بالنسبة للقواعد القانونية التي مصدرها العرف ، والعرف ينشأ في ضمير الجماعة ، وفي المجال الدولي يعتبر من أهم مصادر القانون الدولي العام[١] .

٢ . فيما يخص عدم وجود سلطة عليا مهمتها توقيع الجزاء على من ينتهك قواعد القانون الدولي العام ، نجد أيضا أن هذه الحجة ضعيفة ، ولا تعد دليلا على إنكار الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام ، فالمجتمع الدولي نفسه هو الذي يوقع الجزاء ، وذلك عن طريق تفويض الدولة التي وقع عليها الاعتداء في توقيع الجزاء باسم المجتمع الدولي ، ومن صور الجزاء هنا يمكن أن نذكر المقاطعة الاقتصادية والسياسية والمعاملة بالمثل ، وقد يصل الأمر إلى حد التدخل العسكرى[٢] .

---

[١] د. توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ٣٣ .

[٢] د. محمد حسين عبد العال ، المرجع السابق ، ص ٧٣ ؛ انظر أيضا :محمد سعد

وقد ذهب البعض إلى القول بأنه "وإذا كان الجزاء يترك للافراد على هذا النحو ، يوقعونه بأنفسهم ، فإن هذا هو ما يتفق والمرحلة التي يمر بها القانون الدولي العام ، لأنه قانون حديث النشأة ولا يزال في مراحل تطوره الأولى"[١] ولكن قد ذهب رأى آخر إلى أن التفويض في توقيع الجزاء يعتبر أمرا غير مرغوب فيه ويضعف من قواعد القانون الدولي العام ويجعلها من قبيل القواعد القانونية الناقصة ، فالتفويض في توقيع الجزاء إذا تصورناه في المجتمع الداخلى وتركنا توقيع الجزاء في يد الأفراد لأدى ذلك إلى عدم الاستقرار وذيوع الفوضى والاضطراب[٢] .

ورغم أن القانون الدولي العام لم يبلغ بعد نهاية التطور ، إلا أن وجود محكمة العدل الدولية ، وما تتمتع به الجميعة العامة من قيمة أدبية عظيمة ، وما تتصف به قرارات مجلس الأمن من قوة وصرامة إلى حد إعلان الحرب المشروعة على الدولة المعتدية ، يجعلنا نؤكد اعتبار القانون الدولي العام قانونا بالمعنى الصحيح[٣] ، ولذلك نرى من جانبنا عدم الاتفاق مع الرأى القائل بأن قواعد القانون الدولي العام لا تتوافر لها الصفة القانونية لأن قواعده غير مكفول احترامها بقوة الاجبار الجماعى ، ولا توجد في المجتمع الدولي هيئة تترك الدول منها منزلة الأفراد من الحكومات ، حتى بعد وجود الأمم المتحدة ، نجد أن قراراتها قد تكون معطلة لأنها خاضعة لبعض الدول بما لها من قوة وهيمنة في المجتمع الدولى[٤] ،

خليفه ، حمدى محمد عطيفي ، ص ٨٩ .

[١] د. توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ٣٣ .

[٢] د. محمد حسين عبد العال ، المرجع السابق ، ص ٧٣ .

[٣] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٥٥ .

[٤] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، صـ ٦٥ وما بعدها ، ولكن يؤكد البعض أن ضعف

وعدم اتفاقنا مع هذا الرأى آنف الذكر يرجع إلى أن احترام أو عدم احترام قواعد القانون الدولي العام لا يرجع إلى توافر أو عدم توافر الصفة القانونية في قواعده ، ولكن يرجع إلى مدى خضوعنا إلى هذه القواعد ، وعلى سبيل المثال عدم احترام قاعدة قانونية داخلية لا ينفي عنها الصفة القانونية ولكن المخالف يوقع عليه الجزاء ، وهكذا الحال بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام ، فعدم احترام بعض قواعده لا يعنى فقدان الصفة القانونية ، ولكن فقدان المصداقية ، فقواعد القانون الدولي العام التي طبقت على العراق عند غزو الكويت هي نفس القواعد التي لم تطبق على العدو الإسرائيلى نتيجة عدم احترامه للشرعية الدولية وانتهاكه لحقوق الشعب الفلسطينى ، فليس العيب في قواعد القانون الدولي العام ، ولكن العيب في عدم احترامها والخضوع لها ، ونخلص مما سبق إلى أن القانون الدولي العام يعتبر وبحق قانونا بالمعنى الصحيح

الفرع الثانى : القانون العام الداخلى :

القانون العام الداخلى هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات في الداخل ، والتي تكون الدولة طرفا فيها أو أحد أشخاصها العامة بوصفهم أصحاب سيادة وسلطان ، و القانون العام الداخلى يتفرع إلى عدة فروع منها القانون الدستورى ، القانون الجنائى ، القانون الإدارى ، والقانون المالى ، وسنعرض فيما يلى لكل فرع من فروع القانون العام الداخلى :

أولا : القانون الدستورى :

الجزاء لا يعد عيبا في قواعد القانون الدولي العام نفسها ، وإنما العيب الحقيقى يكمن في عدم الخضوع لتلك القواعد ، وأن ضعف الجزاء أو شدته لها يعد مانا أو حائلا دون مخالفة القواعد القانونية ، فالأفراد يرتكبون القتل رغم علمهم بشدة وصرامة الجزاء الذي سيوقع عليهم ؛ انظر د. توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ٣٤ .

لتناول القانون الدستور بالشرح لابد من دراسة النقاط التالية : التعريف بالقانون الدستورى ، موضوعات القانون الدستورى ، ومدى توافر الصفة القانونية في قواعد القانون الدستورى .

١ . التعريف بالقانون الدستورى :

القانون الدستورى هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد وتبين نظام الحكم في الدولة ، والسلطات المختلفة الموجودة في الدولة ، واختصاصاتها والعلاقات التي تدور بينهم ، كما يحدد القانون الدستورى الحقوق والحريات العامة .

والقانون الدستورى يعتبر القانون الأساسى في الدولة أو دستور الدولة ، وطرق اصدار الدساتير عديدة ، فقد يصدر الدستور عن طريق منحه من الحاكم ، كما قد يصدر نتيجة اتفاق بين الحاكم والمحكومين ، وقد يصدر من قبل جميعة وطنية تأسيسية ، وفي هذه الطريقة الأخيرة قد يسلتزم الأمر عرض الدستور على الاستفتاء الشعبى ، فإما الاكتفاء بأن يصدر الدستور من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية ، وإما الجمع بين ذلك وبين عرض الدستور على الشعب "الاستفتاء الشعبى" وهذه الطريقة الأخيرة هي التي تم بها إصدار دستور مصر في عام ١٩٧١ و٢٠١٤م.

ويوجد نوعين من الدساتير ، الدساتير المرنة والدساتير الجامدة ، ويقصد بالدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بسهولة ، دون اتباع اجراءات خاصة ، أما الدساتير الجامدة هي التي لا يمكن تعديلها سوى بإتباع اجراءات خاصة مثل الاستفتاء الشعبى .

وجدير بالذكر أن القانون الدستورى باعتباره القانون الأساسى في الدولة ، يجب أن يصدر أى قانون متفقا مع أحكامه ، فلا يجوز اصدار قوانين مخالفة لأحكام الدستور ، وإلا تم نعتها بعدم الدستورية ، فيقال هذا القانون غير دستورى ،

أى أنه مخالف لقواعد الدستور والتي تعد أسس القواعد القانونية في الدولة .

٢ . موضوعات القانون الدستورى :

بناء على التعريف سالف الذكر لقواعد القانون الدستورى ، يمكننا أن نعرض للموضوعات والمسائل التي يهتم بها هذا القانون ، والموضوعات التي ينظمها القانون الدستورى هي كالآتى :

أ . بيان شكل الدولة ونظام الحكم فيها : يهتم القانون الدستورى ببيان شكل الدولة وما إذا كانت دولة موحدة كمصر ، أو اتحادية كالولايات المتحدة الامريكية وسويسرا ، كما يهتم بتحديد ما إذا كانت الدولة ملكية أم جمهورية ، وفيما يتعلق بنظام الحكم في الدولة توضح قواعد القانون الدستورى ، ما إذا كان الحكم ديمقراطيا أم ديكتاتوريا ، وما إذا كانت الدولة تأخذ بنظام الحكومة البرلمانية أم غير ذلك .

ب . تحديد السلطات العامة في الدولة : تختص قواعد القانون الدستورى ببيان السلطات العامة في الدولة ، وهي ثلاث سلطات تشريعية ، قضائية ، وتنفيذية ، فالدستور هو الذي يحدد اختصاصات هذه السلطات الثلاث وعلاقاتها ببعضها البعض .

جـ . بيان الحقوق والحريات العامة : يوضح القانون الدستورى الحقوق والحريات العامة في الدولة ، كحق المساواة أمام القانون ، وحرية الاعتقاد ، وحرية الرأى ، وحرية البحث العلمى ، كما يحدد الدستور الواجبات العامة المفروضة على المواطنين كأداء الخدمة العسكرية وأداء الضرائب ، ومن أمثلة حرص الدستور على صيانة الحرية الشخصية نجد أن المادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤ تؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعى لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر

يستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، والمادة ٦٤ من الدستور تؤكد أن الدولة تكفل حرية العقيدة ، وحرية الرأى مكفولة طبقا للمادة ٦٥ من الدستور ، وفيما يتعلق بالواجبات نجد أن المادة ٨٦ من الدستور تؤكد أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأن التجنيد إجبارى.

٣ . مدى توافر الصفة القانونية في قواعد القانون الدستورى :

لقد شكك البعض في توافر الصفة القانونية في قواعد القانون الدستورى على أساس أن قواعده تفتقر إلى الجزاء عند مخالفة هذه القواعد ، كما أنه لا يتصور توقيع الدولة الجزاء على نفسها[١] .فالدولة هي التي تملك وتحتكر سلطات الجزاء والاجبار ، ولا يتصور أن تشرعه في وجه نفسها عند مخالفة قواعد القانون الدستورى ، والتزام الدولة باحترام الدستور ليس التزاما قانونيا بل التزاما أدبيا لا يترتب عليه عند المخالفة سوى جزاء أدبى[٢] .

ولكن قد اعترض البعض على ذلك حيث أن قواعد القانون الدستورى يتوافر فيها الصفة القانونية ، وأن الجزاء عند مخالفتها يختلف عن صور الجزاء في فروع القانون الأخرى ، وذلك لما للقانون الدستورى من طبيعة خاصة ، فالقانون الدستورى كما سبق أن أوضحنا يبين السلطات الموجودة في الدولة ، ويحدد اختصاصاتها ، ومن تحليل قواعد القانون الدستورى نجد أن السلطات الثلاث الموجودة في الدولة تراقب كل منها الأخرى ، فالرقابة المتبادلة تعد وبحق الجزاء عند مخالفة قواعد القانون الدستورى ، فمن حق السلطة التشريعية سحب الثقة من الحكومة ، كما أنه من حق رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب ، بالإضافة إلى

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٤٨ .

[٢] سعد عصفور ، مقدمة القانون الدستورى ، ص ٩ مشار إليه عند د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٦٧ .

ذلك نجد أن السلطة القضائية تراقب مدى دستورية القوانين واللوائح ، فعند مخالفة أحكام الدستور ، يوصم القانون المخالف بعدم الدستورية ، وبالتالى يجب على المحاكم إلغائه[١] .

ويجوز للشعب بإعتباره مصدر السلطات أن يتدخل لفرض احترام الدستور سواء بالطرق السلمية أو الثورية[٢] .

وفضلا عما سلف بيانه ، يجب التنويه إلى أن النظر إلى الدولة بإعتبارها جهاز جبر وقوة يشوه وظيفتها المتمثلة في خدمة القانون وإعمال حكمه ، فاحترام القانون يعتبر أول واجبات الدولة ، فليس القانون هو قانون الدولة تتحلل من احترامه بحسب رغبتها ، بل الدولة هي دولة القانون التي ينبغى عليها احترامه والتقيد بأحكامه ، وعند خرق السلطات العامة للقانون يجوز للأفراد مقاضاتها ، ومطالبة إهدار تصرفاتها غير المشروعة[٣] .

والخلاصة هي أن النتيجة المنطقية لما سبق ذكره هي الاعتراف بتوافر الصفة القانونية لقواعد القانون الدستورى .

ثانيا : القانون الجنائـــى :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جريمة ، والعقوبات المقررة لهذه الجريمة ، وبيان الاجراءات الواجب اتباعها في تعقب المتهم والقبض عليه ، وكيفية محاكمته ، ومن هذا التعريف يتضح لنا أن القانون الجنائى يشتمل على نوعين من القواعد : قواعد موضوعية وقواعد اجرائية أو شكلية ، وعلى

---

[١] د. خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص ٩٧ .

[٢] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٤٩ .

[٣] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٦٨ .

هذا يتفرع القانون الجنائى إلى فرعين :

١ . قانون العقوبات :

هو عبارة عن مجموعة القواعد الموضوعية التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم ، والعقوبات المقررة على هذه الجرائم .

وإذا كان قانون العقوبات أحد فروع القانون العام الداخلى ، إلا أن بعض الفقهاء اعتبره قانونا مختلطا يدخل في نطاق القانونين العام والخاص على السواء ، فهو يقوم على فكرة الدفاع عن المجتمع لكنه في نفس الوقت يعاقب على جرائم تقع على الأفراد وتضر بمصالحهم الخاصة.

والواقع أن قانون العقوبات إنما يمس في الصميم حق السيادة في الجماعة ، إذ هو بتصديه لتحديد الجرائم وتعيين العقوبات إنما يضع أسس الأمن في الجماعة وعلاقة الفرد بالدولة الممثلة للجماعة عند خرق هذه الأسس ، وليس أوثق من هذه الأسس ولا من تلك العلاقة اتصالا بحق السيادة الداخلية ، فيكون هذا القانون بهذه المثابة فرعا من فروع القانون العام[١] .

ومع ذلك فإن الفقه السائد في فرنسا هو اعتبار قانون العقوبات أحد فروع القانون الخاص على أساس أن الجرائم ترتكب ضد مصالح وحقوق الأفراد ، كما أن للأفراد في بعض الأحوال تحريك الدعوى العمومية أو عدم تحريكها كما هو الأمر في جرائم الزنا والسب والقذف ، ولكن هذا الاتجاه يغفل الوضع في القوانين الحديثة ، وأن الجريمة موجهة ضد أمن المجتمع واستقراره ، وأن العقاب حق مقرر للمجتمع[٢] ، وبالتالى يعتبر قانون العقوبات وبحق أحد فروع القانون العام ، وإذا كانت هناك بعض الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى العمومية فيها إلا بعد إذن

---

[١] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٧١ .

[٢] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٥٣ .

الأفراد ، فإن هذه الحالات نادرة واستثنائية لا يقاس عليها ، فأغلبية الجرائم لا يتم تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلا من قبل النيابة العامة ولا شأن للأفراد بذلك .

وقانون العقوبات بوصفه أحد فروع القانون العام ينقسم إلى قسمين : القسم العام والقسم الخاص ، والمقصود بالقسم العام في قانون العقوبات هو مجموعة القواعد العامة التي تتناول المسئولية الجنائية وتقسيم الجرائم بوجه عام،والعقوبات المقررة لهذه الجرائم وحسب وصفها،فعقوبة الجناية تختلفعن عقوبةالجنحة أو المخالفة،والقسم العام يهتم أيضا بتحديد الظروف المخففة والمشددة للمسئولية الجنائية،وموانع المسئولية

وفيما يتعلق بالقسم الخاص في قانون العقوبات ، هو مجموعة القواعد التي تتولى بيان كل جريمة على حدة ، وأركانها والعقوبة المقررة لها ، والجرائم مختلفة فمنها ما يقع على الدولة من حيث الأمن في الخارج كجرائم التجسس والخيانة العظمى ، ومنها ما يقع على الدولة من حيث الأمن في الداخل كجرائم تزييف النقود واختلاس الأموال العامة ، ومن الجرائم أيضا ما يقع على حياة الإنسان أو جسمه كالقتل والضرب ، ومنها ما يقع على عرضه أو شرفه كالزنا وهتك العرض ، ومنها أيضا ما يقع على ماله كالسرقة .

٢ . قانون الاجراءات الجنائية :

هو مجموعة القواعد القانونية التي يجب اتباعها لضبط الجانى ، وتفتيشه ، وكيفية التحقيق معه ، والسلطات المختصة بضبط الجريمة والتحقيق فيها وأحوال الحبس الاحتياطى ، كما أن هذا القانون يهتم ببيان كيفية المحاكمة الجنائية ، وتحديد المحاكم الجنائية ، وكيفية الطعن في الأحكام ، وكيفية تنفيذها .

ثالثا : القانون الإدارى :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية وعلاقاتها

بالأفراد وكيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها الإدارية .

فالسلطة التنفيذية تمارس نوعين من الأنشطة : نشاط سياسى ، ونشاط إدارى ، والمقصود بالنشاط السياسى هو أعمال السيادة كإعلان الحرب والدخول في معاهدات وحل البرلمان وتشكيله ، والقانون الدستورى هو الذي يختص بتنظيم ممارسة السلطة التنفيذية لأعمال السيادة ، أما فيما يخص النشاط الإدارى ، يقصد به نشاط السلطة التنفيذية في حفظ الأمن والنظام ، وإدارة المرافق العامة بانتظام واضطراد كمرفق الكهرباء والمياه والمواصلات والصحة والتعليم ، فهذه الأنشطة الإدارية ينظمها القانون الإدارى أى أن هذا الأخير لا ينظم من أعمال السلطة التنفيذية إلا ما يتعلق بوظيفتها أو أعمالها الإدارية ، والقانون الإدارى طبقا لما سبق ذكره يكون وثيق الصلة بالقانون الدستورى حيث أن هذا الأخير يوضح كيفية إنشاء تشكيل السلطة التنفيذية وممارستها لأعمال السيادة ، والقانون الإدارى يهتم أيضا بالسلطة التنفيذية لكن بنشاطها الإدارى فقط[١] .

<u>الموضوعات التي يهتم بها القانون الإدارى :</u>

تهتم قواعد القانون الإدارى بالموضوعات الآتية :

١ . أنواع الخدمات التي تؤديها السلطة التنفيذية والمرافق التي تقوم بأداء هذه الخدمات ، كمرفق التعليم ، والكهرباء والمياه والصحة والشرطة.

٢ . التنظيم الداخلى للسلطة التنفيذية ، وعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية ، وجدير بالذكر أنه توجد طريقتان لتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والهيئات الإقليمية : طريقة المركزية ، وطريقة اللامركزية ، والمقصود بالمركزية هو ضرورة رجوع الإدارات والهيئات الإقليمية إلى الحكومة المركزية في معظم المسائل التي تتولاها ، أما المقصود باللامركزية هو اعطاء

---

[١] د. عبد الرازق ياسين ، المرجع السابق ، ص ٣٥ .

قدر من الحرية والاستقلال للإدارات الإقليمية في مباشرة مصالحها وعدم الرجوع على الحكومة المركزية إلا في مسائل محددة .

٣ . بيان علاقة الدولة بموظفيها ، وذلك بتحديد كيفية تعيينهم ، وترقيتهم ، والإجراءات المتبعة لتأديبهم .

٤ . تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد ، وتعتبر جهة القضاء الإدارى الممثلة في مجلس الدولة هي المختصة بذلك .

٥ . بيان الأموال العامة المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة ، وتوضيح كيفية إدراتها ، وأوجه الحماية المقررة لها .

٦ . تنظيم التصرفات الإدارية ، وذلك كتحديد القرارات الإدارية وشروطها وآثارها ، وأيضا بيان العقود الإدارية وكيفية انعقادها والالتزامات الناشئة عنها .



رابعا : القانون المالى :

هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تختص بتنظيم مالية الدولة ، وكيفية الحصول علي الإيرادات ، وكيفية إنفاقها ، ويتولى القانون المالى أيضا بيان القواعد المتبعة في تنظيم ميزانية الدولة ، ولذلك نجد أن علم المالية العامة يهتم بدراسة النفقات العامة ، الإيرادات العامة ، القروض العامة والميزانية .

وقد كان القانون المالى أحد فروع القانون الإدراى ، لكنه استقل الآن وأصبح قانونا قائما بذاته وذلك نظرا لتعدد وتشعب موضوعاته .

فالقانون المالى يتولى تحديد موارد الدولة من ضرائب ورسوم ، والأحكام المتعلقة بتحصيل هذه الضرائب والرسوم ومصروفات المصالح الحكومية المختلفة ، كما أنه ينظم المصروفات العامة للدولة والطرق الواجب اتباعها للإنفاق على المرافق العامة ، وأخيرا يتولى القانون المالى تنظيم الميزانية ، وكيفية الموازنة بين الإيرادات والمصروفات .

المطلب الثانى

فروع القانون الخاص

القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم البعض ، كما أنها تنظم العلاقات التي تكون الدولة أو أحد أشخاصها العامة طرفا فيها لا بإعتبارها صاحبة سيادة وسلطان ، ولكن بوصفها شخص معنوى خاص .

والقانون الخاص يعتبر أكثر قدما من القانون العام خاصة وأن هذا الأخير ارتبط وجوده بوجود الدولة بمعناها الحديث ، فمع ظهور الحياة المدنية في الجماعة ظهرت قواعد القانون الخاص لتنظم العلاقات والمعاملات سواء في البيع

أو الشراء أو المقايضة .

وقد كان القانون المدني لفترات طويلة هو القانون الأوحد الذي ينظم مختلف علاقات الأفراد سواء في المجال المدني ، التجاري ، أو الزراعى ، ولكن مع تطور النشاط الإنسانى وتنوعه ليقتحم كافة أو شتى جوانب الحياة ، بدأت تظهر الفروع الأخرى للقانون الخاص ، خاصة وأن القانون المدني أصبح غير منسجما مع بعض العلاقات الأخرى الناشئة في غير المجال المدني .

ويمكننا أن نقسم فروع القانون الخاص إلى الفروع الآتية :

١ ـ القانون المدني . **٢ ـ القانون التجاري .**

٣ ـ القانون البحرى . **٤ ـ القانون الجوى .**

٥ ـ القانون الزراعى **٦ ـ قانون العمل .**

٧ ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية .٨ ـ القانون الدولي الخاص .

وفيما يلى سنعرض لكل فرع من فروع القانون الخاص آنفة الذكر :

١ ـ القانون المدني :

لقد كان القانون المدني كما سبق الحديث يمثل القانون الأوحد ، وكان يطبق على معظم الروابط والعلاقات بين الأفراد ، ولكن ظهرت فروع أخرى للقانون الخاص،ورغم ذلك ظل القانون المدني الشريعة العامة لكل فروع القانونالخاص

والقانون المدني ينظم العلاقات بين الأفراد عدا ما يتناوله بالتنظيم أحد الفروع الأخرى للقانون الخاص ، والقانون المدني ينظم نوعين من الروابط أو العلاقات : روابط الأحوال الشخصية ، وروابط الأحوال العينية.

ويقصد بروابط الأحوال الشخصية كل ما يتصل بالأسرة من زواج وطلاق وقرابة وعلاقة الفرد بأسرته ، وأيضا تنظيم المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية ، أما

المقصود بالروابط العينية هو كل ما يتعلق بنشاط الشخص بالنسبة إلىالأموال ، لبيان التعريف بالمال وأنواعه ، والحقوق المالية للشخص وطرق كسبها وانقضائها .

وجدير بالذكر أن القانون المدني في معظم دول العالم يهتم بتنظيم النوعين معا من الروابط سواء الروابط الشخصية أو الروابط العينية ، لكن الأمر يختلف بالنسبة للقانون المدني المصري ، فهو يقتصر على تنظيم الأحوال العينية فقط ، أما فيما يخص الأحوال الشخصية ، فقد تم تركها لقواعد الدين لتنظمها حسب الديانة التي يدين بها الأفراد في المجتمع ، فالشريعة الإسلامية تنظم الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ، أما الشريعة الطائفية سواء اليهودية أو المسيحية تنظم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين[1] .

والقانون المدني المصري صدر في ١٩٤٨م لكن لم يكن ساريا إلا من ١٥ اكتوبر ١٩٤٩م ، ويتناول هذا القانون العديد من الموضوعات ، منها مصادر القانون المدني ، وتطبيقه من حيث الزمان والمكان وبيان الأشخاص والأموال ويهتم القانون المدني أيضا بدراسة الحقوق الشخصية أو الالتزامات في قسم معين ، أما الحقوق العينية سواء كانت حقوق عينية أصلية كحق الملكية أم حقوق عينية تبعية كالرهن الرسمى ، فقد تم دراسة هذه الحقوق في قسم آخر .

٢ ـ القانون التجاري :

لقد كان القانون المدني هو المطبق أو الذي ينظم العلاقات ذات الطابع التجاري ، ولكن مع التطور الإنسانى وضرورة وجود قواعد خاصة لتنظيم العلاقات

---

[1] يجب التنويع إلى أنه هناك شروط معينة لتطبيق الشريعة الطائفية كالاتحاد في الملة والطائفة ، ووجود قضاء ملى منظم قبل ٣١ ديسمبر ١٩٥٥م ، وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة ، فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة تطق قواعد الشريعة الإسلامية على غير المسلمين .

التجارية ظهر القانون التجاري ، والمقصود بالقانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنطبق على الأشخاص الذين يتمتعون بصفة التاجر وعلى الأعمال التجارية ، فالقانون التجاري هو الذي يحدد الأعمال التي تعتبر تجارية ، كما أن هذا القانون يختص بتنظيم الشركات التجارية بمختلف أنواعها ، وأوجه النشاط التجاري المختلفة من عقود تجارية وملكية تجارية وصناعية ، ومن موضوعات القانون التجاري أيضا القواعد الخاصة بالأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند الاذنى ، والقواعد الخاصة بعمليات البنوك .

ونظرا لتزايد النشاط التجاري أو ضرورة أن يكون هناك ثقة متبادلة بين المتعاقدين ، استقل القانون التجاري عن القانون المدني بقواعد مختلفة عن تلك السائدة في المعاملات المدنية ، وذلك حتى تلائم هذه القواعد العلاقات التجارية ، ومن القواعد الموضوعية التي يختلف فيها القانون التجاري عن القانون المدني :

- في حوالة الحق بالنسبة للقانون المدني لا يجوز أن تتم هذه الحوالة إلا بشروط معقدة ، ولا تكون نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو تم إعلانه بها ، أما في القانون التجاري يكفي التظهير لنقل الحق في الأوراق التجارية .
- فيما يتعلق بالتضامن بين المدينين ، نجد أن القاعدة في القانون المدني هي أن التضامن لا يفترض ، فالتضامن بين المدينين لا يكون إلا بناء على نص في القانون أو بناء على اتفاق ، أما في حالة القانون التجاري نجد أن الأمر يختلف حيث يجوز التضامن بين المدينين ، فالتضامن بينهم مفترض ، ويجوز للدائن أن يرجع على أحدهم لإستيفاء دينه كاملا ، وهذا بالطبع يقوى ويدعم ائتمان الدائن لأنه واثق من إمكانية الحصول على حقه من أى من المدينين[1] .

---

[1] د. توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ٤٨ .

- فيما يتعلق بإثبات التصرفات القانونية التجارية ، نظرا للثقة وعامل السرعة في العلاقات التجارية ، القاعدة هي أن اثبات التصرفات التجارية يجوز بكافة طرق الاثبات ، ولا يشترط التقييد بالكتابة ، فيمكن الاثبات بالبينة أو بالقرائن ، لكن نجد أن الأمر يختلف في القانون المدني حيث أن الاثبات لابد أن يكون بالكتابة في التصرفات التي تزيد قيمتها على قدر معين[١] .

- ومن الموضوعات الأخرى التي يختلف فيها القانون التجاري عن القانون المدني هي أن القانون المدني يجيز للقاضى أن يمنح المدين أجلا للوفاء بدينه إذا حل ميعاد الوفاء ، وذلك بالطبع إذا وجد القاضى أن هناك ظروفا معينة تقتضى هذا التأجيل ، أما في مجال القانون التجاري لا يجوز للقاضى منح المدين هذه الميزة ، وذلك لأن المعاملات التجارية تقتضى ضرورة الوفاء بالدين في الميعاد حتى يستطيع الدائن أن يسير في أعماله ، خاصة وأنه قد رتب مشروعاته على هذا الميعاد[٢] .

---

[١] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٧٣ .

[٢] انظر شرحا لهذا الأمر ، د. توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ٤٨ .

٣ ـ القانون البحرى :

المقصود بالقانون البحرى هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة الملاحة البحرية ، وتعتبر السفينة هي الأساس الذي تدور حوله قواعد القانون البحرى ، من تحديد اسمها وجنسيتها والعقود التي يمكن أن ترد عليها من بيع أو إيجار .

ويهتم القانون البحرى أيضا بتحديد مسئولية مالك السفينة والربان وطاقم السفينة والعلاقات الناشئة بينهم جميعا ، ومن الموضوعات الهامة أيضا في القانون البحرى ، عقود النقل البحرى والرهن البحرى والتأمين البحرى .

ويجب التنويه إلى أن القانون البحرى قد كان جزءا من القانونى التجاري ، ولكن لإعتبارات معينة كإزدياد حركة التجارة الدولية ، أدت إلى استقلال القانون البحرى عن التجاري .

٤ ـ القانون الجـــوى :

إذا كانت السفينة هي محل القانون البحرى ، تكون الطائرة هي محل القانون الجوى ، فيدور هنا القانون حول الطائرة دوران القانون البحرى حول السفينة ، فقواعد القانون الجوى تبين كيفية تسجيل الطائرة ، وجنسيتها ، ومسئوليات طاقم الطائرة ، والعقود التي تنشأ كعقود نقل الركاب أو البضائع عن طريق الجو ، ومن الموضوعات التي يهتم بها أيضا القانون الجوى هي التأمين على الطائرة والمسئولية عن حوادثها .

٥ ـ القانون الزراعى :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تهتم بالنشاط الزراعى ، كملكية الأرض الزراعية ، والاستغلال الزراعى لهذه الأرض ، فالقانون الزراعى يهتم بتنظيم ملكية الأراضى الزراعية ، وكيفية استغلالها سواء عن طريق زراعة المالك لها بنفسه ، أو عن طريق المزارعة ، بمعنى إشراك الغير في استغلال الأرض الزراعية .

ويهتم القانون الزراعى أيضا بتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية بإعتبارها أداة من أدوات النشاط الزراعى ، والاهتمام بالمؤسسات الائتمانية والتي تمنح القروض للمزارعين ، وتنظيم الثروة الزراعية الحيوانية وتطويرها[١] .

ويجب التنويه إلى أن القانون الزراعى حديث النشأة ، فهو لم يظهر إلا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، أى يمكننا القول أن هذا القانون نشأ بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، فهذه الثورة هي السبب الرئيسى لنشوء مثل هذا القانون ، وقد صدر حديثاً القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢م لإعادة تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجرى الأراضى الزراعية من خلال العودة إلى أحكام القانون المدني دون قانون الإصلاح الزراعى .

---

[١] انظر أكثر تفصيلا : محمد سعد خليفة،حمدى محمد عطيفي ، المرجع السابق ، ص ١٠١

٦ ـ قانون العمل :

نظرا لإنتشار الصناعة وتقدمها ، كانت الضرورة تقتضى تنظيم العلاقات الناشئة بين أصحاب الأعمال والعمال ، من هنا نشأ قانون العمل وهو عبارة عن مجموعة القواعدالقانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين أصحاب الأعمالوالعمال .

وقد كان الغرض من تنظيم قواعد قانون العمل لهذه العلاقات هو حماية الطرف الضعيف في العلاقة وهو العامل .

ويمكننا القول بأن السبب الرئيسى لاصدار قانون العمل هو تزايد الفكر الاشتراكى ، ففي ظل المذهب الفردى كانت الغلبة دائما لأصحاب الأعمال باعتبارهم الطرف القوى يتحكمون في العمال كما يريدون ، فالمبدأ السائد هو مبدأ سلطان الإرادة ، ونظرا لتحكم الأقوياء في الضعفاء واستغلال أرباب الأعمال للعمال بدأ يظهر المذهب الاشتراكى والذي يدعو إلى المساواة والتضامن الاجتماعي ، وضرورة حماية الطبقات الضعيفة من تعسف وبطش الطبقات القوية ، فقد كان الفكر الاشتراكى مقيدا بسلطان الإرادة والذي كان سلاحا يشهرونه أرباب الأعمال في وجه العمال اعتمادا على قوتهم الاقتصادية[١] .

ونظرا لهذا التدخل المتزايد للدولة في علاقات العمل ، أدى إلى دعوة البعض إلى إنتماء هذا القانون إلى قواعد القانون العام لا إلى قواعد القانون الخاص ، ولكن في الحقيقة قواعد هذا القانون تنتمى إلى القانون الخاص لا إلى القانون العام فهي لا تهتم بسيادة الدولة ولا بتنظيم السلطات العامة فيها ، إنما يهتم هذا القانون بعلاقات العمل الخاصة بين أصحاب الأعمال والعمال .

وقد كان قانون العمل يتضمن أيضا القواعد الخاصة بالتأمينات الاجتماعية

---

[١] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٧٥ .

كحماية العامل من إصابات العمل والمرض والشيخوخة ، ولكن استقل حاليا قانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل ، وبعض كليات الحقوق تجعل لقسم التشريعات الاجتماعية قسما مستقلا عن قسم القانون المدني .

٧ ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية :

قانون المرافعات المدنية والتجارية يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية ، والاجراءات المتبعة أمام المحاكم للحصول على الحقوق وحمايتها .

وقانون المرافعات المدنية والتجارية يعد وبحق الشريعة العامة لكافة القوانين الإجرائية سواء الجنائية أو الإدارية ، فإذا لم يوجد نص في قانون الاجراءات الجنائية أو الإدارية لبيان كيفية عمل إجراء معين ، لابد من الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ومن التعريف السابق لقانون المرافعات المدنية والتجارية يتضح لنا أنه يتولى بالتنظيم الموضوعات التالية :

- تنظيم السلطة القضائية ، وذلك عن طريق بيان جهات القضاء الموجودة في الدولة ، وأنواع المحاكم ودرجات القضاء ، والاختصاص المحلى والنوعى للمحاكم .
- بيان الاجراءات المتبعة أمام المحاكم ، ككيفية رفع الدعوى ، والمراحل التي تمر بها ، والحكم الصادر في الدعوى ، وكيفية الطعن فيه وطرق تنفيذه .

وقد شكك البعض في انتماء قانون المرافعات المدنية والتجارية لقواعد القانون الخاص ، وأكد هذا الاتجاه على ضرورة اعتبار قانون المرافعات من أحد فروع القانون العام على أساس أنه يتولى تنظيم أحد سلطات الدولة ، وهي السلطة

القضائية[١] ، ولكن البعض الآخر أيد إنتماء قواعد قانون المرافعات إلى فروع القانون الخاص ، وذلك على أساس أنه يتعلق بحقوق وواجبات أطراف النزاع[٢] .

ومن جانبنا لا نؤيد هذين الاتجاهين ، فقانون المرافعات لا ينتمى إلى قواعد القانون العام فقط ، ولا ينتمى إلى قواعد القانون الخاص فقط ، فهو وبحق يعتبر قانونا مختلطا يتعلق بالقانون العام فيما يخص تنظيمه للسلطة القضائية ، ويتعلق بالقانون الخاص فيا يتضمنه من اجراءات للحصول على حقوق الأفراد[٣] .

٨ ـ القانون الدولي الخاص :

القانون الدولي الخاص هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تختص بتحديد الاختصاص القضائى والقانون الواجب التطبيق في العلاقات التي يكون أحد أطرافها عنصرا أجنبيا ، كما أن القانون الدولي الخاص يهتم بدراسة الجنسية ، ويكفية اكتسابها ، وحالات سقوطها أو سحبها ، وبيان المركز القانونى للأجانب ، وحقوقهم وواجباتهم ، فالقانون الدولي الخاص لا ينظم العلاقات بين دول ذات سيادة كما هو الوضع في القانون الدولي العام ، ولكنه ينظم العلاقات الناشئة بين الأفراد من دول مختلفة أو العلاقات ذات العنصر الأجنبى .

وعلى سبيل المثال ، إذا باع مصريا عقارا مملوكا له إلى فرنسيا ، فهل القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة هو القانون المصري ، أم القانون االفرنسي ؟ وما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع عند حدوثه ؟ هل هي المحكمة المصرية أم أن الاختصاص سيكون منعقدا للقضاء االفرنسي ؟ أما إذا باع هذا

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٦٢ .

[٢] د. محمد سعد خليفة ؛ د. حمدى محمد عطيفي ، المرجع السابق ، ص ١٠٢ .

[٣] تدعيما لوجهة نظرنا نجد أن بعض فقهاء القانون يقسمون قانون المرافعات تحت فروع القانون المختلطة ، انظر د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٨٢ .

المصري عقاره الموجود في مصر إلى مصريا آخر ، فهنا العلاقة تكون وطنية في كافة جوانبها ، وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتداد بقواعد القانون الدولي الخاص .

ومن التعريف السابق للقانون الدولي الخاص يتضح لنا أنه يهتم بالموضوعات التالية :

- بيان وتعيين المحكمة المختصة ، وتعيين المحكمة المختصة يكون عن طريق قواعد تنازع الاختصاص القضائى الدولي ، وهذه القواعد تحدد فقط ما إذا كانت المحاكم الوطنية مختصة أم لا ، فهي لا تتولى تعيين المحكمة الأجنبية المختصة إذا كانت المحاكم الوطنية غير مختصة .
- بيان القانون واجب التطبيق ، ويتولى تحديد هذا القانون قواعد تنازع القوانين ، وتسمى بقواعد الاسناد ، أى اسناد النزاع إلى قانون معين بإعتباره القانون الواجب التطبيق .
- تحديد الجنسية وهي علاقة تبعية الفرد لدولة ، وبيان الموطن أى علاقة الفرد بالدولة ، وتحديد مركز الأجانب من خلال بيان حقوقهم وواجباتهم .

وجدير بالذكر أن القانون الدولي الخاص يعد قانونا مختلطا ، وذلك لأن شق من قواعده يهتم بالجنسية ومركز الأجانب وهي تدخل في نطاق القانون العام ، والشق الآخر خاص بقواعد الاسناد وهي شكلية أى لا تقدم حلولا موضوعية في النزاع ، وتحدد القانون الواجب التطبيق على علاقات الأفراد ، فهي حينئذ من علاقات القانون الخاص .

ويجب التنويه أيضا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص موزعة بين القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، فهذه القواعد لا يجمعها تقنين واحد كالتقنين المدني مثلا .

الفصل الثانـــى

القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة

القانون كما نعرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم على سبيل الإلزام السلوك الخارجى للأفراد في المجتمع ، من هذا التعريف يتبين لنا أن قواعد القانون ملزمة ، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا مجال لسلطان الإرادة إزاء القانون ، وأنه لا يتصور وجود اتفاقات مشروعة على خلاف ما يقرره القانون .

ففي الواقع القواعد القانونية ليست نوعا واحدا ، ولكن منها ما يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها ، ومنها ما لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها ، فمن حيث القوة والإلزام تنقسم القواعد القانونية إلى قواعد آمره وقواعد مكملة ، فما هو مفهوم هذين النوعين من القواعد ؟ وما هي معايير التفرقة بين القواعد الآمره والقواعد المكملة ؟ للإجابة على تلكم التساؤلات سنقسم الدراسة في هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين :

المبحث الأول : مفهوم القواعد الآمره والقواعد المكملة .

المبحث الثانى : معايير التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة .

المبحث الأول

مفهوم القواعد الآمرة والقواعد المكملة

من حيث مدى قوة وإلزام القواعد القانونية تنقسم هذه الأخيرة إلى قواعد آمره لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها ، وقواعد مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها .

وفيما يتعلق بالقواعد المكملة ، كيف نصفها بصفة القاعدة القانونية الملزمة وفي نفس الوقت يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها ؟!

لدراسة كل هذه الموضوعات نرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :

المطلب الأول : التعريف بالقواعد الآمرة والقواعد المكملة .

المطلب الثاني : مدى توافر صفة الإلزام في القواعد المكملة .

المطلب الأول

التعريف بالقواعد الآمرة والقواعد المكملة

القواعد الآمرة هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها ، ويتعين عليهم الانصياع لها وعدم الخروج عليها ، ويعتبر باطلا الاتفاق على مخالفة أحكام هذه القواعد ، حيث أن سلطان الإرادة ينعدم تجاه هذه القواعد الآمره ، والحكمة من بطلان الاتفاق على ما يخالف هذه القواعد هي تعلق واتصال هذه القواعد بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية ، فالقاعدة الآمره تمثل إرادة المجتمع

العليا التي رأت تنظيم موضوع معين تنظيما حاسما لا مجال فيه لحرية الأفراد ولا يجوز لهم مخالفة ذلك حفاظا على مصلحة المجتمع .

والقواعد الآمرة تنتشر في كل فروع القانون ، سواء القانون العام أو القانون الخاص ، وجدير بالذكر أن جميع قواعد القانون العام تكون قواعد آمره ، أما في مجال القانون الخاص فهناك من القواعد ما يكون آمرا ، ومنها ما يكون مكملا ، فعلى سبيل المثال معظم قواعد قانون العقوبات تكون آمره ، كالقواعد التي تنهي عن القتل خاصة وأنها تعالج سلوكا أساسيا في المجتمع ، والقواعد المتعلقة بجريمة السرقة أيضا تعتبر قواعد آمره حيث لا يجوز الاتفاق على سرقة شخص ، والقواعد المتعلقة بالقانون الدستورى أو الإدارى أو المالى تكون أيضا آمره ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها .

أما في مجال القانون الخاص هناك من القواعد ما يكون آمرا ، ومنها ما يكون مكملا أى يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها ، فالقواعد المتعلقة بتنظيم الأسرة من زواج وطلاق وحقوق للأولاد كلها آمره ، والقواعد التي تحدد أن سن الرشد القانونى هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة تكون أيضا آمره ، والقاعدة التي بين أنه لا يجوز لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها تكون أيضا آمره ، وكذلك القاعدة التي تضع حداً أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية بحيث لا يزيد على ٧ % تكون قاعدة آمره .

أما المقصود بالقواعد المكملة هي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها ، فالقانون عندما ينظم علاقات الأفراد يترك لهم الحرية في تنظيم علاقاتهم على الوجه الذي يرونه محققا لمصالحهم الخاصة خاصة وأنه لا يعود من جراء ذلك ضررا على المجتمع .

والقواعد المكملة لا مجال لها في فروع القانون العام سواء كان قانون



العقوبات أو القانون الدستورى ، أو القانون الإدارى ، أو القانون المالى ، أما في مجال القانون الخاص نجد العديد من قواعده يكون مكملا .

وعلى سبيل المثال المادة ٤٥٥ مدنى تنص على "إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره" .

فمن خلال نص هذه المادة يتبين لنا أنه يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكام هذه المادة ، ومن القواعد المكملة أيضا ما تقضى به المادة ٤٦٢ مدنى من "أن المشترى يتحمل نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل ونفقات تسليم المبيع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك" ، وما تقضى به المادة ٤٥٦ على أن "يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك" .

المطلب الثانـــى

مدى توافر صفة الإلزام فى القواعد المكملة

لقد عرفنا أن من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة ملزمة بمعنى أنه يجب على الأفراد الخضوع لأحكام القاعدة القانونية ، والقواعد المكملة يقصد بها القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها ، ومن هنا يتجلى لنا التعارض بين صفة الإلزام في القاعدة القانونية وبين قدرة الأفراد على مخالفة أحكام القواعد المكملة ، فهل نستطيع وصف هذه القواعد بأنها غير قانونية لإنتفاء صفة الإلزام ؟!

في الواقع هناك اجماعا فقهيا على أن القواعد المكملة تعتبر قواعد ملزمة ، ولكن اختلف الفقهاء في التوفيق بين توافر صفة الإلزام في القاعدة المكملة وبين السماح لهم بالخروج على أحكامها :

- فمن الفقهاء من رأى أن الزام القواعد المكلمة يستند إلى الإرادة الضمنية للأفراد ، فالمشرع قد افترض انصراف إرادة المتعاقدين إلى الأخذ بحكمها ، فإذا كانت إرادة الأفراد الصريحة لا نريد الأخذ بحكمها ، أخذنا بهذه الإرادة الصريحة ، ولكن قد تعرض هذا الرأى لسهام النقد على أساس أن الأفراد يخضعون لحكم القاعدة المكملة حتى ولو يجهلون حكمها .
- ورأى آخر قد اتجه إلى أن القاعدة المكملة تمر بمرحلتين فهي غير ملزمة واختيارية ابتداء ، وملزمة واجبارية انتهاء ، فهي غير ملزمة قبل إبرام الاتفاق ولكن بعد الاتفاق تكون ملزمة ، ولا يجوز للأفراد الخروج على أحكامها ، ولكن هذا الرأى غير سديد لأنه يغير من الحكم على القاعدة القانونية ، فهي غير

ملزمة قبل الاتفاق ، وملزمة بعده ، فكيف يستقيم ذلك؟[١]

ولكن الرأى الغالب في الفقه يؤكد أن القواعد المكملة ملزمة كالقواعد الآمرة تماما ، ولكن كل ما في الأمر أن تطبيق القاعدة القانونية المكملة معقود بشرط عدم وجود اتفاق مخالف لأحكامها ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن تم الاتفاق بين الأفراد على مخالفة أحكام هذه القاعدة القانونية المكملة ، وجب الامتناع عن تطبيقها[٢] ، وعدم تطبيقها هنا لا يرجع إلى أنها غير ملزمة ، ولكن يرجع إلى عدم توافر أحد شروط تطبيقها .

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٦٧ .

[٢] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٤٥ .

المبحث الثانى

معايير التفرقة بين القواعد الآمره والقواعد المكملة

لقد رأينا أن القواعد الآمرة هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها ، أما القواعد المكملة فهي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها والخروج على أحكامها .

ورأينا أن القواعد الآمرة تعمل في مجال يتعلق بكيان الدولة والمصلحة العامة للمجتمع ، أما القواعد المكملة غالبا ما تعمل في المجال الذي يتعلق بمصالح الأفراد وليس بمصالح عليا للمجتمع ، ويترتب على التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة أن مخالفة القواعد الآمرة والخروج على أحكامها يعتبر باطلا ، فكيف نتعرف إذن على القواعد الآمرة والقواعد المكملة ؟ وما هي معايير التفرقة بين هذين النوعين من القواعد ؟

للتمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد المكملة يستعين الفقه بالمعيارين التاليين :

أولا : المعيار الشكلى .

ثانيا : المعيار الموضوعى .

وفيما يلى سنعرض كل معيار على حده :

أولا : المعيار الشكلى :

يقوم هذا المعيار على الأخذ بألفاظ النص ودلالة عباراته ، فإذا كان مفهوما من ألفاظ النص النهي وعدم المخالفة ، كانت القاعدة آمره ، أما إذا كان مفهوما من عبارات النص السماح بالمخالفة ، كانت القاعدة مكملة .

بعض أمثلة للقواعد الآمره طبقا لهذا المعيار :

- ما تنص عليه المادة ٤٩ مدنى من أنه "ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية"
- المادة ٤٨ مدنى "ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها" .
- المادة ٤٦٥ مدنى "إذا احتفظ البائع عن البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا " .
- المادة ٤٧١ مدنى "لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، وإلا وقع البيع باطلا " .
- المادة ١١٠ مدنى "ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة" .
- المادة ٥١٥ مدنى "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا" .
- المادة ٢/١٣١ مدنى "التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه" .
- المادة ١٠٣١ مدنى "لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية" .

بعض أمثلة للقواعد المكملة طبقا لهذا المعيار :

- المادة ١/١٠٣ مدنى "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك" .
- المادة ٣٤٦ مدنى "يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك" .
- المادة ١/٤٥٦ مدنى "يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم في المبيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك" .

- المادة ٨٢٧ مدنى "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" .
- المادة ٤٦٢ مدنى "نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك" .

من خلال الاطلاع على ألفاظ وعبارات النصوص سالفة الذكر يتبين لنا أنها قواعد مكملة حيث يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ، وهذا واضح من عبارات يجوز ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

ثانيا : المعيار الموضوعى :

كما سبق المعيار الشكلى يقوم على البحث في عبارات وألفاظ النص للتعرف على نوع القاعدة القانونية ، وبيان ما إذا كانت آمره أم مكملة ، أما فيما يتعلق بالمعيار الموضوعى ، فهو لا يعتمد على ألفاظ النص وعباراته ، ولكنه يعتمد على موضوع القاعدة القانونية ، ففي الكثير من الأحيان نجد أن ألفاظ النص قد لا تسعفنا في معرفة نوع القاعدة القانونية ، فالعديد من النصوص لا تسمح عباراتها في التعرف على نوع القاعدة ، فالمادة ٢/٤٤ مدنى والتي تنص على أنه "سن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة" ، لا توضح الألفاظ هنا ما إذا كانت القاعدة آمره أم مكملة .

وقد أضاف البعض القول بأنه حتى ولو كان المعيار الشكلى مجديا فهو لا يكون كذلك إلا بالنسبة للقواعد التشريعية فقط أما القواعد العرفية تكون غير مكتوبة ولا تصاغ في ألفاظ معينة ، وبالتالى لا يمكننا استخدام المعيار الشكلى[١].

---

[١] د. محمد حسين عبد العال ، المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

لكل ما سبق ذكره ، كان من الضرورى البحث عن معيارا آخر لا يعتمد على الألفاظ ولكن على موضوع القاعدة .

والمعيار الموضوعى يقوم على النظر إلى مضمون النص وفحواه ، فإذا كانت القاعدة القانونية تهدف إلى المحافظة على المصالح الحيوية والأساسية للمجتمع كانت قاعدة آمره ، إما إذا كانت تهدف إلى الحفاظ على مصالح الأفراد الخاصة كانت قاعدة مكملة ، والمقصود بالمصالح الأساسية والحيوية للمجتمع هو النظام العام والآداب العامة ، فالنظام العام عبارة عن مجموعة المبادئ والمصالح الرئيسية والجوهرية التي يقوم عليها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلقيا ، ولا يتصور وجود المجتمع بدون هذه المبادئ والمصالح .

وعلى ذلك تكون القاعدة القانونية آمره إذا كانت تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ، أما إذا كانت عديمة الصلة بالنظام العام والآداب العامة كانت القاعدة مكملة ويجوز الاتفاق على مخالفتها .

ماهية فكرة النظام العام :

فكرة النظام العام تقوم على الحفاظ على المصالح الجوهرية والأساسية للمجتمع سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، ولا يكون كيان المجتمع باقيا بدون هذه المجموعة من المصالح الحيوية والجوهرية .

وفكرة النظام العامة مرنة ونسبية ، فهي تتأثر بالزمان والمكان وبالفكر السائد في المجتمع ، فهي تختلف من دولة إلى دولة ، ومن زمن إلى زمن ، فما يعد من النظام العام في زمن ما قد لا يعد من النظام العام في زمن آخر وفي نفس البلد ، وعلى سبيل المثال قد تحرم الدولة التعامل الربوى وتربطه بالنظام العام بحيث يبطل أى اتفاق يبيح الربا ، ولكن قد تعدل الدولة عن اتجاهها في زمن آخر وتتيح التعامل الربوى .

وفيما يتعلق بمرونة فكرة النظام العام من حيث المكان ، نجد ان ما يعد من النظام العام في دولة ما قد لا يعد من النظام العام في دولة أخرى ، فعلى سبيل المثال تعدد الزوجات وقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين تعتبر من النظام العام في مصر ، أما في فرنسا لا تعتبر من النظام العام .

وفكرة النظام العام تتأثر أيضا بالفكر السائد في المجتمع ، فإذا كن الفكر السائد في المجتمع فكراً فرديا تنكمش فكرة النظام العام حيث أن تقديس مصالح الأفراد هي روح المذهب الفردى ، أما إذا كان الفكر السائد هو الفكر الاشتراكى ، فإن فكرة النظام العام تزدهر خاصة وإن نشاط الدولة يزداد وتتدخل في كافة المجالات حيث أن مصالح الجماعة هي روح المذهب الاشتراكى .

وجدير بالذكر أن فكرة النظام العام تكون منتشرة بين فروع القانون ، فجميع قواعد القانون العام تكون متعلقة بالنظام العام نظرا لارتباطها بالمصالح الجوهرية للمجتمع ، فقواعد قانون العقوبات تكون متعلقة بالنظام العام نظرا لأنها تحافظ على حماية المجتمع ، ويبطل أى اتفاق على ارتكاب جريمة أو أن يحل شخص ما محل شخص آخر في تنفيذ العقوبة .

كما أن قواعد القانون الدستورى تتعلق بالنظام العام حيث أنها تهتم بتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وبيان اختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وأيضا قواعد القانون الإدارى تتعلق بالنظام العام حيث أنها تنظم نشاط السلطة التنفيذية ومدى علاقتها بالأفراد ، والقانون المالى أيضا يرتبط بالنظام العام حيث أن قواعده تتصل بالكيان الاقتصادى للدولة .

أما في مجال القانون الخاص ، نجد أن هناك من القواعد ما يتعلق بالنظام العام ، ومنها ما لا يتعلق بالنظام العام ، فالقواعد الشكلية كقواعد قانون المرافعات أو قواعد القانون الدولي الخاص تكون في معظمها متعلقة بالنظام العام ، أما

القواعد الموضوعية فمنها ما يتعلق بالنظام العام كقواعد الأحوال الشخصية ، ومنها ما لا يتعلق بالنظام العام كقواعد المعاملات ، ولكن في هذه الأخيرة قد توجد بعض القواعد التي تتعلق بالنظام العام ، فأحيانا يتدخل المشرع وينظم بعض المسائل بقواعد آمره لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، كتدخله في مجال قانون العمل وتحديد حد أقصى لساعات العمل ، فهنا لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك ، وأيضا القواعد التي تضع حدا أقصى لملكية الأراضى الزراعية تكون متعلقة بالنظام العام.

ماهية فكرة الآداب العامة :

قد يدمج البعض فكرة الآداب العامة مع فكرة النظام العام ، ويتم تعريف فكرة النظام العام والآداب العامة بأنها مجموعة المبادئ والمصالح الجوهرية التي يتأسس عليها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلقيا ، فالأسس الخلقية هي فكرة الآداب العامة ، فإذا أردنا تعريف فكرة الآداب العامة بمفردها يمكننا القول بأنها مجموع الأسس الأخلاقية الضرورية لقيام المجتمع والحفاظ عليه من الانحلال .

والقواعد القانونية التي تتعلق بهذه الفكرة تكون آمره ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وفكرة الآداب العامة مرنة كفكرة النظام العام ، فهي تتأثر بالزمان والمكان ، فما يعد من الآداب العامة في زمن ما قد لا يعد منها في زمن آخر ، فعقد التأمين على الحياة كان من العقود المخالفة للآداب العامة في مصر في وقت معين ، ولكن تغير الوضع حاليا وأصبحت من العقود المشروعة ، ومن حيث المكان فما يعد من الآداب العامة في دولة قد لا يعد منها في دولة أخرى ، فالزواج بين من هم من جنس واحد يعد من الآداب العامة في أماكن معينة لكنه باطل في مصر لمخالفته الآداب العامة .

ويجب التنويه إلى أن المشرع المصري قد جمع بين فكرتى النظام العام والآداب العامة ، والمادة ١٣٥ مدنى تنص على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا".

فالعقد المبرم بين شخصين لاستئجار منزل معين لممارسة الدعارة أو القمار يكون باطلا لمخالفته النظام العام والآداب العامة .

وتقديرها ما إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة يكون من اختصاص قاضى الموضوع وتحت رقابة محكمة النقض ، فمسألة توافر النظام العام والآداب العامة من عدمه مسألة قانون لا واقع وتخضع لرقابة محكمة النقض .

الباب الثالث

مصادر القانــون

المقصود بكلمة مصدر من الناحية اللغوية أصل الشئ أو منبعه ، فنقول مصدر نهر النيل أى منبع نهر النيل ، فمصادر القانون تعنى الأصول والمنابع التي تستقى منها هذا القانون ، ومصادر القانون متعددة فمنها المصادر المادية أو الموضوعية والمصادر التاريخية والمصادر الرسمية والمصادر التفسيرية .

والمصادر المادية أو الموضوعية تعنى الظروف والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية السائدة في المجتمع ، وضرورة مراعاة كل هذه الظروف عند سن القوانين والتشريعات ، فالقانون يستمد موضوعه من واقع وظروف المجتمع الذي يطبق فيه ، فالقانون وبحق يعتبر مرآة وترجمة لواقع المجتمع السياسى والاقتصادى والاجتماعي والخلقى ، وعلى سبيل المثال نجد أن قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢م قد صدر معبرا عن واقع المجتمع المصري قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م ، فقد كان الإقطاع مسيطرا على كل شئ مما نتج عنه شيوع الغضب بين أفراد المجتمع ، فجاءت ثورة يوليو لتعبر عن هذا الواقع المرير الذي عاشه الشعب المصري ، وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى الذي قضى على الإقطاع ووضع حدا أقصى لتملك الأراضى الزراعية .

ويقصد بالمصادر التاريخية الجذور التاريخية التي ينتسب إليها القانون ، فعندما يريد المشرع في بلد معين إصدار قوانين معينة لابد أن ينظر إلى القوانين السابقة للإستفادة منها عن طريق اقتباس الأحكام لتنظيم موضوعات القانون الجديد ، فإذا لم يجد المشرع في قوانين بلده ما يساعده على تنظيم الموضوع الجديد ، فلا ضرر من اللجوء إلى قوانين بعض الدول الأخرى للإستفادة منها ، ومثالاً لذلك نجد

أن القانون المدني المصري قد استفاد من القانون المدني القديم ومن الشريعة الإسلامية ومن القانون االفرنسي ، فكل هذه القوانين تمثل الجذور التاريخية للقانون المدني المصري .

وفيما يتعلق بالمصادر الرسمية ، هي تلك المصادر التي يستمد منها القانون قوته الملزمة ، فالمصدر الرسمى للقانون يعنى الطريقة المعتمدة التي تمر منها القاعدة القانونية وتكتسب من خلالها صفة القاعدة القانونية وتصبح ملزمة وواجبة التطبيق على جميع المخاطبين بأحكامها ، فلا يكفي معرفة المصادر الموضوعية أو التاريخية للقانون بل يجب معرفة الشكل الذي خرج من خلاله القانون ، فالقاعدة القانونية قد ترد في تشريع أو في عرف ، لذلك يقال أن التشريع أو العرف هما الطريق أو الأسلوب الذي عبر عن هذه القاعدة القانونية .

أما المصادر التفسيرية للقانون فيقصد بها المرجع الذي يستعان به عند تفسير القاعدة القانونية لبيان مضمونها وتوضيح الغموض الذي يعتريها ويعتبر كل من الفقه والقضاء مصدرين تفسيرين في القانون المصري واالفرنسي ، فدورهما يقتصر على تفسير القاعدة القانونية أما في بعض الدول الأخرى نجد أن القضاء يمثل مصدراً رسميا للقانون كما في انجلترا ، هذا مع التحفظ على أن القضاء الإدارى في مصر وفرنسا له دور هام في خلق قواعد القانون الإدارى .

وما يهمنا من كل هذه المصادر آنفة الذكر هو المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية للقانون ، وفيما يلى سنعرض لهذه المصادر على أن نخصص الفصل الأول لدراسة المصادر الرسمية أما الفصل الثانى سنخصصه لدراسة المصادر التفسيرية :

الفصل الأول : المصادر الرسمية .

الفصل الثانى : المصادر التفسيرية .

الفصل الأول

المصـــادر الرسميـــة

لقد نصت المادة الأولى من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ والمعمول به ابتداء من ١٥ أكتوبر ١٩٤٩م على أن "تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمتقضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة" .

طبقا لنص هذه المادة يتضح لنا أن المصادر الرسمية للقانون المصري هي :

١ . التشريع .

٢ . العرف .

٣ . مبادئ الشريعة الإسلامية .

٤ . مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .

وهذه المصادر مرتبة ترتيبا تدريجيا ومقصودا من المشرع المصري بحيث يتعين على القاضى الالتزام بهذا التدرج عندما يكون بصدد الفصل في مسألة معينة ، فيجب عليه اللجوء أولاً للتشريع ، فإذا لم يجد الحل كان له اللجوء إلى العرف ، لكنه إذا وجد الحل في التشريع وهو المصدر الأول ، كان عليه الالتزام بذلك ، وتطبيق هذا التشريع على الواقعة المثارة أمامه ، وإذا لم يجد القاضى الحل لا في التشريع ولا في العرف كان عليه الالتجاء إلى المصادر الأخرى كمبادئ الشريعة الإسلامية ثم مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

وهذه المصادر الرسمية للقانون المصري إما أن تكون مصادر رسمية أصلية وإما أن تكون مصادر رسمية احتياطية ، فالمصادر الرسمية الأصلية هي التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية في بعض المسائل كمسائل الأحوال الشخصية ، أما المصادر الاحتياطية فهي العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية في غير مسائل الأحوال الشخصية وأخيرا مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .

وسنعرض للمصادر الرسمية الأصلية والمصادر الرسمية الاحتياطية فيما يلى :

المبحث الأول : المصادر الرسمية الأصلية .

المبحث الثانى : المصادر الرسمية الاحتياطية .



المبحث الأول

المصادر الرسمية الأصلية

هناك مصدرين رسميين أصليين للقانون هما التشريع وقواعد الدين بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية ، فالتشريع هو المصدر الرسمى للقانون في كل المسائل بوجه عام ، سواء المعاملات المالية أو حتى بعض مسائل الأحوال الشخصية التي ورد في شأنها تشريعات خاصة ، أما مسائل الأحوال الشخصية الأخرى التي لم يرد بشأنها تشريع خاص تخضع لقواعد الدين سواء كان دينا إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا ، فقواعد الدين إذن المصدر الرسمى الأصلى لمسائل الأحوال الشخصية .

وسنتناول في مطلب مستقل كل مصدر من هذين المصدرين الرسميين الأصليين للقانون :

المطلب الأول : التشريع .

المطلب الثانى:قواعد الدين بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية .

المطلب الأول

التشريـــــع

المقصود بكلمة التشريع هو وضع القواعد القانونية وإخراجها في صورة مكتوبة ، وبناءً على اتباع اجراءات معينة بواسطة السلطة المختصة في الدولة ، والسلطة المختصة بالتشريع هي مجلس النواب طبقا لنص المادة ١٠١من الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤م ، وقد ينصرف معنى التشريع إلى المصدر بإعتباره هو المصدر المستمد منه القاعدة القانونية ، وقد يراد أيضا بكلمة التشريع هي مجموعة القواعد التشريعية التي تنظم موضوعا معينا أو تتولى تنظيم نشاط معين ، فيقال مثلا تشريع العمل ، تشريع التأمنيات الاجتماعية ، تشريع الضرائب ، التشريع المدني ، التشريع التجاري .

ولدراسة التشريع كمصدر رسمى أصلى للقانون دراسة وافية لابد من تناول الموضوعات التالية :

الفرع الأول : أنواع التشريـع .

الفرع الثانـى: سن التشريع ونفاذه .

الفرع الثالـث : الرقابة على صحة التشريع .

الفرع الرابـع : الغـاء التشريع .

الفرع الخامس : تقييم وتقدير التشريع .

الفرع الأول

أنـواع التشريـــع

يوجد ثلاثة أنوع للتشريع ، وهذه الأنواع الثلاثة مرتبة ترتيبا هرميا ، وتختلف قوة كل نوع بحسب الموضوعات التي ينظمها ويعالجها ، ففي المرتبة الأولى يكون التشريع الأساسى أو الدستورى أو الأسمى ، ويأتى في المرتبة الثانية التشريع العادى أو الرئيسى ، وفي المرتبة الأخيرة يأتى التشريع الفرعى أو اللائحى .

فالتشريع ينقسم إلى ثلاثة أنواع :

أولا : التشريع الأساسى أو الدستورى .

ثانيا : التشريع العادى أو الرئيسى .

ثالثا : التشريع الفرعى أو اللائحى .

وسنتناول فيما يلى كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة .

أولا : التشريع الأساسى أو الدستورى :

يقصد بالتشريع الدستورى هو مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، كما أنه يحدد السلطات العامة في الدولة ، موضحا اختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض ، كما أنه أيضا يوضح مقومات المجتمع الأساسية ، ويبين الحقوق والحريات العامة للأفراد في المجتمع .

ويعتبر التشريع الدستورى أو الأساسى أسمى أنواع التشريع ، ولابد من احترام كل من التشريع العادى أو الرئيسى والتشريع الفرعى أو اللائحى للدستور ، وإذا لم يتفق أحد هذين النوعيين مع أحكام الدستور ، وصف بعدم الدستورية ، فإذا خالف التشريع العادى الدستور كان تشريعا غير دستوريا ، وإذا خالفت اللائحة

الدستور كانت لائحة غير دستورية ، وتعين عدم الأخذ بها .

وهناك طرق معينة لنشأة الدساتير ، فسن الدستور قد يكون عن طريق المنحة أو عن طريق الاتفاق بين الحاكم وشعبه أو عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة لوضع الدستور ، والمقصود بنشأة الدستور عن طريق المنحة هو أن يصدر الحاكم قرار المنح ليتنازل فيه عن بعض حقوقه وسلطاته من أجل عدم ثورة الشعب ، ويعتبر الدستور المصري الصادر في سنة ١٩٢٣م منحة من الملك للشعب ، فقد أصدره الملك فؤاد ليقيد به بعض سلطاته تجنبا لغضب وثورة الشعب ، أما سن الدستور عن طريق الاتفاق هو أن يصدر الدستور في شكل عقد أو اتفاق بين الحاكم وبين الشعب أو ممثلى الشعب ، ومن أمثلة ذلك دستور فرنسا سنة ١٨٣٠م ، ودستور الكويت سنة ١٩٦٢م .

أما الطريقة الثالثة لنشأة الدستور فهي عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب ، وهذا كما حدث في دستور ليبيا سنة ١٩٥١، وقد لا يقتصر الأمر على هذا النحو بل يجب اتباع إجراء آخر بعد وضع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية ، كضرورة عرض الدستور على الشعب لأخذ رأيه ، وهو ما يسمى بالاستفتاء الدستورى ، ومثال هذه الطريقة الأخيرة هو دستور مصر سنة ١٩٧١م ودستور ٢٠١٤م .

فقد صدر دستور مصر عام ٢٠١٤م عن طريق لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسى وبعد موافقة الشعب المصري عن طريق الاستفتاء الشعبى ، وقد تم إصدار هذا الدستور في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور .

وفيما يتعلق بتعديل الدستور ، فالأمر يختلف بحسب نوع الدستور ، فهناك فرق بين الدستور المرن وبين الدستور الجامد ، فالدستور المرن يقبل التعديل بقانون يصدر عن السلطة التشريعية بنفس الاجراءات المقررة لوضع وتعديل

القوانين العادية ، ومثل هذا النوع هو الدستور الإيطالى سنة ١٩٤٨م ، أما الدستور الجامد لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات مغايرة لتلك التي تتبع في وضع القوانين العادية ، ومن أمثلة هذا النوع هو الدستور المصري الصادر في سنة ٢٠١٤م .

ثانيا : التشريع العادى أو الرئيسى :

التشريع العادى أو الرئيسى هو التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية في الدولة ، وطبقا لأحكام الدستور المصري الصادر في سنة ٢٠١٤م يكون سن التشريع من اختصاص مجلس النواب المصرى[١] .

ومن الناحية العملية يطلق على التشريع الصادر من مجلس النواب لفظ القانون ، وهذا التشريع الصادر من مجلس النواب يسمى بالتشريع الرئيسى ، وأن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في إصداره إلا أنه يكون من حق السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين لها نفس قوة القوانين الصادرة من مجلس النواب في حالات استثنائية ، لذلك تسمى هذه التشريعات بالتشريعات الاستثنائية .

التشريعات الاستثنائية :

يمكننا الإشارة إلى حالة يجوز فيهما لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين لها نفس قوة التشريعات الصادرة من مجلس النواب، هي حالة الضرورة،وهو ما يسمى بتشريع الضرورة .

تشريع الضرورة :

لقد خول الدستور المصري الصادر في سنة ٢٠١٤م لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بقوانين لها نفس قوة التشريع الصادر من مجلس النواب

---

[١] مادة ١٠١ من دستور مصر ، سنة ٢٠١٤م .

وذلك في حالة الضرورة .

فالمادة ١٥٦من هذا الدستور تنص على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

ويتضح لنا من خلال تحليل نص المادة ١٥٦ سالفة الذكر أن رئيس الجمهورية له الحق في إصدار قرارات بقانون في حالة الضرورة ، ولكن يجب توافر الشروط والقيود التالية :

أ . أن تكون هناك ضرورة تتطلب إتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير ، كحدوث أمر عاجل يقتضى السرعة في اتخاذ القرارات المناسبة دون تأخير ، لأن هذا الأمر العاجل لا يحتمل الانتظار حتى انعقاد مجلس النواب لإصدار القوانين المناسبة ، ولكن إذا كان الأمر ليس عاجلا لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار هذه القرارات بقوانين .

ب . ألا يكون مجلس النواب قائما ، أى ضرورة أن تكون حالة الضرورة قد توافرت في غيبة مجلس النواب كأن كان منحلاً أو انقضى الفصل التشريعي ، فإذا لم يكن المجلس في غيبة ، فيجب على رئيس الجمهورية دعوته لانعقاد طارئ لمواجهة حالة الضرورة بإصدار القوانين المناسبة .

جـ . يجب أن تكون القرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية متفقة مع أحكام الدستور ، وهذا أمر بديهي ومسلم به ، فإذا كانت القوانين الصادرة من السلطة الأصيلة وهي مجلس النواب يجب أن تكون غير مخالفة للدستور ، فإنه من باب أولى عدم مخالفة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية للدستور .

د . ضرورة عرض القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده إذا لم يكن المجلس قائما ، والحكمة من ذلك هي منع تعسف السلطة التنفيذية في استخدام حقها ، فعن طريق رقابة المجلس على هذه القرارات بقوانين لا تستطيع السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية تجاوز الحدود المحددة لها .

وإذا لم تعرض القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية على مجلس النواب خلال المدة المحددة زال ما كان لها من قوة القانون بأثر رجعى ، أما إذا تم عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب خلال المدة المحددة ، فهذا الأمر لا يخرج عن فرضين : الموافقة على هذه القرارات وفي هذه الحالة تحتفظ بقوتها في مواجهة المخاطبين بأحكامها ، وإما يكون الرفض هو مصير هذه القرارات ، وفي هذه الحالة يزول بأثر رجعى ما كان لها من قوة من وقت إصدارها وليس من وقت رفضها ، ولكن من حق مجلس النواب أن يقصر آثار هذا الزوال على المستقبل فقط دون الماضى ، فللمجلس الحق في معالجة هذا الأمر بالطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للصالح العام .

ثالثا : التشريع الفرعى أو اللائحى :

يقصد بالتشريع الفرعى هو اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في إصدارها بنص الدستور ، فالسلطة التنفيذية لا

تحل محل السلطة التشريعية في إصدار هذه اللوائح كما هو الوضع بالنسبة لتشريع الضرورة ، ومعنى ذلك أن حق السلطة التنفيذية في إصدار هذه اللوائح لا يتوقف على توافر حالة الضرورة.

والتشريع الفرعى يصدر في صورة لوائح تحتوى على قواعد عامة مجردة تختلف عن القرارات الإدارية الفردية التي تخاطب أشخاص معينين بالذات ، فالتشريع الفرعى يعد قانونا من حيث الموضوع وليس الشكل وذلك لأنه يصدر من السلطة التنفيذية[1] ، وجدير بالذكر أن التشريع الفرعى أو اللائحى يصدر من أجل تنفيذ القوانين أو من أجل إنشاء وتنظيم المرافق العامة أو بغرض الحفاظ على الأمن والسكينة العامة ، وترتيبا على ذلك يمكننا تقسيم التشريع الفرعى إلى ثلاث أنواع :

١ . اللوائح التنفيذية :

يقصد باللوائح التنفيذية هي تلك الصادرة من السلطة التنفيذية بغرض تنفيذ القوانين ، فإذا كانت السلطة التشريعية هي المختصة بوضع القانون ، فإن السلطة التنفيذية هي المختصة بإصدار اللوائح بهدف تنفيذ القوانين لا سيما أنها السلطة الأقرب للأفراد في المجتمع ، وتعلم بالمشاكل التي يمكن أن تثور عند تنفيذ القوانين ، لذلك كان الدستور محقا عندما أعطى للسلطة التنفيذية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية .

وقد كان الوضع في ظل المادة ١٤٤ من الدستور المصري الملغي الصادر في ١٩٧١ أن رئيس الجمهورية يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

---

[1] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٩٢ .

ولكن تغير الوضع في ظل دستور ٢٠١٤م حيث نصت المادة ١٧٠ منه على أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يملك الحق في إصدار اللوائح التنفيذية بهدف تنفيذ القوانين ، كما أنه يجوز له تفويض غيره كأحد الوزراء أو المحافظين في إصدار هذه اللوائح ، كما أنه يجوز للقانون أن يعين من الذي يتولى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

ويجب التنويه إلى أن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تتعدى الغرض من إصدار هذه اللوائح ، فعلى سبيل المثال لا يجوز لها أن تتعرض للقانون المراد تنفيذه بالتعديل أو بالتغيير ، وإذا فعلت ذلك يكون مصير هذه الأفعال هو البطلان ، فقد نصت المادة ١٧٠ من الدستور صراحة على عدم تجاوز الهدف من إصدار اللوائح التنفيذية .

٢ . اللوائح التنظيمية :

هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية مشتملة على القواعد اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة في الدولة، وتصدر هذه اللوائح مستقلة عن أي قانون معين بالذات، أي أنها تصدر قائمة بذاتها دون أن تستند إلى قانون معين كما هو الشأن بالنسبة للوائح التنفيذية.

وقد كان الحق في إصدار هذه اللوائح مخولا لرئيس الجمهورية طبقا لدستور ١٩٧١ الملغي، ولكن تغير الوضع في دستور ٢٠١٤ حيث نصت المادة ١٧١ منه أنه "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء".

من خلال الإطلاع على نص هذه المادة يتبين لنا أن رئيس مجلس الوزراء له الحق بنص الدستور في إصدار اللوائح التنظيمية بغرض إنشاء وتنظيم المرافق العامة ، فالهدف الأساسى من هذه اللوائح هو إنشاء وتنظيم المرافق العامة عن

طريق ترتيب وتنسيق العمل في الإدارات والمصالح الحكومية ، ويجب التنوية إلى أن هذه اللوائح لا ترتبط بقانون معين قد صدر ويجب تنفيذه ، إنما هي مستقلة بذاتها ولا تكون من أجل تنفيذ القوانين ، إنما هي من أجل إنشاء وتنظيم المرافق العامة ، كمرفق المياه أو الكهرباء أو الصحة أو التعليم على سبيل المثال .

وبالإطلاع على نص المادة ١٧١ آنفة الذكر يمكننا أن نستنبط أن رئيس مجلس الوزراء وحده الذي يملك الحق في إصدار اللوائح التنظيمية ولا يجوز له أن يفوض غيره كأحد الوزراء في إصدار هذه اللوائح ، خصوصا وأن هذه اللوائح تتولى تنظيم مسائل في غاية الأهمية وهي إنشاء وتنظيم المرافق العامة ، وهذا على النقيض من اللوائح التنفيذية التي يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض غيره في إصدارها .

٣ . لوائح الضبط :

لوائح الضبط تعنى تلك اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية بغرض تحقيق الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، وقد نصت المادة ١٧٢ من الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ على أنه "يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء" ، ومن أمثلة لوائح الضبط لوائح المرور ولوائح المحلات المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة ولوائح الباعة الجائلين ولوائح مراقبة التغذية .

وبالنظر الفاحص لنص المادة ١٧٢ سالفة الذكر يتضح لنا أن رئيس مجلس الوزراء وحده الذي يملك إصدار هذه اللوائح ، ولا يجوز له تفويض غيره في إصدارها ، وهذا كما هو الوضع تماما بالنسبة للوائح التنظيمية التي تصدر من قبل رئيس مجلس الوزراء وحده ، فلوائح الضبط تتعرض لمسائل هامة وغاية في الحيوية لتعلقها بالأمن العام ، لذلك كان منطقيا تخويل الحق في إصدارها لرئيس مجلس الوزراء فقط .

الفرع الثانى

سـن التشريع ونفـاذه

لقد تناولنا في الدراسات السابقة التشريع الدستورى أو الأساسى ، وبينا كيفية إصداره أو سنه سواء عن طريق المنحة أو الاتفاق أو الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء الدستورى ، أما بالنسبة للتشريع العادى الصادر من مجلس النواب فهو محل دراسة هذا الفرع لنبين مراحل سن هذا التشريع ونفاذه حتى يكون ساريا على كافة المخاطبين بأحكامه .

أولا : سن التشريع العادى :

لوضع وسن التشريع العادى يجب المرور بمرحلتين هما مرحلة الاقتراح ثم مرحلة المناقشة والتصويت ، فالسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب في مصر ، يجب لسن القانون اتباع هاتين المرحلتين :

١ . مرحلة الاقتـراح :

طبقا لأحكام الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ يكون حق تقديم الاقتراح بقانون لكل من رئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية[١] ، والإقتراح المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة أو من عشر أعضاء مجلس النواب يطلق عليه اصطلاح "مشروع قانون"، أما الاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب يطلق عليه اصطلاح "اقتراح بقانون"[٢] .

ورغم أن الحق في اقتراح القانون يكون لكل من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب ، إلا أن الدستور فرق بينهما في

---

[١] مادة ١٢٢ من الدستور المصري الصادر في سنة ٢٠١٤م .

[٢] د. محمد سعد خليفة ؛ د. حمدى محمد عطيفي ، المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

خصوص المراحل التي يمر بها الاقتراح ، وهذه التفرقة تتجلى مظاهرها فيما يلى :

أ . مشروع القانون المقدم من الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب يحال مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة لفحصه ودراسته بهدف تقديم تقرير عنه ، فإذا كان مشروع القانون المقدم يتعلق بالزراعة أو بالصناعة مثلا ، يحال الأمر إلى اللجنة النوعية المختصة بدراسة موضوع المشروع بقانون ، أما فيما يتعلق باقتراح القانون المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب ، فإنه يقدم أولا إلى لجنة الاقتراحات لتوضيح مدى جديته ومدى جواز عرضه على المجلس من عدمه ، فإذا وافقت عليه لجنة الاقتراحات يحال إلى اللجنة النوعية المختصة ليأخذ نفس مراحل المشروع بقانون المقدم من الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب.

والحكمة من المغايرة بين المشروع بقانون المقدم من الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب والمشروع بقانون المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب هو أن المشروع بقانون المقدم من الحكومة يخضع لدراسات وافية فيما يتعلق بالموضوع أو بكيفية الصياغة ، فيتولى المتخصصون والخبراء من الأجهزة الحكومية المختلفة دراسة هذا المشروع وصياغته صياغة قانونية سليمة ، هذا وقد نص قانون مجلس الدولة المصري على ضرورة قيام كل وزارة أو مصلحة قبل اصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية بعرض الأمر على قسم التشريع لمراجعة الصياغة حتى نصل إلى صياغة قانونية سليمة تعبر عن حقيقة المقصود من اصدار هذا المشروع بقانون[1]، كما أن المشروع بقانون المقدم من عشر أعضاء مجلس النواب يدل على جديته والرغبة الحقيقية لعدد كبير من النواب في إصدار قانون معبر عن الشعب، أما المشروع بقانون المقدم من أحد أعضاء

---

[1] مادة ٦٣ من القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م بشأن مجلس الدولة .

مجلس النواب لا يخضع لنفس درجات ومراحل العناية التي يمر بها المشروع بقانون المقدم من الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب.

ب . قد ساوى الدستور الحالي الصادر في ٢٠١٤ بين المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون في حالة رفضه من مجلس النواب، حيث لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد طبقا لما جاء في نص المادة ١٢٢ من الدستور، وهذا على عكس ما كان عليه الوضع في ظل دستور ١٩٧١ الملغي، حيث توجد تفرقة بين المشروع بقانون المقدم من رئيس الجمهورية والمشروع بقانون المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب ، فقد جاء في نص المادة ١١١ من الدستور الملغي أن المشروع بقانون المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب يعتبر كأن لم يكن إذا رفضته لجنة الاقتراحات ، ولا يجوز تقديمه مرة ثانية في نفس دورة الانعقاد ، أما فيما يخص المشروع بقانون المقدم من رئيس الجمهورية لم يتضمن الدستور في مادته ١١١ شيئا من ذلك ، وترتيبا على ذلك أنه إذا حدث خلافا حول المشروع بقانون المقدم من رئيس الجمهورية أو تم رفضه، فإنه يجوز عرضه مرة ثانية في نفس دورة الانعقاد .

٢ . مرحلة المناقشة والتصويت :

بعد انتهاء اللجنة النوعية المختصة من دراسة مشروع القانون وفحصه ، فإنها تعد تقريرا للعرض على مجلس النواب مرفقا به مشروع القانون من أجل مناقشته والتصويت عليه ، وأولا يجب على المجلس مناقشة مشروع القانون بصفة إجمالية لمعرفة مدى الموافقة عليه من حيث المبدأ ، فإذا تمت الموافق عليه من حيث المبدأ ، يجب مناقشة مواده ، كل مادة على حدة وأخيرا تؤخذ الأصوات على المشروع في مجموعة ، وطبقا لما ورد في المادة ١٢١ من دستور ٢٠١٤م لا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر

القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

أما فيما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور، فإنها تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

وخلاصة القول أنه يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس جميعا حتى يتسنى لهم مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه ، وإذا توافرت هذه الأغلبية المطلقة لصحة انعقاد المجلس ، يكون المشروع بقانون قد تم الموافقة عليه إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وهي النصف زائد واحد ، ويجب التنويه إلى أن مشروع القانون إذا تمت الموافقة علية من قبل الأغلبية المطلوبة يكون قانونا موجودا بالفعل ، لكنه لا يصبح ساريا ونافذا في حق المخاطبين بأحكامه إلا بعد اتباع اجراءات معينة لنفاذه .

ثانيا : نفـاذ التشريع العادى :

بعد التصويت على مشروع القانون بالموافقة ، أى بعد تحقق الأغلبية المطلوبة يكون مشروع القانون قانونا موجودا بالفعل ، وحتى يكون نافذا في حق كافة المخاطبين بأحكامه ، لابد من إصداره من قبل رئيس الجمهورية حتى يتسنى لرجال السلطة التنفيذية تنفيذه ، ولابد أيضا من نشره حتى يعلم به الأفراد في المجتمع .

فلنفاذ التشريع العادى يشترط المرور بمرحلتين هما مرحلة الإصدار ثم

مرحلة النشر .

١ . مرحلة الإصدار :

يقصد بالإصدار هو العمل التنفيذى الذي يتولاه رئيس الجمهورية من خلال توجيه الأمر إلى رجال السلطة التنفيذية ليقوموا بتنفيذ القانون والإلتزام بذلك شأنه شأن القوانين المعمول بها والنافذة في الدولة ، فالإصدار إذن يكون بمثابة شهادة ميلاد للتشريع ، فبعد موافقة مجلس النواب على القانون يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره ، فإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، لا يملك مجلس النواب سلطة اصدار القانون وتوجيه الأمر إلى السلطة التنفيذية لتنفيذه .

وقد نصت المادة ١٢٣ من الدستور الحالي ٢٠١٤م على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها" ويتضح لنا من هذه المادة أن رئيس الجمهورية هو الذي يملك الحق في إصدار القانون ، ويجب التنويه إلى أن ذلك يكون منطقيا بالنسبة للتشريع العادى الذي تم وضعه من قبل مجلس النواب ، أما بالنسبة للتشريعات الاستثنائية التي توضع في حالة الضرورة، فلا حاجة إلى إصدارها ، لأن السلطة التي لها حق الإصدار هي نفس السلطة التي سنت هذه التشريعات فليس من المنطقى أن توجه السلطة التي وضعت التشريع أمراً إلى نفسها بتنفيذ هذا التشريع .

ويتضح لنا أيضا من الاطلاع على نص المادة ١٢٣ آنفة البيان أن رئيس الجمهورية قد يعترض على إصدار القانون المرسل إليه من مجلس النواب ، ولدراسة هذه المسألة يجب أن نفرق بين الفرضين التاليين :

الفرض الأول :

حالة عدم اعتراض رئيس الجمهورية على القانون ، وهنا عليه أن يقوم بإصداره حتى يتسنى نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية لإعلام الكافة به .

الفرض الثانى :

حالة اعتراض رئيس الجمهورية على القانون ، وهذا حق دستورى خولته المادة ١٢٣ من الدستور لرئيس الجمهورية ، ولكن يجب أن يتم هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من ابلاغه بالقانون من قبل مجلس النواب ، فإذا لم يعترض خلال هذه المدة ، يعتبر عدم الرد قبولاً منه بإصداره ، وهذا ما يسميه البعض بالإصدار المفترض[١] ، أى أننا نفترض قبول رئيس الجمهورية إصدار القانون طالما أنه لم يعترض عليه خلال مدة الثلاثين يوما .

ولكن إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون في المدة المحددة ، فإننا نكون إزاء أحد الموقفين التاليين :

الموقف الأول :

هو قبول مجلس النواب لإعتراض رئيس الجمهورية ، وذلك بإعادة مناقشة نصوص المواد التي تم الاعتراض عليها ، ومراعاة الاعتبارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية عند إعادة النظر في القانون المعترض عليه .

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٩٧ .

الموقف الثانى :

هو إصرار مجلس النواب على القانون ، وإصداره كما هو بكل مواده ، ولكن الأمر هنا يتطلب أغلبية خاصة ، وهي موافقة ثلثى أعضاء المجلس جميعا وليس الحاضرين فقط على البقاء على هذا القانون ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الجمهورية إصداره رغم اعتراضه عليه ، وهذا هو ما يسمى بالإصدار المفروض ، أى يجب على رئيس الجمهورية إصدار القانون ولا يجوز له الاعتراض عليه .

٢ . مرحلـة النشـر :

بعد إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية يجب علم الكافة به ، ولا يتحقق هذا العلم إلا بنشر القانون ، فبالنشر يكون التشريع ملزما للناس، فالمنطق والعدالة يفرضان ضرورة علم الناس بالقانون الذي ينظم سلوكهم في المجتمع ، وجدير بالذكر أن إعلام كافة الناس بالقانون يعد أمراً مستحيلاً ، لذلك العلم المقصود هو العلم الافتراضى ، بمجرد نشر القانون يفترض أن الجميع قد علموا به ، وهذا العلم الافتراضى يتحقق بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقد نصت المادة ٢٢٥ من الدستور الحالي على أنه "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر" ، ويتبين لنا من نص هذه المادة أنه من اللازم نشر التشريع في الجريدة الرسمية حتى يكون ملزما للأفراد المخاطبين بأحكامه.

والجريدة الرسمية كانت تسمى قبل ١٣ من مارس سنة ١٩٥٨ بالوقائع المصرية ، وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة صدر قرارا جمهوريا ، بإنشاء الجريدة الرسمية ، وقد تم تخصيص جريدة الوقائع المصرية لنشر الإعلانات

الحكومية والقضائية ، أما الجريدة الرسمية فهي التي تنشر فيها القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ، وفي سنة ١٩٦٧م صدر قرار جمهورى لتخصيص الجريدة الرسمية لنشر القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ومن رئيس مجلس الوزراء ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة القيم ، وتصدر هذه الجريدة أسبوعيا ما لم يكن هناك أمرا عاجلا لإصدار أعداد غير عادية ، وأصبح للجريدة الرسمية ملحقا يصدر يوميا يسمى بالوقائع المصرية لنشر القرارات الوزارية[١] .

فالنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة المعتمدة قانونا حتى يتحقق العلم الافتراضى بالقانون ، فلا يغنى عن الجريدة الرسمية أية وسيلة أخرى ، كنشر القانون في التليفزيون أو الإذاعة ، ولا يعتبر أيضا نشرا قانونيا بالمعنى الصحيح تعليق صور من القانون في أماكن بارزة على الحوائط في الشوارع والميادين العامة الرئيسية ، فالنشر عن طريق هذه الوسائل لا يكون كافيا لنفاذ التشريع في حق جميع المخاطبين بأحكامه[٢] .

ونشر القانون في الجريدة الرسمية يقتضى طبع هذه الجريدة بأعداد كافية حتى يتسنى للجمهور الحصول عليها ، وضرورة أن توضع الأعداد الصادرة من الجريدة الرسمية موضع التوزيع الفعلى ، فمجرد النشر في الجريدة الرسمية لا يكفي لتحقق علم الناس بالقانون ، بل يجب أن يتبع ذلك توزيع الجريدة .

ومن الناحية العملية يتعذر علم كافة الناس بالقانون فور نشره ، لذلك لا يكون القانون نافذا إلا بعد مضى مدة معينة من تاريخ النشر ، وهذا ما حددته المادة ٢٢٥ من الدستور آنفة البيان ، فالقوانين لا تكون نافذة في مواجهة

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٩٩ .

[٢] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٢٤٥ .

المخاطبين بأحكامها إلا بعد مرور ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، فاليوم الذي تم النشر فيه لا يحسب ، وهذا ما لم يتم تحديد تاريخ آخر لنفاذ القوانين المنشورة ، فقد تحدد هذه القوانين ميعاد آخر أطول أو أقصر لنفاذها ، ومثال ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م بإصدار القانون المدني قد نصت على أن يعمل بهذا القانون ابتداء من ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٩م ، رغم أن هذا القانون قد صدر في ١٦ يولية سنة ١٩٤٨م وتم نشره في ٢٩ يوليه سنة ١٩٤٨م ، ويتضح لنا من مضمون المادة الثانية أن هناك مدة أطول من مدة الثلاثين يوما لنفاذ القانون المدني .

وخلاصة القول أن القانون يكون نافذا في حق المخاطبين بأحكامه بعد نشره في الجريدة الرسمية ، ومراعاة الشروط المقررة لهذا النشر طبقا لنص المادة ٢٢٥ من الدستور المصري ، وطالما تم نشر القانون وتحققت شروط النشر ، لا يجوز لأحد أن يتذرع بالجهل بالقانون الجديد الذي تم نشره ، ولكن يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون في حالة القوة القاهرة ، فالقاعدة هي عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ، والاستثناء هو جواز ذلك الاعتذار في حالة القوة القاهرة .

قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون :

مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يقصد به أن القانون طالما تم نشره في الجريدة الرسمية ، وتحققت شروط هذا النشر طبقا لنص المادة ٢٢٥ من الدستور ، فلا يجوز لأحد الاعتذار بجهله بالقانون ، ويكون هذا الأخير نافذا في حق كافة المخاطبين بأحكامه ، فإنه غير مقبول إدعاء البعض بأنه غير مسئول عن المخالفة التي تمت لأنه لا يعلم بالقانون الذي خالف قواعده ، كما أنه أيضا غير مقبول القول بعدم العلم بالقانون نظرا لعدم معرفة القراءة ، أو للوجود خارج البلاد وقت نشر القانون وبالتالى لا يمكن العلم به .

ومبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يجد الكثير من المبررات التي يقوم عليها ، ويمكننا ذكر المبررات التالية :

١ . مراعاة الضرورة العملية :

قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون تقتضيها الضرورات العملية ، فالدستور جعل نفاذ التشريع متوقفا على النشر في الجريدة الرسمية ومراعاة المدة المحددة بعد النشر لنفاذ القانون ، وأساس العلم بالقانون هو العلم الافتراض لأنه من المستحيل اشتراط العلم اليقينى ، والواقع العملى يتطلب الأخذ بنظرية العلم الافتراضى .

٢ . المساواة بين العالم بالقاعدة القانونية والجاهل بها :

إذا أخذنا بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ، فإننا لن نحقق المساواة بين من علم بالقانون وبين من لا يعلم به ، لأننا لو أعفينا الجاهل بالقانون من أحكامه ، فإننا في هذه الحالة نقدم مكافأة لهذا الشخص المهمل ، وعلى النقيض من ذلك فإننا نلزم من علم بالقانون بأحكام هذا القانون وقواعده ، فكيف نلزم العالم بالقانون ونستثنى الجاهل به غير الحريص على متابعة قوانين بلاده ؟! لذلك نجد أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون تحقق المساواة ، ويكون الجميع ملزما بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية .

٣ . عدم مراعاة الظروف الشخصية :

الأخذ بالاعتذار بالجهل بالقانون يؤدى إلى نتيجة خطيرة وهي رهن تطبيق القانون بالظروف الشخصية ، فالشخص الذي يجد في تطبيق القانون تعارضا مع مصالحه يدعى بعدم علمه بهذا القانون لتجنب أحكامه ، وهذا سيؤدى إلى الأخذ بالظروف الخاصة بكل شخص مما يؤدى إلى إهمال المصلحة العامة .

٤ . تحقيق غايات القانون :

لا شك أن الأخذ بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يؤدى إلى تحقيق غايات القانون ، فالأخذ بنظرية العلم الافتراضى يؤدى إلى تحقيق الاستقرار داخل المجتمع ، وإقامة النظام ، وتحقيق العدل ، وكل هذا هو غايات القانون .

نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون :

مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون لا يقتصر على القواعد القانونية التي يكون مصدرها التشريع ، بل يشمل كافة القواعد القانونية أيا كانت مصادرها ، ولكن أهمية هذا المبدأ تظهر بالنسبة للقواعد القانونية التي يكون مصدرها التشريع خاصة وأن هذا الأخير يصدر ويتغير بسرعة بحيث يتصور عدم إحاطة الكافة به[١] ، فكما لا يقبل من القاضى النكول عن الحكم بحجة عدم وجود حل في التشريع ، بل يجب عليه البحث عن الحل في المصادر الأخرى ، لا يمكن أيضا لأحد الاعتذار بالجهل بالقانون أيا كان مصدره .

ويمتد أيضا مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون إلى الأجانب المقيمين على إقليم الدولة ، فلا يجوز لهم الاعتذار بالجهل بالقانون إذا صدرت منهم مخالفة لأحكامه وقواعده ، وهذا فيه تأكيد لسيادة الدولة على إقليمها .

وقد حدث خلافا فقهيا حول إطلاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون بالنسبة إلى القواعد الآمره والقواعد المكملة ، فالبعض يقصر العمل بهذا المبدأ على القواعد الآمره المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة ، ولكن في الحقيقة هذا المبدأ لا يقتصر على نوع معين من القواعد القانونية ، فهو يشمل القواعد الآمرة وأيضا المكملة ، فكلاهما له صفة الإلزام ، والإلزام يعنى العلم بمضمونها ولا

---

[١] د. محمد حسين عبد العال ، المرجع السابق ، ص ١٥٤ .

يستطيع أحد التذرع بالجهل بهما .

هذا وقد أضاف البعض أن "القول بإباحة الاعتذار بجهل القواعد المكملة لا يستقيم مع طبيعة هذه القواعد من كونها لا تطبق إلا في حال سكوت المتعاقدين عن مخالفتها ، إذ قد يكون سكوتهما عن جهل منهما بأحكامها ، ومع ذلك تلزمهما هذه الأحكام ، لأنه بهذا السكوت يتحقق شرط انطباقها في حقهما[1] .

فالقواعد المكملة ملزمة تماما كالقواعد الآمره ، وكل ما في الأمر أن تطبيقها يتوقف على شرط عدم الاتفاق على مخالفتها ، فإذا تحقق هذا الشرط تكون ملزمة ولا يجوز لأحد أن يدعى الجهل بأحكامها .

الاستثناء : جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في حالة القوة القاهرة :

في الواقع لا يوجد نص يقرر هذا الاستثناء ، إنما الفقه والقضاء مستقر على جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في حالة القوة القاهرة ، وهذا الاستثناء لا يخص أشخاص معينين بالذات ، إنما هو وضع عام يخص كافة الناس ولأسباب عامة ، ويمكننا أن نذكر لتوضيح حالة القوة القاهرة مثال عزل جزء من الدولة عن باقي الأجزاء ، كعزل إقليم معين عن باقي الأقاليم الأخرى بسبب حدوث كارثة معينة كما لو حدثت ثورة أو حدوث حرب أو تحقق كارثة طبيعية كالفيضانات ، فبسبب هذه الكوارث قد يتعذر وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء من أجزاء الدولة.

ففي هذه الحالة يجوز لسكان هذا الإقليم أن يتذرعوا بعدم العلم بالقانون ، خاصة وأن نشر القانون في الجريدة الرسمية وتوزيعها فعليا هو شرط أساسى لنفاذ القانون في حق المخاطبين بأحكامه ، ويجب أن ننوه إلى أن التذرع بالجهل

---

[1] د. حسن كيره ، المرجع السابق ، ص ٣١٩ .



بالقانون استنادا إلى القوة القاهرة يقتصر على القواعد التشريعية فقط سواء كان تشريع دستورى أو عادى أو فرعى ، وسبب ذلك أن النشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة الوحيدة للعلم بهذه القواعد ، كما أن التذرع بالجهل بالقانون مقيد بأسباب قيامه، فإذا زالت هذه الأسباب فلا وجود للاستثناء ، وعلينا تطبيق المبدأ.

وجدير بالذكر أن الجهل بالقانون يختلف عن الغلط في القانون فالجهل لا يعتبر عذرا كقاعدة ، بينما الغلط في القانون يمكن أن يؤدى إلى الحق في طلب البطلان .

جهل القانون والغلط في القانون :

يقصد بالغلط هو توهم غير الحقيقة أو غير الواقع ، فهو تصور شئ على غير حقيقته ، كأن يتصور أحد المتعاقدين شيئا معينا على غير حقيقته بسبب الوهم الذي قام في ذهنه ، وقد نصت المادة ١٢٠ من القانون المدني على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهرى جاز له إبطال العقد ..." فلصحة العقود يشترط القانون أن تكون الإرادة خالية من العيوب ، ومعنى ذلك عدم تعاقد الشخص تحت تأثير وهم يتعلق بمسألة جوهرية في العقد ، فإذا تعاقد الشخص تحت تأثير الغلط الجوهرى كان العقد باطلا .

والغلط ينقسم إلى نوعين : الغلط في الواقع والغلط في القانون ، والغلط في الواقع كأن يشترى شخص تمثالا على أنه أثرى وله قيمة حضارية لكنه غير ذلك وحديث الصنع ، أو أن يشترى شخص قطعة معينة على أنها ذهبية لكنها في حقيقة الأمر نحاسية ، وفيما يتعلق بالغلط في القانون هو أن يبيع شخص نصيبه في التركة على أنه الربع لكنه وفقا للقانون يكون النصف وليس الربع .

وسواء كان الغلط في الواقع أو في القانون ، فقد سوى القانون بينهما ، وأجاز للمتعاقد الذي وقع في الغلط أن يطلب إبطال العقد ، ولكن يجب توافر عدة

شروط في هذا الغلط حتى يتسنى للمتعاقد طلب إبطال العقد ، فيشترط أن يكون الغلط جوهريا ، وأن يكون دافعا إلى التعاقد بمعنى أن المتعاقد كان سيمتنع عن التعاقد إذا لم يقع فيه ، ويجب أيضا أن يكون المتعاقد الآخر على علم بهذا الغلط ، أو كان سهلا عليه أن يكتشفه .

ويجب التنويه إلى أن بعض الفقهاء قد ذهب إلى أن جواز إبطال العقد للغلط في القانون يمثل استثناءاً من مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ، لكن في الحقيقة مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون لا يمنع المتعاقد الذي وقع في الغلط من طلب إبطال العقد ، كما أن المقصود من عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو منع الاعتذار الذي يرمى إلى التهرب من أحكام القانون ، بينما الأمر على خلاف ذلك في حالة التمسك بالغلط في القانون ، لأن المتعاقد لا يسعى إلى التهرب من حكم القانون لكنه يسعى إلى تطبيق حكم القانون الصحيح ، ففي المثال آنف الذكر والخاص بمن اعتقد أن نصيبه في التركة هو الربع لكنه طبقا لقانون المواريث يكون النصف ، هذا الشخص لا يطلب الإفلات من حكم القانون ، لكنه يريد التطبيق السليم للقانون ، بأن يأخذ حقه وهو النصف بدلا من الربع طبقا للقانون ، وهذا في الحقيقة يمثل تأكيدا لمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون وليس استثناءاً عليه .

الفرع الثالث

الرقابة على صحة التشريع

طبقا لمبدأ تدرج التشريع يتبين لنا أن الأنواع الثلاثة للتشريع تتدرج فيما بينها بحسب أهميتها ، فالتشريع الدستورى يكون في القمة ، ويأتى بعده في المرتبة التشريع العادى ، وأخيراً التشريع الفرعى يكون في المرتبة الأخيرة ، ويترتب على هذا التدرج نتيجة هامة ولا تجانب المنطق وفحواها هو عدم مخالفة تشريع أدنى

تشريعا أسمى منه مرتبة ، ولا يجوز أن يتعارض تشريع أدنى مرتبة مع تشريع أعلى منه مرتبة ، ومثالا لذلك لا يجوز أن تخالف لائحة قانون أو دستور ، وإلا كانت غير قانونية أو غير دستورية ، وأيضا لا يجوز للتشريع العادى مخالفة التشريع الدستورى وإلا كان غير دستوريا .

من هنا كانت الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وضرورة عدم الأخذ باللوائح أو القوانين المخالفة للدستور .

أولا : الرقابة على قانونية اللوائح ودستوريتها :

مما لا شك فيه أن اللائحة إذا خالفت تشريعا عاديا تكون غير قانونية ، وإذا خالفت الدستور ، تكون غير دستورية ، ويجمع الفقه على ضرورة عدم الأخذ بهذه اللائحة ، فللقضاء الحق في الرقابة على قانونية ودستورية اللوائح ، ويمكنه عدم تطبيق هذه اللوائح سواء طلب الخصوم ذلك أم لا ، وسواء كانت المخالفة شكلية أو موضوعية ، فقانونية اللوائح ودستوريتها أمر متعلق بالنظام العام ، وبالتالى يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها التصدى لمسألة عدم دستورية اللائحة[١].

وجدير بالذكر أن جهتى القضاء العادى والإدارى تملك الحق في الامتناع عن تطبيق اللوائح غير القانونية أو غير الدستورية ، وإذا كانت جهة القضاء العادى تقف عند حد الامتناع عن تطبيق اللائحة غير القانونية أو غير الدستورية ، فإن جهة القضاء الإدارى لا تقف عند هذا الحد ولكنها تملك الحق في إلغاء اللائحة المعيبة ، وهذا الإلغاء يتم سواء عن طريق دعوى مستقلة يرفعها الأفراد يطلبون فيها الغاء اللائحة أو عن طريق الغاء هذه اللائحة بمناسبة طعن منظور أمام المحكمة في القرار الإدارى الصادر تأسيسا على هذه اللائحة .

---

[١] د. محمد سعد ؛ د. حمدى عطيفي ، المرجع السابق ، ص ١٤٠ وما بعدها .

ثانيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين :

لقد تناولنا فيما سبق ضرورة احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى أو مطابقة التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، والتحقق من هذه المطابقة يدعونا إلى بحث مدى الرقابة القضائية على صحة التشريع المخالف للدستور من حيث الشكل أو من حيث الموضوع ، فأحيانا تصدر قوانين لا تتفق وأحكام الدستور سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع ، وعلى ذلك لتناول الرقابة القضائية على صحة التشريع العادى لابد من دراسة المسائل الآتية :

١ . الرقابة القضائية على صحة التشريع العادى من حيث الشكل .
٢ . الخلاف حول الرقابة القضائية على صحة التشريع من حيث الموضوع .
٣ . الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية .
٤ . الرقابة القضائية على دستورية القوانين في فرنسا .
٥ . الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر .

وفيما يلى سنعرض لكل مسألة من المسائل آنفة الذكر :

١ . الرقابة القضائية على صحة التشريع العادى من حيث الشكل :

إذا صدر قانون غير مستوف للإجراءات والمراحل المنصوص عليها لسنه إو اصداره أو نفاذه يكون قانونا معيبا من حيث الشكل ، وفي هذه الحالة لا خلاف على أحقية القضاء في الرقابة على صحة التشريع من حيث الشكل ، وبناء عليه يجوز للمحاكم الامتناع عن تطبيق هذا التشريع على النزاع المعروض عليها .

ومن العيوب الشكلية التي تعترى التشريع صدوره من هيئة غير مختصة باصداره، كأن يصدر وزير قرارا بقانون جاهلا أن هذا الأمر يقتصر فقط على رئيس الجمهورية ، فعلى المحاكم الامتناع عن تطبيق القانون الذي لم يسنه مجلس النواب، أو غير الصادر من رئيس الجمهورية في أحوال الضرورة.



ومن العيوب الشكلية أيضا صدور القانون دون مراعاة الأغلبية المطلوبة من أعضاء مجلس النواب ، ومثال ذلك صدور قانون اعترض عليه رئيس الجمهورية، وتم رده إلى مجلس النواب، ووافقت عليه أغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين وليس ثلثى أعضاء المجلس جميعا ، كما أن التشريع الصادر من مجلس النواب، ولم ينشر في الجريدة الرسمية أو الذي تم تطبيقه قبل انقضاء المدة المحددة لدخوله حيز العمل يعتبر معيبا من حيث الشكل ، ويجب الامتناع عن تطبيقه ، والحكمة من ذلك أن هذا القانون ليس له وجود قانونى لصدوره دون مراعاة الاجراءات والمراحل المنصوص عليها لسنه أو إصداره أو نفاذه .

٢ . الخلاف حول الرقابة القضائية على صحة التشريع من حيث الموضوع :

المقصود بالرقابة القضائية على صحة التشريع من حيث الموضوع هو بحث مدى تعارض حكماً تضمنه القانون مع حكم موضوعى منصوص عليه في الدستور ، فطبقا لمبدأ تدرج التشريع يجب أن يحترم التشريع الأدنى التشريع الأعلى ، وترتيبا على ذلك يجب أن يحترم التشريع العادى التشريع الدستورى وأن يصدر وفقا له ، فإذا خرق المشرع أحكام الدستور الموضوعية كان مرتكبا لمخالفة موضوعية .

وإذا كان لا خلاف حول أحقية المحاكم في الرقابة على صحة اللوائح من الناحية الموضوعية للتثبت من مدى مطابقتها للتشريع العادى أو الدستورى ، إلا أن هناك خلافا حول أحقية المحاكم في الرقابة على صحة التشريع من حيث الموضوع ، فمسألة الرقابة القضائية على دستورية القوانين كانت وما زالت محل خلاف في الفقه ، فهناك المؤيد للرقابة القضائية على دستورية القوانين ، وهناك أيضا المعارض لهذه

الرقابة .

وجدير بالذكر أن هذا الخلاف لا يثور في الدول ذات الدساتير المرنة التي يمكن تعديلها بتشريع عادى ، فإذا صدر قانون مخالف لأحكام الدستور اعتبر تعديلا له ما دام أنه صدر صحيحا من الناحية الشكلية ، وعلى النقيض من ذلك في الدول ذات الدساتير الجامدة التي لا يمكن تعديلها بتشريع عادى، لا خلاف حول أحقية المحاكم في الرقابة على التشريع العادى من حيث الشكل ، لكن ثار الخلاف حول أحقية المحاكم في الرقابة على صحة التشريع من حيث الموضوع.

فالمعارضين للرقابة على التشريع من حيث الموضوع يرون ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتطلب عدم السماح للمحاكمبرقابة دستورية القوانين ، لأنه طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات يجب عدم اعتداء سلطة على سلطة أخرى ، والسلطة القضائية وظيفتها تطبيق القانون ، وعليها تطبيقه فقط ، ولا يجوز لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية التي أصدرت القانون بحجة أن القانون مخالف للدستور .

أما المؤيدين للرقابة القضائية على صحة التشريع من حيث الموضوع يرون ضرورة الاعتراف للمحاكم بالحق في الرقابة على دستورية القوانين لأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، فالرقابة حق للقضاء الذي يتعين عليه تطبيق التشريع بمعناه الواسع ، سواء كان تشريعا دستوريا أو عاديا أو فرعيا ، وفي حالة تعارض تشريعا عاديا مع تشريعا دستوريا ، فمن حق القضاء الاختيار بينهما ، أى أن يطبق التشريع العادى أو التشريع الدستورى ، ولكنه يلتزم بمبدأ تدرج التشريع ، الذي يفرض عليه الأخذ بالتشريع الدستورى لأنه الأسمى وترك التشريع العادى المخالف لأنه الأدنى ، فالرقابة القضائية على دستورية القوانين حق للقضاء

استنادا إلى مبدأ تدرج التشريع[١] .

ونضيف إلى ما سبق أنه إذا كان هناك إجماعا فقهيا على أحقية المحاكم في الرقابة على صحة اللوائح من حيث الشكل أو الموضوع ، فما المانع من إقرار هذه الرقابة على التشريع العادى أيضا ، فهل الرقابة القضائية على صحة اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية لا تمثل اهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات بينما الرقابة على صحة التشريع العادى الصادر من السلطة التشريعية تمثل إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات .

والإجابة بالنفي ، فإذا أخذنا بحجة المعارضين للرقابة على دستورية القوانين من حيث الموضوع بأن ذلك إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ، فإن الرقابة القضائية على صحة اللوائح يمثل أيضا اهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ولكننا نرى أنه في الحالتين ، أى سواء الرقابة على اللوائح أو الرقابة على صحة التشريع من حيث الموضوع ليس هناك إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ، فصميم عمل القضاء هو الرقابة على صحة التشريعات وفقا لمبدأ تدرج التشريع.

وإذا أثبتنا فيما سبق أحقية القضاء في الرقابة على دستورية القوانين من حيث الموضوع ، فإن طرق الرقابة تتعدد في التشريعات المختلفة ، سواء التشريعات الأنجلوأمريكية ، أو اللاتينية ، وعلى ذلك سنتناول الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم ندرس الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا وفي مصر واللذان يعتبران من النظم اللاتينية .

٣ . الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية :

---

[١] د. محمد حسين عبد العال ، المرجع السابق ، ص ١٦٤ .

لا يوجد في الدستور الأمريكى نصا صريحا يعطى للمحاكم الحق في الرقابة على دستورية القوانين ، وترتيبا على ذلك ثار الخلاف الفقهي والقضائى حول مدى أحقية المحاكم الأمريكية في الرقابة على دستورية القوانين ، فهناك رأى يعارض بشدة السماح للمحاكم بالرقابة على دستورية القوانين لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضى بإستقلال السلطة التشريعية عن السلطة القضائية ، ولكن الرأى الآخر يؤيد الرقابة على دستورية القوانين تأسيسا على مبدأ تدرج التشريع والذي يقضى بسمو الدستور وضرورة احترام التشريعات الدنيا له .وقد انحسم الخلاف لصالح الرأى المؤيد للرقابة القضائية على دستورية القوانين ، ويرجع الفضل في ذلك إلى مارشال رئيس المحكمة العليا ، فقد أعلن في عام ١٧٨٥ أن القضاة لهم أن ينظروا إلى التشريعات الصادرة من الكونجرس والتي تجاوز السلطة المخولة له من قبل الدستور ، وأن هذا التشريع المخالف للدستور يكون باطلا ، وعلى القضاة التصدى إلى هذه الاعتداءات لأنه يجب عليهم حراسة والدفاع عن نصوص الدستور ، هذا وقد أصدرت المحكمة العليا في عام ١٨٠٣ حكما تاريخيا قضت فيه بأن مهمة السلطة القضائية هي بيان القانون ، وعند تعارض القوانين عليها أن تحدد الأولى بالتطبيق ، فعند تعارض القانون مع الدستور ، يجب الأخذ بحكم الدستور لأنه التشريع الأسمى .

٤ . الرقابة القضائية على دستورية القوانين في فرنسا :

لم يعرف النظام االفرنسي الرقابة القضائية على دستورية القوانين احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ، كما أن رجال الثورة الفرنسية التي قامت في سنة ١٧٨٩م ، حذروا تدخل القضاة لفحص المخالفات الموضوعية للدستور لأن دورهم قاصر على بحث المخالفات الشكلية فقط[١] .

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ١١٢ .

وقد نص الدستور االفرنسي الصادر في عام ١٧٩١م في مادته الثالثة على أنه "ليس للمحاكم أن تتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية ، وليس لها أن توقف تنفيذا لقوانين" ، حتى بعد إلغاء دستور ١٧٩١م استمر العمل بنص مادته الثالثة ، فالمادة ١٢٧ من قانون العقوبات تنص على "معاقبة القضاة في حالة تدخلهم في أعمال السلطة التشريعية كتعطيل القوانين أو وقف العمل بها"[١] .

وليس معنى ما سبق هو عدم وجود الرقابة القضائية على دستورية القوانين على إطلاقها ، فقد انتقد جانب كبير من الفقه عدم أحقية القضاء في الرقابة على دستورية القوانين ، فالمشرع االفرنسي أخذ بأسلوب بديل لرقابة القضاء وهو رقابة الأمة عن طريق مجلس الشيوخ المحافظ على الدستور ، والذي كان يشكل من أعضاء يختارهم الإمبراطور ، وكانت مهمة هذا المجلس هي إلغاء القوانين المخالفة للدستور قبل إصدارها[٢] .

وتطور الأمر بعد ذلك إلى أن صدر دستور الجمهورية الخاصة في عام ١٩٥٨م والذي أنشأ نظام للرقابة على دستورية القوانين عن طريق مجلس خاص يسمى بالمجلس الدستورى ، ويشكل أعضاء هذا المجلس من جميع رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين بالإضافة إلى تسعة أعضاء معينين يتم اختيارهم بمعرفة رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ، فكل رئيس من هؤلاء يختار ثلاثة أعضاء ، على أن يتولى رئيس الجمهورية مهمة تعيين رئيس المجلس الدستورى .

والمجلس الدستورى يباشر رقابة سابقة على دستورية القوانين وليست رقابة لاحقة ، فبعد موافقة البرلمان على القوانين يتولى المجلس الدستورى فحص مدى

---

[١] د. خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

[٢] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ١١٢ .

دستوريتها قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية ، فإذا كانت مطابقة لأحكام الدستور تولى رئيس الجمهورية إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية ، أما إذا كانت مخالفة للدستور تم إعادتها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها وضرورة اتفاقها مع أحكام الدستور ، فالرقابة على دستورية القوانين في فرنسا تكون رقابة سابقة بعكس الوضع في مصر حيث تكون الرقابة على دستورية القوانين رقابة لاحقة أى بعد إصدار القانون .

٥ . الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر :

الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر مرت بمراحل متعددة ، فقد كانت المحاكم العادية ومحاكم القضاء الإدارى على حد سواء تباشر هذه الرقابة ، وبعدها صدر القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء المحكمة العليا ، وقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن هذه المحكمة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين إذا ما تم الدفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم .

ولكن يجب التنويه إلى أن قانون المحكمة العليا اقتصر على الفصل في دستورية القوانين فقط ، فليس للمحكمة العليا الفصل في دستورية اللوائح ، وبالتالى ظلت المحاكم العادية ومحاكم القضاء الإدارى تملك الحق في الرقابة على دستورية اللوائح وقانونيتها ، وإذا تبين عدم قانونية اللوائح أو عدم دستوريتها يجوز للمحاكم العادية الامتناع عن تطبيقها لكنها لم تملك الحق في تعديلها أو إلغائها ، فهذا مقصور فقط على محاكم القضاء الإدارى[١] .

وعندما صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية في ١١ سبتمبر ١٩٧١ والذي تم الغائه تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا ، وقد نصت المادة ١٧٤

---

[١] د. خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص ١٧٢ .

من هذا الدستور على أن "المحكمة الدستورية العليا تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ومقرها مدينة القاهرة" ، والمادة ١٧٥ من الدستور نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها" .

فطبقا لدستور ١٩٧١م تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتتولى أيضا تفسير النصوص التشريعية ، ولكن ظلت المحكمة العليا تمارس اختصاصاتها على الرغم من النص على المحكمة الدستورية العليا في دستور ١٩٧١م ، واستمر هذا الأمر حتى صدر القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م في ٢٩ أغسطس ١٩٧٩ بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وبيان اختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والإجراءات المتبعة أمامها.

وبعد إلغاء دستور ١٩٧١، وتم إعداد دستور ٢٠١٤م الذي وافق عليه الشعب، قد سلك هذا الدستور نفس مسلك دستور ١٩٧١ ونص على سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين.

وقد أكدت المادة ١٩٢ من الدستور الحالي على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح وتفسير النصوص التشريعية وغير ذلك من الاختصاصات .

والمحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة ٢٥ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، كما أنها تتولى الفصل في تنازع الاختصاص وذلك بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات

ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلى إحداها عن نظرها أو تخلت كلاهما عنها ، وتختص أيضا المحكمةالدستورية العليا بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضينصادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها .

ومن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا أيضا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .

حالات الرقابة على دستورية القوانين :

نصت المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :

أ . إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية .

ب . إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع معياداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" .

هذا وقد تناولت أيضا المادة ٢٧ من هذا القانون أن المحكمة الدستورية

العليا يجوز لها أن تقضى بعدم دستورية أى نص أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ، ويتصل بالنزاع المطروح عليها بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .وهكذا يوجد ثلاث حالات يجوز فيهم للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وهذه الحالات هي حالة الدفع الفردى أى دفع أثاره أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام محكمة أخرى ، وحالة الإحالة من محكمة الموضوع أى بناء على طلب محكمة أخرى ، وأخيرا حالة التصدى من قبل المحكمة الدستورية العليا نفسها أى أنها تباشر الرقابة من تلقاء نفسها دون طلب من أحد أو من محكمة أخرى .

ويجب التنويه إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها التفسيرية تكون ملزمة لجميع السلطات في الدولة ، ويجب نشر الحكم الصادر في الجريدة الرسمية بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدوره ، ويجب عدم جواز تطبيق النص الذي حكم بعدم دستوريته من اليوم التالى للنشر[١] .

الفرع الرابع

إلغاء التشريع

الغاء التشريع يعنى وقف العمل به ابتداء من هذا الإلغاء أو الإنهاء ، ويجب التنويه إلى أن الإلغاء ليس قاصرا على التشريع فقط كأحد مصادر القانون بل يسرى على جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها ، فالقاعدة القانونية التي يكون مصدرها العرف يمكن أيضا إلغاؤها .

ولتناول موضوع إلغاء التشريع يجب التعرض إلى النقاط التالية :

---

[١] المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا .

أولا : السلطة التي تملك الإلغاء .

ثانيا : صور الإلغاء .

وفيما يلى سنعرض لكل نقطة من النقاط آنفة البيان .

أولا : السلطة التي تملك الإلغاء :

القاعدة أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع في نفس قوته ومرتبته ، فوفقا لمبدأ التدرج التشريعى لا تلغى القاعدة القانونية إلا بقاعدة أخرى في نفس قوتها أو أعلى منها .

وتوضيحا لذلك ، الدستور لا يلغيه إلا دستور ، والقانون لا يلغيه إلا دستور أو قانون ، واللائحة لا تلغيها إلا لائحة أو قانون أو دستور ، فالأعلى مرتبة يمكنه أن يلغى الأدنى ، فلا يستطيع على سبيل المثال التشريع العادى الغاء الدستور بينما العكس صحيح،والعرف لا يمكنه الغاء التشريع لأنه أقل منه مرتبة بينما التشريع يمكنه إلغاء العرف كما القاعدة العرفية الجديدة يمكنها الغاء قاعدة عرفية أخرى إذاكانت مخالفة لها

ثانيا : صـور الإلغاء :

تنص المادة الثانية من القانون المدني على أنه "لا يجوز الغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".

يتضح لنا من مطالعة هذا النص أن المشرع المصري يعرف صورتين للإلغاء هما الإلغاء الصريح والإلغاء الضمنى ، كما يمكننا معرفة أن المشرع المصري لم يعرف الصور الأخرى لإلغاء التشريع كإلغائه بالانعكاس أو بعدم الاستعمال .

وسنتعرض بالشرح للصور التي عرفها المشرع المصري للإلغاء وأيضا الصور الأخرى التي لم يقرها المشرع المصري .

١ . الصور التي عرفها المشرع المصري للإلغاء :

من خلال الإطلاع على نص المادة الثانية من القانون المدني يتبين لنا أن المشرع المصري تعرض لصورتين للإلغاء هما :

أ . الإلغاء الصريح .

ب . الإلغاء الضمنى .

وسنوضح المقصود بكل صورة من الصور سالفة الذكر :

أ . الإلغاء الصريح :

يقصد بالإلغاء الصريح للتشريع هو صدور تشريع ينص فيه صراحة على إلغاء قاعدة أو قواعد معينة من القواعد الموجودة وقت صدوره ، والإلغاءالصريح للتشريع يشمل الإلغاء المجرد والإلغاء المصحوب بتشريع جديد .

ويقصد بالإلغاء المجرد هو إلغاء تشريع دون إصدار تشريع جديد يحل محله ، ويأخذ حكم الإلغاء المجرد الحالة التي يصدر فيها التشريع لمواجهة ظروف مؤقتة ، وبقائه مرهون بوجود هذه الظروف ، وهو ما يعبر عنه بقاعدة انتهاء التشريع بزوال سبب وجوده[١] .

ومن أمثلة الإلغاء المجرد إنهاء تشريع بإنتهاء مدته كالتشريع الصادر للعمل به مدة الحرب فقط ، وأيضا التشريع الذي يلغى بزوال المركز القانونى الذي ينظمه كسقوط النصوص التشريعية التي تنظم مسألة وراثة العرش وحرية العيب في الذات الملكية بعد إعلان الجمهورية في مصر بعد ثورة يوليو ١٩٥٢م .

أما المقصود بالإلغاء المصحوب بتشريع جديد هو أن إلغاء التشريع ليس قاصرا فقط على مجرد الإلغاء بل أن هناك تشريع جديد يحل محل التشريع الملغى

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ١٣٦ وما بعدها .



، ومثال لذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ الخاص بإصدار القانون المدني الجديد من أنه "يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٣ ، والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في ٢٨ يونيو سنة ١٨٧٥ ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون" .

ومثال آخر للإلغاء المصحوب بتشريع جديد هو القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م بشأن المحكمة الدستورية العليا الذي نصت مادته التاسعة على إلغاء قانون المحكمة العليا رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ وقد حل محل هذا القانون قانونا جديدا ينظم المحكمة الدستورية العليا .

ب . الإلغاء الضمنى :

يقصد بالإلغاء الضمنى أن المشرع لم يصرح به ولكنه يستخلص أو يستفاد من التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة أو من قيام المشرع بتنظيم موضوع سبق أن نظمه من قبل .

التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة :

إذا صدرت قاعدة جديدة متعارضة مع القاعدة القديمة فإن القاعدة القديمة تكون ملغية ضمنيا وذلك لتعذر تطبيق القاعدتين معا في وقت واحد ، وحتى يتحقق الإلغاء الضمنى في حالة التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة يجب أن يكون التعارض تاما أو كليا بين أحكامها وأن تكون الأحكام المتعارضة في القانونين القديم والجديد ذات طبيعة واحدة وذلك بأن تكون أحكام القانونين عامة أو خاصة ، فالحكم العام في القانون الجديد يلغى ضمنيا الحكم العام في القانون القديم ، وكذلك الأمر بالنسبة للحكم الخاص .

ولكن يبق الأمر في حالة التعارض التعارض بين أحكام مختلفة الطبيعة أى ليست من طبيعة واحدة كحالة التعارض بين حكم قديم عام وحكم حديث خاص أو التعارض بين حكم قديم خاص وحكم حديث عام.

حالة التعارض بين حكم قديم عام وحكم حديث خاص :

في هذه الحالة لا يترتب إلغاء أثر الحكم القديم كلية إنما يترتب على ذلك تخصيص الحكم العام أى تقييد عمومه بهذا الحكم الحديث الخاص ، أى أن الحكم يظل ساريا إلا في خصوص ما جاء به الحكم الحديث الخاص .

فإذا صدر تشريع يشترط فيمن يشغل الوظيفة العامة ألا يقل عمره عن ثمانى عشرة سنة ، ثم بعد ذلك يصدر تشريعا جديدا يحدد سن من يشغل وظيفة القضاء بثلاثين عاما ، فإن هذا الحكم الحديث الخاص يقيد عموم الحكم القديم في خصوص وظيفة القضاء فقط ، أما ما عدا ذلك من وظائف فإن الحكم العام يظل ساريا وهو ألا يقل السن عن ثمانى عشرة سنة .

حالة التعارض بين حكم قديم خاص وحكم حديث عام :

في هذه الحالة يظل العمل بالحكم القديم الخاص لأنه لم يرد حكما خاصا

ألغى العمل بالحكم القديم ، فالحكم الحديث العام لا يلغى الحكم القديم الخاص ، فهذا الأخير لا يتم إلغائه إلا بحكم خاص جديد يتعارض معه .

٢ . الصور التي لم يعرفها المشرع المصري للإلغاء :

عرفنا أن المشرع المصري أقر صورتين لإلغاء التشريع هما الإلغاء الصريح والإلغاء الضمنى ، ولكن هنا صور أخرى للإلغاء تسبب بعض المشاكل في الواقع الذي نعيشه ومثال ذلك حالة الإلغاء بالانعكاس والذي تعرضت لها محكمة النقض المصرية وحالة الإلغاء بعدم الاستعمال أو الترك .

ففيما يتعلق بصورة الإلغاء بالانعكاس :

يمكننا تعريف الإلغاء بالانعكاس بقيام المشرع عند وضعه لتشريع جديد بالإحالة إلى أحكام تشريع سابق في شأن شروط انطباق أو آثار أو الاجراءات المتبعة بالنسبة للتشريع الجديد ، ثم يتدخل المشرع بعد ذلك ويلغى التشريع السابق الذي أحال التشريع الجديد إليه ، فهل يتم إلغاء التشريع الجديد بالانعكاس خاصة بعد إلغاء النصوص السابقة التي كانت تنظم شروط انطباق وآثار واجراءات هذا التشريع الجديد ؟

وقد تعرض الفقه إلى هذه المسألة وعرض مثالا واقعيا في هذا الخصوص ، فقد صدر القانون رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية المترتبة على حوادث السيارات ، وقد تضمن هذا القانون في مادته الخامسة إحالة صريحة إلى نص المادة السادسة من قانون المرور رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بصدد تحديد المستفيدين من التأمين عند الإصابة البدنية للمؤمن عليه أو وفاته بسبب حادث سيارة ، ففي هذه الحالة إذا تم إلغاء قانون المرور رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ سيؤدى ذلك إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون ٥٦٢ لسنة ١٩٥٥

الخاص بحوادث السيارات الغاء انعكاسيا أم لا يسرى هذا الإلغاء[١] .

لقد تعرضت محكمة النقض المصرية لهذا الأمر وفرقت بين الإحالة المطلقة والإحالة المقيدة ، فإذا كانت الإحالة مطلقة لما يقررها قانون آخر دون تحديد لبيان معين بالذات فإن ذلك يعنى أن القانون المحيل قد ترك للقانون المحال إليه تنظيم كل الأحكام بما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير ، أما الإحالة المقيدة تعنى أن القانون المحيل أحال إلى القانون المحال إليه تنظيم أمر محدد معين بالذات وأصبح هذا الأمر المحدد جزءا من القانون المحيل لا ينفصم عنه[٢] .

وترتيبا على ذلك ، فإن نص المادة الخامسة من قانون حوادث السيارات لا يلغى إلغاءاً انعاكسيا لإلغاء قانون المرور ، كما أن نص المادة السادسة من قانون المرور أصبح جزءا من قانون التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ولا يلغى بإلغاء قانون المرور .

وفيما يخص إلغاء التشريع بعدم الاستعمال ، يمكننا توضيح أن القاعدة التشريعية لا تلغى بعدم الاستعمال أو الترك ، فعدم العمل بالتشريع لا يؤدى على الإطلاق إلى إلغائه خاصة وأن إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع جديد ينص على ذلك صراحة أو ضمنا ، كما أن عدم استعمال التشريع لمدة طويلة والاعتياد على ذلك يمكننا اعتباره قاعدة عرفية ، والعرف لا يمكنه على الإطلاق إلغاء نصا تشريعيا حتى ولو لم يستعمل لعلو مرتبة التشريع على مرتبة العرف .

الفرع الخامس

---

[١] د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ١٤٥ وما بعدها .

[٢] نقض مدنى ٢٧٢ ديسمبر ١٩٧٩ ، مجموعة المكتب الفنى ، س ٣٠ رقم ١٤ ، ص ٤٠٣ .

تقييم وتقدير التشريع

لتقييم التشريع يجب أن نتعرض لمزاياه وعيوبه :

أولا : مزايا التشريع :

١ . سرعة وضعه وتعديله والغائه : فالتشريع لا يأخذ مدة طويلة لوضعه وتكوينه على عكس القاعدة العرفية التي تحتاج إلى مدة طويلة كى ترسخ ويتم الاعتقاد بإلزاميتها .

٢ . عمومية التشريع : فهو عكس العرف يطبق على جميع الناس أو على جميع الأشخاص المخاطبين بأحكامه ، أما العرف الطائفي أو المهنى أو الإقليمى فلا يكون عاماً بل يطبق على أبناء الطائفة أو الحرفة أو الإقليم فقط .

٣ . الدقة والوضوح : من أهم مزايا التشريع الدقة في الصياغة والوضوح ، فهو يعد من قبل خبراء ويتم دراسته في مراحل إعداده المختلفة ، وهو واضحا لأنه مكتوبا ، ويمكن بيسر معرفة مضمونه بالإطلاع على نصوصه.

وإذا كان للتشريع هذه المزايا فإن له عيوبا متعددة أيضا .

ثانيا : عيوب التشريع :

١ . جمود الصياغة : فكما هو معروف يكتب التشريع أو توضع النصوص التشريعية في عبارات محكمة الصياغة محددة المضمون مما يجعلها جامدة ، ولكن يمكننا الرد على هذا العيب بأن السلطة القائمة على تطبيق التشريع تقلل من جموده وتجعله مرنا يتفق وظروف المجتمع ، وهذا بالطبع يتوقف على خبرة وذكاء وعلم وحكمة المفسر والمحلل للنصوص

التشريعية .

٢ . عدم التعبير عن حاجات المجتمع : أحيانا قد يعبر التشريع عن مصالح واضعيه فقط ولا يعبر عن حاجات وظروف المجتمع ، وبذلك يفقد التشريع عنصر التلقائية الاجتماعية على العكس من القاعدة العرفية التي تعبر عن حاجات ورغبات المجتمع.

٣ . وجود المشاكل والمتاعب عندما تكون صياغة التشريع معيبة وغير دقيقة ، لأن ذلك قد يؤدى إلى حيرة عند تفسيره وتحليل النص التشريعى .

ونحن نرى أن كل هذه العيوب آنفة الذكر لا تقلل من أهمية التشريع في العمل على استقرار التعامل ، وأن كل هذه العيوب يمكن التغلب عليها بالدقة عند صياغة التشريع وأخذ رأى أهل الخبرة والفن القانونى في الصياغة ، كما أن مسألة تعبير التشريع في بعض الأحيان عن حاجات واضعيه تعتبر غير دائمة لأنها تتوقف على مدى وجود أو عدم وجود الديمقراطية في المجتمع .

المطلب الثانى

قواعد الدين بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية

لقد كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة منذ الفتح الإسلامى لمصر ، ولكن بعد دخول التقنينات الحديثة وازدياد النفوذ الأجنبى في مصر بدأ البعد عن تطبيق الشريعة الإسلامية ليحل محلها قوانين وضعية ، وبالتالى احتل التشريع المصدر الأول لكن قواعد الدين ظلت المصدر الرسمى الأصلى في مسائل الأحوال الشخصية .

ويقصد بقواعد الدين هو مجموعة الأحكام المستنبطة من أصول الأديان السماوية الثلاثة ، ويجب التنويه إلى أن قواعد الدين كمصدر رسمى أصلى في مسائل الأحوال الشخصية تختلف حسب الديانة التي يعتنقها أطراف النزاع ، فالشريعة الإسلامية تطبق على المسلمين والشريعة المسيحية تطبق على المسيحين والشريعة اليهودية تطبق على اليهوديين مع مراعاة أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة العامة بمعنى أنه في حالة عدم وجود شروط انطباق الشرائع الأخرى فإن الشريعة الإسلامية تكون واجبة التطبيق .

فشرائع غير المسلمين تكون واجبة التطبيق إذا توافرت شروط ثلاثة الأول هو أن يكون هناك اتحاد في الملة والطائفة والثانى أن تكون هناك جهات ملية منظمة حتى ديسمبر ١٩٥٤م والثالث هو عدم تعارض تطبيق الشريعة الطائفية مع النظام العام ، فإذا لم تتوافر هذه الشروط الثلاثة تكون الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق على أطراف النزاع.

هذا وقد حددت المادة ١٣ من قانون نظام القضاء الصادر في ١٩٤٩م والذي ألغى بقانون السلطة القضائية في ١٩٦٥م المقصود بماهية الأحوال الشخصية ، فهي تشمل الحالة والأهلية والولاية والوصاية والحجر والمواريث ونظام

الأسرة من خطبة وزواج ، وطلاق ، ونفقات ، ولكن أصبح بعد ذلك المقصود بمسائل الأحوال الشخصية لتطبق فيها قواعد موحدة على المسلمين وغير المسلمين .

وقد كانت المحاكم الشرعية المنوط بها تطبيق الشريعة الإسلامية ، والمجالس الملية كانت تطبق الشرائع الطائفية ، ولكن في عام ١٩٥٥م تم إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية ، وأصبح الاختصاص للمحاكم العادية لتطبق قواعد الدين كمصدر رسمى أصلى إذا كان النزاع خاصا بأحد مسائل الأحوال الشخصية ، ولتطبق المصادر الأخرى للقانون في غير مسائل الأحوال الشخصية بما فيها مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطى وليس أصلى في غير مسائل الأحوال الشخصية .

المبحث الثانـــى

المصادر الرسمية الاحتياطية

لقد حدد المشرع المصري في المادة الأولى من القانون المدني مصادر القانون ، وأن النصوص التشريعية تطبق على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة والقانون الطبيعى .

وعلى ذلك فقد تجنب المشرع المصري مشكلة القصور في النصوص التشريعية عند حل نزاع معين ، فنص على مصادر أخرى احتياطية في حالة عدم وجود تشريع ينطبق على النزاع المعروض على القاضى ، وعلى ذلك فمن الممكن لهذا الأخير أن يرجع إلى المصادر الاحتياطية الآتية في حالة عدم وجود تشريع :

أولا : العرف .

ثانيا : مبادئ الشريعة الإسلامية في غير مسائل الأحوال الشخصية .

ثالثا : مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .

وسنعرض لكل مصدر من المصادر الاحتياطية آنفة البيان في مطلب مستقل.

المطلب الأول

العـــــرف

يقصد بالعرف هو اعتياد الناس على اتباع سلوك معين في مسألة معينة لمدة طويلة مع اعتقادهم بالزامية هذا السلوك .

ولقد كانت للعرف أهمية كبيرة كمصدر للقانون في المجتمعات القديمة نظرا لبساطة الحياة وقلة المعاملات ولعدم وجود سلطة عليا تقوم بتنظيم شئون الجماعة عن طريق وضع قواعد قانونية لتنظيم العلاقات بين أفرادها مع إجبارهم على احترام هذه القواعد بالنص على عقوبات أو جزاءات معينة عند مخالفتها .

وتطور القواعد العرفية يتم تلقائيا بمجرد حدوث تغير في العلاقات الاجتماعية التي تحكمها .

ويجب التنويه إلى أنه إذا كان العرف يناسب المجتمعات البدائية فإنه مع تطور المجتمع ، وزيادة أوجه النشاط ، وتنوع العلاقات أصبح العرف مقتصرا على مواجهة كل ما تحتاجه الجماعة ، لأنه يحتاج إلى وقت طويل حتى ينشأ عند الجماعة شعور بأن هذه القواعد ملزمة وأن من يخرج عليها لابد وأن يوقع عليه جزاء[1] ولذلك نجد أن العرف لم يلق الأهمية في العصر الحديث لسرعة تغير ظروف المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وغير ذلك .

ولتناول العرف يجب التعرض للنقاط التالية :

<u>أولا :</u> أركان العرف .

---

[1] د. حمدى محمد عطيفي ، مدخل في القانون ، أسيوط ، ٢٠٠٣ ، ص ١٧٢ وما بعدها

ثانيا : مزايا العرف وعيوبه .

ثالثا : أهمية العرف في القانون المصري .

رابعا : القوة الملزمة للعرف .

خامسا : العرف والعادة الاتفاقية .

وسنوالى بالشرح كل نقطة من النقاط سالفة الذكر .

أولا : أركان العرف :

يقصد بالعرف كما سبق هو اعتياد الأفراد على اتباع سلوك معين في مسألة معينة ، مع توافر العقيدة لديهم على إلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالف هذا السلوك لجزاء مناسب .

ويتضح لنا من التعريف السابق للعرف أنه له ركنين اثنين :

١ . الركن المادى للعرف .

٢ . الركن المعنوى للعرف .

١ . الركن المادى للعرف :

الركن المادى للعرف هو اعتياد الأفراد على اتباع سلوك معين في مسألة معينة أو تواتر اتباعهم لهذا السلوك بصورة منتظمة.

ولا يكفي أن يتحقق الاعتياد بمجرد توافر الركن المادى للعرف ، بل يلزم أيضا أن تتوافر في الاعتياد أوصاف وشروط محددة تتمثل فيما يلى :

أ . صفة العمومية :

تناولنا آنفا أن صفة العمومية تعد من أهم وأبرز سمات القاعدة القانونية وخصائصها أيا كان مصدرها . أى سواء كان مصدرها التشريع أو العرف أو

غيرهما . بحيث يجرى تطبيق تلك القاعدة على الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم .

"ويقصد بصفة العموم في الاعتياد كركن مادى للعرف أن تكون العادة أو السنة متبعة من أغلبية أفراد الجماعة ، بحيث لا يقتصر اتباعها على شخص معين بذاته أو أشخاص معينين بذواتهم ، فلا يكفي مثلا لتكوين قاعدة عرفية بين الطلاب أو الأساتذة أن يعتاد طالب معين أو قلة من الطلاب على سلوك معين في مسألة معينة أو أن يعتاد أستاذ معين أو عدد من الأساتذة على نهج محدد بشأن مسألة محددة ولكن ينبغى أن يدرج على اتباع هذا السلوك أو ذاك غالبية الطلاب أو الأساتذة حتى يمكننا القول بأن ثمة قاعدة عرفية تحقق لها ركنها المادى بين طائفة الطلاب أو الأساتذة"[1] .

ولا يقصد من وصف العموم استلزام إجماع الناس كافة على اتباع السنة أو العادة حتى تكتسب صفة القاعدة العرفية بل يكفي أن يدرج على اتباعها غالبية الأشخاص الذين تعنيهم أو تتعلق بشئونهم ومصالحهم .

ويرجع ذلك إلى أن العرف قد يكون عاما يجرى اتباعه في كل أرجاء الدولة ، فيسمى بالعرف العام أو الشامل ، ، وقد يكون تطبيقه مقصورا على إقليم معين دون غيره من أقاليم الدولة ، فيسمى بالعرف المحلى أو يكون متعلقا بطائفة معينة دون سواها من طوائف المجتمع (كالأعراف السائدة بين التجار أو الصناع أو الزارع أو غيرهم من الطوائف الأخرى) فيسمى بالعرف الطائفي ، وقد يكون العرف خاصا بأصحاب مهنة معينة أو حرفة محددة كالأعراف الشائعة في مهنة المحاماة أو الطب أو الصيدلة أو التجارة أو السباكة فيسمى بالعرف المهنى أو الحرفي .

وقد يكون العرف خاص بشخص واحد معين بصفته لا بذاته واسمه ،

---

[1] د. خالد جمال أحمد ، مبادئ القانون ، أسيوط ، ١٩٩٨ ، ص ١٧٩ .

كالعرف الذي ينشأ من اعتياد ملك أو رئيس دولة أو وزير أو غيرهم من الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية ، على اتباع سلوك معين في مجال محدد من المجالات ، ويتكرر منه هذا السلوك حتى يعتقد بإلزاميته ، فيصير سلوكه هذا بمرور الوقت عرفا لمن يخلفه .

ب . صفة القدم :

ينبغى في الاعتياد أن يكون قديما ، بمعنى أن يرتد اعتياد الأفراد على ممارسة العادة إلى زمن بعيد بحيث يستفاد من هذا القدم رسوخها واستقرارها في وجدانهم ، وأنها ليست مجرد سلوك عابر .

ولا يوجد معيار محدد يمكن الاستناد إليه في تحديد المدة الزمنية اللازمة لاكتساب السلوك أو العادة لوصف القدم ، فالأمر يختلف باختلاف العادات وباختلاف ظروف الجماعة التي نشأت فيها ، ولذلك تترك هذه المسألة لتقدير القاضى فهو الذي يقدر كفاية أو عدم كفاية المدة التي اعتاد الأفراد خلالها على اتباع هذه العادات لوصفها بطابع القدم ، باعتبارها من مسائل الواقع التي يستقل القاضى بتقديرها دون رقابة عليه من محكمة النقض .

جـ . صفة الثبات والاستقرار :

وصف الثبات والاستقرار يعد أكثر أوصاف الاعتياد التصاقا وارتباطا بوصف القدم ، فلا اعتبار لقدم عادة أو سلوك لم يتسم اتباع الافراد له بالثبات والاستقرار .

فالعادة المنقطعة أو السلوك المتأرجح بين الأخذ والترك من جانب أفراد المجتمع لا يكون عرفا مهما توغل في القدم ، فلابد أن يكون اعتياد الناس على الأخذ بالعادة أو السنة القديمة متصفا بالثبات والاستقرار بمعنى أن يتواصل الأفراد في اتباعها جيلا بعد جيل فتحظى بالاتباع المستمر منذ بداية نشأتها وتكوينها دون

توقف أو انقطاع أو حتى مجرد التردد في سلوك سبيل تلك العادة أو سبيل غيرها من العادات المخالفة لها[١] .

فإتباع الأفراد لعادة من العادات لفترة طويلة ثم تراجعهم عنها ثم عودتهم إليها مرة أخرى يتنافي مع الثبات والاستقرار أحد شروط الركن المادى للعرف .

"فالاعتياد الذي يفتقر إلى وصف الثبات والاستقرار لا يمكن أن يحقق الركن المادى اللازم لتكوين العرف ، وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يوجد في مصر عرف يقضى بأن الزوج هو وكيل عن زوجته في معاملاتها المالية لمجرد أنه زوج لها إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر في هذا الخصوص" .

ولاشك أن مسألة ثبات العادة كمسألة القدم تعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فيها من محكمة النقض ، طالما أن استخلاصه لها سائغا ومقبولا[٢]" .

د . عدم مخالفة النظام العام والآداب :

يجب ألا ينطوى الاعتياد على مخالفة للنظام العام أو الآداب ، وهذا شرط منطقى لا سيما في الأعراف المحلية أو الطائفية أو المهنية التي قد تخالف الأسس الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي تقوم عليها فكرة النظام العام أو الآداب في المجتمع ، إذ لا يتصور نشأة عرف عام في المجتمع على نحو مخالف لفكرة النظام العام والآداب العامة .

"فالعرف الذي يناهض المبادئ الأساسية في المجتمع يعد عرفا فاسدا ، لا

---

[١] د. خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص ١٨١ .

[٢] د. خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص ١٨١ .

يعتد به قانونا ولا يمكن أن تتولد عنه قاعدة قانونية ، حتى وإن توافرت فيه أوصاف الاعتياد اللازمة للركن المادى في العرف ورسخ في نفوس بعض الأفراد الاعتقاد بإلزاميته فتحقق له العنصر المعنوى للعرف ، فعلى سبيل المثال يشيع في بعض أقاليم الدولة عادة الأخذ بالثأر وهي عادة عامة في هذه الأقاليم وتتسم بالثبات والقدم ، فضلا عن استقرارها في نفوس أفراد هذه الأقاليم ، ومع ذلك لا يمكن أن يتولد عنها عرف واجب الاحترام قانونا ، لمخالفتها للنظام العام والآداب في المجتمع الذي يجعل سلطة الثواب والعقاب من اختصاص الدولة فقط ، وإلا شاعت الفوضى والاضطراب في المجتمع إذا ما ترك للأفراد مزاحمة الدولة في مباشرة هذه السلطة"[1] .

ويجب الإشارة إلى أن فكرة النظام العام أو الآداب فكرة مرنة قابلة للتغيير ، وأن العرف العام قد يسهم في تعديلها أو تغييرها في بعض جوانبها ، فمن المتصور أن ينشأ عرف مخالف لهذه الفكرة في بعض مبادئها . في بادئ الأمر . ثم يشيع هذا العرف في المجتمع بأسره فيساهم ذلك في تعديل هذه الفكرة ، فكم من عادة كانت في مطلع ظهورها ونشأتها مناهضة لجانب ما من جوانب فكرة النظام العام أو الآداب ، ثم استمرت نتيجة لتغير مفهوم النظام العام أو الآداب بشأنها ، مثال ذلك عادة الوساطة في عقد الزواج والتي كان ينظر إليها في بادئ الأمر على أنها عادة تتجافي مع مبادئ الأخلاق في المجتمع ، ثم ما لبثت أن استقرت كعرف واجب الاحترام قانونا بعد أن تغير مفهوم النظام العام بالنسبة لها بسبب شيوع هذه العادة في كل أرجاء الدولة حتى صارت عرفا عاما أسهم في تعديل فكرة النظام العام أو الآداب العامة .

٢ . الركن المعنـوى للعرف :

---

[1] د. خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص ١٨٢ .

العرف لا يولد لمجرد توافر ركنه المادى . المتمثل في اعتياد غالبية الأفراد على اتباع عادة معينة في مجال معين بصورة منتظمة منذ فترة طويلة . بل ينبغى أيضا أن يتوافر له ركنه المعنوى المتمثل في الشعور بإلزامية هذه العادة وضروريتها بالنسبة لأفراد المجتمع .

فالركن المعنوى في العرف هو الذي يميزه عن مجرد العادة ، ففي أى مجتمع من المجتمعات تشيع فيه كثير من العادات والتقاليد التي يدرج الأفراد على اتباعها صورة منتظمة ولفترات زمنية طويلة ، ومع ذلك لا ترقى إلى مرتبة الأعراف لافتقارها إلى الركن المعنوى المتمثل في توافر الاعتقاد في إلزاميتها من جانب الأفراد ، حيث لا يشعرون بأن هذه العادات تحظى في نفوسهم بطابع الإلزام الذي تحظى به القواعد القانونية العرفية ، مثل تبادل الزيارات لتقديم التهانى أو التعزية في المناسبات السارة وغير السارة .

فبدون هذا الركن المعنوى لا ينشأ العرف ويظل السلوك المعتاد مجرد عادة أو سنة غير ملزمة للأفراد ، لهم الحرية في الأخذ بها أو التخلى عنها .

وينبغى أن يكون واضحا أن هناك فرقا بين الشعور بالإلزام كشرط لازم لقيام العرف ، وبين الإلزام كخاصية يكتسبها العرف بعد قيامه بتوافر ركنيه المادى والمعنوى ، بإعتباره قاعدة قانونية واجبة الإتباع من جانب الأفراد من خلال فرض جزاء مادى خارجى يوقعه المجتمع على من يخالف مقتضى العرف.

"فالشعور بالإلزام هو مظهر داخلى كامن في النفس ينبئ عن إحساس الأفراد بأهمية إحدى العادات وضروريتها في تنظيم أحد جوانب حياتهم ، وهذا الشعور بالإلزام يمثل الركن المعنوى اللازم لاكتساب هذه العادة صفة العرف ، فيساهم بذلك في نشأة العرف وقيامه إلى جوار ركن الاعتياد الذي يمثل العنصر المادى في العرف ، دون أن يفيد الحكم بأن هذه العادة أصبحت ملزمة للأفراد

بحيث يوقع جزاء مادى على من يخالفها ، فمثل هذا الأثر الخارجى لا يحققه الشعور بالإلزام ولكن يحققه الإلزام ذاته الذي يفرضه المجتمع"[1] .

أما الإلزام في ذاته فهو مظهر خارجى ملموس يتحقق للعادة بعد صيرورتها عرفا مكتمل العناصر والأركان من خلال قيام المجتمع بفرض جزاء مادى معين يقترن بالقاعدة العرفية ليوقع على من يخالفها مضمونها ، فيحمل الأفراد على مراعاتها واحترامها جبرا عنهم ، بحيث لا يترك أمر تنفيذها لإرادة الأفراد وشعورهم الذاتى بمراعاتها واحترامها من تلقاء أنفسهم .

ثانيا : مزايا العرف وعيوبه :

١ ـ مزايا العرف :

أ . التعبير عن حاجات وظروف الجماعة :

لما كان العرف هو اعتياد الناس على اتباع سلوك معين في مسألة معينة ، فإن العرف يتصل اتصالا مباشرا بالجماعة ولذلك جاءت قواعد معبرة عن حاجة هذه الجماعة خلافا للتشريع الذي تصدره سلطة عامة ، ومن ثم قد لا يأتى معبرا تعبيرا صادقا عن رغبات وحاجات الجماعة بالرغم مما قد يبذل من جهد في وضع التشريع حتى يأتى معبرا عن هذه الحاجات .

ب . تلقائية تطور العرف :

ينشأ العرف بطريقة تلقائية ليعبر عن رغبات وحاجات هذه الجماعة فعندما يتبع الناس قاعدة في تنظيمها لمسألة معينة حتى يعتقدون في إلزامية هذه القاعدة فإن هذه القاعدة تأتى معبرة عن إرادة هؤلاء الناس .

ويتطور العرف أيضا بصورة تلقائية وذلك بمجرد أن تتغير العلاقات التي

---

[1] د. خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

ينظمها وذلك بتغير عادة الناس إلى ما يناسب المتطلبات الجديدة .



٢- عيـــوب العـــــرف :

أ . الغموض وعدم الدقة :

يختلف التشريع عن العرف في أنه لا يصاغ في نصوص دقيقة واضحة ولذلك نجد أن قواعد العرف تثير الكثير من المنازعات حول وجودها ونطاقها فضلا عن غموضها وصعوبة إثباتها .

ب . عدم السرعة في نشأة العرف وتطوره :

لكى يوجد العرف فلابد من إطراد سلوك الأفراد على قاعدة معينة في مسألة معينة وقت طويل حتى يعتقدون في إلزامية هذه القاعدة ، ولذلك يعجز عن معالجة المسائل التي تحتاج إلى علاج سريع ، كما أن العرف بطئ في تطوره ، أيضا حيث لابد من أن يعتاد الناس على إتباع سلوك جديد في تنظيمه المسألة مما يجعله عاجزا عن تلبية حاجات الجماعة المتطورة .

جـ . الإخلال بوحدة النظام القانونى للدولة :

نظرا لأن العرف ينشأ وفقا لحاجات الجماعة وظروفها ، فإن ذلك قد يؤدى إلى تنوعه بين أقاليم الدولة الواحدة ، ومن شأن هذا التنوع اختلاف القواعد القانونية ، مما يؤدى إلى الإخلال بوحدة النظام القانونى.

ثالثا : أهمية العرف في القانون المصري :

قلنا أنه وفقا لنص المادة الأولى من القانون المدني يعتبر العرف مصدرا احتياطيا من مصادر القانون المصري ، بمعنى أن القاضى يطبق النصوص التشريعية على ما يعرض عليه من نزاع فإذا لم يجد فإنه يبحث عن الحل في القواعد العرفية .

تبدو أهمية العرف في القانون المصري من كونه مكملا للتشريع أو معاونا ، بل أنه قد يخالف التشريع أحيانا .



١ . العرف مكمل للتشريع :

قلنا فيما سبق أن العرف مصدر احتياطى للقانون يطبق إذا لم يوجد نص في التشريع ، ولذلك فإن العرف يكمل التشريع ويسد ما فيه من نقص بمعنى آخر أن العرف يستطيع أن يلعب دورا هاما في سد النقص وذلك حين يتخلف تشريع عن تنظيم مسألة ما ، ومن الأمثلة على ذلك أن العرف يلعب دورا هاما في القانون الدولي العام بإعتباره مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي ، ويرجع ذلك إلى عدم وجود سلطة عليا فوق الدول تصدر قواعد قانونية لتنظيم العلاقات فيما بينها ، ومن ثم فإن العرف الدولي يعتبر المصدر الأصلى للقواعد التي تنظم العلاقات بين هذه الدول .

كذلك يلعب العرف دورا هاما في نطاق القانون التجاري ، فغالبا ما يعمد المشرع إلى ترك كثير من المسائل التجارية لحكم العرف .

مثال ذلك . افتراض التضامن بين المدينين بدين تجارى ، جواز تقاضى فوائد على متجمد فوائد في الحساب الجارى ، جواز زيادة الفوائد على رأس المال ، أيضا تسرى فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها...الخ.

٢ . العرف المعاون للتشريع :

يعتبر العرف معاونا للتشريع عندما تحيل النصوص التشريعية إليه لتحديد مضمون فكرة معينة أو لتفسير قصد المتعاقدين أو التعرف على نيتهما ، ومن الأمثلة على ذلك ما تنص عليه المادة ٩٥ من القانون المدني من أنه "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى

فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة " ، وهذا معناه أنه يستعان بالعرف لتحديد المسائل التفصيلية التي لم يتفق عليها أطراف العقد .

من ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ٤٦٤ من أن "نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك" ، ومن ثم لو أن هناك عرف يقضى بأن يتحمل البائع نفقات تسلم الشئ المبيع طبق هذا العرف بالرغم من مخالفته للنص .

نخلص من هذا إلى أن العرف باعتباره مصدرا احتياطيا للقانون ، يلى التشريع في المرتبة ، فلا يجوز أن يخالف نصا تشريعيا آمرا لتعلق ذلك بالنظام العام ، أما فيما يتعلق بالقواعد المكملة فإن العرف قد يحل محلها وإن كان مخالفها لها .



رابعا : القوة الملزمة للعرف :

تنشأ القاعدة العرفية من إطراد سلوك الناس ، في مجتمع ما ، على نحو معين في مسألة من المسائل وألا تعرضوا للجزاء ، فما هو أساس القوة الملزمة للقاعدة العرفية ؟ بمعنى آخر لماذا هي ـ القاعدة العرفية ـ ملزمة بحيث لا يجوز الخروج عليها ؟

ذهب رأى في الفقه إلى أن العرف ملزم لأنه وليد إرادة الحاكم الضمنية ، فالعرف وفقا لهذا الرأى لا يستمد قوته الملزمة من إطراد سلوك الناس على نحو معين ، مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم ، وإنما يستمدها من الموافقة الضمنية للسلطة العامة على كفالة احترام العرف وعدم الإعتراض عليه .

ويؤكد على هذا الرأى أنه يتعارض والواقع التاريخى حيث كان العرف أسبق في وجوده من التشريع ، بمعنى انه كان المصدر الوحيد للقانون قبل وجود السلطة العامة ، وكانت قواعدة ملزمة ، فمن أين أتاها هذا الإلزام ؟؟

ذهب رأى آخر إلى أن العرف ملزم ، ويستمد هذا الإلزام من إرادة المشرع الصريحة ، فقد أحال المشرع صراحة إلى العرف واعتبره مصدرا من مصادر القانون وذلك في المادة الأولى من القانون المدني عندما نصت على أنه إذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف .

إذاً ، العرف لا يستمد . وفقا لهذا الرأى . قوته الملزمة لا من إطراد سلوك الناس على نحو معين مع الاعتقاد في إلزامية هذا السلوك ولا من الإرادة الضمنية للمشرع ، وإنما يستمد هذه القوة الملزمة من الإرادة الصريحة للمشرع والمتمثلة في النص صراحة على اعتبار العرف من مصادر القانون .

ويعيب هذا الرأى ما عاب الرأى السابق ، فالعرف باعتباره مصدرا للقانون

أسبق في وجوده من السلطة العامة التي لم توجد إلا بوجود الدولة الحديثة ، فما أساس القوة الملزمة للعرف قبل وجود السلطة العامة ؟

ذهب رأى ثالث إلى أن أساس القوة الملزمة للعرف يكمن في تطبيق المحاكم له بمناسبة الدعاوى التي تعرض عليها .

فالقضاء . وفقا لهذا الرأى . هو الذي خلق القواعد العرفية ، وذلك باستقراره على تطبيق قواعد معينة ، مع تكرار الأخذ بها في القضايا المماثلة .

ويعيب هذا الرأى ما عاب سابقه ، فالعرف ، تاريخيا ، أسبق في الوجود من القضاء ، فكيف يكون القضاء أساس القوة الملزمة للعرف .

يتعارض هذا الرأى أيضا مع وظيفة القضاء ، فالقاضى في الدولة الحديثة يطبق القواعد القانونية ولا يخلقها ، والقاضى عندما يطبق العرف على النزاع ، إنما يطبقه لأنه ملزم ، ومن ثم فإن تطبيق القاضى إياه ، لا يسبغ عليه صفة الإلزام ، لأنه كان ملزما قبل تطبيقه ، وإلا لما طبقه القاضى .

أساس القوة الملزمة للعرف هو ضرورته لتنظيم العلاقات في المجتمع:

ونحن نعتقد أن العرف إنما يجد قوته الملزمة في كونه تعبيرا عن ضمير الجماعة وحاجاتها ، فالقاعدة العرفية تنشأ تلقائيا عندما يكون هناك حاجة إلى تنظيم مسائل معينة لا يوجد ما ينظمها .

ففي هذه الحالة يتبع الناس قواعد معينة ، وتكتسب هذه القواعد القوة الملزمة بمرور الزمن من شعور الناس بإلزاميتها وضرورتها لتنظيم العلاقات فيما بينهم.

نخلص إلى أن العرف يستمد القوة الملزمة من الضرورة الاجتماعية التي تفرضه وتحتم وجوده ، سواء في الحالات التي لا يوجد فيها تشريع ينظم المسألة أو

في الحالات التي يوجد فيها تشريع ويأتى العرف ، ليطبق على المسائل التي لم يتناولها التشريع بالتنظيم .

خامسا : العرف والعادة الاتفاقية :

قلنا أن العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم ، ومن ثم فإن العرف ينشأ بتوافر الركن المادى المتمثل في إطراد سلوك الناس على نحو معين فترة من الزمن،والركن المعنوى الذي يتمثل في الشعور بإلزاميةهذا السلوك .

وقد يحدث أن يتوافر الركن المادى . إطراد سلوك الناس على نحو معين . دون أن يصل الأمر إلى حد الاعتقاد ، بأن هذا السلوك ملزم ، بمعنى أنه قد يتوافر الركن المادى في العرف دون الركن المعنوى ، وعندئذ لا يمكن القول بوجود العرف ، وإن أمكن القول بوجود العادة ويطلق الفقه عليها "العادة الاتفاقية L'usage conventionelle فالعادة تتمثل في إطراد سلوك الناس في مجتمع ما على نحو معين في تنظيم مسألة معينة دون أن يقترن بالاعتقاد في صفته الملزمة ، ومن ثم لا تعتبر العادة مصدرا للقواعد القانونية ، ولكى تكون ملزمة لابد من أن يتفق المتعاقدان على الأخذ بها لتنظيم مسألة معينة .

ومن هنا جاءت التسمية الشائعة لمثل هذه العادة "العادة الاتفاقية" فهي عادة لأن سلوك الناس قد درج على اتباعها ، وهي اتفاقية لأنها لا تلزم الأفراد في تعاملهم إلا إذا اتفقنا على الأخذ بها .

فالعادة الاتفاقية لا تطبق على النزاع لكونها ملزمة ، وإنما تطبق لأن ذلك هو ما أراده الأفراد ، فهي إذاً تستمد قوتها الملزمة من اتفاق الأفراد على تطبيقها صراحة أو ضمنا ، ومن ذلك قواعد سوق لندن للحبوب أو قواعد سوق البرازيل لتجارة البن ، فإذا أشار المتعاقدان بمناسبة صفقة بن إلى القواعد البرازيلية ، فإن

هذا الاتفاق يكون ملزما ويتعين الرجوع إلى هذه القواعد لمعرفة موعد التسليم ، وطريقة التعبئة ونفقاتها ونسبة العجز والزيادة ونسبة الشوائب المسموح بها ودرجة الرطوبة ... الخ .

ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما يجرى عليه العمل في البيوع المتعلقة بثمار معينة على أساس بيعها بالمائة ، لكن يتم التسليم على أساس مائة وعشرة أو مائة وعشرين حبة عن كل مائة ، وما يجرى عليه العمل في الفنادق والمطاعم من إضافة نسبة مئوية إلى الحساب كوهبة . بقشيش . لمن يقومون بالخدمة .

نخلص إلى أن العادة الاتفاقية هي إطراد سلوك الناس على نحو معين بالنسبة لمسألة معينة دون الاعتقاد في أن هذا السلوك ملزم ، فالعرف قانون والعادة ليست كذلك ، ويترتب على هذا الفارق الجوهرى النتائج التالية :

أ . العرف كقانون ملزم للناس كافة ، سواء علم به أطراف النزاع أم لم يعلموا ، شأنه شأن التشريع ، ومن ثم لا يقبل من أحد أن يتمسك بالجهل بوجوده ، وفقا للقاعدة "لا يعذر أحد بجهله القانون" والقاضى ملزم بتطبيق العرف إذا لم يوجد نص تشريعى ولو أثبت أحد الخصوم أنه يجهل العرف ، فالجهل بالعرف كالجهل بالتشريع لا يقبل عذرا .

أما العادة فهي واقعة مادية غير ملزمة في الأصل إلا إذا اتفق أطراف العقد على الأخذ بها ، الأمر الذي يفترض ، بالضرورة ، علمهم بها ، فالعادة إذاً لا تلزم أطراف العقد إلا إذا علموا بها ، فإذا ثبت أن أحدهم يجهلها ، فلا تطبق .

ب . يطبق القاضى العرف على النزاع المعروض عليه ، باعتباره قانونا ومن تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك بتطبيقه أحد الخصوم ، أما العادة فهي شرط . صريح أو ضمنى . من شروط العقد ، ومن ثم فلا يملك القاضى أن يطبقها من تلقاء نفسه ، فلابد من أن يتمسك بها من له مصلحة



في تطبيقها .

جـ . يفترض علم القاضى بالعرف ، وبالتالى لا يكلف الخصوم بإثباته ، أما العادة الاتفاقية ، فيجب على من يدعى وجودها أن يقيم الدليل على وجود هذه العادة وعلى إنصراف إرادته وإرادة من تعاقد معه إلى تطبيقها عند حدوث نزاع بينهما

د . عندما يطبق القاضى القواعد العرفية،فهو يخضع لرقابة محكمة النقض لأنه يطبق قواعد قانونية،ووظيفة محكمة النقض هي رقابةصحة تطبيق القانون،أما إذا طبق القاضى العادة،لأن أحد الأفراد تمسك بها،فإنه لا يخضعبالنسبةلهالرقابة محكمة النقض ، لأنها من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع.

المطلب الثانى

مبادئ الشريعة الإسلامية في غير مسائل الأحوال الشخصية

تعتبر الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة الأولى من القانون المدني مصدرا احتياطيا للقانون ، وإذا كان المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية الرأى الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان ، فإن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها مصدرا احتياطيا للقانون وفقا لنص المادة الأولى . سابق الإشارة إليها . هي المبادئ العامة الكلية دون التقيد بالأحكام التفصيلية ، ودون التقيد بمذهب معين ، ومن ذلك مثلا ، لا ضرر ولا ضرار ، والضرورات تبيح المحظورات ، ودفع المضار مقدم على جلب المنافع ... الخ .

وبمعنى آخر أن القاضى عندما لا يجد نصا تشريعيا أو قاعدة عرفية تطبق على النزاع المعروض أمامه ، فإنه يلجأ إلى المبادئ الكلية التي لا تختلف من مذهب إلى مذهب ليأخذ منها ما يراه أكثر ملاءمة للتطبيق ، وتجدر الإشارة إلى أن مبادئ الشريعة هنا تطبق بالنسبة للجميع من مسلمين وغير مسلمين وفي جميع المسائل إلا ما تعلق منها بالأحوال الشخصية .

الشريعة الإسلامية في ظل دستور عام ٢٠١٤م :

حرص دستور ٢٠١٤م على أن ينص في المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .

وقد اختلفت الآراء في تحديد مركز الشريعة الإسلامية في ظل دستور ١٩٧١م الملغي، حيث كانت المادة الثانية تنص على أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، وذهب الرأى الغالب إلى أن النص على أن الشريعة

الإسلامية "مصدر رئيسى للتشريع" يمثل توجيها للسلطة التشريعية في أن تعتمد بصفة رئيسية على مبادئ الشريعة الإسلامية فيما تسنه من تشريعات جديدة ، أما على مستوى التطبيق القانونى فإن دور الشريعة الإسلامية مقتصر على ما جاء في المادة الأولى من القانون المدني من أنها مصدر احتياطى للقواعد القانونية ، لا يلجأ إليها القاضى إلا عند عدم وجود نص تشريعى أو قاعدة عرفية[١] .

مركز الشريعة الإسلامية بعد تعديل المادة الثانية من الدستور :

عدلت المادة الثانية من دستور ١٩٧١م الملغي بالاستفتاء على تعديل الدستور يوم ٢٢ مايو سنة ١٩٨٠ . وأصبحت تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وهذا هو نفس مسلك المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤م.

وقد اختلف الرأى في تفسيره "المصدر الرئيسى للتشريع"[٢] ، فذهب رأى إلى أن المادة الثانية من الدستور سواء قبل التعديل أو بعد التعديل، تتضمن توجيها للمشرع المصري (مجلس النواب) بالاهتمام بالشريعة الإسلامية كمصدر للقانون ، فإذا أراد تنظيم مسألة معينة عليه أن يبحث في الشريعة الإسلامية لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت لهذه المسألة بالتنظيم ، فعليه عندئذ أن يصوغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها ، وحتى تتم صياغة أحكام الشريعة الإسلامية ، وتصدر في صور تشريع ، فإن هذا التعديل لا يترتب عليه

---

[١] راجع : توفيق حسن فرج ؛ محمد يحيى مطر ، المدخل للعلوم القانونية ، ١٩٩٠ ، الدار الجامعية ، ص ٢٧٥ وما بعدها .

[٢] راجع في ذلك : عبد الناصر العطار ، مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية ، ص ١٦٢ وما بعدها .

أى إخلال بالترتيب السابق للمصادر الرسمية للقانون[1] .

وذهب رأى إلى أن هذا التعديل يحمل أمرا للمشرع المصري بتطبيق الشريعة الإسلامية وليس فقط الاهتمام بها كمصدر للقانون .

وترتيبا على ذلك ، فإن المشرع المصري ملزم بأن يستمد التشريع الوضعى من الشريعة الإسلامية بحيث يعتبر النص المخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية نصا غير دستورى لا يجوز العمل به ، ويستوى في ذلك أن يكون هذا التشريع المخالف لأحكام الشريعة قد نفذ بعد نفاذ الدستور أو كان قائما وقت نفاذ الدستور.

ويتفق رأى ثالث مع الرأى سابق الإشارة إليه في أنه يجوز الطعن بعدم دستورية التشريعات التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، يستوى في ذلك أن يكون التشريع عاديا أو فرعيا ، لكن هذا الطعن لا يجوز إلا بالنسبة للتشريعات اللاحقة على تعديل المادة الثانية من الدستور .

أما التشريعات السابقة على تعديل هذه المادة ، فإنها تظل قائمة ونافذة ، بمعنى أن التعديل الدستورى لسنة ١٩٨٠ لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد هذا التاريخ ، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فإنها تكون بمنأى عن الرقابة الدستورية[2] .

---

[1] راجع المادة الأولى من القانون المدني .

[2] راجع : حكم المادة الدستورية العليا في ١٩٩٢/٩/٥ ، محمد إبراهيم دسوقى ، نظرية القانون ، ١٩٩٥ ، ص ١٧٥ .

المبحث الرابع

مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة

اعتبرت المادة الأولى من القانون المدني ، مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة مصدرا رسميا للقانون حيث نصت على أنه "إذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة" .

ومبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة ليست قواعد محددة ، يلجأ إليها القاضى كما هو الحال في قواعد التشريع أو العرف ، وإنما مجرد مبادئ عامة يستخلص منها القاضى ، وفقا للظروف وطبيعة العلاقات ما يراه مناسبا من الأحكام للفصل فيما يعرض عليه من نزاع ، مسترشدا بالشرائع الأجنبية وأحكام القضاء ، والمبادئ العامة التي يقوم عليها النظام القانونى ككل .

إذاً يمكن القول بأن مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة ليست مصدرا قانونياً قادرا على التعبير عن إرادة الجماعة وإنما هي دعوى للاجتهاد في استخلاص القواعد القانونية من المبادئ القانونية العامة وفي الحالات التي لا يوجد فيها قاعدة قانونية مستمدة من التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية .

وعلى القاضى في هذه الحالة أن يجتهد رأيه للتوصل إلى حل النزاع المعروض حيث لا يجوز له أن يمتنع عن الحكم بحجة عدم وجود نص قانونى ، وحتى لا يعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة[1] .

---

[1] مادة ١٢٢ مدنى .

ولذا قيل بأن المشرع قد أراد أن يهيئ للقاضى مصدرا مرنا طيعا ، يتيح له فرصة الاجتهاد بغية الوصول إلى الحل العادل للنزاع ، وهكذا ، فإن مهمة القاضى قد تقترب من مهمة المشرع في هذه الحالة لأن القاضى يبحث ويجتهد ليصل إلى القاعدة واجبة التطبيق ، لكن اجتهاده هنا ، مؤسس على اعتبارات موضوعية عامة لا عن تفكير ذاتى خاص ، فيرجع إلى القواعد الكلية التي تستمد من القانون الطبيعى أو قواعد العدالة مسترشدا . كما قلنا . بالقانون المقارن وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون .

ويقصد الفقه بالقانون الطبيعى ، مجموعة القواعد التي يستخلصها العقل البشرى من طبيعة الروابط الاجتماعية باعتبارها المثل الأعلى الذي يهتدى به المشرع عند وضعه القانون .

بمعنى آخر هو مجموعة القواعد الجوهرية العامة التي يقوم عليها النظام القانونى ، وهذه المبادئ يكشف عنها ضمير الإنسان ، وعقله وهي تكون في مجموعها المثل الأعلى الذي يهتدى به المشرع عند وضعه القانون الوضعى ليصل إلى درجة الكمال[1] .

أما العدالة . كما يقول الفقه . فهي الشعور الكامن في النفس والذي يكشف عنه العقل السليم ويوحى به الضمير المستتر ويهدف إلى إعطاء كل ذكى حق حقه .

وبمعنى آخر . وكما سبق القول . فالعدالة هي المساواة في المعاملة في الحالات المتماثلة ، فلا يكون هناك أفضلية لشخص على آخر أو محاباة لطائفة على أخرى ، بحيث يشعر كل فرد من أفراد المجتمع بالإنصاف .

---

[1] راجع الجزء الخاص بالقانون الطبيعى .

ومن الحالات التي طبق فيها القضاء مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة تلك التي قررها في شأن الملكية الأدبية والصناعية (كحماية حق المؤلف والفنان وصاحب الملكية الصناعية) ، وكذلك ما قرره بشأن التعسف في استعمال الحق ، وتحمل التبعة ... الخ .

وبعد أن تعرضنا في عجالة لمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة ، كمصدر رسمى من مصادر القانون المصري ، فإن لنا أن نسأل الآن ، هل نحن في حاجة إلى جعل مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة مصدرا رسميا من مصادر القانون ؟

في الحقيقة أننا في حاجة إلى إعادة النظر في هذا المصدر من مصادر القانون ، فلم نكن بحاجة إلى إضافته إلى المصادر الأخرى ، وكان يكفي حصر المصادر في التشريع ، العرف ، مبادئ الشريعة الإسلامية ، وذلك للأسباب الآتية :

١ . أن هناك خلافا لم يحسم بعد ، حول فكرة القانون الطبيعى ، فهو فكرة غير محددة ، غامضة ، بل أن البعض قد تساءل عما إذا كان هناك حقا ما يسمى بالقانون الطبيعى ، أما العدالة فهي شعور يختلف باختلاف البلاد والأشخاص أكثر منها فكرة ثابتة محددة ، وهذا الشعور ، وإن خفف من عدم مرونة القانون في حالة معينة ، فإنه لا ينهض لإكمال نصوصه .

٢ . عندما نسأل عن المقصود بالإحالة إلى القانون الطبيعى وقواعد العدالة ، فماذا يقصد ؟ نقول أنه وفقا لما صرحت به المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد ، نجد أن المشرع لم يقصد رد القاضى إلى ضابط يقينى ، وإنما هي دعوة للاجتهاد ، بمعنى أن القاضى أن يجتهد رأيه ليحسم النزاع المعروض ، حتى لا يمتنع عن الحكم بحجة عدم وجود نص قانونى ، كل ما في الأمر ، أن اجتهاده يجب أن

يصدر عن اعتبارات موضوعية عامة لا عن تفكير ذاتى خاص ، فالإحالة إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة إذاً ، لا تمدنا بقواعد قانونية ، كما هو الشأن بالنسبة للمصادر الرسمية الأخرى ، فكيف يكون مصدرا رسميا للقانون ؟

٣ . وعند وضع القانون المدني الجديد فقد كان من الواضح عند مناقشة هذا الموضوع . فكرة القانون الطبيعى وقواعد العدالة . أن هناك خلافا عليها ، فقد رأى البعض استبعادها ، ورأى البعض استبدالها بفكرة أخرى إيجابية موضوعية ، ولتوضيح ذلك نجد أنه لما أنشئت المحاكم المختلطة ، فقد جاء في المادة ٥٢ من اللائحة . لائحة ترتيب المحاكم المختلطة . أنه "إذا لم يوجد في القانون نص ينطبق على الحالة المعروضة أو كان النص قاصرا أو غامضا يتبع القاضى مبادئ القانون الطبيعى كمصدر ، فإن هذا لم يتكرر فيما بعد" ، فعندما أنشئت المحاكم الأهلية جاء في المادة ٢٩ من لائحة ترتيبها أنه ان لم يوجد نص صريح في القانون يحكم بمقتضى قواعد العدالة ، فلم يشر المشرع هنا إلى القانون الطبيعى .

أما عند وضع القانون المدني الجديد ، فقد رأى البعض استبدالها واقترح أن تحل محلها فكرة أخرى هي "المبادئ العامة المشتركة بين الدول"[١] ، ثم توقفت اللجنة التي بحثت الموضوع ، وعند بحثه من جديد ، وضعت الصيغة الحالية ، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى تعليقا على هذا النص ، أن المشرع لم يشأ أن يجارى التقنين المدني السويسرى فيأذن القاضى بأن يطبق في هذه الحالة ما كان يضع هو من القواعد لو عهد إليه بأمر التشريع (فقرة ٢ من المادة ١) بعد أن أخذ على هذه الصيغة من ناحية الشكل أنها تخول القضاء حق

---

[١] انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، جـ ١ ، ص ١٨٣ وما بعدها .

إنشاء القواعد القانونية ، مع أن عمله ينحصر في تطبيق هذه القواعد فحسب ، ولم يشأ المشرع كذلك أن يحيل القاضى إلى المبادئ العامة في قانون الدولة (م ٣ من التقنين المدني الإيطالى الجديد) أو إلى مبادئ القانون العامة فحسب (م ١ من القانون الصينى) ، بل احتفظ بعبارتى القانون الطبيعى وقواعد العدالة[١] .

لكن ما الذي أضافه المشرع باختياره هذا ؟ نجد أن المذكرة الإيضاحية ، عندما تحدثت عن المجال الذي أعملت فيه فكرة القانون الطبيعى وقواعد العدالة ، قالت أنه في كنف مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة طبقت المحاكم المبادئ العامة في القانون المصري وأخذت ببعض أحكام الشريعة الإسلامية ، واتبعت بعض القواعد المقررة في تشريعات أجنبية أو معاهدات دولية ، بل وعمدت إلى استحداث أحكام اقتضتها طبيعة الروابط الاجتماعية دون أن يكون لها سند في سوابق التشريع أو العرف ، وعلى هذا النحو لم يتقيد القضاء بضرورة التزام المبادئ العامة في القانون المصري فحسب وإنما استعان بهذه المبادئ كما استعان بغيرها ، متوخيا اختيار أصلح القواعد وأكثرها ملائمة لطبيعة الأوضاع التي قصر القانون عن تنظيمها .

هل معنى هذا أن المشرع قد اعتنق فكرة القانون الطبيعى الذي هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تقوم عليها القوانين ؟ وهل معنى ذلك أن يندمج في القانون الوضعى ذاته ؟ وإذا كان كذلك فهل يمكن القول بأن للقانون الطبيعى وجود مستقل ؟ أو هل هناك حقا ما يسمى بالقانون الطبيعى ؟ أن المشرع . في رأينا . قد استخدم مصطلح مبادئ القانون وقواعد العدالة ، دون أن يحدد معناه ، وما ذلك إلا لأن فكرة القانون الطبيعى ، فكرة غامضة ، غير محددة ، وكان أجدر بالمشرع أن يتخلص منها .

---

[١] المرجع السابق ، ص ١٨٨ .

٤ . أن ما يدعونا إلى طرح فكرة القانون الطبيعى جانبا ، ليس فقط لأنها فكرة غامضة ، تستعصى على التحديد ، ولكن لأننا . حقا . لسنا بحاجة إليها ، فمبادئ الشريعة الإسلامية والتي أحالت إليها المادة الأولى من القانون المدني ، تستغرق . في رأينا . فكرة القانون الطبيعى ، لأن ما أوحى به الله عز وجل ، إنما يمثل العدل المطلق ، والكمال المطلق ، والمثالية المطلقة ، فكيف نترك ما هو يقينى ومنضبط ، ونلجأ إلى فكرة غيبية ، غير محددة ، نلتمس فيها قواعد العدل والانصاف ، وننسى أن الدين السماوى . مطلق الدين ، به من القواعد ما يصلح حال البشر ، الآن وإلى أن يرث الله ، عز وجل الأرض ومن عليها .

٥ . أنه حتى . وإن كان غير صحيح . وإن كنا في حاجة إلى فكرة القانون الطبيعى أن وجدت يجب أن توضع في موضعها الصحيح فيجب أن يدرس القانون الطبيعى بمناسبة البحث عن أساس للقانون ، أى العوامل الجوهرية التي منها يتكون القانون أو المادة الأولية للقانون ، ولا يكون محل دراسته المصادر الرسمية للقانون ، بمعنى آخر ، إذا أردنا الدقة فيمكن أن يسمى بالمصدر المادى أو الموضوعى للقانون ، لا المصدر الرسمى ، كما فعلت المادة الأولى من القانون المدني المصري .

الفصل الثانى

المصادر التفسيرية

لقد عرفنا أن المادة الأولى من القانون المدني قد حددت المصادر الرسمية للقانون ، وبالإضافة إلى ذلك يوجد مصدران آخران هما الفقه والقضاء ، وهما مصدران تفسيريان للقانون ، ونقصد بالمصدر التفسيرى ، الوسائل التي تحدد المقصود من القانون الوضعى وكشف وإزالة اللبس والغموض الذي يعتريه[١] .

المبحث الأول

الفقـــــه

الفقه في اللغة هو العلم بالشئ والفهم له ، وفي الاصطلاح القدرة على فهم واستنباط الأحكام من أصولها ومصادرها ، ولفظ الفقه في الدراسات القانونية قد يعنى علماء القانون أو مجموعة الآراء التي تصدر عن فقهاء القانون ، فالفقه عبارة عن مجموعة الآراء التي يبديها علماء القانون بهدف شرح القانون وتفسيره ونقده في مؤلفاتهم أو في بحوثهم أو في فتاواهم أو في تعليقاتهم على أحكام القضاء[٢] ويمكننا ملاحظة أهمية الفقه فيما يتعلق بالقاضى والمشرع ، فكثيرا ما يسترشد القاضى ، بآراء الفقه ، لمعرفة حكم القانون لأن الفقه يكشف غموض القواعد القانونية بما يقوم به من شرح وتحليل ونقد ومقارنة المواد مع بعضها والرجوع إلى

---

[١] عبد المنعم البدراوى ، المدخل للعلوم القانونية ، دار الكتب العربية ، ١٩٦٢ ، ص ١٥٦ وما بعدها .

[٢] د. خالد جمال أحمد ، مبادئ القانون ، ١٩٩٨ ، ص ٢٤٢ وما بعدها .

مصادرها التاريخية ، وترتيبا على ذلك يتضح للقاضى غموض النصوص القانونية ، فيتمكن بذلك من تطبيقها التطبيق السليم .

لكن يجب التنويه إلى أن هذه الآراء التي يسترشد بها القاضى غير ملزمة له ، فهو غير ملزم بالأخذ برأى الفقه في المسألة المعروضة عليه ، بل له مطلق الحرية في الأخذ بها أو طرحها .

"ويؤثر رأى الفقه على المشرع ، لما يقومون به من تحليل ونقد للقوانين القائمة ، وما يستنبطونه من آراء علمية تبين ما يجب أن يكون عليه القانون ، كل ذلك يساعد المشرع على تعديل القانون القائم أو وضع قانون جديد أكثر ملائمة ، فهو إذاً يعاون في إنشاء أو تعديل قواعد قانونية جديدة دون أن يقوم بخلقها"[١] .

وتاريخيا نجد أن الفقه قد لعب دورا هاما في القانون الرومانى ، بل أكثر من هذا فقد كان لبعض الفقهاء الحق في إصدار فتاوى ملزمة للقاضى وقد اعترف بالفقه كمصدر رسمى للقانون الرومانى في بعض مراحل تطوره .

كذلك لعب الفقه دورا هاما في الشريعة الإسلامية ، وذلك بعد وفاة الرسول . صلى الله عليه وسلم . فقد قام الفقه بتفسير القرآن الكريم وبيان أحكام الشريعة الإسلامية فيما يصدره من فتاوى للناس ، وأيضا حاليا نجد أن الفقه يلعب دورا هاما ومحوريا فيما يتعلق بالقوانين الحديثة ومسألة تطور الفكر القانونى ، فالفقه يتصدى للمشاكل القانونية الجديدة كما هو الحال في مجال المعلوماتية ، ويقدم آراء عظيمة يسترشد بها لوضع القوانين الجديدة .

المبحث الثانى

القضـــــــاء

---

[١] د. حمدى محمد عطيفي ، مدخل في القانون ، أسيوط ، ٢٠٠٢ ، ص ٢٢٦ .

يطلق لفظ القضاء ويراد به أحد المعانى الآتية :

الأول : مجموعة المحاكم الموجودة في الدولة والتي يمكن أن نطلق عليها السلطة القضائية ، والتي تقابل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات .

الثانى : قد يطلق لفظ القضاء على الحكم الصادر في خصومه معينة أو مجموعة الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم وسواء كانت محاكم عادية أو محاكم القضاء الإدارى .

الثالث : يطلق لفظ القضاء على ما استقرت عليه المحاكم في مسألة معينة واطراد قضائها طبقا لهذا المسألة ، فعندما يعرض نزاع معين ، على القضاء ، فيفصل فيه ويضع مبدأ يسير عليه ، يقال بأن القضاء قد استقر على الأخذ بمبدأ قانونى معين في مسألة معينة .

والقضاء بهذا المعنى الأخير يلعب دورا هاما كمصدر رسمى للقانون في البلاد التي تأخذ بمبدأ السوابق القضائية ، بمعنى أن المحاكم عندما تقرر مبدأ معينا بصدد مسألة معينة فإنها تلتزم في قضائها بهذا المبدأ القانونى الذي قررته وذلك في القضايا اللاحقة كما أنها تكون ملزمة بالأحكام التي أصدرتها المحاكم الأعلى درجة ففي بلد كإنجلترا يبحث القاضى في السوابق القضائية ليتعرف على القاعدة التي حكم فيها القضاء في الحالات المشابهة .

أما في البلاد التي لا تأخذ بالسوابق القضائية كفرنسا ومصر فإن المحكمة لا تلتزم بما تصدره من أحكام إلا في القضايا التي صدر فيها أما في غيرها من القضايا فلا تكون ملزمة ، لا للمحكمة التي أصدرت الحكم ولا لغيرها من المحاكم حتى ولو كان مصدر الحكم هي محكمة أعلى درجة "محكمة النقض" هذا من الناحية القانونية ، وإن كان من الناحية العملية فإن المحاكم تتبع قضاء محكمة

النقض باعتبارها المحكمة الأعلى درجة ، فالقضاء إذاً مصدر تفسيرى للقانون ، وأحكام المحاكم مهما علت درجتها لا تقيد المحاكم التي أصدرتها ولا المحاكم الأدنى درجة .

وبالرغم من أن مهمة القضاء هي تطبيق القانون لا خلقه إلا أنه في بعض الحالات قد يصعب التعرف على مضمون القاعدة المراد تطبيقها على النزاع لغموضها ، ولذا يجد القاضى نفسه ملزما بالبحث والاجتهاد في تفسير هذه القاعدة مستعينا بذلك بألفاظ عبارات النص وظروف المجتمع ولما كان من شأن تفسير القواعد القانونية أن يؤدى إلى اختلاف المحاكم ، فقد عهد إلى محكمة النقض بمهمة الرقابة على تفسير القانون وتطبيقه من قبل المحاكم الأدنى .

ويذهب بعض الفقه إلى أن القضاء قد يلعب من الناحية العملية دورا في خلق القواعد القانونية ، وذلك بحكم صلته بالحياة الاجتماعية وظروف المجتمع المتغيرة فإنه قد يسلك مسلكا معينا ، في تفسير القاعدة القانونية ويطرد على هذا المسلك فتظهر بذلك قاعدة قانونية جديدة تختلف عن القاعدة التي جرى العمل بها ، مثال ذلك ما أخذه القانون المدني الجديد عن القضاء المصري كأحكامه في التعسف في استعمال الحق ، والملكية الشائعة ، والتزامات الجوار ... الخ .

الباب الرابـــع

تطبيق القانون وتفسيره

قلنا أن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم فقد جعل الدستور للسلطة التشريعية (مجلس النواب) الاختصاص الأصيل في سن القوانين في الدولة ، أما السلطة التنفيذية فقد أناط بها سلطة تنفيذها ، وعهد أخيرا إلى السلطة القضائية مهمة تطبيقها.

فالقانون إذاً ، يصدر من السلطة التشريعية ، لتطبقه السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة تتكون من قضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، كما أنه يمتنع على أية سلطة أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية حتى تتحقق العدالة، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفير الاستقلال الكامل في العمل القضائى ، ولذك فالقضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسآلتهم تأديبيا[1] .

ولكى يطبق القاضى القانون ، لابد له من تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النزاع المعروض وما ترتبه من آثار وفقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة ، ووسيلة القاضى في ذلك هي التفسير .

فتفسير القانون ، يعنى الكشف عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ، وتحديد مضمونها وشروط انطباقها على الواقعة المعروضة أمام القضاء ، ومن المسائل التي تدرس في هذه المناسبة التعريف بالجهاز الذي يتولى تطبيق القانون ، ونطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان ، ثم أخيرا مشكلة تفسير القانون ونتناولها في ثلاثة فصول :

خطة البحث :

---

[1] مادة ١٨٦ من دستور ٢٠١٤م .

الفصل الأول : الجهاز القضائى في مصر .

الفصل الثانى : نطاق تطبيق القانون .

الفصل الثالث : تفسير القانون .

الفصل الأول

الجهاز القضائى في مصر

ينقسم الجهاز القضائى (المحاكم) في مصر إلى جهتين :

الأولى : جهة القضاء العادى .

الثانية : جهة القضاء الإدارى .

وقبل أن نعرض بإيجاز للقضاء العادى والإدارى ونخصص لهما مبحثين يجب أن نشير إلى أن الدستور قد اعتبر المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة .

المبحث الأول

القضـاء العـــادى

وجهة القضاء العادى هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعام أى أنها تختص بكافة المنازعات إلا ما يجعله القانون من اختصاص جهة أخرى .

وتتكون جهة القضاء العادى من محاكم تتدرج فيما بينها بحسب الاختصاص المحلى والنوعى لكل منها.

وعلى قمة القضاء العادى توجد محكمة النقض، وتختص بالنظر في الأحكام التي يطعن فيها بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم .

فمحكمة النقض تسهر على صحة تطبيق القانون ولا شأن لها بمسائل الواقع ، أى لا تنظر وقائع الدعوى ، ولذلك فهي ليست درجة من درجات التقاضى ، لإنحصار مهمتها في مراقبة تطبيق المحاكم العادية للقانون ، فهي إذاً محكمة قانون.

وقد نص دستور ٢٠١٤م على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، حيث نصت المادة ١٠٧ على أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم".

وتنعقد محكمة النقض في هيئة دوائر ، دائرة للمسائل المدنية والتجارية ، ودائرة للمسائل الجنائية ، ودائرة لمسائل الأحوال الشخصية ، وتتكون كل دائرة من خمسة مستشارين ، ومقرها مدينة القاهرة .

وينقسم القضاء العادى إلى قضاء مدنى وقضاء جنائى .

القضاء المدني :

القضاء المدني درجات ، فالنزاع يعرض على محكمة أول درجة فإذا فصلت فيه أمكن للخصوم استئناف الحكم أمام محكمة أعلى .

المحاكم الجزئية :

وتوجد في دائرة كل مركز أو قسم ، وتشكل من قاضى فرد ، وتختص بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعون ألف جنيه ، والحكم هنا ابتدائى ويمكن استئنافه .

أما إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف جنيه[١] ، فإن حكمها

---

[١] مادة ٤٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية (معدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ، والمادة ١١ ، ١٣ ، من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ .

يكون انتهائيا أى لا يستأنف ، وقد أسند لها المشرع بجانب ذلك الفصل في بعض الدعاوى كدعاوى القسمة ووضع اليد ومنازعات الرى والصرف[١] .

المحاكم الابتدائية أو الكلية :

وتوجد في كل عاصمة من عواصم المحافظات ، وتشكل من ثلاثة قضاءة ، وتختص بالحكم ابتدائيا بصفتها محكمة أول درجة في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، وفي الدعاوى التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه ، والحكم هنا يمكن استئنافه .

أما إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى أربعون ألف جنيه ، فإن حكم المحكمة الابتدائية يكون انتهائيا .

كما تختص المحكمة الابتدائية . بصفتها محكمة استئنافية أى محكمة ثانى درجة . بالنظر في الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية[٢] .

محاكم الاستئناف :

وتوجد في بعض عواصم محافظات الجمهورية كالقاهرة . الاسكندرية . أسيوط . بنى سويف . طنطا . المنصورة . الإسماعيلية .

وتشكل كل محكمة من ثلاث من المستشارين ، وتختص باعتبارها محكمة ثانى درجة ، بالنظر في الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من

---

[١] المادة ٤٣ من قانون المرافعات (معدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢) .

[٢] راجع المادة ٩ وما بعدها من قانون السلطة القضائية ، المادة ٤٧ من قانون المرافعات (معدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢) .

المحاكم الابتدائية[1] .

القضاء الجنائى :

محاكم الجنح :

تختص إحدى دوائر المحكمة الجزئية التي توجد في دائرة كل مركز أو قسم ، بالنظر في المخالفات والجنح ، فمحكمة الجنح إذاً هي إحدى دوائر المحكمة الجزئية .

محاكم الجنح المستأنفة :

تختص المحكمة الابتدائية بجانب اختصاصها السابق بنظر الطعون التي ترفع أمامها في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ، ويصدر الحكم من ثلاثة قضاة وتسمى بمحكمة الجنح المستأنفة فهي هنا محكمة ثانى درجة .

محاكم الجنايات :

وتوجد في العواصم التي يوجد بها محاكم استئنافية ، فهي دائرة من دوائرها ، وتشكل من ثلاثة مستشارين ، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعتبرها القانون جنايات وبعض الجنح التي نص عليها القانون ، وأحكام محكمة الجنايات . التي هي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف . لا تستأنف أمام محكمة أخرى أعلى منها درجة ، فهي تعتبر في نفس الوقت محكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجة .

ولكن يجوز فقط الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض أمام محكمة النقض ، ومحكمة النقض . كما سبق القول . لا تنظر من جديد في الوقائع ، وإنما تراقب فقط تفسير القانون وتطبيقه أى تنظر المسائل القانونية التي تتعلق بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالدعوى .

---

[1] مادة ٤٨ من قانوان المرافعات ، المادة ٦ من قانون السلطة القضائية .

المبحث الثانى

القضـــاء الإدارى

يختص القضاء الإدارى بالفصل في جميع المنازعات الإدارية كالمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، والمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، والعقود الإدارية ودعاوى الجنسية ، ويتكون القضاء الإدارى من المحاكم التأديبية والمحاكم الإدارية ، ومحكمة القضاء الإدارى ، والمحكمة الإدارية العليا ، والقضاء الإدارى يمثل القسم القضائى بمجلس الدولة[1] ، بجانب قسمي الفتوى والتشريع به .

والمحكمة الإدارية العليا ، توجد على رأس محاكم القسم القضائى ، وقد أسند إليها مهمة التعقيب على جميع الأحكام ، فهي كمحكمة النقض بالنسبة للقضاء العادى ، ويقع مقرها في مدينة القاهرة ، ويرأسها رئيس مجلس الدولة ، وتتكون من عدة دوائر ، أما محكمة القضاء الإدارى وتختص كقاضى أول درجة بنظر المنازعات الإدارية ، وكقاضى استئناف بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية ، ويقع مقرها في مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر لها في المحافظات ، وقد صدرت قرارات بالفعل بإنشاء دوائر لها في الأسكندرية ، المنصورة ، أسيوط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، طنطا ، قنا ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل من ثلاثة مستشارين ، أما المحاكم الإدارية ، فهي بمثابة محاكم أول درجة من درجات التقاضى ، ويتم إنشاؤها بقرار من رئيس مجلس الدولة ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل من مستشار مساعد رئيسا ، واثنين من النواب كأعضاء ويمكن استئناف أحكامها أمام محكمة القضاء الإدارى .

---

[1] القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ ، راجع مصطفي أبو زيد فهمى ، القضاء الإدارى ومجلس الدولة ، ١٩٧٩ ، منشأة المعارف .

وأخيرا المحاكم التأديبية ، وتختص بمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية[1] .

[1] وبجانب القضاء العادى والقضاء الإدارى توجد هيئات قضائية مستقلة ، ومن ذلك المحكمة الدستورية العليا ، ومحكمة القيم (القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٥) ، والقضاء العسكرى (القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل) كما توجد هيئات لها سلطة الحكم مثال ذلك : اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ، لجان الطعون الضريبية ، لجان القسمة القضائية ، مجالس التأديب ، وتوجد هيئات قضائية ليس لها سلطة الحكم مثال ذلك : هيئة قضايا الدولة ، هيئة النيابة الإدارية ، وهيئة مفوض الدولي لدى المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الإدارية .

الفصل الثانى

نطاق تطبيق القانون

إذا وجدت القاعدة القانونية ، كانت واجبة التطبيق ، وأصبح واجبا على كل فرد من أفراد المجتمع توجيه سلوكه على مقتضاها ، وإذا ثار النزاع بين الأفراد ، فلابد من اللجوء إلى السلطة المختصة بفض المنازعات وهي السلطة القضائية ، فهي وحدها صاحبة الحق . كما سبق القول . في فحص الوقائع المعروضة عليها ، وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ، واختيار الجزاء الذي تراه مناسبا .

فإذا ما صدر الحكم ، أصبح واجب التنفيذ ، وتتولى هذا الأمر السلطة التنفيذية .

وقد قلنا فيما سبق ، أن القاعدة القانونية ملزمة للكافة ، ولا يجوز لأحد أفراد المجتمع ، أن يتذرع بجهل القاعدة القانونية ، ليفلت من إنطباقها عليه ، ويعبر عن ذلك بالمبدأ المعروف لا يفترض في أحد الجهل بالقانون أو مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

فجهل القاعدة القانونية لا يصلح إذاً عذرا ، وتسرى القاعدة القانونية في حق جميع المخاطبين بأحكامها ، من علم بها ومن جهلها على السواء .

ومع ذلك فإن سريان القاعدة القانونية يتحدد من زاويتين ، أولهما مكانية ، والثانية زمانية ، فنعرض أولا لنطاق تطبيق القانون من حيث المكان ، ثم نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان وذلك في مبحثين :

المبحث الأول : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان .

المبحث الثانى : نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان .

المبحث الأول

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

مبدأ إقليمية القوانين :

لكل دولة الحق في السيادة على كل إقليمها[1] ، ولها كذلك الحق في السيادة على كل من يقيمون على هذا الإقليم ، وطنيين وأجانب ، وترتيبا على ذلك فإن قانون كل دولة يتناول بالتنظيم كل نشاط يحدث على هذا الإقليم ولا يتعداه ، احتراما لسيادة الدولة الأخرى وقوانينها ، وهو ما يسمى بمبدأ إقليمية القوانين.

مبدأ شخصية القوانين :

لما كان وجود أى دولة مرتبط بشعب يقوم على إقليمها ، وأن القوانين إنما توضع لتنظيم العلاقات بين هؤلاء الناس ، فإن المصلحة تقتضى أن يطبق قانون الدولة على جميع الأشخاص الذين ينتسبون إليها في أى مكان يوجدون ، أى سواء أكانوا موجودين في داخل إقليمها أم كانوا خارج هذا الإقليم ، وهو ما يسمى بمبدأ شخصية القوانين.

نخلص إلى أنه إذا كان من نتائج الأخذ بمبدأ إقليمية القوانين ، امتداد تطبيق قانون دولة معينة على كل ما يوجد من أشخاص وأشياء على إقليمها ، وعدم امتداد تطبيقه خارج حدود إقليم هذه الدولة ، فإن مبدأ شخصية القوانين يسمح . على العكس . بتطبيق قانون الدولة على جميع رعاياها سواء كانوا موجودين على إقليمها أم على إقاليم دول أخرى.

التعارض بين مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية :

---

[1] عبد الناصر العطار ، المرجع السابق ، ص ٢٣٤ وما بعدها والفقه المشار إليه بالهامش .

ويترتب على الأخذ بمبدأ إقليمية القوانين ، تطبيق قانون الدولة على كل المقيمين على إقليمها ، بغض النظر عن جنسيتهم ، وهذه النتيجة تتعارض مع مبدأ شخصية القوانين ، الذي يقضى بتطبيق قانون الدولة على رعاياها فقط ، فالأجانب لا يخضعون إلا لقانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .

كما يترتب على الأخذ بمبدأ شخصية القوانين . كما قلنا . تطبيق قانون الدولة على جميع رعاياها ، حتى ولو كانوا خارج حدود إقليمها ، وهو ما يتعارض مع مبدأ الإقليمية ، الذي لا يسمح بسريان القانون خارج إقليم الدولة .

إذاً ، الأخذ بالمبدئين "إقليمية القوانين " ، "شخصية القوانين" ، يؤدى إلى وجود تعارض صارخ يحول دون تطبيقهما معا في نفس الوقت ، لذلك فإن الدول تأخذ بكل من المبدئين في حدود متفاوتة متغيرة حسب ما تقتضيه ظروف ومصالح كل دولة[١] .

الأصل هو مبدأ إقليمية القوانين :

نظرا لأن الدولة لا تملك سلطة حقيقة إلا على إقليمها ، بما يسمح لها بممارسة سيادتها على كافة الأفراد الموجودين عليه سواء أكانوا وطنيين أم أجانب ، ونظرا لأن الدولة لا تملك حق ممارسة سلطتها هذه خارج إقليمها ، وإلا اصطدم ذلك بحق دولة أخرى في السيادة على إقليمها ، مما يجعل سلطة الدولة غير فعالة في السيطرة على مواطنيها بسبب وجودهم خارج إقليمها ، فإنه كان من الطبيعى أن يسود مبدأ إقليمية القوانين ، ألا أن هذا المبدأ لا يصلح إلا في المجتمعات البسيطة . كالمجتمعات البدائية . حيث لا يوجد أى تعاون أو تبادل أو انتقال فيما بينها ، لذلك كان لظهور التعاون بين الدول ، وانتشار التجارة الدولية ، وتقدم المواصلات

---

[١] عبد الناصر العطار ، المرجع السابق ، ص ٢٣٥ وما بعدها .

مع ما ترتب عليه من انتقال الأفراد بين الدول أثره في التخفيف من غلواء التمسك بمبدأ السيادة من جانب كل دولة ، فقد رؤى أن تطبيق الدولة لقوانينها ، تطبيقا شاملا ومطلقا على كل من يوجد على أرضها ، قد يمس في بعض الأحيان الرعايا الأجانب المقيمين على أرضها ، لإختلاف العقائد أحيانا ، ولإختلاف الأعراف والتقاليد أحيانا أخرى وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية .

أدت هذه الاعتبارات ، إلى ظهور مبدأ الشخصية بجانب مبدأ الإقليمية ، فسمح ذلك بقبول بعض الاستثناءات المستمدة من مبدأ الشخصية .

فمبدأ إقليمية القانون يمثل القاعدة العامة ، حيث أن لكل دولة حق كامل في ممارسة سيادتها على إقليمها ، لذلك نجد أن الغالبية العظمى من القواعد القانونية في كل دولة ، تسرى على كل المقيمين على أرضها مهما اختلفت جنسياتهم ، ويجد مبدأ إقليمية القوانين تطبيقه الطبيعى في قواعد القانون العام ، لأنها . كما قلنا . قواعد تمس بالدرجة الأولى سيادة الدولة واستقلالها .

فالأصل أن يسرى قانون العقوبات سريانا إقليميا ، فنصت المادة الأولى عقوبات مصرى مثلا على أن "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه" ، فقواعد قانون العقوبات تطبق على كل من يرتكب ، في مصر جريمة ولو كان أجنبيا ، والعكس فمن سيرتكب جريمة في الخارج ، لا يطبق عليه القانون المصري ولو كان مصريا .

كذلك يسرى القانون الإدارى سريانا إقليميا ، فالقانون الإدارى . كما قلنا . هو مجموعة القواعد التي تبين كيفية قيام السلطة التنفيذية بوظيفتها الإدارية ، فإذا عهد إلى أجنبى بوظيفة من الوظائف العامة في مصر ، فإن القانون المصري هو الذي يحكم علاقته بالجهة التي يعمل بها .

كذلك يسرى القانون المالى سريانا إقليميا ، فإذا مارس أجنبى نشاطا في

مصر ، فإنه يخضع في نشاطه للقانون المصري ، فيلتزم مثلا بأداء الضريبة المقررة إذا كان هذا النشاط مما يخضع للضريبة .

لكن مبدأ مصلحة الدولة والأفراد ، اقتضت الأخذ بمبدأ شخصية القوانين إلى جانب مبدأ إقليمية القوانين ، فإذا كان الأصل أن نطاق تطبيق قانون ما ، طبقا لمبدأ إقليمية القوانين ، هو إقليم الدولة التي سنت هذا القانون دون أن يتجاوزه إلى إقليم دولة أخرى ، فإن الأخذ بمبدأ شخصية القوانين يؤدى إلى سريان القانون على رعايا هذه الدولة حتى ولو كانوا على إقليم دولة أخرى .

يؤدى الأخذ بمبدأ الشخصية إذاً ، إلى تنوع القوانين المعمول بها داخل إقليم كل دولة ، وذلك حسب تعدد جنسيات الأشخاص المقيمين داخل هذا الإقليم ، مما يتصور معه قيام تنازع بين القوانين ، الأمر الذي يدعو إلى البحث عن القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة .

وتطبيقا لذلك ، يوجد جزء هام من قواعد القانون الدولي الخاص ، يطلق عليها قواعد تنازع القوانين ، وظيفتها بيان القانون الواجب التطبيق عندما توجد علاقة قانونية ذات عنصر أجنبى من علاقات القانون الخاص .

وقد وضع المشرع المصري ، قواعد تنازع القوانين من حيث المكان في المواد ١٠ . ٢٨ من القانون المدني الجديد ، وهذه القواعد تحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض فقد يفضى إعمالها إلى تطبيق القانون المصري ، وقد يفضى إلى تطبيق القانون الأجنبى ، فمثلا تقضى المادة ١٧ من القانون المدني على أنه "يسرى على الميراث قانون المورث" ، وإعمالا لهذه القاعدة . قاعدة إسناد . إذا توفي أجنبى في مصر وترك أموالا فالقانون الذي يطبق هو القانون الأجنبى الذي ينتمى إليه المورث بجنسيته وبالعكس ، إذا توفي مصرى في الخارج وترك أموالا ، طبق القانون المصري لأنه قانون المورث .

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في مصر بالنسبة لتطبيق القانون من حيث المكان ، لا يختلف عما هو عليه في غيرها من الدول الأخرى ، فالقاعدة هي سريان القانون سريانا إقليميا ، وتجد هذه القاعدة مجالها الطبيعى في فروع القانون العام . كما قلنا . بالإضافة إلى مسائل العقارات والاختصاص والاجراءات ، وإذا كانت القاعدة هي إقليمية القانون ، إلا أنه توجد استثناءات تؤدى إما إلى عدم تطبيق القانون المصري داخل الإقليم المصري أو تؤدى إلى تطبيقه خارج الإقليم المصري .

المبحث الثانى

نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

(تنازع القواعد القانونية في الزمان)

مشكلة التنازع بين القوانين المتعاقبة في الزمان :

الغاية من القانون هي تنظيم الروابط والعلاقات داخل المجتمع ، وهذه العلاقات وتلك الروابط دائمة التغيير والتطور بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفلسفية التي يمر بها المجتمع ، ومن ثم يجب أن يواكب القانون هذه التطورات ، وهذا الأمر يحتم على المشرع ضرورة التدخل من حين لآخر ، لإلغاء القواعد القانونية التي لم تعد تلائم ظروف المجتمع وإبدالها بقواعد قانونية أخرى أكثر ملائمة وأصدق تعبيرا عن حاجات الناس ومصالحهم .

ولكن التغير المستمر لقواعد القانون ، وإن كان ضروريا وحتميا ، إلا أنه يطرح مشكلة دقيقة وشائكة ، إذ يتعين عندئذ تحديد التاريخ الذي ينتهي عنده سريان القواعد القانونية الملغية ، ويبدأ ، إعتبارا منه ، سريان القواعد القانونية الجديدة ، وهو ما يعرف بمشكلة التنازع بين القوانين المتعاقبة في الزمان .

ولبيان هذه المشكلة وإلقاء الضوء على معالمها ، إليك بعض الأمثلة[1] :

١ . إذا صدر قانون جديد يقرر أن الطلاق لا يجوز إلا بإذن القاضى ، وللأسباب التي بينها القانون ، فهل يقتصر سريان هذا القانون على عقود

---

[1] هذه الأمثلة مأخوذة من كتاب الأستاذ الدكتور / شمس الدين الوكيل ، مبادئ القانون ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٨ ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بند ١٣٦ ، ص ٢٢٦ . ٢٢٧

الزواج التي تمت بعد نفاذه ، أم يخضع من تزوج في ظل القانون القديم الذي كان لا يشترط هذا الشرط ، للقيود الواردة في القانون الجديد .

٢ . الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية في ظل القانون المدني الحالى هي ٧% (المادة ١/٢٢٧ مدنى) ، فإذا صدر قانون جديد يجعل هذا الحد ٦% ، فما أثر هذا الحكم على عقود القرض بفائدة التي أبرمت في ظل القانون القديم ؟ وهل ينطبق هذا الحكم على العقود المبرمة قبل نفاذ القانون الجديد ؟ وإذا إفترضنا سريانه ، فهل يقصتر ذلك على تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للآثار المستقبلة ، أم يجب خصم الفائدة الزائدة عن السعر الجديد والتي تقاضها الدائن في الفترة الماضية منذ نشأة العقد ؟

٣ . يعتبر الشخص كامل الأهلية ، في ظل القانون الحالى ، إذا بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ، فإذا صدر قانون جديد يرفع سن الرشد إلى ٢٣ سنة ، فما أثر هذا الحكم الجديد على الأشخاص الذين اعتبروا راشدين وفقا للقانون الحالى ، إذا لم يكونوا قد بلغوا السن المقررة في القانون الجديد هل يعودون قاصرين مرة أخرى ؟ وإذا افترضنا عودتهم قاصرين فهل تتأثر تصرفاتهم التي أبرموها في ظل القانون القديم ، وتصبح باطلة على أساس اعتبارهم قاصرين وفقا للقانون الجديد .

تلكم كانت أمثلة قليلة لتعاقب القوانين في الزمان وتزاحمها في التطبيق على الأوضاع والعلاقات القانونية الخاضعة لها .

ولا مشكلة في الأمر إذا كانت الأوضاع والعلاقات القانونية قد نشأت ورتبت كل آثارها في ظل القانون القديم ، إذ لا مناص عندئذ من القول بخضوعها لهذا القانون ، ولا محل للقول على الإطلاق بخضوعها للقانون الجديد الذي لم يبدأ في السريان إلا بعد أن اكتملت وانتجت جميع آثارها ، والقول بغير ذلك يعنى

حدوث قلاقل وإضطرابات في المعاملات بين الناس لا مبرر لها .

مثال ذلك ، إذا أبرم عقد بيع ، وهو عقد فورى ، وأنتج كافة آثاره في ظل القانون المدني القديم ، وقبل نفاذ القانون المدني الجديد في ١٥ أكتوبر ١٩٤٩ ، فهذا العقد ، يخضع بلا شك ، لأحكام القانون المدني القديم وليس القانون المدني الجديد ، وذلك بالنسبة لجميع المنازعات المتعلقة به ، بما في ذلك المنازعات التي تعرض بعد العمل بالقانون المدني الجديد .

ولكن المشكلة تثور بالنسبة للأوضاع والوقائع والأعمال القانونية التي نشأت في ظل قانون قديم وظلت تنتج بعض آثارها في ظل قانون جديد ، إذ يثور سؤال ، في هذه الحالة ، بالنسبة للآثار المستقبلة ، أى التي ترتبت بعد إلغاء القانون القديم وسريان القانون الجديد ، وهل ستخضع للقانون الجديد أم يحكمها القانون القديم ، مثال ذلك شخص وضع يده على عقار مملوك للغير بنية تملكه بالتقادم ، فهذا الأمر يستلزم مرور مدة معينة ليعتبر واضح اليد مالكا بالتقادم ، فإذا صدر قانون جديد ، بعد بدء وضع اليد وقبل اكتمال المدة المقررة في القانون القديم لإكتساب الملكية ، فأى من القانونين يسرى على هذه المسألة ؟ هل هو القانون القديم أم القانون الجديد ؟

لقد أسفرت جهود الفقه ، في البحث عن حل لمشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان عن بلورة نظريتين هامتين هما : نظرية عدم رجعية القانون الجديد ، ونظرية الأثر الفورى أو المباشر للقانون الجديد .ودراستنا في هذا المبحث تنصب على إلقاء الضوء على كل نظرية منهما .

وعلى ذلك ، نقسم هذا المبحث إلى مطلبين كالآتى :

المطلب الأول : مبدأ عدم رجعية القانون الجديد .

المطلب الثانى : مبدأ الأثر الفورى أو المباشر للقانون الجديد .

المطلب الأول

مبدأ عدم رجعية القانون الجديد

المقصود بالمبـــدأ :

يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون الجديد ، عدم سريانه على الأوضاع القانونية التي نشأت وإنقضت وأنتجت كافة آثارها في ظل قانون سابق ، ويقتصر تطبيق هذا القانون على الأوضاع التي تتكون أو تنقضى أو تنتج كل آثارها بعد نفاذه .

ويفترض هذا المبدأ ، بداهة ، أن تكون هناك وقائع قانونية معينة قد نشأت أو إنقضت ورتبت كل آثارها في ظل قانون قديم ، ثم صدر بعد ذلك قانون جديد يعدل من شروط نشوء أو إنقضاء هذه الوقائع أو يعدل في آثارها ، وهنا لا يطبق القانون الجديد على هذه الوقائع ، لا من حيث نشوئها ، ولا من حيث إنقضائها ، ولا من حيث آثارها ، طالما تمت في ظل القانون القديم الذي تظل خاضعة له[1].

وقد أكدت دساتير مصر مبدأ عدم سريان القانون الجديد على الماضى ، وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية القانون ، فقد نص عليه الدستور المؤقت في المادة ٦٦ منه ، كما تضمنت نفس المبدأ المادة ١٧٨ من الدستور الملغي الصادر في ١١ سبتمبر ١٩٧١م ، وذلك بنصها على أن "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب". وقد سلك الدستور الحالي ٢٠١٤م نفس المسلك وأكدت ذلك المادة

---

[1] عبد المنعم البدراوى ، مبادئ القانون ، الكتاب الأول ، النظرية العامة للقانون ، ١٩٨١ ، ص ١٦٠ .

٢٢٥ منه.

المبررات التي يستند إليها مبدأ عدم رجعية القانون :

يستند مبدأ عدم رجعية القانون إلى عدة مبررات توجبه أهمها:

١. العدالـة : فالعدالة تأبى أن تحاسب الناس في سلوكهم وتصرفاتهم وفقا لقانون لم يكون ساريا وقت قيامهم بفعل أو تصرف معين[١] ، فإذا كان القانون هو مجموعة قواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، وهذه القواعد مكفولة بجزاء يوقع على المخالف ، فإن العدالة تقتضى أن يحاسب الناس وفقا للقانون السارى وقت وقوع المخالفة ، وليس وفقا لقانون جديد يصدر بعد ذلك .

٢ . استقرار المعاملات : فإستقرار المعاملات بين الناس يوجب ألا يسرى القانون الجديد على العلاقات القانونية التي نشأت وإنقضت وترتيب آثارها في ظل قانون سابق ، والقول بغير ذلك يجعل الناس حيارى لا يعرفون القانون الذي تخضع له علاقاتهم ، مما يؤدى إلى اضطراب المعاملات وإهدار ثقة الناس في القانون[٢]

٣ . المنطق : يقضى المنطق بألا يكون للقانون الجديد أثر على التصرفات التي نشأت وأنتجت كل آثارها وإنقضت قبل نفاذه والعلم به فالتشريع لا يسرى في مواجهة الأفراد إلا بعد نفاذه ونشره في الجريدة الرسمية ومضى مدة معينة بعد تاريخ النشر ، وذلك لكى يتحقق العلم الإفتراضى به ، ذلك العلم الذي يجعل الإعتذار بالجهل بالقانون غير مقبول كعذر ، فكيف يؤاخذ الناس بالقانون الجديد ، والفرض أنهم لم يعلموا به ولم يكن له وجود

---

[١] شمس الدين الوكيل ، المرجع السابق ، ص ٢٢٩ .

[٢] شمس الدين الوكيل ، المرجع السابق ، ص ٢٢٩ ؛ البدروای ، المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

مادى أو قانونى عندما أقدموا على تصرفاتهم ومعاملاتهم ، إن المنطق يقضى بقصر تطبيق القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد العمل به ، وعلى آثار هذه الوقائع ، دون أن يكون له أثر رجعى على ما تم قبل نفاذه من تصرفات .

حدود مبدأ عدم رجعية القانون الجديد :

مبدأ عدم رجعية القانون هو مبدأ يقيد القاضى وليس المشرع ، فالمشرع يستطيع . في غير المسائل الجنائية والضريبية الخروج على هذا المبدأ وتقرير رجعية قانون ما ، أى يسمح بسريانه على الماضى ، وذلك بالنص على ذلك صراحة في التشريع ، وبشرط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب طبقا لنص المادة ٢٢٥ من الدستور الحالي ٢٠١٤م، والأغلبية المطلوبة هنا هي أغلبية خاصة ، فلا تكفي الأغلبية العادية اللازمة لسن التشريعات وهي نصف عدد الحاضرين +١ ، وينبغى أن يكون للخروج على مبدأ عدم الرجعية من قبل المشرع مبررات قوية تقتضيها المصلحة العامة[١] ، كما ينبغى الاعتدال وعدم الإفراط في تقريره ، لأنه يهدر الثقة في القوانين بوجه عام ويغرى الناس على الإحجام والتحفظ في التعامل[٢] .

أما القاضى ، فلا يجوز له أن يطبق قانون جديد بأثر رجعى ، ما دام هذا القانون لم يقرر صراحة سريانه على الماضى .

الإستثناءات من مبدأ عدم رجعية القانون :

هل توجد استثناءات على مبدأ عدم رجعية القانون ؟ الواقع أن هناك

---

[١] البدراوى ، المرجع السابق ، ص ١٦٣ .

[٢] شمس الوكيل ، المرجع السابق ، ص ٢٣١ .

استثناءات متفق عليها ، وهناك استثناءات محل خلاف في الفقه ، وذلك على النحو التالى :

١ . النص الصريح : فمبدأ عدم الرجعية . كما سبق أن ذكرنا . يقيد القاضى الذي يطبق القانون ، ولا يقيد المشرع ، فالمشرع إذن يستطيع ، إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، أن ينص في التشريع الجديد ، في غير المواد الجنائية والضريبية ، على سريانه على الماضى ، بشرط أن تكون إرادة المشرع صريحة ، فلا تكفي الإرادة الضمنية[١] ، وبشرط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب جميعا .

٢ . القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب : فهذه القوانين تطبق بأثر رجعى وتعتبر إستثناءا من مبدأ عدم رجعية القانون الجديد ، حتى لو كان في تطبيقها مساس بالحقوق المكتسبة للأفراد ، وتبرير ذلك أنه لا يجوز لشخص أن يتمسك بحق إكتسبه في ظل قانون قديم متى أصبح هذا الحق مخالفا للنظام العام والآداب وفقا للقانون الجديد ، فإذا بلغ شخص سن الرشد وهو ١٨ سنة في ظل قانون قديم ، ثم صدر قانون جديد يرفع سن الرشد إلى ٢١ سنة ، فهذا الشخص يعود قاصرا تطبيقا لأحكام القانون الجديد ، بالرغم من أنه قد صار رشيدا في ظل القانون القديم ، لتعلق قواعد الأهلية بالنظام العام .

٣ . القوانين الجنائية الأصلح للمتهم : فالقاعدة أن القوانين الجنائية لا تسرى بأثر رجعى ، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، وتقضى المادة الخامسة من قانون العقوبات بأن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ، ومع ذلك يجوز أن تسرى القوانين الجنائية الجديدة بأثر رجعى إذا كانت أصلح للمتهم بأن كانت تبيح الفعل أو

---

[١] في هذا المعنى ، شمس الوكيل ، المرجع السابق ، ص ٢٣٣ .

تخفض العقوبة المقررة في القانون القديم ، ولا يعد ذلك مساسا بالمصلحة العامة ، بل على العكس ، هذا الإستثناء له ما يبرره من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العدالة ، إذ من الظلم والتناقض أن تطبق على المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيه الشارع بعدم فائدتها أو بزيادتها على الحد اللازم ، وليس من حق الجماعة أن توقع عقوبة ظهر أن توقيعها ليس في مصلحتها ، إذ العقوبة تقدر بالقدر اللازم لتحقيق هذه المصلحة[١] ، وقد تقرر هذا الاستثناء في المادة الخامسة من قانون العقوبات حيث جاء بها ... ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، ولنا عودة إلى هذا الموضوع عند دراسة الحلول التشريعية لمشكلة التنازع الزمانى للقوانين في القانون المصري .

٤ . **القوانين المفسرة** : وهي القوانين التي تهدف إلى تفسير ما غمض وإيضاح ما إستشكل من ألفاظ وعبارات النصوص التشريعية القائمة ، ويذهب بعض الفقهاء إلى أن القوانين المفسرة يكون لها أثر رجعى ، ومن ثم تنسحب إلى الماضى منذ تاريخ صدور القانون الذي تفسره ، وتعتبر جزءا منه ، ويتعين على القاضى أن يطبق هذه القوانين على القضايا المنظورة أمامه طالما لم يفصل فيها بعد بحكم قضائى ، ولكننا نرى مع البعض الآخر[٢] ، أن هذه القوانين لا تعتبر استثناءاً حقيقيا على مبدأ عدم رجعية القانون الجديد ، لأنها لا تتضمن حكما جديدا ، وإنما قصد منها مجرد الإفصاح عن إرادة المشرع ، ولذلك تنطبق قواعدها من تاريخ نفاذ القانون القديم ، أى القانون الذي صدرت تفسيرا له

---

[١] البدراوى ، المرجع السابق ، ص ١٦٥ .

[٢] شمس الوكيل ، المرجع السابق ، ص ٢٣٢ . ٢٣٣ ؛ البدراوى ، المرجع السابق ، ص ١٦٤ .

المطلب الثانى

مبدأ الأثر الفورى أو المباشر للقانون

تقرير المبدأ ومبرراته :

يقصد بهذا المبدأ وجوب تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر وفورى على الوقائع والأعمال القانونية التي تقع بعد نفاذه والعمل به .

ويعتبر هذا المبدأ من إبداعات الفقه الفرنسى[١] ، واعتنقه الفقه المصري بعد ذلك ، وليس له سند تشريعى ، كما هو الحال بالنسبة لمبدأ عدم رجعية القانون الجديد ، وقد قام هذا المبدأ إلى جانب مبدأ عدم رجعية القانون كمكمل ومعضد له.

ويقوم مبدأ الأثر الفورى أو المباشر للقانون الجديد على عدة مبررات أهمها:

أولا : إن المشرع حينما يقوم بتعديل قانون قديم أو إلغاءه وإبداله بقانون جديد ، يفترض أن القانون الجديد يكون أكثر إستجابة للظروف المستحدثة في المجتمع ، وأصدق تعبيرا عن حاجات الناس ومصالحهم ، وإلا لما كان هناك داع للتغيير ، وطالما كان الأمر كذلك ، فإن القانون الجديد يجب أن يسرى على كل ما يقع من أعمال بعد نفاذه .

ثانيا : وفي تطبيق القانون الجديد بأثر فورى على كافة الأوضاع القانونية ، سواء كانت أوضاعا جديدة نشأت بعد نفاذه ، أم كانت أوضاعا قديمة لم تستكمل تكوينها ، أو لم ترتب كافة آثارها ، ما يعزز وحدة القانون المطبق في الدولة[٢] .

النتائج التي تترتب على مبدأ الأثر الفورى للقانون :

---

[١] شمس الدين الوكيل ، المرجع السابق ، ص ٢٣٥ .

[٢] شمس الدين الوكيل ، المرجع السابق ، ص ٢٣٥ . ٢٣٦ .

يترتب على تطبيق القانون بأثر فورى أن يسرى القانون الجديد على ما يأتى:

١ . كافة الأوضاع القانونية الجديدة التي تطرأ بعد نفاذه : ويسرى القانون الجديد على إنشاء هذه الأوضاع وعلى إنقضائها وعلى آثارها .

٢ . الأوضاع القانونية الناقصة ، وذلك بالنسبة للعناصر التي تتم بعد نفاذ القانون الجديد ، أما العناصر التي إكتملت في ظل القانون القديم فتظل خاضعة له ، فإذا صدر قانون جديد يعدل من شروط التعيين في الوظيفة العامة ، فإنه يسرى بأثر مباشر على كل شخص لم يكن قد تم تعيينه وفقا للقانون القديم ، حتى لو كان قد تقدم بطلب التعيين في ظل هذا القانون ، لأن التعيين لا يتم بمجرد تقديم الطلب ، بل بصدور قرار من السلطة المختصة بذلك ، وهذا القرار لم يصدر في ظل تطبيق القانون القديم ، فيسرى عليه القانون الجديد .

٣ . إنقضاء الأوضاع القانونية التي لم تتحقق في ظل القانون الجديد ، فإذا صدر قانون جديد يطيل مدة سقوط حق المطالبة بحق معين ، فإن المدة الجديدة تسرى على كل الحقوق التي لم تنقض بالتقادم في ظل تطبيق القانون القديم .

٤ . الآثار المستقبلة للأوضاع القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم ، ويحدث ذلك بالنسبة للعقود الزمنية أو المستمرة ، كعقد الإيجار وعقد العمل ، فإذا صدر قانون جديد يعدل من آثار هذه العقود ، فإنه يسرى على آثارها الممتدة في الزمن ، ما دامت القواعد الجديدة هي قواعد قانونية آمره ، دون أن يعد ذلك تطبيقا للقانون بأثر رجعى .



الفصل الثالث

تفسيـــر القانـون

لا يتمكن القاضى من إعمال حكم القاعدة القانونية على الحالات التي تتناولها القاعدة بالتنظيم ، إلا بعد تحديد معناها ، حتى يستطيع أن يتبين مدى انطباقها على الحالة المعروضة عليه ، وسبيل القاضى إلى ذلك هو التفسير .

يقصد إذاً بالتفسير ، إزالة الغموض وما قد يوجد من لبس في حكم القاعدة القانونية ، ودراسة هذا الموضوع ، تقتضى التعرض لأنواعه والاتجاهات العامة فيه ، وطرقه ، وذلك في ثلاثة مباحث :

خطة البحث :

المبحث الأول : أنواع التفسير .

المبحث الثانى : الاتجاهات العامة للتفسير .

المبحث الثالث : طرق التفسير .

المبحث الأول

أنــواع التفسيــر

يتنوع التفسير بحسب الجهة التي أصدرته إلى تفسير تشريعى وتفسير قضائى وتفسير فقهي ، فإذا تولى المشرع نفسه تفسير ما أصدره من تشريع أو فوض سلطة معينة في ذلك ، كان التفسير تشريعيا ، وإذا قام به القضاء عند تطبيق التشريع على الوقائع المعروضة ، كان التفسير قضائيا ، وأخيرا إذا انصرف إلى ما يقوم به الفقهاء عند شرحهم لنصوص التشريع ، كان التشريع فقهيا .

أولا : التفسير التشريعــى:

هو التفسير الذي تقوم به السلطة التشريعية التي أصدرت التشريع أو سلطة أخرى يتم تفويضها في ذلك[١] ، ويحدث هذا . في الغالب . عندما تختلف المحاكم اختلافا بينا في فهم تشريع معين ، إلى حد يهدد بعدم الاستقرار في التعامل ، مما يتطلب حسم الخلاف على وجه قاطع ، والسبيل إلى ذلك أن يتدخل المشرع نفسه فيصدر تشريعا يفسر التشريع الذي أثير بشأنه الخلاف ، وقد يقدر المشرع ، عند وضع تشريع معين ينظم مسألة معينة ، أن هذا التشريع سوف يثير خلافا في التفسير ، وأنه من الأفضل حسم ما ينشأ بمناسبة تطبيقه من خلاف في الرأى ، فيفوض سلطة معينة بتفسير هذا التشريع .

الأصل إذاً ، أن يصدر التفسير التشريعى من ذات السلطة التي أصدرت التشريع ، لكن لهذه السلطة أن تفوض جهة أخرى غيرها للقيام بهذه المهمة .

ومن أمثلة التفسير التشريعى[٢] ، الذي صدر من المشرع نفسه ، المرسوم

---

[١] توفيق حسن فرج ؛ ويحيى مطر ، المرجع السابق ، ص ٣٩٢ وما بعدها .

[٢] عبد الناصر العطار ، ص ٢٤٨ .

بقانون الذي أصدره المشرع المصري بتاريخ ٢ مايو ١٩٣٥ بتفسير مرسوم ، أغسطس ١٩١٤م ، فبعد صدور مرسوم ١٩١٤ الخاص بتقرير السعر الإلزامى لأوراق البنكنوت ، وتقرير بطلان الدفع بالذهب ، فسرت المحاكم المختلطة ، النص الذي يقرر بطلان شرط الدفع بالذهب ، بأن المقصود به هو بطلان شرط الدفع بالذهب في المعاملات الداخلية فقط ، أما شرط الدفع بالذهب فيبقى صحيحا في المعاملات الدولية ، فتدخل المشرع وأصدر مرسوما بتاريخ ٢ مايو سنة ١٩٣٥ يفسر به مرسوم ١٩١٤ وقرر أن البطلان المنصوص عليه في مرسوم ١٩١٤ ، عام ومطلق ، وأنه لا يقتصر على المعاملات الداخلية ، بل يشمل كذلك المعاملات الدولية .

ومن الأمثلة على التفسير الذي يصدر من سلطة مفوضة في تفسير تشريع معين ، التفسيرات العديدة التي أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعى لتفسير قوانين الإصلاح الزراعى ، فقد نصت المادة ١٢ مكررة من قانون الإصلاح الزراعى . التي أضيفت إلى هذا القانون بالمرسوم بقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٢ . على أنه "للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون ، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر في الجريدة الرسمية" .

وقد تعطى هذه السلطة تفويضا مطلقا ، ولا يقتصر على تفسير تشريع معين . كما في الحالة السابقة . ولكن يكون لها حق تفسير القوانين بوجه عام ومن ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ ، بإصدار قانون المحكمة العليا من أن تختص المحكمة العليا "بتفسير النصوص القانونية التي تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائى وذلك بناء على طلب وزير العدل ، ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزما" .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق اصبح للمحكمة الدستورية العليا التي

حلت محل المحكمة العليا بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

وسواء صدر التفسير من المشرع نفسه ، أو من سلطة مفوضة في تفسير المشرع ، فهو ملزم ، ومن ثم وجب على القاضى أن يتقيد به عند تطبيق النصوص القانونية التي فسرت .

ولكن ماذا لو تجاوز المفسر نطاق سلطته في التفسير فوضع قواعد جديدة لا تحتملها النصوص التي يقوم بتفسيرها ؟ لمعرفة القوة الملزمة لما يصدر من تفسيرات في هذه الحالة ، يجب أن نفرق بين التفسير الذي يصدر من المشرع نفسه ، والتفسير الذي يصدر من سلطة فوضت فيه .

فإذا كان المشرع نفسه هو الذي تولى التفسير ، فإن التفسير الذي أصدره ، يعتبر ملزما سواء كان التفسير مستفيداً بالمعنى الحقيقى للنص ، أو خرج عن نطاق التفسير بأن تضمن مالا تحتمله النصوص المفسرة ، إذ تكون . في هذه الحالة . بصدد تعديل في التشريع والمشرع يملك تعديل ما سبق أن أصدره من تشريعات ولو كان ذلك في صورة تفسير .

أما إذا صدر التفسير من سلطة مفوضة ، فإن التفسير الصادر عنها يلزم القاضى إذا لم يتجاوز نطاق التفسير الصحيح ، أما إذا تجاوزت السلطة المفسرة حدود اختصاصاتها وحملت نصوص التشريع الذي تفسره مالا يحتمله ، فيعتبر عملها تعديلا للتشريع وليس تفسيرا له ، وهذا الأمر لا يملكه غير المشرع ، وبالتالى يكون من حق المحاكم ألا تلتزم به .

ثانيا : التفسير القضائى :

يطلق التفسير القضائى على ما يقوم به القاضى من تفسير للقواعد

القانونية بمناسبة تطبيقه لها على الأقضية المطروحة أمامه[1] .

والقاضى وهو يفسر القانون بمناسبة الفصل فيما يعرض عليه من منازعات ، يتأثر إلى حد كبير بالإعتبارات العملية والظروف الواقعية المحيطة بالمنازعات التي تثير التفسير عند الفصل فيها ، وقد يميل القاضى إلى دواعى العدالة والاعتبارات العملية ، فيهدر نصا تشريعيا تحت ستار تفسيره ، فيكون الحكم ملائما ومتمشيا مع تلك الاعتبارات .

وما تتوصل إليه المحاكم من تفسيرات بمناسبة تطبيق القانون ، ليس ملزما لها ، كما أنه لا يلزم المحاكم الأخرى ولو كانت أدنى منها درجة ، وذلك لأن المحاكم لا تضع . بمناسبة تطبيقها للقانون . قواعد قانونية عامة مجردة ، وإنما تعطى تفسيرا جزئيا ، وحلا نسبيا لحالة معينة .

ومع ذلك فقد نصت المادة ٢٦ من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن هذه المحكمة تتولى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .

وقد اعتبرت المادة ٤٩ من قانون المحكمة ، أن ما يصدر من تفسيرات من هذه المحكمة يعد ملزما لجميع المحاكم .

ثالثا : التفسير الفقهى:

يطلق التفسير الفقهي على ما يقوم به الفقه من دراسة وتحليل وتعليق وشرح للنصوص القانونية .

---

[1] توفيق حسن فرج ؛ يحيى مطر ، المرجع السابق ، ص ٣٩٧ ، والفقه المشار إليه بالهامش .



ويغلب على التفسير الفقهي . على خلاف التفسير القضائى . الطابع النظرى الذي تغلب فيه اعتبارات المنطق ، فالفقه يهمه معرفة حكم القانون ، وأوجه القصور فيه ، وقد يؤدى ذلك إلى تدخل المشرع . لتعديل التشريع أو إلغائه . إذا كان ما شابه من نقص أو عيب يبرر هذا التدخل مسترشدا في ذلك برأى الفقهاء .

وتناول الفقيه للتشريع في مجموعة وأصوله ونظرياته العامة قد يؤدى إلى تفاوت في الرأى بينه وبين القاضى ، لكن لا يوجد تعارض تام بين الفقه والقضاء ، فهما . على العكس من ذلك . يحرصان على التعاون فيما بينهما بما يتيح الجمع بين الفوائد النظرية والعملية على السواء .

فلا يقتصر دور الفقه على تناول النصوص القانونية بالشرح والتحليل ، وإنما يتناول أيضا أحكام المحاكم ، مبينا ما فيها من جوانب الخلل والصواب .

ويفضل القضاة الرجوع إلى تفسيرات الفقه ، كما أن الفقه يضع دائما في اعتباره وهو يتناول النصوص القانونية بالتفسير ما تسير عليه المحاكم ، فهذه الأحكام تمده بفروض عملية .

المبحث الثانى

الاتجاهات العامة للتفسير

يهدف التفسير إلى التعرف على المعنى الذي تدل عليه النصوص ، وذلك بالبحث والوقوف على مقصود المشرع من عباراته ، فالنصوص ليست إلا تعبيرا عن إرادة واضعها ، وقد أدى ذلك إلى اختلاف وجهات النظر في حقيقة دور المشرع في وضع القاعدة القانونية ، وتبعا لذلك اختلفت المذاهب في التفسير ، وأهم الاتجاهات العامة في التفسير :

أولا : مدرسة الشرح على المتون أو مدرسة التزام النص .

ثانيا : المدرسة التاريخية أو الاجتماعية .

ثالثا : المدرسة العلمية أو مدرسة البحث العلمى الحر .

أولا : مدرسة الشرح على المتون أو مدرسة التزام النص :

ظهرت مدرسة الشرح على المتون في أعقاب التقنينات الفرنسية التي وضعت على أثر الثورة حتى أواخر القرن التاسع عشر ، وقد أحيطت هذه التقنينات بقدر كبير من التقديس كما ساد الاعتقاد بأنها حوت كل ما يلزم من قواعد لمواجهة مشاكل الحياة ، كما أنها تنبأت بكل ما قد يعرض في المستقبل من فروض[1] .

ونظرا إلى أن القواعد التشريعية ليست إلا تعبيرا عن إرادة المشرع ، وأن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون ، فيجب أن ينصرف التفسير إلى التعرف على إرادة المشرع وقت وضع التشريع .

وليست هناك مشكلة ، إذا كانت عبارات النص واضحة الدلالة ، بحيث

---

[1] توفيق حسن فرج ؛ ويحيى مطر ، المرجع السابق ، ص ٤٠١ ، والفقه المشار إليه بالهامش .

تكشف بسهولة عن الإرادة الحقيقية للمشرع وحيث تستخلص هذه الإرادة من التفسير اللفظى أو اللغوى للنصوص ، مما يكاد يقتصر معه دور المفسر على التطبيق الآلى للنص دون تعديل أو تأويل ، فلا اجتهاد مع النص .

أما المشكلة فتثور ، إذا كان النص غامضاً أو مبهماً بحيث لا يكشف عن الإرادة الحقيقية للمشرع ، وفي هذه الحالة يجب البحث عما كان يقصده المشرع من استعمال هذه الألفاظ وذلك بتقريب الألفاظ بعضها للبعض الآخر ، وبتقريب النصوص المختلفة ، وكذلك بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للنص ومصادره التاريخية .

وإذا استحال الوقوف على الإرادة الحقيقية للمشرع ، فنلجأ إلى ما يسمى بالإرادة المفترضة ، أى الإرادة التي يفترض المفسر أن المشرع لو عرض للمسألة التي يبحث فيها ليعبر عنها ، وتستخلص هذه الإرادة المفترضة عن طريق الاستنتاج المنطقى ، فعلى المفسر أن يعتمد على بعض الإمارات ، كمسلك المشرع في مسألة أخرى ، والسوابق التاريخية ، ومبادئ التشريع ونظرياته العامة.

ويؤخذ على هذه المدرسة ، تطرفها في التعلق بنصوص التشريع مما أدى إلى وقف جهد التفسير على نصوص التشريع بإعتباره المصدر الوحيد للقانون ، والإسراف في استعمال طرق التفسير اللفظى أو اللغوى بشأنها . وقد أخذ عليها إسرافها في التمسك بحرفية النصوص لإستخلاص إرادة المشرع ومن ثم يفترض أن للمشرع إرادة حيث لا توجد إرادة حقيقية .

ثانيا : المدرسة التاريخية أو الاجتماعية :

ظهرت هذه المدرسة في ألمانيا ، وتعتبر صدى لتعاليم المذهب التاريخى في تصور القانون بإعتباره خلقا ذاتيا ينبعث من ضمير الجماعة ، أى أن القانون حدث اجتماعي ينشأ تلقائيا نتيجة تفاعل للعوامل المختلفة التي تؤثر في المجتمع

ويتطور بتطور الظروف الاجتماعية .

فالقانون ليس تعبيرا عن إرادة المشرع ، وليس لهذه الإرادة قيمة في ذاتها ، وإنما قيمتها في كونها تعبيرا عن حاجات الجماعة المتطورة[1].

فدور المشرع ليس صنع القانون . كما تذهب مدرسة الشرح على المتون . وإنما تسجيل للقانون الذي خلقته البيئة ، فإذا عبر المشرع عن هذه القواعد بنصوص تشريعية ، انفصلت هذه النصوص عن إرادة واضعيها ، ويكون لها حياتها الخاصة المستقلة والمتصلة بالحياة الاجتماعية .

ونظرا لارتباط القانون وتفاعله مع الظروف الاجتماعية ، فإن قواعده يتغير معناها من وقت لآخر لتكون ملائمة للظروف الاجتماعية السائدة وقت التفسير .

نخلص إلى أن النصوص التشريعية لا تفسر . وفقا لهذا الاتجاه . وفقا لإرادة المشرع الحقيقية أو المفترضة لأنها انفصلت منذ وضعها عن هذه الإرادة ، بل وفقا للإرادة المحتملة للمشرع ، أى الإرادة التي كان يتجه إليها المشرع ، لو أنه وجد في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الموجودة عند تطبيق النص ، وبهذا تتحقق للتشريع المرونة التي تجعله يساير الظروف الاجتماعية .

ولكن يؤخذ عليها أنها تفتح الباب ليدلى كل برأيه ، مما يؤدى إلى الخروج بالتفسير عن وظيفته وتحويله إلى خلق للقواعد القانونية كما أن فيه توسيع غير مأمون لسلطة المفسر ، فيفقد التشريع بهذا ما يميزه من انضباط يؤدى إلى استقرار المعاملات .

ثالثا : المدرسة العلمية

وزعيم هذه المدرسة هو الفقيه االفرنسي Gény ويأخذ البحث عن إرادة

---

[1] المرجع السابق ، ص ٤٠٢ والفقه المشار إليه بالهامش .

المشرع الحقيقية وقت التشريع ، وذلك في حالة وجود نص تشريعى.

أما إذا لم يوجد نص تشريعى ، فلا يجب البحث عن الإرادة المفترضة للمشرع وقت صدور التشريع، وإنما يجب الرجوع إلى جوهر القانون ومجموعة الحقائق . الطبيعية أو الواقعية . والحقائق التاريخية والحقائق العقلية والحقائق المثالية التي تتكون منها مادة القانون لتستلهم منها حل المسألة المعروضة وهي ما يسمى بالبحث العلمى الحر .

فتفسير النصوص إذا ، يتطلب الوقوف على إرادة المشرع الحقيقية وقصده من النصوص وقت وضعها ، دون أن نلجأ إلى ما يسمى بالإرادة المفترضة ، فلا يجوز أن نفترض أمراً وننسبه إلى المشرع.

فإذا لم توجد للمشرع في المسألة المعروضة إرادة حقيقية ، لعدم وجود نص في التشريع يواجه ما يعرض في العمل من فروض ، فعندئذ نتلمس الحل في المصادر الرسمية الأخرى للقانون وأهمها العرف ، فإن عجزت كل المصادر الرسمية عن إعطاء الحلول اللازمة فلا يكون أمامنا إلا ما يسمى بالبحث العلمى الحر .

فمدرسة البحث الحر تخالف مدرسة الشرح على المتون فيما يدعيه أنصارها من حصر مصادر القانون في التشريع ، كما تخالف المدرسة التاريخية فيما تذهب إليه من تفسير التشريع وفقاً للظروف السائدة وقت التفسير للوصول إلى ما يسمى بالإرادة المحتملة للمشرع .

رابعا : التفسير في القانون المصري :

يبدو من نص المادة الأولى . والتي تنص على أنه "تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها" أن المشرع المصري لم يأخذ بفقه مدرسة الشرح على المتون على إطلاقه ،

كما أنه تأثر بفقه المدرسة التاريخية أو الإجتماعية ، وبفقه مدرسة البحث العلمى الحر .

فالتشريع ليس المصدر الوحيد للقانون كما يقول فقه مدرسة الشرح على المتون ، فعلى العكس يحيل القانون المصري القاضى إلى العرف عند عدم وجود نص تشريعى ، فإذا لم يوجد بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة[1]. والمشرع المصري هنا تأثر بفقه المدرسة التاريخية أو الإجتماعية .

كما يجب . وفقاً للقانون المصري . الوقوف على الإرادة الحقيقية للمشرع متى وجد نص تشريعى دون اصطناع إرادة مفترضة له حتى في حالة غياب النص ، وإنما يجب البحث عن حل للمسألة المعروضة في مصادر القانون الأخرى فإذا لم يجد فعليه أن يجتهد رأيه وفقاً لاعتبارات موضوعية عامة ، لا عن تفكير ذاتى خاص ، والقاضى يستعين في هذه الحالة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعى ، ومبادئ القانون بوجه عام ، وهذا يتفق مع فقه مدرسة البحث العلمى الحر .

---

[1] المرجع السابق ، ص ٤٠٢ والفقه المشار إليه بالهامش .



خامسا : طرق التفسيـــر :

لكن ما هي الوسائل الفنية التي يهتدى بها المفسر في سبيل التعرف على معنى النص القانونى ؟

للإجابة على هذا السؤال نفرق بين حالتين : الحالة الأولى حالة وجود نص صريح ، والحالة الثانية حالة عدم وجود نص صريح .

١. حالة النص الصريح :

يلجأ المفسر لإستخلاص معانى النصوص القانونية إلى ألفاظ النص أو ما يشير إليه عن طريق دلالته ، أو يلجأ إلى فحوى النص وروحه .

ويقتضى هذا الوقوف على معنى كل لفظ وتقريب الألفاظ بعضها من البعض الآخر ، فالألفاظ يفسر بعضها البعض ، والعبرة بمجموعة العبارات وليس بكل لفظ على حده .

على المفسر إذا متى كان النص واضحاً ، أن يستخلص معناه من ألفاظه . وهو ما يسمى بالمعنى الحرفي للنص . أى من عباراته ومفرداته ، وإذا كان للفظ معنيان ، معنى لغوى ، وأخر اصطلاحى تعين الأخذ بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا تبين أن المقصود هو المعنى اللغوى.

فلفظ الزنا ، يطلق ويراد به لغة ، كل علاقة جنسية غير مشروعة بين رجل وامرأة ، أما في معناه الاصطلاحي ، فيطلق ويراد به معنى أضيق ، إذا لا يستخدم إلا إذا كان أحد طرفي العلاقة الجنسية غير المشروعة متزوجاً .

وقد يستفاد الحكم القانونى من إشارة النص ، ويقصد به المعنى الذي وإن كان لا يتبادر فهمه من ألفاظ النص ، إلا أنه يعتبر نتيجة حتمية لها ، أى هو المعنى اللازم للمعنى المستفاد من عبارة النص .

مثال ذلك ، ما تنص عليه المادة ١٠٣٣ مدنى من أنه "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا اقره المالك الحقيقى بورقة رسمية" إذا نظرنا إلى نص هذه المادة ، نجد أنه يدل بعبارته على أن إقرار المالك يصحح عقد الرهن ، ويدل بإشارته على أن عقد الرهن إذا صدر من غير مالك يعتبر قبل إقرار المالك موجوداً ، فلا يتصور أن يرد الإقرار على شئ غير موجود .

وكما يستفاد الحكم من دلالة اللفظ ، فإنه يستفاد من فحواه وروحه ، تطبيقاً لنص المادة الأولى مدنى "تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها" .

وللمفسر أن يستعين . في حالة ما إذا كان النص مشوباً بخطأ مادى أو معنوى ، أو بغموض أو نقص أو كان متعارضاً مع نص آخر ، بالغاية التي يهدف النص إلى تحقيقها ، وبالأعمال التحضيرية وهي مجموعة الوثائق والمستندات التي توضح الخطوات التي مر بها النص عند وضعه وله أن يرجع إلى المصادر التاريخية ، فإذا كان النص مأخوذاً من قانون دولة أخرى ، فإن الرجوع إلى أقوال الفقهاء ، وأحكام المحاكم في تلك الدولة تساعد المفسر في الكشف عن المعنى المقصود

وإذا لم يستطيع المفسر . قاضياً كان أم فقيهاً . الوصول إلى المعنى المقصود للنص أو الحكم المطلوب للحالة المعروضة بإستخدام الاستنتاج المنطقى . سالفة الذكر . كان عليه أن يلجأ إلى المصادر الأخرى للقاعدة القانونية . العرف . الشريعة الإسلامية . فإذا لم يوجد لم يكن أمامه إلا الإجتهاد من خلال مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة

٢. حالة عدم وجود نص :

وفي هذه الحالة يتم الكشف عن حكم الحالة المعروضة بطريق المنطق والاستنتاج ، وقد يتم الاستنتاج بطريق مفهوم الموافقة . القياس ، وقد يكون بطريق مفهوم المخالفة .

مفهوم الموافقة أو القيـاس :

ومعناه إعطاء حالة غير منصوص عليها ، حكم حالة منصوص عليها ، لإتحاد العلة بالنسبة لهما ، والقياس على نوعين القياس العادى والقياس من باب أولى .

القياس العادى : هو إعطاء حالة لم يصرح المشرع بحكمها ، حكم حالة منصوص عليها ، لإتحاد علة الحكم وتساويها في الحالتين ، ومن الأمثلة على ذلك ما تنص عليه المادة ٣١٢ عقوبات مصرى من أنه " لا يحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ..." .

فقيس النصب وخيانة الأمانة على السرقة من حيث الإعفاء من العقاب ، لأن علة الإعفاء وهي المحافظة على كيان الأسرة وتدعيم العلاقات بين أفرادها متوفرة في الحالات الثلاث .

القياس من باب أولى : هي اعطاء حالة لم يصرح المشرع بحكمها حكم حالة منصوص عليها ، لأن علة الحكم في الحالة الأولى أظهر وأقوى منها في الحالة الثانية ، ومن الأمثلة على ذلك ما تنص عليه المادة ٢٣٧ عقوبات مصرى من أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن زننى بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، أى أن الزوج القاتل يعاقب هنا بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية ، فلو أن الزوج في مثل هذه الحالة . ضرب زوجته ومن زنى بها ، فأحدث عاهة مستديمة . وهي في



الأصل جناية . فيجب أن تقاس هذه الحالة على حالة القتل ، وتخفف العقوبة لأن الزوج أولى بالتخفيف منه في الحالة المنصوص عليها .

مفهوم المخالفــة :

هو اعطاء حالة لم ينص المشرع على حكمها عكس الحكم المنصوص عليه في حالة أخرى ، لإختلاف العلة أو تخلفها ، ومن الأمثلة ما تنص عليه المادة الرابعة من القانون المدني من أن "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأن من ضرر " فيستنتج من هذا النص بمفهوم المخالفة أن من يستعمل حقه استعمالاً غير مشروع يكون مسئولاً عما ينشأ عن هذا الاستعمال من ضرر .

وإذا لم يستطيع المفسر ، التوصل إلى حل للحالة المعروضة عليه ، بإستخدام طرق الاستنتاج المنطقى السابقة ، كان عليه أن يلجأ إلى مصادر القانون الأخرى كالعرف ، والشريعة الإسلامية ، فإن لم يجد اجتهد رأيه من خلال مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .

بمعنى أن المفسر لا يلجأ إلى المصادر الأخرى للقاعدة القانونية بحثاً عن المعنى المقصود والحل المنشود ، إلا إذا استنفذ سبيل الوصول إلى ما ينشده من المصدر الأول للقاعدة القانونية . التشريع . وذلك بكل وسائل التفسير التي تكلمنا عنها بما فيها القياس .

الجزء الثاني

نظريـــة الحـــق

أ.د / خالد جمال أحمد حسن

مبحث تمهيدي

التعــريف بالحـــق

المطلـب الأول

معنـــى الحـــق

لقد أورد الفقهاء –قديما وحديثا– تعريفات عديدة للحق، نختار من بينها ما ذهب إليه البعض بقوله أن الحق معناه "استئثار شخص بقيم أو أشياء معينة استئثارا يكفل له التسلط والاقتضاء، بهدف الوصول إلى تحقيق مصلحة يحميها القانون لأنها ذات قيمة اجتماعية" [١] ، أو هو "الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الأشخاص ويكون له بمقتضاه إما التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر " [٢].

<u>ويظهر لنا مما سبق أن الحق يقتضي وجود العناصر الآتية:–</u>

أولاً: عنصر الاستئثار بأشياءأو بقيم معينة:

إن عنصر الاستئثار يعد أهم العناصر المميزة للحق، وهو يقتضى وجود شخص معين يستأثر بشيء أو بقيمة معينة دون سواه بحيث ينفرد وحده بالفائدة أو الميزة التي يعطيها له هذا الشيء أو تلك القيمة، فصاحب حق الملكية مثلا ينفرد دون سواه بالميزات التي يخولها له هذا الحق، فله وحده الحق في استعماله واستغلاله والتصرف فيه [٣] .

---

[١] أ.د/ الوكيل بند ١٨٤، ص ٣٠١، وقرب ذلك أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٧٤ حيث يرى أن الحق معناه "استئثار بشيء أو بقية استئثارا يحميه القانون".

[٢] أ.د/ نبيل إبراهيم سعد " المدخل إلى القانون ، نظرية الحق ، ص ٤٠ ، عام ٢٠٠١م، منشأة المعارف بالإسكندرية.

[٣] وينبغي أن يكون ماثلا في الذهن أن حق الملكية لم يعد حقا مطلقا كما كان عليه الحال في ظل المذهب

ولا يلزم لثبوت الاستئثار بوصفه أحد عناصر الحق أن تكون للشخص إرادة، فقد يثبت هذا الاستئثار للمجنون وللصبي غير المميز، كما أنه قد يثبت للشخص رغم عدم تدخل إرادته فيه مثل ثبوته للوارث وللغائب، ولعل الأخذ بهذا المعنى هو الذي يبرر ثبوت الاستئثار أو الحق للأشخاص الاعتبارية رغم عدم وجود إرادات حقيقية لها، ذلك أن الإرادة لا تلزم لوجود الحق وإنما تلزم لمباشرة ما يخوله هذا الحق أو الاستئثار من سلطات أو صلاحيات.

ومن الطبيعي أن ينصب الاستئثار على موضوع معين مثل أشياء أو قيم معينة، فقد يرد الاستئثار على أشياء مادية مثل ورود حق الملكية أو حق الانتفاع مثلا على العقارات والمنقولات، وقد يرد على أشياء معنوية مثل ورود حق المؤلف على نتاجه الذهني والفكري من أبحاث ومؤلفات ومخترعات.

كما أنه قد يكون موضوع الاستئثار قيما معينة سواء كانت هذه القيم موضوع الحق قابلة للتقدير المالي مثل الخدمات التي يقتضيها صاحب الحق من الغير والتي تتمثل في أداء عمل معين أو الامتناع عن عمل معين أو كانت قيما لا تقبل الخضوع للتقدير المالي أو الاقتصادي مثل القيم اللصيقة بشخص الإنسان مثل الحقوق والحريات.

ثانيا: عنصر التسلط والاقتضاء:

لا يكفي لإبراز مقومات الحق توافر عنصر الاستئثار، وإنما يلزم أيضا توافر عنصر التسلط والاقتضاء حتى يتسنى لصاحب الحق الإفادة من هذا الحق.

ويقصد بالتسلط الصلاحية أو السلطة التي تثبت لصاحب الحق على ما يستأثر به من أشياء أو قيم معينة، فالمرء حينما يستأثر بشيء أو قيمة معينة لا

الفردي، وإنما أضحى حقا مقيدا ذا وظيفة اجتماعية يحددها له القانون بحسب ما يقتضيه الصالح العام في المجتمع .

يقدر على جني ثمار استئثاره ما لم يعترف له بسلطات أو صلاحيات معينة يتفاوت قدرها ومداها تبعا لطبيعة هذا الشيء أو تلك القيمة، فمن يملك عمارة أو شقة يستأثر بها حقا لكنه لا يتمكن من جني ثمار استئثاره لها إلا إذا خوَّله القانون التسلط عليها بحيث يتمكن من استعمالها واستغلالها والتصرف فيها، في حين أن التسلط الذي يرد على القيم اللصيقة بشخص الإنسان – مثل حقه في التنقل وحريته في العقيدة – محدود ومقيد بطبيعته، إذ لا يتصور مجاوزة التسلط الممنوح للإنسان للحدود المرسومة له حدود استعمالها، فمن غير المعقول أن يُمْنَحَ المرء حق التصرف في حريته أو أن يبيع أحد حقوقه اللصيقة بشخصيته مثل حقه في الحياة.

ويقصد بالاقتضاء أن صاحب الحق يقتضى من الناس كافة احترام استئثاره بقيم أو أشياء معينة، أي يطلب منهم الالتزام بعدم التعرض له في تسلطه عليها، وعدم إتيان أي عمل من شأنه الإضرار به في استئثاره وتسلطه[1].

ويوجد إلى جانب هذا الاقتضاء العام بالمعنى المتقدم، اقتضاء خاص يظهر في حق الدائنية، يتمثل في التزام المدين بأداء الدين الذي في ذمته لصالح الدائن، وهو التزام إيجابي إلى جانب الالتزام العام السلبي الذي يُلْقَى على عاتق الكافة فيلتزموا بمقتضاه بعدم الإضرار بحق الدائن لدى المدين.

ثالثا: غاية الحق مصلحة ذات قيمة اجتماعية يحميها القانون.

لا يكفي لقيام الحق أن يستأثر الشخص بشيء معين أو بقيمة معينة متسلطا عليها في مواجهة غيره، وإنما يلزم إلى جانب ذلك أن تثبت له الحماية القانونية المقررة لحماية هذا الحق، إذ أنه من المتصور أن يثبت لشخص ما الاستئثار والتسلط على شيء معين دون أن يعد صاحب حق عليه لعدم ثبوت

---

[1] أ.د/ الوكيل بند ١٨٦، ص ٣٠٣ .

الحماية القانونية المقررة قانونا لحقه على هذا الشيء، كما لو كان سارقا أو مغتصبا لهذا الشيء، فعلى الرغم من أن لكل منهما الاستئثار المادي على هذا الشيء إلا أنه لا تتوافر لحقه الحماية القانونية، ومن ثم لا يعد أي منهما صاحب حق على ما يستأثر به من أشياء.

والحماية القانونية لا تتقرر إلا إذا كانت المصلحة ذات قيمة اجتماعية جديرة بالاحترام والحماية، فإذا كانت المصلحة التي يسعى الشخص إلى تحقيقها من استئثاره بالشيء وتسلطه عليه مشروعة بأن كانت متفقة مع المصلحة العامة، فإنها تكون جديرة بالحماية القانونية وإلا فلا.

وتنصرف الحماية القانونية إلى إقرار استئثار صاحب الحق وما يخوله له هذا الاستئثار من ميزات، بحيث يكفل له القانون القدرة على مباشرة جميع السلطات اللازمة لتحقيق إنفراده بالشيء أو بالقيمة، فمثلا تتحقق الحماية القانونية لمالك الشيء عندما يكفل له القانون القدرة على مباشرة جميع سلطات المالك عليه.

والقانون إذ يقر استئثار الشخص فإنه يمنحه أيضا وسيلة الدفاع إذا ما أُعتدي على حقه أو كان مهدداً فيه بالاعتداء، عن طريق الدعوى أو الدفع أمام القضاء، بيد أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الدعوى أو الدفع هما من وسائل حماية الحق ولذا فهما لا يدخلان في عناصر وجود الحق، فثمة فرق بين الحماية القانونية التي هي عنصر في وجود الحق وبين وسائل هذه الحماية [1] .

المطلب الثاني

تمييز الحق عن غيره

بعد أن عرفنا معنى الحق يجدر بنا أن نميزه عما قد يختلط به من

---

[1] انظر في هذا المعنى إلى: أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٧٦ .

مصطلحات وألفاظ قد تقترب منه أو تتشابه ظاهريا معه دون أن تعد من قبيل مرادفاته ومعانيه.

أولا: الفرق بين الحق والمصلحة:

الحق Le Droit أمر يختلف عن المصلحة L'intérêt ، صحيح أن كل حق ينطوي على مصلحة ولكن ليست كل مصلحة جديرة بأن ترقى إلى مصاف الحق ، يمكن أن تدخل في عداد الحقوق، فالمصلحة هي الغرض العملي من الحق أو هي الهدف من الحق لكنها ليست الحق ذاته، فالهدف أمر خارج عن الذات لأنه يسبقه، وما دامت المصلحة هي هدف الحق فلابد والحالة هذه أن يكون الحق شيئا آخر مختلفا عن هدفه ، فمثلا نجد أن حق الإنسان في الحياة شيء والاستمتاع بالحياة الذي هو هدف هذا الحق شيء آخر [1] ، فلا يجوز من ثم الخلط بين الشيء وهدفه.

هذا فضلا عن أنه قد توجد في الحياة بعض المصالح المشروعة ولكنها لا يمكن أن ترقى إلى مصاف الحقوق، مثال ذلك مصلحة من يحصل على نفقة شهرية من آخر لإعانته على متطلبات الحياة وضرورياتها دون أن يكون ملزما قانونا بالإنفاق عليه، فعلى الرغم من أن مصلحته في الحصول على هذه النفقة مصلحة مشروعة يقرها القانون إلا أنها لا ترقى إلى مصاف الحق الذي يوفر القانون لصاحبه وسائل الحصول عليه، فلا يملك أن يدعى أن له حقا في هذه النفقة فيطلب من القضاء الحكم له بها وعدم قطعها أو التعويض عنها.

ثانيا: الفرق بين الحق والسلطة:

يختلف الحق Le droit عن السلطة Le pouvoir، فالسلطة عنصر

---

[1] انظر في نفس المعنى إلى: أ.د/ عبد الحي حجازي : مذكرات في نظرية الحق" ص ١٩ طبعة عام ١٩٥١، مطبعة دار الكتاب العربي، أ./ نعمان جمعة –المرجع السابق– ص ٢٩١ .

أصيل في الحق، فلا يمكن وجود الحق بدون سلطة، في حين أنه قد توجد سلطة للشخص دون أن يكون له حق مثل سلطة الوصي أو النائب، هذا فضلا عن أن الحق دائما يقابله واجب على شخص آخر، بخلاف السلطة فقد لا يقابلها واجب، بل قد يحدث أن يوجد الواجب على عاتق صاحب السلطة نفسه، وفي هذه الحالة تعتبر السلطة وسيلة لتنفيذ هذا الواجب مثل سلطة الوالد على ولده فهي تمكنه من القيام بواجب العناية بولده وتهذيبه وتثقيفه [١] .

ومن ناحية أخرى فإن السلطة تختلف عن الحق من حيث الإرادة، ذلك أن الحق لا يلزم فيه الإرادة ، فالمجنون والصبي غير المميز يصلحان لاكتساب الحقوق بخلاف السلطة فتلزم فيها الإرادة، وبناء عليه لا يملك الصبي غير المميز أو المجنون مباشرة السلطات التي تنشأ عن هذه الحقوق، وإنما ينوب عنه في ذلك وليُه أو وصيُه أو القيم عليه .

ثالثا: الفرق بين الحق والمكنة:

إن ثمة فرقا كبيرا بين الحق La droit والمكنة La faculté، فالمكنة هي الميزة التي ينطوي عليها الحق وليست هي الحق ذاته، ففي حق الملكية يكون للمالك مكنة الانتفاع مباشرة بالشيء المملوك له، وفي الحق الشخصي يكون للدائن مكنة مطالبة المدين بالدين [٢] .

هذا فضلا عن أن الحق ذو طابع مستقل فهو ينشأ من العلاقة القانونية ثم يستقل عنها بعد ذلك ليصير له كيان مستقل عنها مثال ذلك حق الملكية ينشأ عن عقد البيع ثم بعد ذلك يصير ذا وجود مستقل عن هذا العقد، بخلاف المكنة فهي لا تنشأ عن العلاقة القانونية وإنما تنشأ عن الحق وتبقى وتنقضي ببقائه وانقضائه

---

[١] أ.د/ عبد الحي حجازي – المرجع السابق– ص ١٩ .

[٢] أ.د/ عبد الحي حجازي – المرجع السابق– ٢٠،٢١ .

فهي تدور مع الحق وجودا وعدما.

رابعا: الفرق بين الحق والحالة الشخصية.

إن ثمة اختلافا بين الحق Le droit والحالة الشخصية L'état personnel، فالحالة الشخصية هي صفة قانونية دائمة بحسب الأصل، تتوافر في الشخص وينشأ له منها حقوق، بل وواجبات في بعض الأحيان، فهي ليست حقا إذن، ولكنها مصدر للحق، مثال ذلك أن يكون الشخص زوجا، فهذه حالة شخصية يتفرع عنها بعض الحقوق وبعض الواجبات، إذ ينشأ له حق الطاعة على زوجته وينشأ عليه واجب الإنفاق على زوجته [١].

خامسا: الفرق بين الحق ومجرد الأمل.

يوجد فرقٌ بين الحق Le droit ومجرد الأمل La simple expectative ، فالأمل حق ناقص أو حق في دور التكوين أو حق ينقصه أحد عناصر وجوده [٢].

ولنضرب أمثلة لإيضاح الفارق بين الحق ومجرد الأمل، فالوارث بعد موت مورثه يكون له حق على ما تركه المورث من أموال بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا ، أما قبل موت المورث فليس له على أموال قريبه سوى مجرد الأمل فحسب في أن يكون له عليها حق في المستقبل إن بقى حيا وتوفي قريبه قبله واستوفى شروط الإرث منه ، كذلك الحال لو أن شخصا تبرع لآخر بشئ معين فقد صار المتبرع له صاحب حق على المال المتبرع به ، لكن يختلف الأمر إذا علق تبرعه هذا على نجاح أحد أبنائه أو رجوعه سالما من ميدان القتال، فلا يكون

---

[١] أ.د/ عبد الحي حجازي – المرجع السابق– ٢٠،٢١ .

[٢] أ.د/ عبد الحي حجازي –المرجع السابق– ص ٢١ .



للشخص خلال فترة التعليق سوى مجرد الأمل في الحصول على الشيء الموعود بالتبرع به عند تحقق الشرط، كما أن واضع اليد على عقار مملوك لغيره بنية تملكه ليس له قبل اكتمال مدة التقادم المكسب سوى مجرد الأمل في كسب ملكيته، ولا يصير صاحب حق عليه إلا بعد اكتمال هذه المدة.

الباب الأول

الشخصيــة القانونيــة

الباب الأول

الشخصيــة القانونيــة

تمهيد :

القانون ما هو إلا خطاب يحمل معنى الأمر أو النهي لتوجيه سلوك الأشخاص وتنظيم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ومن ثم لا يتصور أن يوجه خطاب القانون إلى الأشياء، وإنما يوجه إلى الأشخاص.

ولفظ الشخص إذا أطلق في اللغة الدارجة انصرف الذهن مباشرة إلى الإنسان فقط، في حين أن لفظ الشخص في القانون أوسع مدى حيث يضم إلى جانب الإنسان أو الشخص الطبيعي ما يسمى في القانون بالشخص المعنوي أو الشخص الاعتباري وهو عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات.

فالشخصية القانونية هي صفة يضفيها القانون على أي كيان ليصير بموجبها أهلاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، والقانون كما يستطيع أن يضفيها على الإنسان يستطيع أيضا أن يضفيها على مجموعات الأشخاص أو مجموعات الأموال.

فلقد فرضت مظاهر التقدم الإنساني على واضع القانون ألا يقصر الشخصية القانونية (أي أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات) على الأشخاص الطبيعيين فقط، وإنما يعترف بها أيضا لمجموعات الأشخاص الذين يجتمعون فيما بينهم لتحقيق أغراض مالية أو إنسانية فتتولد من تجمعهم هذا وحدة أو كيان له وجود مالي وسياسي مستقل عن وجود كل واحد من هؤلاء الأشخاص، أو لمجموعات الأموال التي ترصد لتحقيق غاية معينة فيصبح لها كيان مستقل عن كيان الأشخاص الذين قدموا هذه الأموال.

وبذلك سنقسم هذا الباب إلى فصلين، نتناول في الفصل الأول كل ما يتعلق بالشخص الطبيعي، ثم نتكلم في الفصل الثاني عن الشخص المعنوي.

الفصل الأول

الشخـص الطبيعـي

تمهيد :

الشخص الطبيعي هو الإنسان، فكل إنسان يتمتع بالشخصية القانونية لأنه أهل للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات، حتى وإن كان مجنوناً أو صبياً غير مميز، ولم يكن الرقيقُ شخصاً في نظر القانون قديما لأنه لم يكن صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، وإنما كان ينظر إليه نظرة دونية بوصفه مثل غيره من الأشياء التي ترد عليه الحقوق فيصير محلاً لها فيباع ويشترى ويتبرع به أو يُعار لشخص ما من الأشخاص.

وإذا كان القانون الآن يثبت الشخصية القانونية لكل الأشخاص الطبيعيين فلا يحرم أحدا منهم من ثبوتها له بسبب الجنس أو الدين أو غير ذلك من الأسباب، إلا أن نطاق هذه الشخصية القانونية ومداها (أي مدى الواجبات والحقوق التي تثبت له) يتفاوت فيما بينهم تبعا لاختلاف الحالة الطبيعة (أي الجنس) والحالة السياسية (الجنسية) والحالة الدينية (أي الدين) والحالة العائلية (أي مركز الشخص من أسرته التي ينتمي إليها) الخاصة بكل واحد منهم.

وسنقسم هذا الفصل إلى عدة مباحث، نذكر في المبحث الأول النطاق الزمني للشخصية الطبيعية لنتعرف على بدايتها ونهايتها، ثم نتناول في المبحث الثاني مميزات الشخص الطبيعي التي تعيننا على التعرف على المركز القانوني

لكل شخص وتحديد نطاق شخصيته، ثم نعرض في المبحث الثالث لمدى قدرة الإنسان وصلاحيته لمباشرة الحقوق وأداء الواجبات وهي ما تسمى بأهلية الأداء، ونتكلم في المبحث الرابع عن الذمة المالية للشخص الطبيعي، وأخيراً نتناول أحكام الولاية على المال في مبحث خامس.

المبحث الأول

النطاق الزمني للشخصية الطبيعية

لقد نظم القانون النطاق الزمني للشخصية الطبيعية فحدد لها بدايتها ونهايتها بوصف عام، فضلا عن بيانه لما يرد عليها من استثناءات، حيث نصت المادة ٢٩ من التقنين المدني المصري الحالي على أن "١- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته". "٢- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون".

كما نصت المادة ٣٢ من ذات التقنين على أن "يسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية".

أولا: بداية الشخصية الطبيعية :

تبدأ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي فيصير أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات بتمام ولادته حيا (م ٢٩/ ١ مدني)، ومن ثمَّ لا تثبت الشخصية القانونية للإنسان بوصف عام إلا بتوافر هذين الشرطين:-

١- الشرط الأول: تمام ولادته: أي ضرورة أن ينفصل المولود عن بطن أمه انفصالاً كاملاً أو تاماً، فلا يكفي مجرد خروج الرأس أو خروج معظم أجزائه، بل يلزم خروجه كله، فإن خرج أكثره حياً ثم مات قبل خروجه كاملاً فلا يعدُ شخصاً

ويعامل وكأنه خرج ميتاً فلا يرثُ شيئاً [1] .

٢- الشرط الثاني:

ثبوت الحياة: لا يكفي لثبوت الشخصية القانونية للمولود مجرد انفصاله عن بطن أمه انفصالا تاماً وكاملاً، ولكن يلزم إلى جانب ذلك أن ينفصل حياً لا ميتاً، فيلزم أن تثبت له الحياة ولو للحظة واحدة عقب الولادة حتى وإن مات بعدها مباشرة، كي يصير أهلاً اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات.

ويستدل على حياة المولود ببعض العلامات الظاهرة مثل الاستهلال (أي الصراخ أو البكاء) أو الحركة أو التنفس، فإن تعذر التيقن من حياته بأحد هذه العلامات الظاهرة، فإنه يستعان برأي أهل الخبرة من الأطباء الشرعيين لمعرفة مدى انفصاله عن بطن أمه حياً أو ميتاً.

ولقد أوجب قانون الأحوال المدنية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠م على الوالد الإبلاغ عن المولود إن كان حاضراً ، فإن لم يكن حاضراً وجب الإبلاغ على من حضر من أقاربه البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المولود، فإن لم يكن أحدهم حاضراً فعلى من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث، فإن لم يكن فعلى العمدة أو مديري المؤسسات مثل المستشفيات ودور الولادة، ويوجه البلاغ إلى مكتب الصحة المختص أو العمدة خلال ثمانية أيام من تاريخ الولادة.

ويتم إثبات الولادة بحسب الأصل بموجب السجلات الرسمية المعدة لذلك

---

[1] انظر في ذلك إلى: أ.د/ عبد الحي حجازي ص ٨٨، أ.د/ العطار ص ٣٢٢ ، أ.د/عبد المهيمن بكر " القسم الخاص في قانون العقوبات" ،ص ١٧٢ ، طبعة عام ١٩٦٨م ، دار النهضة العربية ، أ.د/محمود مصطفي "شرح قانون العقوبات" القسم الخاص ، رقم ٢٦٠، ص٢٩٤، وللمؤلف "مراحل نمو الجنين ومظاهر الحماية القانونية المقررة له" ، ص ١٢٠،١٢١ ، طبعة عام ٢٠٠٣م .

مثل شهادة الميلاد، فإن تعذر وجودها جاز لذوي الشأن إثبات واقعة الولادة بوصفها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات (م٣٠ مدني) مثل شهادة الطبيب الذي أجرى الولادة أو شهادة القابلة أو شهادة من حضر واقعة الولادة من النساء .

ثبوت الشخصية القانونية للجنين على سبيل الاستثناء:

إذا كان الأصل العام –كما رأينا آنفا– أن الشخصية القانونية لا تثبت للإنسان إلا بتمام ولادته حيا، إلا أن القانون قد اعترف صراحة للجنين الذي لم يزل في بطن أمه بالشخصية القانونية خروجا على هذا الأصل العام (م ٢٩/ ٢ مدني) لاكتساب بعض الحقوق، على أساس أن الجنين وإن كان حقا لا يزال جزءا من أمه ينتقل بانتقالها ويقر بقرارها كأنه عضو من أعضائها، إلا أنه من وجه آخر كائنٌ مستقلٌ عنها لأنه منفردٌ بالحياة بداخلها وهو في الطريق إلى الانفصال عنها ليصير إنسانا قائما بذاته، لذلك فقد حماه القانون بأن جَرَّمَ الاعتداء عليه بإجهاضه ولو برضاء أمه ، كما رتب له بعض الحقوق مثل حقه في ثبوت نسبه من أبيه واكتساب جنسيته، وحقه في استحقاق ما يوصى به إليه ، وحقه في الميراث، إذ يوقف للحمل من تركه المتوفى أوفر النصيبين على فرض أنه ذكر أو أنثى، فإن نقص ما أوقف له عما يستحقه كما لو كان الجنين توأمين ذكرين ، فعندئذ يُرْجَعُ له بحقه على أولئك الورثة الذين دخلت الزيادة في أنصبائهم، وإن زاد الموقوف للحمل عما يستحقه جرى رد هذه الزيادة إلى من يستحقها من الورثة [1].

وتظل هذه الحقوقُ سالفةَ الذكر رهينةً بتمام ولادة الجنين حياً فإن ولد حياً استقرت حقوقه السابقة له، إما إن ولد ميتاً زالت شخصيتُه منذ وقت الحمل بأثر رجعي وتم توزيعُ ما أُوقف له على باقي الورثة، وبذلك تبدو الشخصيةُ القانونيةُ الثابتةُ للجنين قبل ولادته وكأنها شخصيةٌ مقترنةٌ بشرط فاسخ ألا هو شرط ولادته

[1] انظر للمؤلف بحث بعنوان "ماهية الحقوق المدنية للجنين" ،ص ١٣٨ ، طبعة عام ٢٠٠٥م .

ميتاً [1].

ثانيا: انتهاء الشخصية القانونية:

تنتهي الشخصية القانونية بموت الإنسان، فبحدوث الموت الفعلي يتجرد المرء من شخصيته التي هي مناط اكتسابه الحقوق وتحمله بالواجبات. ، وقد كان الرأي مستقراً قديما بين الأطباء على ثبوت الموت بتوقف ضربات القلب أو أجهزة التنفس عن أداء وظائفها، ثم صار الآن الاستدلال على الموت قائما على ثبوت موت خلايا المخ أو ما يعرف بموت الدماغ . ويراعى عند الشك في حدوث الوفاء أن يجري الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة من الأطباء الشرعيين للتيقن من حصول الموت أو عدم حصوله .

وبثبوت الموت فعلا تزول الشخصية القانونية للإنسان، ولا يستقيم القول ببقائها حكما بعد موته قياساً على افتراض شخصية الجنين قبل أن يوجد في الحياة، لتبرير بعض الآثار القانونية بالنسبة للميت مثل قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون، بحجة أن افتراض بقاء شخصية الميت أمرٌ تقتضيه هذه القاعدة، نظرا لأن أمواله لا تؤول إلى ورثته إلا بعد سداد الديون، وقد يستغرق سدادُ الديون فترة طويلة من الزمن، لذلك كان لزاما أن يفترض امتداد شخصيته رغم وفاته إلى حين سداد ديونه حتى لا تكون أموالُه في الفترة ما بين الوفاة وسداد الديون بغير مالك وهذا مما لا يجوز [2].

وأعتقد أن هذا القول مع وجاهته محل نظر، لأن قياس المتوفى على الجنين بافتراض بقاء شخصية المتوفى قياسا على افتراض ثبوت الشخصية للجنين

---

[1] انظر في نفس المعنى: أ.د/ العطار بند ١٥١، ص ٣٢٦، ٣٢٧، أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٢٣ .

[2] أ.د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، جـ١، فقرة ١٤، أ.د/ عبد المنعم فرج الصدة "نظرية الحق في القانون المدني الجديد"، فقرة ١٤٥، طبعة عام ١٩٥٠ .

وهو لم يزل في رحم أمه رغم عدم وجوده في الحياة قياس مع الفارق ، لأن الجنين وإن لم يخرج إلى الحياة بعد إلا أنه موجودٌ حقيقة في بطن أمه بعكس الشخص المتوفى فهو غير موجود حقيقةً ، هذا فضلا عن أنه من الممكن بسهولة معالجة مشكلة بقاء أمواله بعد موته بغير مالك في الفترة ما بين الوفاة إلى وقت سداد الديون بسبب قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون بعيدا عن مجال الافتراض والخيال (أي بافتراض امتداد شخصية المورث رغم موته إلى وقت سداد الديون) من خلال القول بأن أموال المورث تنتقل إلى ورثته فور موته محملة بما عليها من ديون على ألا يسأل هؤلاء الورثة عن هذه الديون إلا في حدود هذه التركة، وبذلك يستقيم القول فتزول شخصية المرء بموته وفي نفس الوقت لا تكون أمواله وتركته بغير مالك إذ تنتقل إلى ورثته محملة بالديون التي عليه.

ولقد أوجب القانون (قانون الأحوال المدنية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠م) على عاتق من حضر الوفاة من أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه أو أقاربه البالغين الذكور ثم الإناث، الإبلاغ عن واقعة الوفاة إلى مكتب الصحة المختص خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ حصولها، فإن لم يكن أحد هؤلاء الأقارب سالفي الذكر حاضرا الوفاة، وجب الإبلاغ على عاتق من كان يقطن مع المتوفى في مسكن واحد وإلا فالعمدة ثم الطبيب.

ويتم إثبات الوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك مثل شهادة الوفاة، فإن تعذر ذلك جاز إثباتها بأية طريقة أخرى مثل محضر التحقيق في الحادث التي تُوفي فيها الشخص أو شهادة الحانوتي الذي قام بدفنه أو غيرها من الطرق الأخرى، نظرا لأن واقعة الوفاة – مثل واقعة الميلاد– واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

بيد أنه إذا كانت شخصية الإنسان لا تنتهي إلا بموته الحقيقي أو الفعلي

بصفة عامة، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه يدور حول معرفة مدى بقاء أو زوال هذه الشخصية القانونية عمن خرج من بيته غائبا لأي سبب من الأسباب فانقطعت أخباره ولم تُعْرَفْ له حياةٌ من ممات؟

لا مراء في أننا لو طبقنا الأصل العام سالف الذكر على مثل هذا التساؤل لكان الحكم أن مثل هذا الشخص رغم غيابه وفقده يظل محتفظا بشخصيته القانونية فلا تزول عنه إلا بثبوت موته حقيقة وفعلا، غير أن تطبيق مثل هذا الحكم لن يخلو من المضار الجسيمة على أسرته وماله لاسيما إذا طالت غيبته ولم يستدل على حقيقة أمره لتعرف حياته من مماته، لذلك فقد أراد القانون وضع حد لهذه المشكلة فأجاز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى القاضي ليصدر حكما بموت قريبهم المفقود رغم عدم التأكد من وفاته فعلا، ورتب على ذلك عددا من الآثار القانونية، وبذلك تزول عنه شخصيته على سبيل الاستثناء خلافا على القاعدة العامة التي تقضى بأنه لا تنتهي الشخصية القانونية إلا بموته حقيقة أو فعلاً، فما هي حقيقة المركز القانوني للمفقود في القانون المصري؟.

الوضع القانوني للمفقود :

عرفنا فيما سبق أن المفقود هو شخص غائب انقطعت أخباره فلم تعرف له حياة من ممات، ولقد أحال واضع التقنين المدني المصري الحالي في تنظيم الوضع القانوني للمفقود إلى الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن تعذر وجودها تعين الالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية (م ٣٢ مدني [١])، ويقصد بالقوانين الخاصة، القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية(المعدل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٥٨، والقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢م

---

[١] حيث تنص هذه المادة على أن " تسرى في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .

، والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦م) وقانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢م.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض الوضع القانوني للمفقود يثير عدداً من التساؤلات الآتية:-

١- متى يحكم بموت المفقود:

فَرَقَ قانونُ الأحوالِ الشخصيةِ المصري في خصوصِ مدةِ الفقدِ اللازمةِ قبل الحكمِ بموتِ المفقودِ بين نوعين من الظروفِ في ضوءِ ما إذا كان يَغْلُبُ على هذه الظروفِ طابعُ الهلكةِ أم طابعُ السلامةِ ، وذلك على النحو الآتي :

أ- **الفقدُ في ظروفٍ يغلبُ عليها طابعُ الهلاكِ**

إذا كان فقد الشخص قد حدثَ في ظروفٍ أو ملابساتٍ يغلبُ عليها طابعُ الهلاك عادةً ، فقد فرقتْ المادةُ ٢١ من قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ المصري وهو القانونُ رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ م المعدلة بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ م والقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ م بين هؤلاءِ الأنواعِ الثلاثةِ من المفقودين في مثل هذه الظروفِ :

المفقودُ في ظروفٍ ظاهرُها الهلاكُ من غيرِ أفرادِ القواتِ المسلحةِ وفي غيرِ غرقِ سفينةٍ أو سقوطِ طائرةٍ :

إذا كان المفقودُ من غيرِ أفرادِ القواتِ المسلحةِ ولم يغرقْ في سفينةٍ ولم يسقطْ من طائرةٍ ، كما لو كان المفقودُ قد فُقِدَ في حربٍ غيرِ عسكريةٍ (مثال ذلك أن يُفْقَدَ في حربٍ أهليةٍ) ، أو فُقِدَ على إثرِ حدوثِ كارثةٍ طبيعيةٍ (كما لو حصلَ فيضانٌ أو زلزالٌ) ، فعندئذٍ لا يحْكُمُ القاضي بموتِه بناءً على طلبِ ذي المصلحةِ إلا إذا مضتْ على فقدِه أربعُ سنواتٍ على الأقلِ ، تأسيساً على أن استمرارَ غيبةِ المفقودِ

وانقطاعِ خبرِه طوالَ هذه الفترةِ في مثلِ هذه الظروفِ التي يترجحُ فيها عادةً ظنُ الموتِ على ظنِ الحياةِ يُعَدُ قرينةً قانونيةً على وفاتِه مما يُبرِرُ للقاضي الحكمَ بموتِه ليقطعَ دابرَ الشكِ حولَ حقيقةِ أمرِه منهياً بذلك حالةَ التعليقِ لمركزِه القانوني المتأرجحِ بين الحياةِ والموتِ [١] .

إذ تنصُ المادةُ ٢١ من قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ المصري وهو القانونُ رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ م المعدلة بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ م على أن " يُحْكَمُ بموتِ المفقودِ الذي يغلبُ عليه الهلاكُ بعدَ أربعِ سنواتٍ من تاريخِ فقدِه"[٢].

المفقودُ في ظروفٍ ظاهرُها الهلاكُ من بين أفراد القوات المسلحة وفُقِدَ في إحدى العملياتِ العسكريةِ

إذا كان المفقودُ من بينِ أفرادِ القواتِ المسلحةِ المصريةِ وفُقِدَ أثناء إحدى العمليات العسكرية ، فعندئذ ينعقدُ الاختصاصُ بإصدار قرار موته لوزير الدفاع المصري (وليس القاضي) وذلك بعد البحث والتحري عنه بكافة الوسائل الممكنة التي تُسَاعِدُ على معرفةِ حقيقةِ أمرِه إن كان حياً أو ميتاً ، ويصدر وزير الدفاع قراره

---

[١] د / حسن كيرة – المرجع السابق – بند ٢٦٦ ، ص ٥٣٢ ، د / محمد حسين عبد العال " المدخل لدراسة القانون البحريني " ص ٣٤٤ ، الطبعة الأولى عام ٢٠٠٤ م ، مطبعة جامعة البحرين ، د / خالد جمال أحمد حسن " المدخل في مبادئ القانون البحريني " ص ٣٣١ ، الطبعة الأولى عام ٢٠١٠ م ، مطبوعات جامعة العلوم التطبيقية ، تنفيذ الطباعة لمكتبة فخراوي للدراسات والنشر – مملكة البحرين .

[٢] إذ تنص المادة ٢١ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مستبدلة بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ ، ثم استبدلت بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ واستقرت على ما يلي " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي .على إلا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة إلى معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتاً " .

باعتبار هذا المفقود ميتاً موتاً حكمياً بعد مضي سنة من تاريخ هذا الفقد .

وقد علقَ واضعُ القانون في المذكرةِ الإيضاحيةِ للقانونِ رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٨م على إسنادِ الاختصاصِ في هذا الفرضِ لوزيرِ الدفاعِ وليس للقاضي برغبتِه في توفيرِ الجهدِ المادي على زوجاتِ المفقودين من العسكريين الناجمِ عن انتقالِهم إلى ساحاتِ المحاكمِ وتجنيبِهم ما قد ينشأُ عن ذلك من أسى ولوعةٍ وإثارةِ شجونٍ كامنةٍ في نفوسِهم [1].

المفقودُ على ظهرِ سفينةٍ غرقتْ أو طائرةٍ سقطتْ

إذا كان المفقودُ قد فُقِدَ على ظهرِ سفينةٍ غرقتْ أو على متنِ طائرةٍ سقطتْ سواء كان عسكرياً أو مدنياً ، مادامَ أن ذلكَ لم يحدثْ في إحدى العمليات العسكرية انعقدَ الاختصاصُ بإصدارِ قرارٍ بموتِه لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ أو لوزير الدفاع (وذلك بحسب كون المفقود عسكرياً أو مدنياً) وليس للقاضي ، وهذ ما نصتْ عليه الفقرةُ الثانيةُ من المادةِ ٢١ من القانونِ رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بعد تعديلِها بالقانونِ رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ م بقولِها " ويعتبرُ المفقودُ ميتاً بعد مضى مدةِ خمسةِ عشر يوماً على الأقل من تاريخِ فقدِه ، في حالةِ إذا ثبتَ أنه كان على ظهرِ سفينةٍ غرقتْ أو كان في طائرةٍ سقطتْ ..... " ، وإسنادُ الاختصاص ههنا لرئيسِ الوزراءِ وليس للقاضي من شأنِه دون أدنى شك أن يجنبَ أهلَ المفقودِ وذويه مشآقَ الالتجاءِ إلى المحاكمِ وما يغلبُ على إجراءاتِ التقاضي أمامها من طابعِ البطءِ الشديدِ ، الذي كثيراً ما يثبطُ همَ الراغبين في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه .

وبطبيعة الحال لا يصدرُ القرارُ من رئيس مجلس الوزراء أو من وزير الدفاع

---

[1] راجع في ذلك : د / محمد حسام محمود لطفي – المرجع السابق – ص ١١١ .

باعتبار هذا المفقود ميتاً إلا بعد مضي خمسةَ عشر يوماً من تاريخِ فقدِه وبعدَ اتخاذِ كلِ ما يلزمُ من الإجراءاتِ والوسائلِ اللازمة للتحري والبحثِ عن حقيقةِ أمرِه على إثرِ غرقِ السفينةِ أو سقوطِ الطائرةِ ، وهذا ما نصتْ عليه المادةُ ٢١ سالفة الذكر بعد آخر تعديل لها بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ م بقولها " ويصدرُ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ أو وزيرُ الدفاعِ بحسبِ الأحوالِ وبعدَ التحري واستظهارِ القرائنِ التي يغلبُ معها الهلاكُ قراراً بأسماءِ المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكمِ الفقرةِ السابقةِ . ويقومُ هذا القرارُ مقامَ الحكمِ بموتِ المفقودِ " .

ويراعى أن المادة ٢٢ من قانون الأحوال الشخصية المصري (المستبدلة بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢م) لم ترتب أثراً على حالة الفقد ولو بعد مضي المدة المحددة قانوناً لذلك إلا بدءاً من تاريخ صدور الحكم القضائي أو نشر القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، وتطبيقاً لذلك تنص هذه المادة على أنه " عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار من وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى " .

ويستفاد من النص سالف الذكر أنه يكفي في الحكم القضائي كي يؤتي أثره في اعتبار المفقود ميتاً مجرد صدوره دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر لاحق عليه كنشره مثلاً في الجريدة الرسمية ، في حين لم يعتد بالقرار الإداري الصادر باعتبار المفقود ميتاً بمجرد اتخاذه من صاحب الاختصاص بإصداره ، إنما يلزم نشره في الجريدة الرسمية ، وليس هناك مطعن – في اعتقادي في رأيي– على اشتراط هذا الإجراء في حد ذاته ، وإنما يعاب على هذا النص أنه لم يحدد موعداً معيناً يلزم فيه مصدر هذا القرار الإداري أو جهة إدارية أخرى بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنشره في الجريدة الرسمية خلالها ، ضماناً لعدم تلكأ الجهة المختصة في

مباشرة هذا الإجراء على نحو يضر بورثة المفقود .

وبناء عليه ننادي مع البعض بضرورة التدخل لتحديد مدة معينة يلزم خلالها نشر القرار الإداري الصادر باعتبار المفقود ميتاً ، بل ويتعين أيضا تقرير جزاء قانوني صارم يوقع عند التأخير في إجراء هذا النشر ،وفي ذلك حماية فاعلة لذوي المفقود تسهم في سرعة تمكينهم من الحصول على حقوقهم دون إبطاء[1].

ب- <u>مدةُ الفقدِ في ظروفٍ يغلبُ عليها طابعُ السلامةِ</u>

أما إذا كانَ اختفاءُ المفقودِ وغيبتُه في ظروفٍ يغلبُ عليها طابعُ السلامةِ (أي لا يغلبُ عليها الهلاكُ عادةً) أي أنها ظروفُ يترجحُ فيها رغم انقطاعِ أخبارِ المفقودِ بقاؤه حياً وسالماً على موتِه وهلاكِه ، كما لو ثبتَ أنه شخصٌ خرجَ من بيتِه إلى داخلِ وطنِه أو خرج من وطنِه إلى بلدٍ آخر خارجِه من أجلِ التجارةِ أو طلبِ العلمِ أو السياحةِ ، ثم انقطعتْ أخبارُه ولم يُسْتَدلْ له على موطنٍ أو محلِ إقامةٍ ، ولم تُعْرَفْ له في نفس الوقت حياةٌ من مماتٍ ، فعندئذٍ يُتْرَكُ للقاضي أمرُ تقديرِ المدةِ التي يترجحُ له بعدَها رجحانُ موتِ المفقودِ على حياتِه وذلك في ضوءِ ما يثبتُ أمامَه من الأماراتِ والقرائن .

ولم يكنْ القانونُ قبلَ التعديلِ الذي جَرَى عام ١٩٩٢م يقيدُ حكمَ القاضي بمدةٍ معينةٍ في هذا الفرضِ تاركاً له كامل السلطةِ التقديريةِ في أمرِ تحديدِها ، غير أن الفقه رغم ذلك كان يدعو آنذاك إلى ضرورة أن يُفْرض قيدٌ منطقيٌ على سلطة القاضي التقديرية مؤداه ألا يحْكم القاضي بموتِ المفقودِ في مثلِ هذه الظروفِ الآمنةِ قبل مضي أربعِ سنواتٍ ، تأسيساً على أنه إذا كانتْ هذه المدةُ هي المدة

---

[1] د / محمد حسام محمود لطفي – المرجع السابق – ص ١١٢ ، حيث يقول سيادته " ..... حيث إن النشر لا يتم للأسف بصورة تلقائية ، فقد يتم بعد مرور مدة طويلة ، وهو ما يجعلنا ننادي بوضع جزاء على عدم النشر في خلال مدة زمنية معينة حتى لا تقع أسرة أسرة المفقود بين رحى بيروقراطية الإدارة " .

التي يُقيدُ بها القانونُ سلطة القاضي في التقديرِ في الظروفِ التي يغْلُبُ فيها الهلاكُ فإن تقييده بهذه المدةِ في الظروفِ التي لا يغْلُبُ فيها الهلاكُ يكون أولى وأظهر .

ثم جاءَ القانونُ رقم ٣٣ لسنة ١٩٩٢ مقنناً هذا القيدَ بقولِه " وفي الأحوالِ الأخرى يُفَوَضُ تحديدُ المدةِ التي يُحْكَمُ بموتِ المفقودِ بعدها إلى القاضي على ألا تقلُ عن أربعِ سنواتٍ وذلك بعد التحري عنه بجميعِ الطرقِ الممكنةِ الموصلةِ إلى معرفةِ إن كان حياً أو ميتاً " ، ثم جاءَ تعديلُ المادة ٢١ سالفة الذكر بالقانونِ رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ م متضمناً ذات القيدِ .

٢- <u>أثر الحكم أو القرار باعتبار المفقود ميتا</u>:

إذا صدر حكم باعتبار المفقود ميتا أو صدر قرار بذلك، أخذ المفقود حكم الميت موتا حقيقيا فتزول شخصيته من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار بالجريدة الرسمية بصفة عامة أو من تاريخ الفقد على سبيل الاستثناء، وذلك على التفصيل الآتي:

<u>أ- الأصل العام: اعتبار المفقود ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار.</u>

يعد المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته أو نشر القرار الصادر باعتباره ميتا في الجريدة الرسمية، نظرا لأن الحكم أو القرار يعد منشئا لهذا الموت الاعتباري وليس كاشفا له، ويترتب على ذلك نتيجتان:-

<u>- النتيجة الأولى</u>:

يظل المفقود إلى ما قبل صدور الحكم أو نشر القرار بموته محتفظا بشخصيته القانونية، ومن ثمَّ يبقى أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات خلال فترة غيابه إذ يرث من غيره فيوقف له نصيبه إلى أن يتضح أمره، كما يلزم بالإنفاق

على أسرته وأقاربه، وتظل رابطة الزوجية بينه وبين زوجته قائمة ما لم تطلب الطلاق للضرر من غيبته [١]، وتظل أمواله مملوكة له على أن تعين المحكمة وكيلا عنه لإدارة أمواله إذا لم يكن قد ترك وكيلا عنه ومضت على غيبته سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه (م ٧٤: ٧٦ من قانون الولاية على المال).

- النتيجة الثانية:

يعد المفقود ميتا فتزول شخصيته القانونية بدءا من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار باعتباره ميتا، فيعامل منذ ذلك الوقت معاملة الميت موتا حقيقيا، فتوزع أمواله على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار، وتزول رابطة الزوجية بينه وبين زوجته بحيث يحل لها أن تتزوج من غيره بعد انقضاء عدة الوفاة [٢]، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام [٣].

ب- الاستثناء: اعتبار المفقود ميتا من تاريخ الفقد:

لقد خرج واضع القانون على الأصل العام فاعتبر المفقود ميتا من تاريخ الفقد وليس من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار بموته في خصوص ما كان موقوفا له من إرث أو وصية، وذلك حتى يمكن رد هذا الموقوف من الإرث أو الوصية على

---

[١] حيث تنص المادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م على أنه "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه" .

[٢] وهذا هو ما نصت عليه المادة ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لعام ١٩٢٩م والمعدلة بالقانون رقم ٣٣ لعام ١٩٩٢م إذ تقول " عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على النحو المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو النشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى " .

[٣] وذلك عملا بقول الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ..... " آية رقم ٢٣٤ من سورة البقرة" .

من يستحقه من ورثة المورث أو الموصي الذين كانوا موجودين وقت موت المورث أو الموصي .

ذلك أننا لو طبقنا الأصل العام على ما أوقف للمفقود من إرث أو وصية لدخل هذا المال في تركته واستحقه مع باقي أمواله ورثته هو الموجودون وقت صدور الحكم أو نشر القرار، ويرجع هذا الاستثناء إلى أنه يشترط لاستحقاق الإرث أو الوصية تحقق حياة الوارث أو الموصى له وقت وفاة المورث أو الموصي، في حين أن حياة المفقود طوال فترة الفقد لم تكن إلا مجرد حياة احتمالية غير حقيقية فلا تكون من ثم كافية لاستحقاقه الإرث أو الوصية من غيره.

٣- أثر ظهور المفقود بعد الحكم بموته:

يُعابُ على قانون الأحوال الشخصية المصري إغفالُه أمر تنظيم أثر ظهور المفقود حياً بعد الحكم بموته على ما جرى توزيعُه من ماله بين ورثته ، رغم تنظيمهما لتأثير هذا الظهور على زوجة المفقود ، وهذا إغفالٌ غير مبرر ، غير أن الفقه والقضاء في مصر مستقرٌ على أنه إذا ظهر المفقودُ حياً كان له حقُ استرداد ما بقي في أيدي ورثته من مال تركته ، أما ما استهلكه الورثةُ من مال المفقود أو تصرفوا فيه أو أتلفوه فليس عليهم شيءٌ فيه ، إذ لا ضمان بغير تعدٍ ، والورثة لم يحدث منهم أي تعدٍ ، بل أخذوا هذا المال بسند شرعي وهو الإرث وبناء على حكم قضائي قضى باعتبار المفقود ميتاً [١] ، وهذا هو عين ما نصت عليه المادة ٤٥

---

[١] د / إسماعيل غانم " محاضرات في النظرية العامة للحق " ، ص ١٨٤ ، طبعة عام ١٩٦٦ م ، القاهرة ، د / حسام الدين كامل الأهواني " أصول القانون " ، بند ٥٠٩ ، ص ٤٥٧ ، طبعة عام ١٩٨٨ م ، القاهرة ، د / عبد الحي حجازي – المرجع السابق – بند ٥٨١ ، ص ٥٠٤ ، ٥٠٥ ، الشيخ / أبو زهرة " الأحوال الشخصية " بند ٣٩٧ ، ص ٥٣٠ ، طبعة عام ١٩٥٠ م ، بون دار نشر ، د / محمد حسام محمود لطفي – المرجع السابق – ص ١١٦ ، ١١٧، د / عبد الوهاب خلاف " أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية " ، بند ١٣٨ ، ص ٢٦٢ ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ نشر أو دار نشر ، د/عمر عبد الله " أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية " ص ٢٢٥ ، طبعة عام ١٩٥٦ م ، بدون دار نشر ، د/ حسن كيرة – المرجع السابق – بند ٢٦٨ ، ص ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، د / محمد حسين عبد العال – المرجع

من قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م ، إذ تقول " فإن ظهر (أي المفقود) حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة " .

بل إن من الفقه من ذهب – وبحق – إلى إلزام من تلقى مالاً عن مفقوده بأن يرد له إلى جانب ما بقي تحت يده من هذا المال ، ما اكتسبه من غيره بديلاً عن مال مفقوده أو ما أخذه من هذا الغير مقابلاً لهذا المال ، تحقيقاً لاعتبارات العدالة ، بحيث إذا كان الوارث الذي آل إليه ميراث المحكوم بموته قد قايض على ثمار مزرعة مفقوده بأدواتٍ للزراعة أو باعها نظير مبلغ نقدي معين ، فيحق للمفقود استرداد ما جرت المقايضة به وهي أدوات الزراعة أو المقابل النقدي وهو ثمن الثمار ، وذلك إعمالاً لفكرة الحلول العيني [١] .

أما بالنسبة لمن كانت زوجة للمفقود ، فإن لها لحق في إعادتها إليه قانوناً في أي من الحالات الآتية :

١- إذا عاد المفقود أو تبينت حياته وزوجته لم تتزوج بآخر .

٢- إذا عاد المفقود أو تبينت حياته وتزوجها آخر وهي لم تزل في العدة .

٣- إذا ظهرت حياة المفقود بعد أن عقد عليها غيره دون أن يدخل بها .

٤- إذا ظهرت حياة المفقود بعد أن عقد عليها غيره ودخل بها وهو عالم بحياة المفقود .

السابق – ص ٣٤٦ .

[١] د / محمد حسام محمود لطفي – المرجع السابق – ص ١١٧ .

وتطبيقاً لذلك تنص المادة ٨ من القانون المصري رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ م على أنه " إذا جاء المفقود أو لم يجيء وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول ، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول " .

وقد لاحظ البعض وبحق أن واضع القانون قد غفل عن مراعاة اعتبار جوهري عند المفاضلة بين الزوجين ألا وهو اعتبار الإنجاب ، بحيث يفضل من ولد له من الزوجة ولد على من لم يولد له ولد ، فإن تساويا في الإنجاب أمكن النظر إلى الاعتبارات الأخرى [١].

وتنطبق الأحكام السابقة سواء أكان المفقود رجلا أو امرأة ، غاية ما هنالك أنه إذا كان المفقود امرأة متزوجة ثم ظهرت حياتها فإنها ترجع إلى زوجها إذا لم يكن قد تزوج بغيرها أو تزوج بأخرى تعلم أنها حية أو كان للزوج حق في تعدد زوجاته [٢].

---

[١] أ.د/ إسماعيل غانم " محاضرات في النظرية العامة للحق ، ص ١٨٥ ، طبعة عام ١٩٦٦ م .

[٢] أ .د/عبد الناصر العطار ، بند ١٥٢،ص٣٢٩ .

المبحث الثاني

مميزات الشخص الطبيعي

تمهيد :

إن لكل إنسان شخصيته القانونية، ولهذه الشخصية خصائص ومميزات تميزه عن غيره من بني جنسه وتكشف النقاب عن معالم شخصيته، فلكل إنسان اسم يتميز به عن غيره، كما أن له حالة تحدد مركزه من الدولة أو الأسرة أو الدين، كما أن له موطنا يعرف من خلاله مكانه وإقامته.

المطلب الأول

اسم الشخص الطبيعي

أولا: تحديد الاسم وأهميته :

لا جرم أن الاسم هو العلامة أو العنوان الذي يميز الإنسان عن غيره من بني جنسه، لذلك تعين أن يكون لكل شخص اسم يميزه ويدفع عنه الاختلاط أو الاشتباه بغيره، فهو بذلك ضرورة للشخص نفسه من هذه الزاوية، كما أنه ضرورة أيضا للمجتمع الذي يعيش فيه، إذ لا يتصور تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع دون أن يكون لأفراده أسماء خاصة بهم تميزهم وتعين ذواتهم، وإلا صارت الحياة فوضى لا تستقيم فيها صور التعامل الإنساني سواء فيما بين الدولة وأفرادها أو فيما بين الأفراد بعضهم بعضا.

ويقصد بالاسم بوصفه أحد مميزات الشخصية الطبيعية الاسم بالمعنى الواسع الذي يشمل إلى جانب الاسم الشخصي أو الاسم الخاص للشخص Le prénom، اسم الأسرة أو العائلة Le nom de famille التي ينتمي إليها، والذي يشترك في حمله جميع أفراد الأسرة أو العائلة، ولا يقتصر على الاسم

بالمعنى الضيق الذي يقتصر على اسم الشخص وحده والذي يميزه عن غيره من أفراد الأسرة أو العائلة الواحدة [١]، وبذلك يتكون الاسم بمعناه الواسع من اسم الشخص واسم أبيه وجده، وقد يضاف إليه لقب الأسرة إن كان لها لقب[٢].

وجرت العادة في الدول الأوربية على أن تلقب الزوجة بلقب أسرة زوجها، ولكن يغلب في الشرق عامة وفي مصر خاصة احتفاظها باسم أبيها ولقب أسرتها، وهذا أدعى إلى الحق وأقرب إلى القسط، وصدق الله إذ يقول " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " [٣] لما فيه من إبقاء لنسبها الحقيقي واحتفاظ لكامل مقومات شخصيتها الإنسانية المستقلة عن زوجها [٤] .

والأصل أن يكتسب الشخص اسمه عند ولادته، حيث يوجب قانون الأحوال المدنية الإبلاغ عن اسم المولود عند إخطار مكتب الصحة المختص بواقعة ميلاده [٥]، وللوالدين أو من يقوم مقامهما مطلق الحرية في اختيار اسم المولود طالما أنه لا يتنافي مع فكرة النظام العام ، ويرخص القانون للشخص أن يغير اسمه وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً لذلك [٦].

---

[١] انظر في نفس المعنى: أ.د/ حسن كيره نبد ٢٧٧، صـ٥٤٦، ٥٤٧، أ.د/ نعمان جمعة صـ٤٢٧ .

[٢] حيث تنص المادة ٣٨ من التقنين المدني الحالي على أنه " يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده " وكان من مقتضى هذا النص أن يكون لكل شخص لقب إلى جوار اسمه، غير أن المادة ٣٩ من ذات التقنين نصت على أن " ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها " ولم يصدر هذا التشريع حتى الآن .

[٣] آية رقم ٥ من سورة الأحزاب .

[٤] انظر في نفس المعنى: أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٥٤، صـ٣٣٠ .

[٥] ولقد رتب القانون جزاء على من يتخلف عن واجبه في الإبلاغ عن واقعة الميلاد واسم المولود إلى مكتب الصحة المختص، حيث توقع عليه غرامة مالية لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات (م ٥٧ من قانون الأحوال المدنية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠) .

[٦] صحيح أن للمرء الحق في أن يغير اسمه ولكن يلزمه مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، ويتم التغيير بناء على طلب يتقدم به طالب التغيير إلى المحافظة التي ولد بدائرتها، ثم تقوم المحافظة بعد فحص الطلب بتحويله إلى وزارة الصحة، ويتم بعد ذلك الإعلان عن هذا التغيير بنشره في إحدى الجرائد اليومية فضلا عن

ثانيـاً: التكييف القانوني للاسم :

لقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للاسم، فمنهم من عده واجبا على أساس أنه أداة لازمة لتنظيم المعاملات واستقرارها داخل المجتمع، فضلاً عن كونه وسيلة للتمييز بين الأشخاص، ومنهم من اعتبره واجباً وحقاً في نفس الوقت (أما عن أساس وصفه بأنه واجب فمشار إليه في الرأي الأول، أما كونه حقا فمرده إلى أن للإنسان الحق في أن يتميز عن غيره باسم خاص به يكشف عن ذاته ونسبه) ولكنهم اختلفوا مع ذلك في طبيعة هذا الحق، فذهب البعض منهم إلى أنه حق من حقوق الأسرة، ولكنه رأي مردود لأن اللقيط له اسم رغم عدم وجود أسرة له .

وذهب البعض الآخر إلى أن الاسم حق ملكية يرد على شيء معنوي، وهذا رأي محل نظر أيضاً لأن الاسم لا تتوافر فيه خصائص حق الملكية، لأن حق الملكية يمكن للشخص أن يتصرف فيه أو يستغله بعكس الاسم فلا يجوز للشخص التصرف فيه أو استغلاله، لذلك فقد استقر الرأي على أن الاسم حق من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان إلى جانب كونه واجباً، فهو حق من الحقوق ذات الطبيعة المزدوجة أو المركبة [1].

ويترتب على كون الاسم واجباً وحقاً من الحقوق الشخصية الآثار الآتية:-

١- وجوب أن يكون للشخص اسم يميزه عن غيره.

تعليق نشرة بذلك على باب القسم أو المركز أو باب العمدة، ثم إذا لم يحدث اعتراض من أحد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر يعرض الأمر على المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها مكتب السجل المقيدة به واقعة ميلاد الشخص المراد تغيير اسمه، ويتم تغيير الاسم بصدور حكم نهائي من هذه المحكمة بذلك (م ٣٦ من قانون الأحوال المدينة رقم ٢٦٠ لسنة١٩٦٠م) .

[1] انظر في ذلك إلى: أ.د/ حسن كيره نبد ٢٨٠، ص٥٥٢ وما بعدها، أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٥٤، صـ٣٣١، ٣٣٢، أ.د/ الوكيل بند ١٩٩، صـ٣١٥، أ.د/ نعمان جمعة صـ٤٢٤ وما بعدها، أ.د/ توفيق حسن فرج صـ٢٣٢ .



٢- عدم جواز تغيير الاسم إلا بعد إتباع الإجراءات المقررة لذلك قانوناً، فلا تكفي مجرد رغبة الشخص في التغيير.

٣- عدم جواز التصرف في الاسم أو التنازل عنه لغيره، كما لا يجوز استغلاله بصفة عامة باستثناء الاسم التجاري (نظراً لأنه إذا أطلق اسم الشخص على محل تجارى أضحى هذا الاسم أحد عناصر المحل التجاري ومن ثَمَّ يمكن التصرف فيه بالتبعية للتصرف في المحل التجاري).

٤- عدم سقوط اسم الشخص بعدم الاستعمال أو مضى المدة.

ثالثـاً: أنــواع الاسم:

للاسم بوصفه أحد عناصر الشخصية الطبيعية صور مختلفة وأنماط متعددة، إذ أنه من المتصور أنه يكون للشخص إلى جانب اسمه الحقيقي الذي يكتسبه بطريق النسب منذ ولاته (والذي يتكون كما عرفنا آنفا عند الحديث عن تحديد الاسم من اسمه الشخصي مضافاً إليه اسم أبيه وجده)، أسماء أخرى، (مثل اسم الشهرة الذي يطلقه عليه الناس، والاسم المستعار الذي يخلعه هو على نفسه عند مباشرته بعض أنشطته، والاسم التجاري الذي يطلقه هو على محله التجاري فيصير بذلك أحد عناصر المحل التجاري الخاص به)، والتي سنعرض لها بشيء من التفصيل على النحو الآتي:-

١- اسم الشهرة Le surnom:

يقصد باسم الشهرة ذلك الاسم الذي يطلقه الناس على شخص معين خلافا لاسمه الحقيقي، فيشتهر به بينهم، وعادة ما يكون اسم الشهرة مشتقاً من جانب بارز من مقومات شخصية الإنسان أو من طبيعة نشاطه الإنساني الذي يمارسه في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم الشهرة متى أطلق على الشخص واشتهر به بين الناس، صار حقاً له وتمتع بكل وسائل الحماية القانونية المقررة للاسم الحقيقي، على أن يراعى أن اشتهار الشخص باسم الشهرة لا يؤدي إلى انقضاء حق الإنسان على اسمه العام أو الحقيقي [١].

٢- الاسم المستعـار: Le pseudonyme

يقصد بالاسم المستعار الاسم الذي يخلعه الشخص على نفسه ليخفي خلفه اسمه الحقيقي أثناء مباشرة عمل أو نشاط معين.

ويحدث عادة اللجوء إلى هذا الاسم المستعار بين طبقة الممثلين وبعض رجال الأدب والسياسة والصحافة لإضفاء نوع من الجاذبية على شخصيتهم، كما يلجأ إليه معظم رجال الدين غير المسلمين أو بعض الملوك لإضفاء نوع من المهابة والوقار على شخصياتهم [٢].

ويتضح لنا مما سبق أن الاسم المستعار يختلف عن الاسم الحقيقي وعن اسم الشهرة، فالاسم المستعار يخلعه الشخص على نفسه، في حين أن الاسم الحقيقي يكسبه الشخص عند الولادة بطريق النسب، واسم الشهرة يطلقه الناس على الشخص، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يستعمل الاسم المستعار لمباشرة عمل أو نشاط معين، في حين يستعمل الشخص اسمه الحقيقي أو اسم الشهرة في باقي الأنشطة الأخرى.

وهذا بالإضافة إلى أن الاسم المستعار لا يصدق عليه وصف الواجب من حيث طبيعته القانونية لأنه لو كان واجباً لأجبر الإنسان على أن يتخذ لنفسه اسماً

---

[١] أ.د/ نعمان جمعة صـ٤٢٨ .

[٢] أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٥٦، صـ٣٣٣ .

مستعار وهذا أمر غير متصور، ولكن يصدق عليه وصف الحق فهو من قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية، بخلاف الاسم الحقيقي فهو واجب وحق في نفس الوقت.

ويترتب على اعتبار الاسم المستعار من قبيل حقوق الشخصية ثبوت الحماية القانونية له، فيكون لصاحبه أن يدفع منازعة الغير له فيه ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر يلحقه من جراء هذه المنازعة، هذا فضلاً عن عدم جواز التصرف فيه أو التنازل عنه أو استغلاله، وعدم سقوطه بعدم الاستعمال أو بمضي المدة.

٣- الاسم التجاري: Le nom commercial

هو الاسم الذي يخلعه الشخص على محله التجاري فيضحى بذلك أحد عناصره ومكوناته المالية [١].

إذن لا يعد الاسم التجاري علامة مميزة لشخصية الإنسان ولكنه علامة مميزة لنشاطه التجاري، ومن ثمَّ فهو يدخل في عناصر ومقومات المحل التجاري فتثبت له صفة مالية مثل المحل التجاري، مما يجعله مختلفاً في خصائصه عن الاسم الحقيقي واسم الشهرة والاسم المستعار باعتبارهم حقوقاً لصيقة بالشخصية لا تقبل التصرف فيها، إذ يجوز التصرف في الاسم التجاري أو التنازل عنه بالتبعية عند التصرف في المحل التجاري أو التنازل عنه.

رابعـاً: الحماية القانونيـة للاسم :

لقد كفل القانون الحماية اللازمة للاسم بوصفه أحد مميزات الشخصية

---

[١] ويعرفه البعض بأنه هو الاسم الذي يتخذه شخص أو شركة أو أية مؤسسة تجارية لكي يتميز به المحل أو المنشأة. وقد يكون هذا الاسم هو اسم صاحب المحل أو المنشأة وقد يكون اسماً آخر. وفي جميع الحالات يعتبر الاسم التجاري عنصراً من عناصر المحل التجارى، ويدخل في تقويمه (أ.د/ توفيق حسن فرج صـ٢٣٣) .

الطبيعية، إذا ما وقع عليه اعتداء من جانب أي شخص، سواء أكان اسماً حقيقياً أم اسما مستعاراً أم اسم شهرة، فجعل للشخص الحق في دفع هذا الاعتداء باللجوء إلى القضاء طالباً كف الاعتداء عليه فيه، كما جعل له الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي يصيبه مادياً أو أدبياً من جراء هذا الاعتداء.

ويتخذ الاعتداء على الاسم إحدى صورتين إما المنازعة فيه أو انتحاله، ويقصد بالمنازعة في الاسم اعتراض الغير دون مبرر على حق الشخص في التسمي بالاسم الذي يحمله وفي استعماله له، أما الانتحال أو الإدعاء فيقصد به تسمى الغير باسم شخص معين واستعماله إياه بدون حق [١].

ولعل هذا هو ما نصت عليه المادة ٥١ من التقنين المدني الحالي بقولها " لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ".

المطلب الثاني

الحالــة L'état

يقصد بالحالة مجموع الصفات التي يتصف بها الشخص ويرتب القانون عليها آثاراً معينة [٢]. وتتحدد حالة الشخص ببيان نوعه أو جنسه (وهو ما يسمى

---

[١] أ.د/ حسن كيره نبد ٢٧٩، صـ٥٥٠، وقرب ذلك أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٥٥، صـ٣٣٢ .

[٢] أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٥٨، صـ٣٣٤، وقرب ذلك أ.د/ توفيق حسن فرج صـ٢٢٧ حيث يعرف الحالة بأنها " مجموعة من الصفات يدخلها القانون في الاعتبار ليعلقعليها آثاراً قانونية " وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بنفس المعنى قائلة إن الحالة هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات التي يرتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية، هذه الصفات قد تكون طبيعية (ذكورة وأنوثة) أو عائلية (زوجاً أو أرملا أو أباً أو أبناً) أو مدنية (من حيث اكتمال أهليته أو نقصانها أو تقييدها) أو دينية (ككون الإنسان مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً) أو سياسية (الجنسية والتوطن) أو حرفية (ككونه محامياً أو موظفاً أو عاملاً) نقض ٩٣٤/٦/٢١ مجموعة القواعد القانونية جـ١ صـ١١٧٧ مشار إليه لدى د/ محمد سعد خليفة " نظرية الحق " صـ٢٠٦ .

بحالته الطبيعية) وتحديد مدى انتمائه إلى دولة معينة (وهو ما يسمى بالحالة السياسية أو الجنسية) وتحديد مركزه داخل الأسرة التي ينتمي إليها (وهو ما يسمى بالحالة العائلية)ثم أخيراً تحديد مركزه من حيث كونه معتنقاً لديانة معينة (وهو ما يسمى بالحالة الدينية) .

أولاً: الحالة الطبيعية أو الجنس:

لا شك أن الشخص يتميز بجنسه أو نوعه، أي بحسب كونه ذكراً أو أنثى.

ثانيـاً: الحالة السياسية أو الجنسية: **La nalionalité**

يقصد بالحالة السياسية مركز الشخص من حيث انتسابه إلى دولة معينة وارتباطه بها – بوصفه عضوا من أعضائها – برابطة التبعية والولاء أو ما يسمى بالجنسية [1].

ويتولى القانون في كل دولة تحديد الشروط التي تثبت بها الجنسية للأفراد الذين ينتمون إليها وتبنى الجنسية الأصلية للشخص على أساس النسب فيأخذ الولد جنسية أبيه أو أمه، وهو ما يسمى بحق الدم، وقد تبنى على أساس الميلاد على أرض الإقليم فيأخذ المولود جنسية الدولة التي يولد على أرضها، وهو ما يسمى بحق الإقليم، وإلى جانب ذلك فقد تكتسب الجنسية بطريق الزواج كما يحدث في بعض البلاد إذ تكتسب المرأة جنسية زوجها بطريق الزواج، كما أنه قد يتجنس الشخص بجنسية دولة معينة بحسب الشروط التي تضعها هذه الدولة لاكتساب جنسيتها، وهو ما يعرف بالتجنس أو الجنسية الطارئة.

ويرتب القانون على الجنسية آثاراً قانونية من حيث تحديد حقوق الشخص

---

(١) أ.د/ حسن كيره بند/٢٧، صـ٥٣٩ .



وواجباته ونشاطه القانوني، فمثلاً نجد أن الحقوق السياسية (مثل حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولى الوظائف العامة) مقصورة–بصفة عامة– على المواطنين دون الأجانب، كما أن الدول كثيراً ما تحظر على الأجانب–كأصل عام– تملك العقارات بصفة عامة والأراضي الزراعية بصفة خاصة، أو تحظر عليهم امتهان بعض المهن الحرة مثل الطب والمحاماة، كما أن الأجانب يعفون دائماً من أداء الواجبات العامة ، والتي تفرض فقط على المواطنين مثل واجب أداء الخدمة العسكرية.

ثالثا: الحالـة العائليـة:

يقصد بالحالة العائلية مركز الشخص في أسرة معينة بوصفه عضواً فيها، تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة مصاهرة [1].

أ– قرابة النسب:

يقصد بها الصلة التي تنشأ بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك (م ٢/٣٤ مدني) سواء كانت قرابة مباشرة أو قرابة غير مباشرة(أي قرابة حواشي).

***القرابة المباشرة:**

يقصد بالقرابة المباشرة تلك الصلة أو الرابطة التي تنشأ بين الفروع والأصول (م١/٣٥ مدني) مثل قرابة الابن لأبيه أو أمه أو جده ، حيث يعد الابن فرعاً لأي منهم، ويستوي بعد ذلك أن تكون قرابة الفرع للأصل من جهة الذكورة أو من جهة الأنوثة.

*** القرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي:**

---

[1] أ.د/ توفيق حسن فرج صـ٢٢٨ .

ويقصد بالقرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي تلك الصلة أو الرابطة التي تنشأ بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك من غير أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر (م ٢/٣٥ مدني) مثل قرابة الأخ لأخيه حيث يجمعهم أصل مشترك وهو الأب دون أن يعد أحدهم فرعاً للآخر، وكذلك قرابة أبناء العمومة ببعضهم البعض فهي قرابة غير مباشرة حيث يجمعهم أصل مشترك وهو الجد من غير أن يعد أحدهم فرعاً للآخر.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون قد بيَّنَ بوضوح كيفية حساب درجة القرابة بين الأقارب قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.

ففي القرابة المباشرة نحسب درجتها باعتبار كل فرع درجة حتى نصل صعوداً إلى الأصل ثم نسقط درجة الأصل ونحسب درجة الفرع فقط، فمثلا قرابة الابن بأبيه تعد قرابة من الدرجة الأولى لأن الابن بوصفه فرعا يحسب درجة والأب بوصفه أصلا تسقط درجته، وقرابة الابن لجده قرابة من الدرجة الثانية لأن الابن فرع فيحسب درجة ثم نصعد إلى الفرع الثاني وهو الأب [١] فيحسب درجة حتى نصل صعوداً إلى الجد فهو باعتباره أصلا تسقط درجته فلا تحسب.

ولعل هذا هو ما نصت عليه المادة ٣٦ مدني بقولها " يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل .... ".

أما في قرابة الحواشي أو القرابة غير المباشرة فيجرى حساب درجة القرابة فيها بالصعود من الفرع إلى الأصل ونحسب درجة الفرع مع إسقاط الأصل ، ثم ننزل من الأصل إلى الفرع ونحسب درجة الفرع دون الأصل .

---

[١] وقد يقول قائل أليس الأب في هذا المثال يعد أصلاً للابن فيجب إسقاط درجته، فنرد عليه بأن الأب مع وجود الجد يعد فرعاً لا أصلا فتحسب درجته بوصفه فرعا مثله في ذلك مثل الابن تماماً .

فمثلاً تعد قرابة الأخ لأخيه قرابة من الدرجة الثانية، ويجرى حسابها بالصعود من الأخ باعتباره فرعا إلى أبيه بوصفه أصلا فنحسب درجة الأخ (الفرع) دون الأب (الأصل)، ثم تنزل من الأصل وهو الأب – فلا تحسب درجته – إلى الفرع وهو الأخ الثاني فتحسب درجته فيكون المجموع درجتين، كما تعد قرابة ابن العم لابن عمه قرابة من الدرجة الرابعة، إذ يجرى حساب درجة القرابة بالصعود من ابن العم (الفرع) إلى أبيه (الفرع) حتى نصل إلى الجد (الأصل) فنحسب درجة كل فرع وهما ابن العم وأبوه ونسقط درجة الجد (الأصل)، ثم ننزل من الجد (الأصل) إلى العم (الفرع) ثم إلى ابنه (الفرع) أيضاً ونحسب درجتيهما دون درجة الجد الأصل، فيكون المجموع أربع درجات، ولمزيد من الإيضاح إليك هذا الاسم:-

- **<u>الجد كأصل لا تحسب درجته لا في الصعود ولا في النزول</u>**

درجة فرع الأب درجة فرع الأب

درجة فرع ابن العم درجة فرع ابن العم

<u>ب- قرابة المصاهرة:</u>

يقصد بقرابة المصاهرة تلك الرابطة التي تنشأ بين الزوج (رجلا كان أو امرأة) وأقارب زوجه الآخر بسبب الزواج. وفي ذلك تنص المادة ٣٧ من التقنين المدني المصري على أن "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

وتجدر الإشارة إلى أنه يجري حساب درجة قرابة المصاهرة تبعا لدرجة قرابة النسب، فتكون درجة قرابة المصاهرة بين الزوج (رجلا كان أو امرأة) وأقارب زوجه

الآخر على نفس درجة قرابة النسب التي تربط هذا الأخير بأقاربه من النسب، ومن ثمَّ تكون درجة المصاهرة بين الزوج (الرجل)ووالد زوجته قرابة من الدرجة الأولى، على أساس أن درجة الزوج من والد زوجته هي ذات درجة قرابة زوجته بأبيها من النسب،وينطبق نفس الحكم على درجة قرابة المصاهرة بين الزوجة ووالد زوجها فهي قرابة من الدرجة الأولى، نظراً لأن قرابة زوجها بأبيه من النسب قرابة من الدرجة الأولى.

ويعد أخو الزوجة بالنسبة لزوج أخته قريبا من الدرجة الثانية، على أساس أن هذه الدرجة هي ذات درجة قرابته لأخته من النسب، ويقاس على هذه الأمثلة أشباهها ونظائرها من الحالات الأخرى.

وينبغي أن يكون ماثلا في الذهن أن هذه القرابة(أي قرابة المصاهرة) لا يمتد أثرها إلى أقارب الزوجين في علاقاتهم ببعضهم البعض، فلا تنشأ قرابة مصاهرة مثلا بسبب الزواج بين والد الزوج أو والدته أو أخته أو عمته أو خالته، وبين والد الزوجة أو والدتها أو أختها أو عمتها أو خالتها، حيث يقف أثر هذه القرابة على علاقة الزوج (رجلا كان أو امرأة) بأقارب زوجه الآخر دون أن تمتد إلى غيرهما .

آثـار القرابــة:

لا تعد القرابة مجرد وشيجة إنسانية يقف دورها عند حد توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأقارب وتعميق الصلات بين الأشخاص الذين ينضوون تحت لوائها، وإنما هي في حقيقتها رابطة أو صلة إنسانية لها آثارها التي تنسحب على ذويها إيجابا(بإثبات بعض الحقوق لهم)أو سلبا(بفرض بعض الالتزامات على عاتقهم).

لذلك يرتب القانونُ على القرابة – ولاسيما قرابة النسب–آثاراً قانونية بين

ذويها فيثبت لبعضهم عددا من الحقوق تجاه البعض الآخر،ويفرض عليهم أيضاً بعض الواجبات،على ضوء مراكزهم القانونية في محيط الأسرة أو العائلة، فالمرء باعتباره أبا في محيط أسرته مثلا تتولد عن قرابته لأفرادها بعض الحقوق والواجبات المتبادلة، فيثبت له في مواجهة أبنائه مثلا حق الولاء والطاعة(والذي يمثل في نفس الوقت واجبا على الأبناء لصالح أبيهم). ويفرض عليه واجب التربية والإنفاق عليهم (والذي يمثل حقا للأبناء على أبيهم).

هذا بالإضافة إلى أن القانون قد يجعل من رابطة القرابة بنوعيها(أي سواء أكانت قرابة نسب أم قرابة مصاهرة)سببا في الحد من طلاقة قدرة الإنسان وحقه في مباشرة بعض الأعمال أو الأنشطة القانونية الخاصة به، والأمثلة على ذلك في القانون المصري كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- حرمان الشفيع من الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو بين الأقارب قرابة نسب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأقارب قرابة مصاهرة حتى الدرجة الثانية [1].

ب-حرمان الواهب من حقه في الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو كان الموهوب له ذا رحم محرم [2].

---

[1] تنص المادة ١/٩٣٩ على أنه:"لايجوز الأخذ بالشفعة:-

أ-.....

ب-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين وبين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .

[2] إذ تنص المادة ٥٠٢ من التقنين المدنى على أن "يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

أ-..... ب-..... ج-.....

د-إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

هـ- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم. و-..... ز-..... ح-..... .

جـ- الحد من سلطة المرء في شأن الزواج، إذ يحرم عليه الزواج ببعض أقاربه إلى درجة معينة، فلا يحل له أن يتزوج بامرأة إذا كانت من المحرمات عليه شرعاً [1].

---

[1] يحرم على المرء شرعا وقانونا أن يتزوج واحدة من النساء الآتى ذكرهن:

١- الأم سواء كانت أما بالنسب أو بالرضاعة، وتأخذ الجدة أيضاً حكمها وإن علت.

٢- البنت : سواء أكانت بطريق النسب أم بطريق الرضاعة، وتأخذ حكمها بنت الابن وبنت البنت مهما امتدت الفروع.

٣- الأخت : بطريق النسب أو بطريق الرضاعة.

٤-العمة: بطريق النسب أو بطريق الرضاعة.

٥-الخالة: بطريق النسب أو بطريق الرضاعة.

٦-بنات الأخ وبنات الأخت بطريق الرضاعة أو بطريق النسب.

٧- الربيبة: وهي بنت الزوجة المدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بالأم فلا جناح عليه إن يتزوج من بنتها.

٨-زوجة الأب بطريق النسب أو بطريق الرضاع، لأنها بزواجها من أبيه صارت في منزلة أمه فتحرم عليه مراعاة لحرمة أبيه.

٩- أم الزوجة بطريق النسب أو الرضاعة فهي بزواج الرجل من ابنتها صارت في منزلة أمه، وهي تحرم عليه بمجرد العقد ولو لم يدخل بها.

١٠-حليلة الابن: ويقصد به الابن من الصلب لا الابن من التبني.

١١-الجمع بين الأختين: فيحرم على الرجل أن يجمع في عصمته بين الأختين اتقاءً للفتنة وقطيعة الرحم وإبقاءً على دوام أواصر المحبة والمودة بينهما.

١٢- المرأة المتزوجة: فلا يحل لها أن تجمع بين رجلين في آن واحد، ويلزم لزواجها بآخر أن تنتهي رابطة الزواج الأولى بموت أو طلاق ثم تقضى بعد ذلك عدتها بحسب نوعها- فإن كان عدة طلاق فعدة المطلقة ثلاثة حيضات وإن كانت عدة وفاة فعدتها أربعة أشهر وعشرا -ولقد جاء ذكر المحرمات من النساء السالف ذكرهن في قول الله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح أبناؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا،حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين"[الآيات٢٢:٢٤من سورة النساء]. =

= ولقد أضافت السنة النبوية المطهرة -إلى جانب ما أورده القرآن الكريم على النحو سالف الذكر - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها فقد روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "لا تنكح المرأة على عمته أولا على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".

د- اعتبار القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم، إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة أو كانت له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره مصلحة في الدعوى، وذلك رغبة في تجنيب القاضي مواطن الشبهات ، وإعانة له على تحقيق العدل بين الخصوم وعدم الميل لنفسه أو لبعضهم على حساب البعض الآخر [1].

المطلب الثالث

الموطن Le domicile

أولاً: تعريف الموطن وأهميته وتقسيماته:

يقصد بالموطن المقر القانوني للشخص فيما يتعلق بنشاطه القانوني وعلاقاته مع غيره من الأشخاص، بحيث يعد موجوداً فيه على الدوام ولو تغيب عنه بصفة

ويراعى أيضا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أنه يحرم على الرجل أن يتزوج ببعض قريباته من الرضاعة(مثل أمه من الرضاعة وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة وبنات أخته وأخيه من الرضاعة ...الخ)سواء بسواء مثلما يحرم عليه بعض قريباته من النسب، وذلك عملا بقول النبي –صلى الله عليه وسلم– الذي جاء في الصحيحين" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .

[1] حيث تنص المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أن" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

١-إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

٢-إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

٣-إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

٤- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

مؤقتة [1]، والموطن بهذا المعنى يختلف عن " محل الوجود " La demeure، والذي قد يقيم فيه الشخص على نحو عارض ولمدة مؤقتة مثل الفندق الذي يقيم فيه الشخص عند سفره لبضعة أيام.

وتتجلى أهمية وجود موطن للشخص – بوصفه إحدى مميزات شخصيته – في كونه المقر الذي يعتد به القانون فيما يتعلق بنشاطه القانوني وما يجريه مع غيره من علاقات قانونية، فالوفاء بالدين يتم بصفة عامة في موطن المدين وقت الوفاء (م ٢/٣٤٧ مدني)، وترفع الدعاوى الشخصية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين (م٤٩ مرافعات)، والأوراق القضائية تعلن إلى الشخص في موطنه (م ١٠مرافعات)، وشهر الإفلاس يكون من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين التاجر .

<u>وللموطن نوعان:</u> موطن عام Domicile général ، وموطن خاص Domicile spécial ، ويقصد بالموطن العام المقر الذي يعتد به القانون في خصوص النشاط القانوني للشخص وما يجريه مع غيره من الأشخاص من أعمال وعلاقات بصفة عامة، في حين يقصد بالموطن الخاص المقر الذي يعتد به القانون فيما يتعلق بأحد أعمال الشخص أو بعض أنشطته ومعاملاته على وجه الخصوص.

<u>١- الموطن العام:</u>

هو المقر الذي يعتد به القانون في جميع معاملات الشخص وأنشطته بوجه عام.

ومن الطبيعي بوصف عام أن يكون هذا الموطن من اختيار الشخص، لأن

---

[1] أ.د/ حسن كيره بند ٢٨٣، صـ٥٦٠ .



المرء لا يجبر على القرار في مكان لا يريده، والقانون إذ يعتد بمكان معين بوصفه موطنا للشخص، فهو بذلك يعتد بالمقر الذي ارتضاه المرء لنفسه بإرادته واختياره، ولذلك يطلق عليه اصطلاح الموطن الإرادي أو الاختياري Le domicile volontaire، وذلك يكون بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون أعمالهم بأنفسهم.

بيد أنه قد يحدث في بعض الأحوال الاستثنائية أن يتدخل القانون فيفرض على بعض الأشخاص موطناً معيناً مراعاة لمصلحتهم، ومن ثمَّ لا تكون لإرادتهم دخل في اختياره، وهذا ما يحدث بالنسبة للأشخاص الذين لا يقدرون على مباشرة أعمالهم بأنفسهم مثل القصر والمحجور عليهم ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الموطن اصطلاح الموطن الإلزامي أو القانوني Le domicile obligatoire ou légal.

أ- <u>الموطن الإرادي أو الاختياري:</u>

يتضح لنا مما سبق أن الموطن الإرادي يمثل الصورة الغالبة أو القاعدة العامة في الموطن العام، ويعرف القانون هذا الموطن العام بأنه " المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة " (م ٤٠/١ مدني).

لذلك ينبغي لكي يعد مكاناً ما موطناً عاماً للشخص أن يتوافر فيه وصفان:-

- <u>الوصف الأول: الإقامة الفعلية:</u>

يلزم لكي يعد مكانا ما موطناً للشخص أن يقيم فيه إقامة فعلية، ومن ثمَّ لا يعد موطناً ذلك المكان الذي يقوم الشخص بإعداده للسكنى دون أن يسكن فيه فعلاً، كما لا تتحقق الإقامة الفعلية من مجرد نزول الشخص ضيفاً على أحد أقاربه أو أصدقائه حتى ولو كان يقضي معه معظم ساعات النهار أو الليل، مادام لا يقيم

معه إقامة فعلية [1].

– الوصف الثاني: الإقامة المعتادة أو المستقرة:

لا يكفي مجرد الإقامة الفعلية في المكان حتى يعد موطناً ، بل يلزم إلى جانب ذلك أن تكون لهذه الإقامة صفة الاعتياد أو الاستقرار، ومن ثمَّ لا يعد الفندق أو المصيف أو المشتى موطناً للشخص رغم إقامته فيه إقامة فعلية لانتفاء وصف الاستمرار أو الاعتياد في هذه الإقامة، إذ أن إقامته في أي من هذه الأماكن رغم كونها إقامة فعلية إلا أنها إقامة عارضة ومؤقتة.

غير أن الاستقرار باعتباره وصفا لازماً في الإقامة لا يستلزم أن تكون إقامة مستمرة متصلة، فقد يكون للشخص أكثر من مكان يقيم فيه إقامة فعلية ومستقرة على فترات متباعدة دون أن يقدح ذلك في اعتبار كل منهما موطناً له، مثال ذلك من يتزوج بزوجتين في مكانين مختلفين ويقيم عند كل واحدة منهما أسبوعاً مثلاً، فمثل هذه الإقامة الفعلية رغم أنها غير مستمرة ومنقطعة إلا أنها تتصف بوصف الاستقرار الذي تصلح معه بأن تكون موطناً للشخص [2].

بل إنه من المتصور ألا تصلح الإقامة المستمرة المتصلة في بعض الأحوال لاكتساب المكان وصف الموطن بالنسبة للشخص، مثال ذلك أن يذهب تاجر إلى مكان معين للتجارة ويسكن فيه مدة عام مثلا أو ينتقل مهندس لعمل مشروع في مكان معين ويقيم فيه فتره طويلة متصلة، فعلى الرغم من توافر وصف الاستمرار

---

[1] انظر في نفس المعنى: أ. د/ نعمان جمعة ص ٤٣٦، ٤٣٧ .

[2] ولنضرب مثالاً آخر للتدليل على أن عدم استمرار الإقامة لا يقدح في كونها إقامة فعلية مستقرة، لو فرضنا أن شخصاً يقيم في مكان معين مع أسرته إقامة فعلية ومتصفة بالاستقرار غير أن ظروف عمله تضطره للبقاء في مكان عمله والمبيت به لفترات طويلة قد لا يرجع فيها لمنزله إلا لوقت بسيط على فترات متباعدة، كما لو كان يعمل بالقوات المسلحة أو يعمل في مجال الطيران أو السياحة، فمثل هذا الانقطاع في إقامته وعدم كونها مستمرة ومتصلة، لا يقدح في كونها إقامة فعلية ومستقرة على النحو الذي تصلح معه أن تكون موطناً له .

في إقامة أي منهما إلا إنه لا يمكن أن نصف مكان إقامة أي منهما بأنه يعد موطناً له، وذلك لافتقار هذه الإقامة لوصف الاستقرار أو الاعتياد، ومن ثمَّ فهي إقامة عارضة ومؤقتة وإن طالت مدتها أو ظلت مستمرة ومتصلة لمدة طويلة.

ويترتب على استلزام توافر هذين الوصفين في الإقامة الآثار الآتية:-

١- إنه قد يحدث أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن، طالما كانت إقامته في كل واحد من هذه المواطن إقامة فعلية ومستقرة، كما لو كان الشخص متزوجاً بزوجتين أو ثلاث أو أربع في أكثر من مكان مثلا ويقيم مع كل واحدة منها أو منهن إقامة فعلية ومستقرة حتى ولو على فترات متباعدة، أو كان الشخص تاجراً يتنقل بصورة منتظمة بين أكثر من محافظة ويقيم في كل محافظة إقامة فعلية ومستقرة.

٢- إنه من المتصور أن يعيش المرء بلا موطن كما هو الحال بالنسبة للبدو الرحل الذين لا يستقرون في مكان معين يمكن أن يوصف بأنه يعد موطناً لهم، فإقامتهم الفعلية في مكان معين تفتقر إلى عنصر الاستقرار.

٣- إنه من حق الشخص أن يغير موطنه في أي وقت ليكتسب موطناً جديداً، كما لو كان الشخص يقيم في الريف إقامة فعلية ومستقرة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإقامة في المدينة إقامة معتادة ومستقرة، ويجعل إقامته في الريف بعد ذلك إقامة مؤقتة وعارضة لبضعة أيام مثلا فينتفي بذلك عن إقامته بالريف وصف الاعتياد أو الاستقرار، ويضحى مسكنه في المدينة موطنا له دون مسكنه في الريف.

ب- الموطن الإلزامي أو القانوني:

يمثل الموطن الإلزامي أو القانوني الصورة الاستثنائية للموطن العام، حيث يتدخل القانون لتحديده دون إرادة أو اختيار من جانب الشخص فيجعل مكاناً معيناً موطنا له جبرا عنه رغم أن إقامته الفعلية والمعتادة في موطن آخر، وذلك مراعاة

لظروفه الخاصة التي تعجزه عن مباشرة أعماله بنفسه واختيار مكان معين موطناً له بشأن تلك الأعمال .

وفي ذلك ينص القانون في المادة ١/٤٢ مدني على أن " موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً ".

فأي من هؤلاء يجعل القانون موطنه الأصلي هو موطن من ينوب عنه قانونا مثل الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل، فالقاصر موطنه هو موطن وليه أو وصِّيه، والمحجور عليهم موطنهم هو موطن القيم عليهم، والمفقود أو الغائب موطنه هو موطن وكيله القائم على إدارة أمواله.

ويظل موطن أي من هؤلاء هو موطن النائب عنه قانونا إلى أن يزول عنه ذلك الاعتبار الذي تدخل القانون بسببه وفرض عليه قانوناً موطن النائب عنه موطناً له، فإذا زال السبب كان له أمر تحديد موطنه بإرادته واختياره، بحيث يكون موطنه ذلك المكان الذي يقيم فيه إقامة فعلية ومستقرة.

٢- الموطن الخاص:

يقصد بالموطن الخاص – كما سبق أن عرفنا – ذلك المقر الذي يعتد به القانون في خصوص بعض أعمال الشخص أو بعض أنشطته، ولقد أوضح القانون أنواعاً مختلفة للموطن الخاص هي موطن الأعمال، وموطن القاصر فيما يعد أهلا لمباشرته من تصرفات، فضلا عن الموطن المختار، وسنعرض هذه المواطن فيما يلي :-

أ- موطن الأعمال:

تنص المادة ٤١ مدني على أن " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة".

يظهر واضحاً من هذا النص أن المكان الذي يباشر فيه الشخص أعمال تجارته أو حرفته يعتبر موطنا خاصاً للشخص فيما يتعلق بتلك الأعمال، أما ما عداها من أعمال الشخص ومعاملاته الأخرى فيعد موطنها هو الموطن العام لذلك الشخص أي المقر الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة.

إذن فموطن الأعمال الذي يخص تجارة أو حرفة معينة يكون مقصوراً عليها دون غيرها من الأعمال الأخرى. هذا مع مراعاة أنه لا يصدق وصف الموطن الخاص على المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله بوصفه موظفا عاما في الدولة فيما يتعلق بأعمال وظيفته [1].

ب- موطن القاصر بالنسبة لما يعتبر أهلا لمباشرته من تصرفات:

إذا كان الأصل العام أن الموطن العام للقاصر ومن في حكمه هو موطن من ينوب عنه قانوناً، حيث يتدخل القانون فيفرض عليه موطنا معيناً لا دخل لإرادته في اختياره مراعاة لصغر سنه الذي كان سببا في جعله غير قادر على مباشرة أعماله بنفسه، إلا أنه قد يحدث أن يبيح القانون للقاصر مباشرة بعض التصرفات القانونية بوصفه أهلا للقيام بها على سبيل الاستثناء، فكان طبيعياً أن يترك لهذا القاصر أمر تحديد الموطن الخاص لهذه التصرفات المأذون له بالقيام بها بنفسه، على أن يبقى موطن النائب عنه قانونا هو الموطن العام الإلزامي لهذا القاصر خارج نطاق الأعمال أو التصرفات المأذون له في مباشرتها.

وفي ذلك تنص المادة ٢/٤٢ مدني على أنه " ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها ".

---

[1] نقض مدنى ٧ فبراير ١٩٥٢، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الثالثة، رقم ٧٦، ص ٤٤٤، مشار إليه لدى: أ. د/ حسن كيره ص ٥٦٨، هامش ١ .

وفي هذه الحالة قد يتحدد – في هذا الإطار الاستثنائي – موطن القاصر الخاص بالأعمال المأذون له بمباشرتها بمحل إقامته الفعلية المستقرة أو بالمحل الذي يباشر فيه أعماله وتصرفاته المأذون له قانونا بسلطة مباشرتها.

ج- الموطن المختار: Le domicile élu

يرخص القانون للشخص أن يختار موطنا خاصاً لتنفيذ عمل قانوني معين، سواء كان هذا الاختيار بإرادته المنفردة أو بموجب اتفاق بينه وبين غيره، تيسيراً لأداء هذا العمل، إذ تنص المادة ١/٤٣ مدني على ذلك بقولها "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ". وعندئذ يكون هذا الموطن المختار موطنا خاصاً للشخص –إلى جانب موطنه العام أي محل إقامته المعتادة– فيما يتعلق بشئون هذا العمل القانوني طوال الفترة التي تستغرقها عملية تنفيذه، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، ما لم يتفق صراحة على قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى (م ٣/٤٣ مدني).

ولعل اتخاذ موطن مختار قد يقصد منه تثبيت الموطن طوال المدة التي يستغرقها تنفيذ عمل قانوني دون أن يتأثر بتغير محل إقامة ذوي الشأن أو تجنيب الدائن مشاق وتكاليف إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة مدين مقيم في منطقة نائية أو بعيدة عن العمران أو تركيز إجراءات التنفيذ الجبري في يد وكيل معين مثل المحامي [1].

ولقد أوجب القانون صراحة ضرورة إثبات الموطن المختار بالكتابة أيا كانت قيمة العمل القانوني الذي اختير هذا الموطن لتيسير مهمة تنفيذه (م٢/٤٣ مدني).

---

[1] أ.د/ حسن كيره بند ٢٨٩، صـ٥٧٠ .

والأصل أن يكون قيام الشخص باتخاذ موطن مختار بشأن عمل قانوني معين أمراً جوازياً له فلا يجبر عليه، ولكن قد يحدث أن يتدخل القانون فيفرض على الشخص أن يختار بإرادته المنفردة موطنا مختاراً له بشأن تنفيذ عمل قانوني معين، مثال ذلك إلزام القانون للدائن المرتهن بأن يعين له محلاً مختاراً في دائرة المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المرهون (م٣٠ من قانون الشهر العقاري) وما تنص عليه المادة ٢/٧٤ مرافعات من أنه "على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه".

المبحث الثالث

أهليــة الشخص الطبيعـي

أهلية الوجوب وأهلية الأداء:

الأهلية في اللغة تعنى الصلاحية، فحينما نقول أن محمداً أهل لأداء عمل معين، فنعنى بذلك أنه صالح لتنفيذه وقادر على حسن القيام به أو هي صفات عقلية أو خلقية تستحق التقدير ، أقول منصب ناله عن أهلية : أي عن كفاءة ، وأقول أهلية عامل :أي صلاحيته القانونية [١]، ويقال فلان أهل لكذا يقال ذلك لمن استحق التقدير لصفات أو لأعماله ، يقال تلميذ أهل للمكافأة : للواحد أو الجمع معه سواء :أي كفء ذو استحقاق [٢] أما في اصطلاح الفقهاء فهي تعنى "صلاحية الشخص لتلقى الحقوق والتحمل بالالتزامات [٣].

---

[١] انظر في ذلك إلى " المنجد في اللغة العربية" ، ص٥١ ، طبعة أولى عام ٢٠٠٠م ، دار الشروق . لبنان . بيروت .

[٢] انظر في ذلك إلى "قطر المحيط" تأليف بطرس البستاني ، جـ، ص ٥٧ ، مكتبة لبنان . بيروت . لبنان ، الرائد" معجم لغوى عصري تأليف جبران مسعود ، ص ٢٨٢، دار العلم للملايين بيروت .لبنان.

[٣] انظر في ذلك إلى :أ.د/ عبد الحى حجازى "المدخل لدراسة العلوم القانونية " ، جـ٢ ، الحق وفقا للقانون الكويتى ، دراسة مقارنة ، بند ٢٧، ص ٣٩١ ، مطبوعات جامعة الكويت ، أ.د/ محمد حسام لطفي " المدخل لدراسة

والأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.

المطلب الأول

أهلية الوجـوب

ويقصد بأهلية الوجوب Capacité de jouissance صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، وهي حسبما يظهر من تعريفها تنطوي على عنصرين، أحدهما إيجابي وهو الصلاحية لكسب الحقوق، والآخر سلبي وهو الصلاحية لتحمل الواجبات، فإذا توافر العنصران كانت أهلية الوجوب كاملة، أما إذا توافر العنصر الإيجابي فقط دون العنصر السلبي كانت أهلية الوجوب ناقصة.

أولاً: أهلية الوجوب الناقصة:

وهي تعنى صلاحية الشخص لاكتساب بعض أو كل الحقوق دون التحمل بالواجبات، وهي تثبت للجنين في بطن أمه أو الحمل المستكن، ذلك أن الجنين لا يعد شخصاً كاملا، إذ لا يتحقق كمال الشخصية إلا بتمام ولادة الإنسان حياً، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نعد الجنين عدما لأنه ينعم بالحياة والوجود في بطن أمه، لذلك فقد وجب عده في مرحلة وسطى بين الحياة والعدم ، والاعتراف له من ثمَّ بشخصية قانونية ناقصة تسوغ أن تكون له أهلية وجوب ناقصة .

فالجنينLe foetus له أهلية وجوب ناقصة لأنه لا يتحمل بواجبات ما والتي تمثل العنصر السلبي في أهلية الوجوب، هذا فضلا عن أنه ليس أهلا لاكتساب كل الحقوق ولكنه–من وجهة نظر البعض– يصلح فقط لاكتساب بعض الحقوق، فأهليته مقصورة على الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول لثبوتها له مثل حقه في

القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء" الكتاب الثانى ، نظرية الحق ، ص ١٤٤، الطبعة الثالثة عام ١٩٩٣م ، فضيلة الإمام محمد أبو زهرة "الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، بند ١٥٤، ص ٢٦١ .

ثبوت نسبه من أبيه، وحقه في الإرث والوصية، أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول لثبوتها فلا يصلح الجنين لاكتسابها مثل قبول الهبة أو الصدقة، لأنه لا يتصور منه قبول، ولا يمكن لأحد أن يتولى القبول عنه لأن الولاية لا تبتدئ على الإنسان إلا بتمام ولادته حيا [١].

وأرى مع بعض الفقهاء صلاحية الجنين لاكتساب جميع الحقوق سواء ما كان لا يحتاج منها إلى قبول أو ما كان محتاجا إلى قبول حيث ينوب عنه نائبه (وليه أو وصيه) في تلقى هذه الحقوق عنه [٢]

ثانيـاً: أهلية الوجوب الكاملة:

ويقصد بها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل الواجبات [٣]، ويرجع وصف الكمال فيها لانطوائها على عنصريها الإيجابي (والذي يتمثل في صلاحية اكتساب الحقوق) والسلبي (والذي يتمثل في صلاحية التحمل بالواجبات).

والأصل العام أن الإنسان بمجرد تمام ولادته حيا يتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، كما يتمتع أيضاً بأهلية وجوب كاملة بحيث يكون أهلا لاكتساب كافة الحقوق سواء ما كان منها لا يحتاج إلى قبول مثل الميراث والوصية أو ما كان يحتاج منها إلى قبول مثل الصدقة والهبة حيث يتولى وليه القبول نيابة عنه، والتحمل أيضاً بكافة الواجبات.

بيد أنه على الرغم من أن الإنسان بتمام ولادته حيا يتمتع بأهلية وجوب

---

[١] أ.د/ عبد الحى حجازى صـ٩١ وما بعدها .

[٢] أ.د/جلال العدوى "المراكز القانونية" ص ١٣٥،طبعة عام ١٩٨٨م ، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية .

[٣] وهذا هو نفس تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية ، حيث يعرفونها بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه " ،انظر في ذلك " أصول السرخسي "لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسي ، جـ ،ص٣٣٢ ، دار المعرفة ، بيروت . لبنان ، أصول الفقه" للأستاذ الدكتور / محمد زكريا البرديسي ، ص ١٣٥ ، طبعة عام ١٩٨٣م ، دار الثقافة للنشر والتوزيع .

كاملة، وتتوافر له بموجبها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات إلا أن مدى هذه الصلاحية ونطاقها قد يختلف سعة وضيقاً تبعاً لحالة الشخص أي بحسب حالته الطبيعية (نوعه أو جنسه) وحالته السياسية (أي جنسيته) وحالته العائلية (أي مركزه داخل الأسرة) وحالته الدينية (أي دينه الذي يعتنقه)، وذلك على التفصيل الآتي:-

١- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعاً للحالة الطبيعية:

لا جرم أنه بصفة عامة تثبت للمرأة أهلية وجوب كاملة مثلها في ذلك مثل الرجل سواء بسواء، بحيث تتوافر لها بمقتضاها الصلاحية الكاملة لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، إلا أن مدى هذه الصلاحية قد يتفاوت فيما بينهما مراعاة للتكوين الطبيعي الخاص بكل منهما فيجعل أحدهما غير صالح لاكتساب بعض الحقوق أو التحمل ببعض الواجبات .

فعلى سبيل المثال لا تتحمل المرأة واجب أداء الخدمة العسكرية بخلاف الرجل، كما أنها لا تتقلد المناصب القيادية في الشرطة أو الجيش بعكس الرجل.

وينبغي للإنصاف والعدل أن نقول أن الحد من مدى صلاحية المرأة لاكتساب بعض الحقوق أو التحمل ببعض الواجبات لا يقدح في كمال شخصيتها ولا ينال من قدرتها ومكانتها، طالما أن ذلك مرده إلى مراعاة تكوينها العضوي والنفسي ودورها المرسوم لها في المجتمع الذي تعيش فيه، بل إن تسويتها بالرجل في كسب الحقوق والتحمل بالواجبات تسوية مطلقة دون النظر إلى ما بينهما من فروق متنوعة لا تخلو من الظلم الشديد لها ، لأن فيها تجاهلاً مقيتاً لظروفها الخاصة العضوية والنفسية والاجتماعية، فالمساواة المطلقة لا تكون إلا بين شيئين متماثلين وهذا غير متحقق بين الرجل والمرأة، لذلك كان طبيعياً أن يتفاوت نطاق

صلاحية كل منهما لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات [1].

٢- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعاً للحالة السياسية:

يجري العملُ في معظم الدول على الحد من أهلية الوجوب للشخص الطبيعي تبعاً لحالته السياسية أي جنسيته، فيحرم الأجانب مثلا من ممارسة الحقوق السياسية مثل حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولى الوظائف العامة، كما يحرمهم أيضاً من أداء بعض الواجبات مثل واجب أداء الخدمة العسكرية بعكس المواطنين الذين يتمتعون بكل هذه الحقوق ويتحملون هذه الواجبات، وبذلك يكون مدى أهلية الوجوب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص قد تأثر بحالة الشخص السياسية.

٣- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعاً للحالة العائلية:

على الرغم من أن كل فرد في الأسرة له أهلية وجوب كاملة يصير بمقتضاها أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، إلا إن نطاق هذه الأهلية أو تلك الصلاحية ومداها ليختلف بحسب حالة الشخص العائلية أي مركزه داخل الأسرة ، فحقوق الأب والتزاماته مثلا تختلف عن حقوق الابن والتزاماته ، كما أن للزوج حقوق وعليه واجبات تغاير حقوق الزوجة والتزاماتها .

٤- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعاً للحالة الدينية:

لا جرم أن الدين لا يشكلُ عنصراً للتمييز بين الأشخاص في اكتسابهم للحقوق وتحملهم بالواجبات ، فلكل شخص وإن اختلفت ديانتُه أهلية وجوب كاملة يصير بمقتضاها أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، إلا أن مدى أهليته قد يختلف تبعاً للدين الذي يعتنقه ، فمثلا للرجل المسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة أو يتزوج بغير المسلمة كما له أن يطلق زوجته، في حين أنه لا يجوز للرجل المسيحي

---

[1] انظر في نفس المعنى: أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٨٠ صـ٣٧٠، ٣٧١ .

أن يتزوج بأكثر من واحدة أو يتزوج المسلمة ، كما أنه ليس له أن يطلق زوجته بصفة عامة إلا في حالات معينة على سبيل الحصر.

المطلب الثانى

أهلية الأداء Capacité d' éxercice

تعريف أهلية الأداء :

يقصد بأهلية الأداء قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية لحساب نفسه [١] أو هي قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيراً منتجاً لآثاره القانونية في حقه وذمته [٢].

وتفترق أهلية الأداء عن أهلية الوجوب من عدة نواح، فمناط أهلية الأداء التمييز والإرادة ولذلك فهي تنعدم بانعدامهما وتنمو وتتزايد بتزايدهما، بعكس أهلية الوجوب فمناطها الشخصية القانونية التي تثبت للإنسان بولادته حيا، إذ بمجرد ولادة الإنسان حيا تثبت له الشخصية القانوية فتكون له أهلية وجوب كاملة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أهلية الوجوب تبدأ كاملة منذ تمام ولادة الإنسان حياً وتظل ثابتة له إلى أن يموت دون أن تتأثر بصغر سن الشخص أو بمرضه بعكس أهلية الأداء فهي تتدرج من حيث انعدامها ونقصانها وكمالها تبعاً لتدرج سن الشخص ولا تبلغ درجة الكمال إلا ببلوغ الشخص سناً معينة (ألا وهي سن الرشد والتي كانت في القانون المدني القديم ١٨ عاماً ثم صارت في القانون المدني الجديد ٢١ عاماً) فضلاً عن أنها تتأثر أيضاً بالأمراض التي قد تلحق بالشخص بعد اكتمالها فتنعدم أو تتناقص تبعاً لدرجة خطورة هذا المرض (إذ تنعدم بالجنون

---

[١] أ.د/ شمس الدين الوكيل بند ٢٠١، صـ٣٢٣ .

[٢] أ.د/ حسن كيره بند ٢٩٠، صـ٥٧٢ .

أو العته، وتتناقص بالسفه أو الغفلة) [1].

ومن زاوية ثالثة فإن توافر أهلية الوجوب لدى الشخص لا يعنى أكثر من كون الشخص ذا وضع استاتيكي هو مجرد صلاحيته لأن يكون صاحب حق أو مدين بالتزام ، في حين أن أهلية الأداء تمثل للشخص وضعا ديناميكيا متمثلا في صلاحيته للقيام بما يكسبه من الحقوق أو بما يحمله من الواجبات ، ومن ثم فإن الشخص الذي ليست له أهلية أداء لا يستطيع بمفرده الخروج من الوضع الاستاتيكي الذي يثبت له بمقتضى أهلية الوجوب [2].

وأخيرا فإن انعدام أهلية الوجوب لا سبيل لعلاجه أو إصلاحه ، بعكس انعدام أهلية الأداء حيث يمكن علاجه أو إصلاحه عن طريق مباشرة العمل القانوني اللازم لعديم الأهلية بواسطة نائبه القانوني ، من أجل ذلك لم يجز انعدام أهلية الوجوب لأحد ، لأن ذلك معناه محو الشخصية ذاتها وهذا لا يجوز ، ومن ثم لزم أن يكون ما يلحق أهلية الوجوب هو النقصان وليس الانعدام ، بعكس أهلية الأداء التي يتصور انعدامها كلية لوجود الوسيلة التي تحقق علاج آثارها وإصلاحها ، كما يتصور نقصانها .

وسنعرض – بمشيئة الله تعالى – مراحل تدرج الأهلية تبعاً لتدرج سن الشخص، فضلا عن مدى تأثرها بما قد يلحقها من عوارض أو موانع، وذلك على التفصيل الآتي:-

الفرع الأول

مراحل أهلية الأداء

---

[1] انظر في نفس المعنى: أ.د/ عبد الحى حجازى صـ٩٨،٩٧ .

[2] أ.د/ عبد الحى حجازى –المرجع السابق –بند ٤٤٩،ص٤٠٣ .

إذا كانت أهلية الوجوب تبلغ حد الكمال بمجرد تمام ولادة الإنسان حياً، فإن أهلية الأداء ليست كذلك، إذ أنها تتطور وتتدرج انعداماً ثم نقصاناً إلى أن تبلغ مبلغ الكمال تبعا لنمو الإنسان وتدرج سنه، ومرد هذا الاختلاف بينهما يرجع إلى أن أهلية الوجوب مناطها الشخصية التي تتوافر للإنسان منذ ولادته حيا، بعكس أهلية الأداء فمناطها الإدراك أو التمييز وهما يتدرجان شيئاً فشيئا بمرور الزمن ولا يتحققان للإنسان دفعة واحدة .

لذلك كان طبيعياً أن تمر أهلية الأداء بمراحل مختلفة من الانعدام والنقصان والاكتمال بحسب تدرج سن الإنسان ومراحل نموه، وذلك عن التفصيل الآتى:-

أولا: المرحلة الأولى مرحلة انعدام الأهلية:

وهي تبدأ من ولادة الإنسان حيا إلى ما قبل سن السابعة، أي مرحلة سن الصبي غير المميز، وفي هذه المرحلة رغم أن للشخص أهلية وجوب كاملة إلا أنه تنعدم لديه أهلية الأداء، نظراً لأن الشخص في هذه السن يفتقر إلى الإرادة والتمييز اللذين هما مناط هذه الأهلية، وإن توافرت له الشخصية (والتي تثبت للإنسان بتمام ولادته حيا) التي هي مناط أهلية الوجوب، فلا يكون أهلا لمباشرة جميع التصرفات القانونية أيا كانت طبيعتها، أي سواء كانت تصرفات نافعة نفعا محضا مثل قبول الهبة أو الوصية أو كانت ضارة ضرراً محضا مثل التبرع أو كانت دائرة بين النفع والضرر مثل البيع والشراء والمقايضة، وهذا ما أكدته المادة ٤٥ مدني بقولها " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن ... ، وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز ".

وتعدُ جميع الأعمال أو التصرفات القانونية التي تصدر عن الصبي غير المميز تصرفات باطلة بطلانا مطلقاً ، ويتسنى للمحكمة أن تقضي بهذا البطلان

ولو من تلقاء نفسها، ويمكن لكل ذي مصلحة أن يتمسك به [1]، ولا يجوز تصحيحه من النائب عن هذا الصبي قبل البلوغ أو من الصبي نفسه عند بلوغه سن الرشد.

ثانياً: المرحلة الثانية: مرحلة نقص الأهلية:

وتبدأ هذه المرحلة ابتداءً من سن السابعة إلى ما قبل بلوغ سن الرشد (وسن الرشد في القانون المدني الجديد هي واحد وعشرون سنة)، وهي تسمى بمرحلة الصبي المميز، وفي هذه المرحلة تكون للشخص – إلى جانب أهلية الوجوب الكاملة – أهلية أداء ناقصة نظرا لتمتعه بالإرادة والتمييز اللذين هما مناط هذه الأهلية، غير أنه نظرا لعدم اكتمالهما في الشخص فهما في مرحلة وسطى بين الانعدام والاكتمال، لذلك لم تجعل له أهلية أداء كاملة بل كانت له أهلية أداء ناقصة، وهذا ما أكدته المادة ٤٦ مدني بقولها " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ... يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ".

حكم تصرفات الصبي المميز في هذه المرحلة:

لقد وضع القانون حكماً عاماً لجميع التصرفات التي تصدر عن الصبي المميز بوصفه ناقص الأهلية، ثم خرج عليه في بعض الأحوال الاستثنائية بأحكام خاصة تخالف ذلك ، وهذا ما سنوضحه على التفصيل الآتي :-.

١- الحكم العام بالنسبة لتصرفات الصبي المميز:

لقد وضع القانونُ حكماً عاماً لتصرفات الصبي المميز مَّيَز فيه بين الأنواع الثلاثة من التصرفات القانونية، فعد التصرفات النافعة نفعاً محضاً صحيحة إذا صدرت منه، فعامله بالنسبة لهذه التصرفات معاملة كامل الأهلية، إذ لا يترتب

---

[1] وصاحب المصلحة هو كل من له مصلحة ترقى إلى مصاف الحق يضار فيها بسبب بطلان العقد أو عدم بطلانه مثل طرفي العقد وخلفهما العام وخلفهما الخاص ودائنيهما .

على صدور هذه التصرفات منه خروج شيء من ذمته، بل على العكس تماماً فهي تؤدي إلى غنمه واغتنائه لا إلى غرمه وافتقاره، في حين أنه حكم على ما يصدر عنه من تصرفات ضارة ضرراً محضا مثل الهبة والإبراء بالبطلان المطلق، فعامله فيها معامله عديم التمييز، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر مثل البيع مثلا فقد حكم عليها بأنها تتم منه صحيحة ولكنها تكون قابلة للبطلان لمصلحة القاصر، بحيث يكون لوليه أو وصيه إذا ما كانت هذه التصرفات في غير مصلحة الصبي المميز أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلانها، كما أن للصبي إذا ما بلغ سن الرشد طلب إبطالها إذا رأى في ذلك مصلحة له، فإذا ما طلب الإبطال من الولي أو الوصي أو الصبي المميز بعد بلوغه سن الرشد وجب على القاضي تلبية طلبه واعتبار هذه التصرفات كأن لم تكن وتزول آثارها – بصفة عامة – بأثر رجعى، أما إذا أجازها الولي أو الوصي أو المحكمة أو الصبي المميز بعد بلوغه سن الرشد سقط الحق في طلب إبطالها واستقرت صحيحة بصفة نهائية.

وهذا هو عين ما نصت عليه المادة ١١١ من التقنين المدني بقولها "١- إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا".

"٢- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون".

٢- الأحكام الاستثنائية لتصرفات الصبي المميز:

لقد خرج واضع القانون على الحكم العام سالف الذكر الخاص بتصرفات الصبي المميز. ومنحه على سبيل الاستثناء أهلية أداء كاملة بالنسبة لبعض



التصرفات التي كانت تخرج أصلا عن نطاق أهليته الأصلية، وذلك في الأحوال الآتية:-

أ- <u>للقاصر أهلية التصرف في الأموال المخصصة لأغراض نفقته</u>.

إذ تنص المادة ٦١ من قانون الولاية على المال (مرسوم بقانون رقم ١١٩ لعام ١٩٥٢م) على أن "للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم إليه أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط".

ويظهر لنا من هذا النص أن القانون يعترف للقاصر الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد، بأهلية أداء كاملة بالنسبة لما يخصص له من أموال لأغراض نفقته، بحيث يكون له الحق في التصرف فيها بكافة أنواع التصرف أيا كانت طبيعته أو الأثر المترتب عليه، (أي سواء كان تصرفاً ضاراً ضررا محضاً كأن يتبرع أو يتصدق بهذا المال أو كان تصرفا دائرا بين النفع والضرر من باب أولى)، على أن يراعى أنه لا يجوز الرجوع على القاصر بشأن ما ينشأ عن تصرفه هذا من التزام إلا في حدود هذا المال المخصص لأغراض نفقته ، وهذا من باب حماية القاصر ورعايته.

<u>ب- للقاصر أهلية إبرام عقد العمل:</u>

تنص المادة ٦٢ من قانون الولاية على المال على أن "للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لأحكام القانون، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذي شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة".

ويتضح من النص القانوني سالف الذكر أن للقاصر أهلية أداء كاملة بالنسبة لإبرام عقد العمل (وهو من قبيل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر إذا كان القاصر يأخذ أجرا لعمله أو من التصرفات الضارة ضررا محضا إذا كان لا

يحصل على أجر لعمله كما لو كان العقد عقد تمرين للقاصر على عمل معين) فيعد إبرامه لهذا العقد صحيحا، غير أن القانون قد جعل من حق الولي أو الوصي أو غيرهما من ذوي الشأن طلب إنهاء هذا العقد من المحكمة إذا كان في الإنهاء مصلحة للقاصر كما لو كان العملُ شاقاً لا يتناسب مع صغر سنه أو كان يضر بمستقبله العلمي أو كان طالب إنهاء العقد يستهدف توجيه القاصر لعمل آخر يتناسب مع سنه وقدراته ومهاراته الخاصة.

فإذا ما أجابت المحكمة طلب الإنهاء اقتصر أثرُه على المستقبل فلا يرتد إلى الماضي.

وينبغي أن يكون ماثلا في الذهن أن الاعتراف سالف الذكر بحق القاصر في إبرام عقد العمل الفردي مقصور على حال كونه عاملا لا رب عمل، لأن إبرامه لهذا العقد بوصفه رب عمل يقتضى أن تكون له أهلية إدارة أمواله كلها أو بعضها وهذا ما لا يتحقق إلا ببلوغه سن الثامنة عشرة [1] .

ولقد ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كانت سلطة إبرام هذا العقد من جانب العامل تثبت لمطلق القاصر أم أنه يلزم أن يصل القاصر إلى سن معينة؟

فذهب رأي إلى أن لمطلق القاصر (أي كل من بلغ السابعة فما فوق) أهلية إبرام هذا العقد على أساس أن النص جاء مطلقا عن القيد، فأعطى الحق للقاصر ولم يخصه بسن محددة، في حين ذهب رأي آخر إلى أنه لا يثبت هذا الحق إلا لمن بلغ سن الثانية عشرة، لأن الإطلاق الوارد في نص المادة ٦٢ من قانون الولاية على المال، مقيدٌ بأحكام قانون العمل، والذي تحظر نصوصه (م١٢٤/ ١

---

[1] انظر عرض ذلك لدى: أ.د/ محمد حلمي مراد "قانون العمل والتأمينات الاجتماعية" فقرة ٢٢٠، الطبعة الرابعة عام ١٩٦١، أ.د/ حسن كيره "أصول قانون العمل" جـ١ عقد العمل، فقرة ٦٥، ص ١٨٩، طبعة عام ١٩٦٩، محمد سعد خليفة "نظرية الحق" ص ٢٣٢، طبعة عام ١٩٩٦م.

من قانون العمل القديم رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩، والمادة ١٤٤ من قانون العمل الحالي رقم ٣٧ لسنة ١٩٨١م) حظرا باتا تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن اثنى عشره سنة [١].

واتخذ رأي ثالث –نرجحه– موقفا وسطا بين الرأيين السابقين قائلا إذا كان القاصر ممن يخضعون لقانون العمل، فإن عقد العمل لا يكون صحيحا –باعتبار القاصر طرفا فيه– إلا إذا بلغ الثانية عشرة من عمره، أما إذا كان القاصر لا يخضع لقانون العمل مثل خدم المنازل ، فإن العقد يكون صحيحا ما دام قد بلغ سن السابعة [٢].

ج– <u>للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلية التصرف في كسب عمله:</u>

تنص المادة ٦٣/ ١ من قانون الولاية على المال على أن "يكون للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته".

ويبرزُ جلياً من هذا النص أن القانون يعترف للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة بأهلية أداء كاملة بشأن ما يكتسبه من عمله، فيكون له أن يتصرف فيه كيفما شاء أيا كان نوع التصرف الذي يجريه سواء كان تصرفاً ضاراً ضرراً محضاً مثل التبرع أو دائراً بين النفع والضرر مثل البيع والمقايضة، وذلك بشرط أن يكون التزامه الناشئ عن مثل هذا التصرف لا يتجاوز أثره حدود هذا المال الذي اكتسبه من عمله، فلا يمتد إلى أموال القاصر الأخرى وذلك حماية لمصلحة القاصر وحفاظا على ذمته العامة.

---

(١) انظر في ذلك إلى المراجع السابقة .

(٢) د/ محمد سعد خليفة –المرجع السابق – ص ٢٣٣ .



د- للقاصر المأذون له بالزواج أهلية التصرف في المهر والنفقة:

تنص المادة ٦٠ من قانون الولاية على المال على أنه "إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال، كان ذلك إذنا له في التصرف في المهر والنفقة، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق".

ويستفاد من هذا النص أنه إذا أذنت المحكمة للقاصر الذي له مال بالزواج، كان هذا الإذن إذنا له أيضاً في التصرف في ماله في حدود المهر والنفقة، فيكون له أهلية أداء كاملة في التصرف في ماله بالقدر الذي يستوجبه المهر والنفقة، ويكون للزوجة القاصر حق التصرف في مهرها ونفقتها دون حاجة إلى الرجوع إلى الولي أو الوصي في ذلك.

وينبغي أن يكون ماثلا في الذهن أنه وإن كان للقاصر حق اختيار الوقت الذي يتزوج فيه في حدود أحكام شريعته الدينية، إلا أن المحكمة لن تأذن له بالزواج ذكرا كان أو أنثى إلا عند بلوغ أيهما سن الثامنة عشرة ١من عمره (وقديما قبل تاريخ رفع هذه السن كان سن الزواج هو ست عشرة سنة هجرية إن كان أنثى

---

(١) من أجل ذلك نصت المادة ٣١ مكرر من القانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨م المعدل للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ م في شأن الأحوال المدنية ، على أنه " لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة " ، وحتى نوحد حكم الرجل والمرأة في السن القانونية اللازمة لصحة إبرام عقد زواجهما وتلك السن القانونية اللازمة لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد زواجهما ، يجب تعديل نص المادة ١/١٧ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠١ م والتي تنص على أن " لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كانت سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى " . حتى لا تمسع دعاوى الزوجية سواء كانت مرفوعة من المرأة أو الرجل إلا إذا كانت سن أيها لا تقل عن ثمانية عشرة عامة .

.

أو ثماني عشرة سنة هجرية إن كان ذكراً عملاً بنص المادة ٩٩/ ٥ من لائحة المحاكم الشرعية).

هـ- <u>للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أهلية إدارة أمواله متى أذن له بذلك:</u>

تنص المادة ١١٢ من التقنين المدني على أنه "إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأُذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون".

وقد صدر بعد ذلك قانون الولاية على المال (المرسوم بقانون رقم ١١٩ لعام ١٩٥٢م) فجاءت نصوصه مؤكدة لما جاء في التقنين المدني، حيث تنص المادة ٥٤ من قانون الولاية على المال بأن "للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشر في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها"، كما تنص المادة ٥٥ من نفس القانون على أن "للمحكمة، بعد سماع أقوال الوصي، أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشر في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها".

ويفهم من هذه النصوص سالفة الذكر أن القاصر إذا بلغ سن الثامنة عشر وأذن له وليه (أي أبوه أو جده لأبيه) أو أذنت له المحكمة بعد سماع أقوال الوصي، في تسلم أمواله كلها أو بعضها، كانت له أهلية أداء كاملة في مباشرة كل ما يلزم لإدارة هذه الأموال من أعمال، سواء ما كان منها من أعمال الإدارة بطبيعته مثل قيامه بزراعة الأرض واكتراء الأجراء والعمال للفلاحة فيها وتنقيتها من الأشواك والحشائش، أو بتأجيرها للغير وقبض أجرتها، أو ما كان منها من قبيل أعمال التصرف اللازمة لإدارة هذه الأموال مثل شراء الأسمدة وأدوات الفلاحة والري والسقي (م ٧٠١/ ٢ مدني).

وكان من مقتضى القواعد العامة أن تكون أعمال الإدارة الصادرة من القاصر (بوصفها من قبيل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر) صحيحة مع

قابليتها للإبطال لمصلحة القاصر، ولكن خروجا على هذه القواعد جعلها القانون صحيحة بصفة نهائية وغير عرضة للإبطال.

و- <u>للقاصر أهلية الاتجار في أمواله متى أذنت له المحكمة وبلغ الثامنة عشرة</u>

تنص المادة ٥٧ من قانون الولاية على المال على أنه "لا يجوز للقاصر، سواء كان مشمولا بالولاية أو الوصاية، أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقاً أو مقيداً".

يستفاد من هذا النص أن القاصر يعامل معاملة ذي أهلية الأداء الكاملة فيتاجر في أمواله متى بلغ سن الثامنة عشرة من عمره وأذنت له المحكمة بذلك (فهي الوحيدة التي تملك هذا الأذن، فلا يملك الولي أن يأذن للقاصر بالاتجار في أمواله ولو كان بالغا سن الثامنة عشرة من عمره، لأن حدود سلطة الولي في الإذن للقاصر مقصورة على أعمال الإدارة فقط أما الإذن بالاتجار فهو مقصور على المحكمة، نظرا لأن الاتجار يعد من أعمال التصرف [١])، شريطة أن يكون مدى هذه الأهلية ونطاقها في حدود الإذن الصادر من المحكمة، فقد يكون الإذن مطلقا فعندئذ يكون للقاصر الاتجار في كل أمواله، وقد يكون مقيدا بنسبة معينة من ماله أو بنوع معين من هذا المال، فعندئذ تكون حدود أهليته مقيدة بالنطاق المأذون له بالاتجار فيه.

<u>ثالثا: المرحلة الثالثة:مرحلة اكتمال الأهلية:</u>

---

[١] وكثيرا ما تدق التفرقة بين أعمال الإدارة وأعمال التصرف ، والمحك في ذلك هو محل العمل أو التصرف هل يقع على الأصل أم على ثماره ، بغض النظر عن طبيعة العمل أو التصرف في ذاته ، أي حتى ولو كان التصرف في ذاته من أعمال التصرف فقد يعد رغم ذلك من قبيل أعمال الإرادة ما دام منصبا على ثمار الشيء وليس على أصله ، ولذا فإن البيع في ذاته وإن كان من أعمال التصرف ، إلا أنه إذا ورد على ثمار الشيء ولم يرد على أصله كان من أعمال الإدارة ، في حين إذا ورد البيع على أصل الشيء كان من أعمال التصرف .

إذا بلغ الشخص سن الرشد وهي واحد وعشرون سنة ميلادية (وقد كانت سن الرشد في التقنين المدني القديم ثماني عشرة سنة، وعدلت في التقنين المدني الجديد وصارت واحد وعشرين سنة) ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية يفقده أهليته مثل الجنون أو العته أو يضعف اعتدالها وحسن تقديرها مثل السفه أو الغفلة، كان ذا أهلية أداء كاملة بحيث يملك إجراء كافة التصرفات القانونية بنفسه أيا كانت طبيعتها، أي سواء كانت تصرفات نافعة نفعاً محضا أو ضارة ضررا محضا أو كانت دائرة بين النفع والضرر.

وتنتهي عن الشخص ببلوغه سن الرشد ما كان ثابتا عليه من ولاية أو وصاية بسبب كونه كان قاصرا من قبل، هذا ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية أو الوصاية عليه (م ١٨، ٤٧ من قانون الولاية على المال) بسبب إصابته بأحد عوارض الأهلية فأفقده الإدراك والتمييز مثل الجنون أو العته، أو أخل بتقديره وتدبيره للأمور مثل السفه والغفلة.

وقد يحدث أن يكتمل إدراك الشخص وتمييزه ببلوغه سن الرشد ويصير ذا أهلية أداء كاملة تخول له إجراء كافة التصرفات القانونية، ثم بعد ذلك يلحقه أحد عوارض الأهلية، عندئذ يجوز لكل ذى مصلحة طلب الحجر عليه لمنعه مطلقا من مباشرة هذه التصرفات متى كان العارض يعدمه التمييز مثل الجنون أو العته أو لمنعه من بعض التصرفات إذا كان العارض بسيطا لا يؤدي إلى انعدام التمييز ولكن يؤدي إلى المساس بحسن تقديره أو سلامة تدبيره مثل السفه أو الغفلة.

الفرع الثاني

عـوارض الأهليــة

يمكننا أن نعرف عوارض الأهلية بأنها أوصاف تلحق بالإنسان فتعدمه إدراكه وتمييزه مثل الجنون والعته، أو تخل بحسن تقديره وسلامة تدبيره مثل السفه

والغفلة [1] . وعوارض الأهلية في القانون المصري الجنون والعته، والسفه والغفلة، والتي سنعرض لها على التفصيل الآتي:-

أولا: الجنون والعته:

الجنون هو آفة أو مرض يصيب العقل فيعدمه التمييز، أما العته فهو اختلال العقل ونقصانه دون أن يبلغ مبلغ الجنون، فيجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام.

ويلاحظ على القانون المصري أنه قد سوى بين الجنون والعته في الحكم والأثر، على الرغم من أن العته في الأصل لا يعدم التمييز دائما بعكس الجنون وإنما قد يقتصر فقط على الانتقاص منه، الأمر الذي كان يستوجب التفريق في الحكم بين العته المعدم للتمييز والمساوي للجنون وبين مجرد العته المنتقص فقط من التمييز كما فعل فقهاء الشريعة الإسلامية حيث يعتبرون المعتوه غير المميز والمجنون في حكم الصبي غير المميز، أما المعتوه المميز فيأخذ حكم الصبي المميز (أي يعتبرونه ناقص الأهلية).

كما لم يفرق القانون المصري بين الجنون المطبق أو الكامل وهو الذي يصاحب الإنسان ويلازمه في جميع الأوقات، وبين الجنون غير المطبق أو المتقطع وهو الذي يلازم الإنسان وقتا ويفارقه في وقت آخر أو هو الذي لا يصاحب الإنسان في جميع أوقاته، فاعتبر الجنون سواء كان مطبقا أو غير مطبق معدما لأهلية الإنسان، ولعل هذا المسلك يحقق حماية أكبر لمصالح المجنون ويقطع دابر الخلاف والشقاق حول طبيعة الجنون ونوعه إذا ما أثيرت منازعات

---

[1] وقرب ذلك تعريف أستاذنا الدكتور عبد الناصر العطار إذ يقول إن "عوارض الأهلية هي أحوال تعتري الإنسان فتنقص أهليته أو تذهب بها" بند ١٨٩، ص ٣٨٧ .

بشأن تصرفات المجنون [1].

وإذا ثبت بلوغ الشخص رشيدا عاقلا ثم طرأ عليه عارض الجنون أو العته، تَمَّ الحجر عليه بناء على طلب ذي المصلحة وأصدرت المحكمة قرارها بالحجر عليه فيعامل معاملة الصبي غير المميز، ويظل محجورا عليه إلى أن يثبت زوال هذا العارض عنه ، فتصدر المحكمة على إثر هذا قرارها برفع الحجر عنه وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لذلك.

حكم تصرفات المجنون أو المعتوه:

لقد فرق القانون في حكمه بين التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر عليه، وبين تلك التصرفات التي تصدر منه بعد تسجيل قرار الحجر.

١- حكم التصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر:

الأصل العام أن التصرفات التي تصدر عن المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر عليه تعد تصرفات صحيحة أيا كانت طبيعتها، أي حتى وإن كانت تصرفات ضارة ضررا محضا كما لو تبرع المجنون بماله أو بجزء منه.

ولعل هذا الحكم يمثل من وجهة نظري أحد تطبيقات الحماية القانونية للوضع الظاهر، لأن الغير إذا تعامل مع شخص بالغ رشيد في أي تصرف من التصرفات ولم يكن يعلم بعارض الجنون أو العته المصاب به ولم تكن حالة جنونه شائعة، تنبغي حمايته لاسيما وأن الوضع الظاهر لا يفيد بجنون من يتعامل معه أو عتهه.

---

[1] انظر في هذا المعنى: أ.د/ حسن كيره بند ٢٩٩، ص ٥٨٥، حيث يحمد سيادته لواضع القانون عدم تفرقته في الحكم بين الجنون المطبق والجنون المنقطع قائلا "وحسنا فعل، لأن ذلك أدعى إلى الحسم والقطع في أمر كهذا يستعصى على الإثبات ويفتح الباب واسعا لكثير من المنازعات" .

غير أنه تبطل تصرفات المجنون أو المعتوه الصادرة منه قبل تسجيل قرار الحجر في حالتين :-

أ- **الحالة الأولى:** إذا كانت حالةُ الجنون أو العته شائعةً ومعروفةً وقت صدور التصرف، حتى وإن كان من تعاقد مع المجنون أو المعتوه لا يعلم بذلك. حيث كان من الواجب عليه أن يستعلم عن حالته العقلية لاسيما وأنها شائعةٌ بين الناس.

ب- الحالة الثانية: إذا كان الطرف المتعاقد مع المجنون أو المعتوه يعلم بحالته، حتى ولو لم تكن حالة الجنون أو العته شائعة بين الناس، كما لو كان الطرف الآخر في التصرف قريبا للمجنون أو المعتوه أو جاراً له مما أتاح له فرصة العلم بحالته رغم عدم شيوعها بين الناس.

٢- حكم التصرفات الصادرة بعد تسجيل قرار الحجر.

لقد اعتبر القانون التصرفات الصادرة من المجنون أو المعتوه بعد تسجيل قرار الحجر تصرفات باطلة بطلانا مطلقا، وذلك أيا كانت طبيعتها أي حتى وإن كانت تصرفات نافعة نفعا محضا.

ولعل هذا كله هو عين ما نصت عليه المادة ١١٤ مدنى بقولها "١- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر".

"٢- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها".

ثانيا: السفه والغفلة:

يمكننا تعريف السفه بأنه التبذير والإسراف في إنفاق المال على خلاف

مقتضى الشرع والعقل، أما الغفلة فهي السذاجة المفرطة التي تحول دون إدراك الرابح أو الخاسر من التصرفات فتؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الغبن عادةً.

والسفه والغفلة بوصفهما عارضين من عوارض الأهلية لا يعدمان التمييز تماما لدى الشخص بعكس الجنون والعته، ولكن يؤثران فقط على حسن تقديره وسلامة تدبيره للأمور، من أجل ذلك لم يعامل القانون السفيه أو ذا الغفلة معاملة الصبي غير المميز ولكنه عاملهما معاملة الصبي المميز.

وإذا كان السفيه أو ذو الغفلة صغيرا لم يبلغ سن الرشد ثم بلغها سفيها أو ذا غفلة استمرت الولاية أو الوصاية عليه، أما إذا بلغ الصغير سن الرشد عاقلا ثم أصابه عارض السفه أو الغفلة، جاز طلب الحجر عليه، وتصدر المحكمة قرارها بالحجر بعد ثبوت السفه أو الغفلة وتقيم المحكمة قيماً على السفيه أو ذي الغفلة بعد الحجر عليه لإدارة أمواله، ولا يرفع هذا الحجر عنه إلا بقرار من المحكمة [1] .

حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة:

يفرق القانون – بصفة عامة – بين تصرفات السفيه وذي الغفلة الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر، وتلك التي تصدر عنهما بعد تسجيل قرار الحجر.

فالتصرفات الصادرة من السفيه أو ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر تعد صحيحة أيا كانت طبيعتها، أي سواء كانت تصرفاتٍ ضارةً ضرراً محضاً أو نافعةً نفعاً محضاً أو دائرةً بين النفع والضرر، ولا تكون باطلةً أو قابلةً للإبطال فتأخذ حكم التصرفات الصادرة بعد تسجيل قرار الحجر إلا في حالتين:

<u>أولاهما:</u> إذا كان ثمة استغلالٌ من جانب المتعاقد الآخر للسفيه أو ذي الغفلة لابتزاز أمواله.

---

[1] أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٩١، ص ٣٩٠، ٣٩١ .



وثانيهما: إذا كان هناك تواطؤٌ بين السفيه أو ذي الغفلة وبين من تعاقد معه لتبديد أمواله مخافة الحجر عليه أو الحجز عليها من دائنيه .

أما التصرفات الصادرة من السفيه أو ذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر عليه، فإنها تأخذ حكم تصرفات الصبي المميز فتكون باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت ضارة ضررا محضا، وتكون قابلة للإبطال لمصلحة السفيه أو ذى الغفلة إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، وتكون صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محضا.

ولعل هذه الأحكام سالفة الذكر هي عين ما نصت عليه المادة ١١٥ من التقنين المدني بقولها "١- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات المميز من أحكام".

"٢- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ".

وإذا كانت الأحكام السابقة تمثل الأصل العام بالنسبة لتصرفات السفيه وذي الغفلة، إلا أن واضع القانون قد خرج عليها – على سبيل الاستثناء- في حالتين اثنتين هما:-

(١)- الحالة الأولى:

تنص عليها المادة ١١٦/ ١ مدني بقولها "يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحا متى أذنته المحكمة في ذلك".

ويستفاد من هذا النص أن المحجور عليه لسفه أو غفلة يصير ذا أهلية أداء كاملة في التصرف في ماله بالإيصاء أو بالوقف متى أذنته المحكمة في ذلك خروجا على الأصل العام، والذي كان يقتضي اعتبار هذا التصرف باطلا بطلانا

مطلقا لكونه من التصرفات الضارة ضررا محضا.

(٢) الحالة الثانية:

تنص عليها المادة ١١٦/ ٢ بقولها "وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون".

ويظهر من النص سالف الذكر أن السفيه أو ذا الغفلة متى أذنته المحكمة في تسلم أمواله كلها أو بعضها كان ذا أهلية أداء كاملة بشأن أعمال الإدارة اللازمة لها، بحيث يكون له الحق إذا كانت هذه الأموال أرضا زراعية مثلاً أن يؤجرها ويقبض أجرتها بنفسه، وأن له مباشرة أعمال التصرف اللازمة لإدارتها كأن يشتري أسمدةً لها أو يشتري الأدوات الزراعية الخاصة بها، ولكنه لا يملك التصرف فيها بالبيع أو بالتبرع.

وإلى جانب هذين الاستثنائين اللذين نصَّ عليهما القانون يجيز جانب من الفقه – وبحق – للسفيه وذي الغفلة مباشرة بعض التصرفات المصرح بها للصبي المميز والتي تتناسب مع العارض الذي يعتريه مثل أن يرخص له بوصفه عاملا في إبرام عقد العمل الفردي وأن يرخص له أيضا بالتصرف في الأموال المخصصة لأغراض نفقته الشخصية، وفي التصرف في المال الذي يكسبه من عمله الخاص، أما التصرفات الأخرى المسموح بها للصبي المميز ولكنها تتعارض وحالة السفيه أو ذي الغفلة فلا يرخص لهما بمباشرتها مثل الإذن له بالاتجار في أمواله مثلما يؤذن للصبي المميز الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره بالاتجار في أمواله بإذن المحكمة، لأن التجارة تقتضي سلامة التقدير وحسن التدبير وهذا ما لا يتوافر في السفيه وذي

الغفلة [1] .

الفـرع الثالـث

مـوانع الأهـلية

يمكننا أن نعرف موانع الأهلية بأنها أحوال أو ظروف (سواء كانت مادية أو طبيعية أو قانونية) يتعرض لها الإنسان، فتمنعه رغم كمال أهليته من مباشرة التصرفات القانونية أو توجب إشراك غيره معه في مباشرتها.

فالأصل أن الإنسان متى بلغ سن الرشد دون أن يعتريه أحد عوارض الأهلية (مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة) كان ذا أهلية أداء كاملة يملك أن يباشر بنفسه كافة التصرفات القانونية أيا كانت طبيعتها (أي سواء كانت نافعة نفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع والضرر)، ولكن قد تستجد له ظروف وأحداث لا تنال من سلامة عقله ولا حسن تدبيره وتقديره تمنعه من مباشرة شئون أمواله بنفسه رغم كمال أهليته بحيث ينوب عنه غيره في مباشرتها كما لو غاب أو فقد (بوصفه مانعا ماديا) ولم تعرف حياته من مماته، أو حكم عليه بعقوبة جنائية فتعذر عليه لكونه خلف أسوار السجن أن يقوم بإدارة أمواله (بوصفه مانعا قانونيا) أو أصيب بعاهتين من ثلاث عاهات وهم الصمم والبكم والعمى مما يستوجب تعيين شخص بوصفه مساعدا له يشاركه في هذه الإدارة (باعتباره مانعا طبيعياً).

إذن موانع الأهلية في القانون المصري ثلاثة إما أن يكون مانعا مادياً وهو الغيبة، أو مانعا قانونيا وهو الحكم بعقوبة جنائية، أو مانعا طبيعيا وهو الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسمانى شديد.

---

[1] أ.د/ حسن كيره بند ٣٠٠، ص ٥٩٠ .

أولا: الغيبة :

تنص المادة ٧٤ من قانون الولاية على المال على أن "تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه".

"أولا – إذا كان مفقودا لا تعرف حياته أو مماته".

"ثانيا – إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها".

ويتضح لنا من النص سالف الذكر أن الغيبة بوصفها مانعاً مادياً تحول بين الشخص وتولي شئون أمواله بنفسه، ترخص للمحكمة رغم كمال أهليته أن تختار وكيلاً عنه ليتولى إدارة شئونه ومصالحه بهدف المحافظة عليها من الضياع والهلاك والركود، متى انقضت سنة فأكثر على غيبته ولم تعرف له حياة من ممات أو عرفت حياتُه ولكن لم يستدل له على موطن أو محل إقامة معلوم داخل الجمهورية أو كان موطنه أو محل إقامته معلوماً ولكن خارج الجمهورية بما يستحيل معه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها.

ويراعى أنه إذا كان الشخص قبل غيابه قد ترك وكيلاً عنه، فإن المحكمة تصدرُ قراراً بتثبيته إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت شخصاً آخر غيره (م ٧٥ من قانون الولاية على المال).

وتنتهي الغيبة بزوال سببها أي برجوع الغائب فيتولى بنفسه إدارة شئونه ومصالحه، كما تنتهي بموت الغائب حقيقةً أو بموته حكما –أي بصدور حكم قضائي باعتباره ميتا – (م ٧٦ من قانون الولاية على المال)، فتنتقل أمواله وتركته إلى ورثته.

ثانياً : الحكم بعقوبة الجناية

يترتب على الحكم على الشخص بعقوبة الجناية المتمثلة في الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن، منع الشخص من إدارة أمواله مدة اعتقاله . حتى لا يستعين بها في التمرد على تنفيذه مدة العقوبة المحكوم بها عليه، ويتولى القيام بهذه المهمة قيمٌ يختاره المحكوم علية وتقره المحكمة عليه ، وإلا عينت له المحكمة قيماً بناء على طلب النيابة العامة أو صاحب المصلحة في ذلك، ولا يملك المحكوم عليه التصرف في أمواله مدة اعتقاله إلا بعد استئذان المحكمة، فإن أذنت له صح تصرفه وإلا كان تصرفه باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر هذا التصرف بغير إذن المحكمة (م ٢٥ عقوبات).

ويلاحظ أن القانون يقصر هذا المانع باعتباره عقوبة تبعية على المحكوم عليه بعقوبة الجناية فقط دون عقوبة الجنحة أو المخالفة نظرا لخطورة الجناية وشناعة أثرها على الفرد والمجتمع، مما ناسب معها حرمان الشخص المحكوم عليه بعقوبة الجناية من إدارة أمواله وتقييد سلطته في التصرف فيها، هذا فضلا عن أن هذه العقوبة التبعية تحول دون المحكوم عليه ومحاولة استغلال ثرواته للهرب من السجن والإفلات من العقاب.

ثالثا: العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد:

قد يتعرض الشخص (رغم كمال أهليته وعدم ورود أي عارض عليها من عوارض الأهلية) للإصابة بعاهتين اثنتين من عاهات ثلاث وهي الصمم والبكم والعمى، فيكون أعمى أصما أو أصما أبكما أو أبكما أعمى، بما يعجزه عن الإلمام بواقع المعاملات وظروفها أو يحول دونه والتعبير عن إرادته في هذه المعاملات تعبيرا واضحا ومفهوما، مما قد يؤدى إلى الإضرار بمصالحه الخاصة، أو يتعرض الشخص رغم سلامته من هذه العاهات لعجز جسماني شديد مثل الشلل النصفي أو



الكلى الذي يخشى معه من انفراد الشخص بمباشرة شئونه والتصرف في أمواله، ففي مثل هذه الحالة وأشباهها يجيز القانون تعيين مساعد قضائي يتولى معاونة هذا الشخص في مباشرة كافة صور التصرف في أمواله بناء على طلب الشخص المطلوب مساعدته أو غيره من ذوى الشأن .

ويعرض أمر تعيين المساعد القضائي على المحكمة، وهي لا تصدر قرارها بالموافقة على ذلك إلا بتوافر هذين الشرطين:-

١- **الشرط الأول:** أن يكون الشخص مصابا بعاهتين من العاهات الثلاث الآتية: الصمم ، البكم ، العمى أو أن يكون به عجز جسماني شديد.

٢- **الشرط الثاني:** أن يترتب على إصابته بهاتين العاهتين أو بالعجز الجسماني الشديد، عدم قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرا واضحا ومفهوما أو يخشى عليه بسبب ذلك من انفراده بهذا التعبير.

وإذا أصدرت المحكمة قرارها بتعيين المساعد القضائي لمعاونة الشخص وجب اشتراكهما معا في مباشرة جميع التصرفات، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون مشاركة الآخر له في إبرامه، ومن ثمَّ إذا انفرد المساعد بالتصرف دون مشاركة من تقررت المساعدة لمصلحته، لم يكن تصرفه نافذا في حق ذي العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد، وإذا انفرد ذو العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد بالتصرف دون مشاركة المساعد له كان تصرفه قابلا للإبطال ، هذا إذا كانت مصلحته في ذلك وكان التصرف قد صدر منه بعد تسجيل طلب أو قرار المساعدة، أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل طلب أو قرار المساعدة فلا يكون التصرف قابلا للإبطال إلا إذا كان المتعاقد معه سيء النية (م ١١٧/ ٢ مدني، م ١٠٢٨ مرافعات).

وإذا كان القانون يوجب الاشتراك على النحو سالف الذكر، إلا أنه من

المتصور أن تتعارض رغبات كل واحد منهما بشأن التصرف الواحد، وفي هذه الحالة ينبغي عرض الأمر على المحكمة للترجيح بين رغبتيهما، فمثلا إذا أراد ذو العاهتين أو العجز الجسماني الشديد إبرام تصرف معين وطلب من المساعد أن يشاركه في ذلك ولكنه لم يستجب، جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للشخص أن ينفرد بالتصرف أو عينت له شخصا آخر للمساعدة في إبرامه، وكذلك الحال يمكن للمحكمة أن تأذن للمساعد بالانفراد بتصرف معين إذا كان في امتناع الشخص الذي تقررت له المساعدة عن هذا التصرف مما يعرض أمواله للخطر (م ٧١ من قانون الولاية على المال).

المبحث الرابع

الذمة المالية للشخص الطبيعي

أولا: تعريف الذمة المالية:

يقصد بالذمة المالية **Le patrimoine** في فقه القانون مجموع ذلك الكيان أو الوعاء الذي يضم ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات ذات صفة مالية [١]، وهي بذلك المعنى تمثل الجانب المالي في الشخصية القانونية، إذ يقصد بالشخصية القانونية صلاحية الشخص أو قابليته لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات أيا كانت طبيعتها (أي بصرف النظر عن كونها حقوقا مالية أو غير مالية).

والذمة المالية بمعناها سالف الذكر تنطوي على عنصرين: عنصر إيجابي Un élément positif يعبر عن حقوق الشخص المالية، والتي تمثل عنصر الدائنية في ذمته، وعنصر سلبى Un élément négatif يعبر عن الواجبات

---

[١] انظر في ذلك إلى: أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٦٠، أ.د/ نعمان جمعة ص ٤٨٤، أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٦٢، ص ٣٤٤ .

والالتزامات المالية التي تقع على عاتق الشخص، والتي تمثل عنصر المديونية في ذمته.

وتتعلق الذمة المالية بحسب تعريفها السابق بالحقوق والواجبات ذات الطابع المالي فقط، أي بالحقوق والواجبات التي يمكن إخضاعها للتقويم الاقتصادي أو التقدير المالي، أما الحقوق والواجبات غير المالية، أي الحقوق والواجبات التي تكون محالها قيم واعتبارات أدبية تستعصي على التقويم الاقتصادي، فهي تخرج عن نطاق الذمة المالية.

ولعل من أمثلة الحقوق المالية التي تتعلق بفكرة الذمة الحقوق العينية (مثل حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر) والحقوق الشخصية (أي مكنة اقتضاء أداء معين من الغير سواء كان عملا أو امتناعا عن عمل أو التزاماً بإعطاء)، والحقوق الذهنية في جانبها المالي (مثل حق الاستغلال المالي للمصنف)، أما الحقوق غير المالية فمن أمثلتها الحقوق السياسية (مثل حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولى الوظائف العامة) وحقوق الشخصية أو حقوق الإنسان (مثل حق الإنسان في حياته وسلامة بدنه وصيانة شرفه واعتباره ..... إلخ) وحقوق الأسرة في عناصرها غير المالية مثل حق الأب في تربية أولاده وتهذيبهم وحق الزوج في طاعة زوجته له، أما حقوق الأسرة في جانبها المالي مثل حق النفقة وحق الإرث فهي ترتبط بفكرة الذمة، كما يدخل في الحقوق غير المالية الحقوق الذهنية في جانبها الأدبي فهي لا ترتبط بفكرة الذمة [١].

كما أن من أمثلة الواجبات ذات الطابع المالي فترتبط بفكرة الذمة الالتزام بعمل والالتزام بامتناع عن عمل والالتزام بإعطاء [٢]، أما الواجبات غير المالية التي

---

[١] أ.د/ نعمان جمعة ص ٤٨٤ .

[٢] يقصد بالالتزام بإعطاء أي الالتزام بنقل حق عينى أي بنقل حق الملكية أو بنقل أي حق عينى آخر (سواء كان

تخرج عن نطاق فكرة الذمة فمثالها الواجب العام باحترام حقوق الغير، وواجب أداء الخدمة العسكرية [١].

وتجدر الإشارة إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية يعطون للذمة معنى أكثر رحابة وسعة من معناها في فقه القانون إذ يعرفونها بأنها وصف شرعي يُقَدَّرُ وجوده في الإنسان ليكون صالحا للإلزام أو للالتزام، وهي بذلك تثبت لكل إنسان لأنه يصلح للإلزام والالتزام، ولعل هذا المعنى كما يرى البعض –وبحق– يُقَرِّبُ معنى الذمة في الفقه الإسلامي من معنى الشخصية القانونية في فقه القانون [٢].

ثانيا: الطبيعة القانونية للذمة المالية.

لقد ظهرت في الفقه نظريتان حاولتا البحث عن الطبيعة القانونية للذمة المالية، فذهبت إحداهما إلى ربط الذمة المالية بالشخصية أي بالإنسان فعرفت باسم "نظرية الشخصية"، وذهبت الأخرى إلى الفصل بين الذمة المالية والشخصية، وصورت الذمة على أنها لا تعدو عن كونها مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تخصص لغرض معين بصرف النظر عن وجود شخص تستند إليه، فعرفت هذه النظرية باسم "نظرية التخصيص" [٣].

١– <u>نظرية الشخصية:</u> هذه النظرية هي النظرية التقليدية في بيان التكييف القانوني للذمة المالية، وقد قال بها الفقيهان الفرنسيان Aubry et Rau ، وهي تنظر إلى الذمة المالية على أنها تمثل الجانب المالي في الشخصية القانونية أو

حقا عينيا أصليا مثل حق الانتفاع أو حق الاستعمال أو حق السكنى، أو حقا عينيا تبعيا مثل حق الرهن الرسمى، وحق الرهن الحيازى وحق الاختصاص وحق الامتياز) على شئ معين بالذات.

[١] أ.د/نعمان جمعة ص ٤٨٤، ٤٨٥ .

[٢] أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٦٢، ص ٣٤٤ .

[٣] انظر في عرض هاتين النظريتين بالتفصيل إلى: أ.د/ نعمان جمعة ص ٤٩٢ وما بعدها، أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٦٢، ص ٣٤٦، ٣٤٧، أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٦١ .

هي الشخصية القانونية منظوراً إليها من الناحية الاقتصادية، ومن ثمَّ فهي تعنى الصلاحية أو القابلية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات ذات الطابع المالى، وبذلك يربط أنصار هذه النظرية الذمة المالية بالشخصية (أي بالإنسان) ويعدونها جزءا من شخصيته القانونية، ورتبوا على هذا التصوير النتائج الآتية:-

أ- إن الشخص القانوني أو الإنسان هو وحده الذي تكون له ذمة، فلا تثبت لغيره، لأنه وحده هو الذي يصلح لأن يكون صاحب حق أو مكلفا بواجب.

ب- إن لكل شخص (أي إنسان) ذمة، فهي تثبت له بمجرد ولادته حياً، نظرا لأن الشخصية القانونية (أي صلاحية اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات) تثبت للإنسان بمجرد ولادته حيا، والذمة جزء من شخصيته القانونية، إذن لكل إنسان ذمة، فلا يتصور وجود إنسان دون أن تكون له ذمة لأن لكل إنسان شخصية قانونية والذمة جزء من هذه الشخصية.

ج- إن الإنسان لا تكون له إلا ذمة مالية واحدة غير قابلة للتجزئة، نظرا لأن الذمة جزء من شخصيته القانونية، والشخصية القانونية وحدة واحدة لا تقبل التجزئة فكذلك الحال ذمته المالية فهي كيان واحد لا يقبل التجزئة.

ومن ثم يرى أنصار هذه النظرية أن الشخص ليس في مقدوره أن يجزئ ذمته المالية فيقسمها إلى عدة أجزاء أو مجموعة تقسيمات فيربط مثلا مجموعة من ديونه بمجموعة من حقوقه التي تمثل بعض عناصر ذمته المالية، نظرا لأن الذمة المالية بوصفها كياناً واحداً يعد وحدة واحدة لا تتجزأ.

د- إن الذمة المالية ترتبط بالشخص فهي جزء من شخصيته القانونية ولذا فهي تتمتع بكل ما لشخصيته القانونية من خصائص أبرزها وأهمها عدم قابليتها للتنازل أو الحجز أو السقوط بالتقادم.

بل إنهم يرون أن انتقال أموال المورث إلى ورثته لا يعنى انتقال ذمته إلى

ذمتهم، على أساس أن الوارث يعد امتداداً لشخصية مورثه، فلا يوجد انتقال للذمة وإنما هو استمرارٌ لها مع اندماجها في ذمة الوارث.

نقد هذه النظرية :

لقد تعرضت هذه النظرية للنقد من عدة زوايا، فمن ناحية قد ربط أنصارها بين الذمة والشخصية القانونية إلى حد الخلط بينهما، هذا فضلا عن أن القول بأن الذمة المالية لا تنتقل إلى الغير قول محل نظر، إذ يكذبه الواقع لأن ذمة الشخص تنتقل فعلا إلى ورثته بما تحمله من حقوق وواجبات (على أن يراعى أن الورثة لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود عناصر ذمته المالية)، ومن ثمَّ فقد أضحى نفي هذا الانتقال (بدعوى أن انتقال أموال المورث إلى ورثته لا يعنى انتقال ذمة هذا المورث إلى ذمتهم بقدر ما يعنى استمرار ذمته واندماجها في ذمة الوارث، واعتبار شخصية الوارث امتداداً لشخصية مورثه) متجافيا مع الحقيقة والواقع، لأن ذمة المورث تنتقل فعلا إلى ذمة ورثته، كما أن للوارث شخصية مستقلة تماما عن شخصية المورث.

ومن ناحية ثالثة ليس صحيحا ما ذهب إليه أنصار هذه النظرية من أن الذمة وحدة لا تقبل التجزئة، إذ توجد فروض عملية كثيرة يُتَصَوَّرُ معها وجود أكثر من ذمة مالية للشخص الواحد، ويكون لكل ذمة منهم ذاتيتها الخاصة ونظامها القانوني المستقل عن غيرها، فمثلا بالنسبة للقاصر الذي بلغ سن السادسة عشرة من عمره يرخص له القانون في التصرف في الأموال التي يكسبها من عمله الخاص بشرط ألا تتجاوز مسئوليته عن هذا التصرف حدود هذه الأموال (م ٦٣/ ١ من قانون الولاية على المال)، إذ يفهم من ذلك بوضوح أن القانون يجعل للقاصر ذمتين مستقلتين إحداهما تتعلق بحقوقه وواجباته بصفة عامة، والأخرى تقتصر على أمواله التي كسبها من عمله الخاص وما يرتبط بها من التزامات نشأت عن

أعمال الإدارة أو التصرف التي صدرت عن القاصر بشأن هذه الأموال.

٢- نظرية التخصيص:

يميل أنصار هذه النظرية إلى الفصل بين الذمة والشخصية القانونية، وينظرون إليها على أساس أنها مجموعة من الحقوق والواجبات التي تخصص لغرض معين، فليس ضروريا نسبة هذه المجموعة إلى شخص معين، فمعيار الذمة ليس هو الشخص الذي تنسب إليه الحقوق والواجبات وإنما هو الهدف الذي تسعى هذه المجموعة إلى تحقيقه.

ويرتب أنصار هذه النظرية على تصويرهم للذمة بأنها مجموعة من الحقوق والواجبات التي تسعى إلى غرض معين النتائج الآتية:-

أ- ليس حتميا أن تنسب الذمة إلى شخص قانوني.

ب- ليس حتميا أن يكون للشخص ذمة، على أساس أن الذمة ليست مجرد تصوير قانوني يمكن إلصاقه حكميا بأي شخص، ولكنها واقع يستند إلى وجود مجموعة فعلية من الحقوق والديون تسعى إلى هدف معين، وبناء عليه إذا انتفي وجود هذا الواقع لا يكون ثمة مجال للحديث عن الذمة.

ج- إنه من المتصور أن يكون للشخص أكثر من ذمة، فالذمم تتعدد بتعدد المجموعات من الحقوق والواجبات ذات الهدف الواحد.

د- يمكن انتقال ذمة الشخص إلى غيره سواء كان ذلك بطريق الميراث أو بطريق التصرف، فالأمر يتعلق بمجموعة واقعية من الحقوق والواجبات غير اللصيقة بشخص صاحبها، ومن ثم كان من الجائز انتقالها إلى الغير.

هـ- ليس ثمة ما يدعو للإبقاء على فكرة الشخص المعنوي، على أساس أن الشخصية القانونية لا يمكن أن تكون لغير الإنسان، أما خارج نطاق الإنسان فلا

مجال للاعتراف بكيان قانوني إلا لمجموعات الحقوق والواجبات التي تسعى إلى هدف معين، وهذه المجموعات لا تحتاج إلى نسبتها إلى شخص معين وهي تؤدى نفس غرض الشخص المعنوي، فالشركة أو المؤسسة ليست سوى مجموعة من الأموال الموجهة لتحقيق غرض معين.

نقد هذه النظرية:

لم تَسْلَمْ هذه النظرية أيضا من الانتقاد من عدة زوايا، فمن ناحية يؤخذ عليها إنكارها لفكرة الشخص المعنوي والذي يتعارض مع موقف القانون في كل دول العالم. إذ يعترف القانون بالشخصية المعنوية لمجموعات الأموال أو الأشخاص التي تنشأ لتحقيق أغراض معينة (مثل مباشرة نشاط اقتصادي أو اجتماعي معين) ويكون لها كيان قانوني مستقل عن الأشخاص المؤسسين لها، ومن ناحية أخرى ليس صحيحا ما تذهب إليه هذه النظرية من أن الذمة لا تقتضى وجود شخص تنسب إليه، لأن الذمة ما هي إلا مجموع من الحقوق والواجبات وهذا يقتضى وجود شخص تنسب إليه إذ لا يتصور وجود حق أو واجب دون أن يكون هناك شخص يمكن نسبته إليه سواء كان هذا الشخص شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ومن ناحية ثالثة فإن القول بتعدد ذمم الشخص الواحد بصفة مطلقة لا يخلو من عنصر الخطورة، لما يترتب على ذلك من صعوبة التعامل، فضلا عن أنه يساعد على سهولة التلاعب من جانب الشخص ليتهرب من دائنيه بإنشاء ذمم مستقلة تكون بمنأى عن مطالبتهم ويدخل فيها ما لديه أو ما يكتسبه من الحقوق.

وعلى أية حال فالذمة المالية هو مجموع ما للشخص من حقوق وواجبات مالية، فهي كيان أو فكرة تتميز عن الحقوق والواجبات التي تحتويها، فهي أشبه بوعاء لهذه الحقوق والواجبات يتغير ما بداخلها وهي باقية كما هي [1]، أو هي

---

[1] أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٦٢، ص ٣٤٤، ٣٤٥ .

عبارة عن تصوير قانوني يقع على عنصر معنوي ينسب إلى الشخص القانوني فيعكس حالته المالية إيجابا وسلبا، فهي فكرة معنوية لها ذاتيتها التي لا تختلط مع الحقوق والواجبات المالية للشخص، ومن ثمَّ فهي أشبه بالوعاء أو السجل الذي يقيد فيه حقوق الشخص وواجباته، فيضيق ويتسع بضيق واتساع حجم الحقوق والواجبات التي يتضمنها [١].

المبحث الخامس

أحكـام الولايــة على المـال

أولاً: الفرق بين أهلية الأداء والولاية على المال:

لا غرو في أن تمتع الشخص بأهلية أداء كاملة غير مشوبة بأي عارض من عوارض الأهلية (مثل عارض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة)أو مانع من موانع الأهلية (مثل الغيبة باعتبارها مانعا ماديا أو العجز الجسماني بوصفه مانعاً طبيعياً أو الحكم على الشخص بعقوبة الجناية بوصفه مانعا قانونياً)يجعله أهلا لمباشرة كافة التصرفات القانونية بنفسه ولحسابه بصورة منتجة لآثارها القانونية في حقه، مما لا يعوزه إلى ولاية الغير على شئونه المالية.

ومن ثم فإن الولاية [٢]على المال تفترض أن الشخص الذي تلزم له الولاية على أمواله من الغير، شخص لا يملك الأهلية اللازمة للتعبير عن إرادته تعبيراً

---

[١] أ.د/ نعمان جمعة ص ٤٨٦، ٤٨٧ .

[٢] الولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال، وتكون الولاية على النفس في المسائل المتعلقة بشخص المولى عليه كولاية التعليم والحضانة وولاية التزويج في حين أن الولاية على المال تكون في المسائل المالية الخاصة بالمولى عليه،وقد قصرنا الدراسة على أحكام الولاية على المال دون الولاية على النفس،على أساس أن الولاية على النفس تدخل في مجال دراسة مسائل الأحوال الشخصية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالزواج وآثاره فتخضع–من ثم –لقواعد الأديان المختلفة فيما لم ترد به نصوص تشريعية (انظر في ذلك إلى: أ.د/ حسن كيره – المرجع السابق – بند ٣٠٦، ص: ٥٩٧، أ.د/ عبد الناصر العطار – بند ١٩٣، ص : ٣٩٧) .

منتجاً لآثاره القانونية في ذمته، ويستوي بعد ذلك أن يكون عدم قدرته على مباشرة شئونه المالية راجعا إلى انعدام أهليته (كما هو الحال في الولاية على عديم التمييز ومن في حكمه من المجانين والمعتوهين) أو إلى نقصان هذه الأهلية (كما هو الحال في الولاية على القاصر أي الصبي المميز ومن في حكمه من السفهاء وذوي الغفلة) أو إلى وجود مانع من موانع الأهلية رغم اكتمال الأهلية (كما هو الحال بالنسبة للغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية وذي العاهتين أو المصاب بالعجز الجسماني الشديد).

ويظهر لنا مما سبق أنه إذا كانت أهلية الأداء تعني صلاحية الشخص وقدرته على أن يتولى بنفسه ولحسابه مباشرة كافة التصرفات القانونية على نحو ينتج أثرها القانوني في حقه، فإن الولاية على المال تعني صلاحية الشخص وقدرته على مباشرة التصرفات القانونية باسم ولحساب غيره(الذي يفتقر إلى أهلية الأداء اللازمة للتعبير عن إرادته تعبيراً منتجاً لأثره القانوني في حقه) بصورة منتجة لآثارها القانونية في مواجهة ذلك الغير.

ومن ثمَّ فإن الولاية على المال حينما تثبت على شخص ما فهي تعني عدم تمتعه بأهلية الأداء اللازمة للتعبير عن إرادته تعبيراً ذا أثر قانوني في ذمته المالية وافتقاره – من ثم –إلى ولاية غيره، وتعنى في نفس الوقت أن ذلك الغير الذي تثبت له هذه الولاية يملك أهلية الأداء اللازمة للتعبير عن إرادة غيره تعبيرا منتجا لأثره القانوني في مواجهة ذلك الغير،كما يملك أيضاً من باب أولى هذه الأهلية الكاملة بالنسبة لشئونه المالية لأنه من غير المتصور أن يملك بالنسبة لغيره ما لا يملكه بالنسبة لنفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

وإلى جانب الاختلاف بين الولاية على المال والأهلية من حيث ماهية ومعنى كل منها، فإن ثمة اختلافا آخر بينهما من حيث الجزاء، ذلك أن الجزاء

القانوني المترتب على مخالفة أحكام الولاية على المال من جانب صاحب الولاية يتمثل في عدم نفاذ تصرفه في حق المولى عليه، على الرغم من صحته (نظرا لصدور التصرف من شخص يملك الأهلية المطلوبة لصحته) في حين أن الجزاء القانوني المترتب على مخالفة أحكام الأهلية يتمثل في بطلان التصرف أو قابليته للبطلان تبعا لنوع البطلان (أي بحسب كونه بطلاناً مطلقا أو بطلانا نسبياً والذي يتوقف على مدى أو درجة الأهلية التي يمتلكها المتصرف على نحو يخالف به أحكام الأهلية) [1].

ثانياً:القانون المنظم لأحكام الولاية على المال:

بادئ ذي بدء ينبغي أن نفرق في هذا الصدد بين التنظيم الموضوعي لنظام الولاية على المال والتنظيم الإجرائي له،ففيما يتعلق بالتنظيم الموضوعي يجرى تطبيق قواعد القانون رقم١١٩ لسنة ١٩٥٢ م (قانون الولاية على المال) فقد أحال القانون المدني إلى قانون ينظم الجانب الموضوعي للولاية على المال، فنصت المادة ٤٧ من القانون المدني على أن" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للأوضاع المقررة في القانون"، ثم بعد صدور القانون المدني صدر قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢م ليجرى تطبيقه على الجانب الموضوعي من نظام الولاية على المال،أما ما يتعلق بالتنظيم الإجرائي لنظام الولاية على المال فقد نظمها واضع القانون في الكتاب الرابع من تقنين المرافعات الملغى رقم٧٧ لسنة ١٩٤٩ م، وهو الكتاب المخصص للإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية، حيث ظلت نصوصه باقية رغم صدور ونفاذ تقنين المرافعات الجديد رقم ١٣ لسنة١٩٦٨م لتحكم الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها إجراءات

---

[1] انظر في نفس المعنى: أ.د/ نعمان جمعة– المراجع السابق–ص:٤٧٣ .

الولاية على المال(ويضم هذا الكتاب المواد من ٨٦٨ حتى المادة ١٠٣٢) [١].

ثالثاً: أنواع الولاية على المال:

يتضمن القانون المصري صورا مختلفة للولاية على المال، فهناك الولاية على مال القصر (وهي تثبت–على ما سنرى– للأب ثم للجد الصحيح[٢].وهو والد الأب إن لم يكن هناك وصى مختار من قبل الأب قبل موته، ثم للوصي المعين من قِبل المحكمة عند عدم وجود الأب أو الوصي المختار أو الجد الصحيح)، وهناك ولاية على مال المحجور عليهم ممن بلغوا سن الرشد وأصابهم بعد ذلك عارضٌ من عوارض الأهلية مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ، وهي تثبت للقيم الذي تعينه المحكمة لإدارة أموال هؤلاء الأشخاص المحجور عليهم، وهناك ولايةٌ على مال ذوى موانع الأهلية وهي تثبت للوكيل عن الغائب إن كان المانع ماديا (ألا وهو الغيبة) وللمساعد القضائي إن كان المانع طبيعيا (ألا وهو الإصابة بعاهة مزدوجة من العاهات الثلاث–العمى، البكم، الصم–أو بعجز جسماني شديد) وللقيم إن كان المانع قانونيا (ألا وهو الحكم على الشخص بعقوبة الجناية).

المطلب الأول

الولاية على مال القصر

أولا:–من له الولاية على مال القصر:

---

[١] أ.د/ حسن كيره– المراجع السابق–٥٩٧،أ.د/ عبد النصر العطار– المرجع السابق– ص:٣٩٧،أ.د/ نعمان جمعة– المرجع السابق–ص:٤٧٣ .

[٢] وتجدر الإشارة إلى القانون يقصر إطلاق لفظ "الولى" على كل من الأب والجد الصحيح، وهذا موقف مأخوذ من فقهاء الشريعة الإسلامية (انظر :في ذلك إلى: أ.د/ حسن كيره – المرجع السابق – ص :٥٩٩) وهذا هو المعنى الضيق للولى والولاية، ذلك أن للولى معنى واسعا يضم سائر الأشخاص الذين تثبت لهم قانونا سلطة ما على شئون غيرهم المالية .

تنص المادة الأولى من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢م على أن "للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا،الولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة "ثم تنص المادة٢٩ من نفس القانون على أنه "إن لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصياً".

ويستفاد من هذين النصين أن الولاية على مال الصغار القصر تثبت أولاً للأب فهو أولى الناس بأبنائه القصر لكمال شفقته عليهم وكمال حرصه على أموالهم، هذا فضلا عن كونه أبعد الناس عن مظان الإفساد أو التضييع لهذه الأموال، ثم تثبت من بعد الأب لمن يختاره الأب قبل موته وصياً على أولاده القصر، وذلك مراعاة لرغبته واحتراما لإرادته في تحديد من يخلفه في رعاية أموالهم [١]. ثم تثبت بعد ذلك للجد الصحيح وهو والد الأب، ثم تثبت أخيرا- عند عدم وجود أحد هؤلاء الثلاثة سالفي الذكر – للوصي الذي تعينه المحكمة ليرعى أموال القصر.

وسنلقي الضوء- بمشيئة الله تعالى- على أصحاب الولاية على مال القاصر على التفصيل الآتي:

١-ولاية الولي [٢] (أي الأب والجد الصحيح):

---

[١] فالأب قد يفضل أن يختار قبل موته وصيا على أولاده الصغار أو القصر يخلفه في رعاية أموالهم درءاً لأيلولة الولاية من بعده بقوة القانون إلى أبيه، ذلك أنه وإن كان صحيحا أن الجد الصحيح يعد من أكثر أقارب النسب بعد ابنه حرصا على أموال أحفاده إلا أنه قد يفتقر في بعض الأحايين إلى مقومات الولاية الناجحة لأسباب كثيرة (سواء أكان ذلك مرده إلى شيخوخته وهرمه التي قد تعوق حركته أو إلى قلة خبرته وحنكته في إدارة الأموال، إلى غير ذلك من الأسباب) في ذات الوقت الذي يجد فيه الأب ضآلته في شخص آخر من داخل عائلته أو خارجها

[٢] إن لفظ الولى في معناه الضيق ينصرف وحسب في القانون المصري إلى الأب والجد الصحيح، وهذا اتجاه مأخوذ عن فقهاء الشريعة الإسلامية كما سلفت الإشارة .

الأصل في الولاية على مال الصغير أو القاصر أنها تثبت أولا لأبيه (فهو أولى الناس بابنه وأكثرهم حرصا على ماله) ثم تثبت من بعده للجد الصحيح (وهو أبو الأب) مادام أن الأب لم يختر وصياً على ابنه قبل موته.

ولا جرم أن ولاية الأب والجد الصحيح على مال الصغير أو القاصر ولاية طبيعية تستوجبها صلة الدم وتقتضيها رابطة القرابة المباشرة التي تجمع بين الأصل وفرعه، ولذا فهي تثبت بقوة القانون من غير حاجة إلى استصدار قرار من جانب المحكمة لتقريرها لأي منهما أو تثبيته عليها، بل أنها لا تمثل لأي منهما حقا فقط في مواجهة القاصر ولكنها تعد في نفس الوقت واجباً مفروضاً عليهما لا يملك أحدهما التنحي عنه أو التنصل من أدائه إلا بإذن من المحكمة (م١ من قانون الولاية على المال).

ويشترط في الولي أباً كان أو جداً صحيحاً لصلاحيته لمباشرة الولاية على الصغير أو القاصر ،أن يكون هو نفسه كامل الأهلية ، وهذا أمر منطقي لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا كان أهلا لمباشرته أصلاً عن نفسه هو (م٢ من قانون الولاية على المال[1]).

وبناء عليه فإنه لو حدث أن كان الولي (سواء أكان أباً أم جداً) أهلاً لمباشرة بعض حقوق الولاية دون البعض الآخر فعندئذ تثبت له الولاية فقط فيما هو أهل لمباشرته أما مما ليس هو أهلا له فتتولى المحكمة تعيين وصي على هذا المال وإدارته(م٣١/د).

٢-حدود ولاية الولي :

بداية ينبغي التنويه بأن واضع القانون قد حرص في رسمه لحدود ولاية

---

(١) تنص المادة الثانية من قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لعام ١٩٥٢ على أنه " لا يجوز للولى مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو" .

الولي– أبا كان أو جدا– وتنظيمه لسلطاته على مال الصغير أو القاصر، على مراعاة اعتبارين أساسيين:

الاعتبار الأول:

يتمثل في حماية ورعاية المصلحة الخاصة للصغير أو القاصر (على اعتبار أن ذلك يمثل الهدف والغاية من ثبوت ولاية الولي بقوة القانون على مال الصغير أو القاصر) ومن أجل ذلك فقد حظر على الولي أبا كان أو جدا مباشرة بعض التصرفات ورخص له في بعضها الآخر، كما علق الترخيص في بعضها الثالث على ضرورة الحصول على إذن مسبق من قبل المحكمة، على أساس أن الولاية ما تثبت لأي منها بقوة القانون إلا رعاية للصغير أو القاصر وحفاظا على أمواله من الضياع ورغبة في تنميتها وتزويدها حتى لا تأكلها أفواه الصدقة أو النفقة اللازمة له أو الواجبة عليه.

الاعتبار الثاني:

يتمثل في مراعاة مدى التفاوت في درجة القرابة والصلة بين الابن وأبيه والابن وجده ، فالجد ليس مثل الأب في كمال حنوه على الصغير وكمال شفقته عليه وعلى ماله، من أجل ذلك فقد أجرى واضع القانون تفاوتاً بينهما في مدى سلطات كل منهما على مال الصغير أو القاصر، فأباح للأب بعض ما حظره على الجد الصحيح، هذا بالإضافة إلى أنه قد أعفى الأب من بعض الواجبات التي ألزم الجد بأدائها وتنفيذها دون تحلل أو تنصل.

ويمكننا في ضوء هذين الاعتبارين السابقين رسم حدود ولاية كل من الأب والجد الصحيح على مال الصغير أو القاصر، لتوضيح ما يرخص لهما بإطلاق دون تقييده بالإذن المسبق من المحكمة، وما لا يرخص لهما إلا بشرط الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وما يرخص للأب دون الجد من تصرفات وما يعفي



الأب من أدائه من الواجبات على خلاف الجد، وذلك على النحو الآتي:-

أ- ما يرخص به للأب والجد دون تقييد بالإذن:

يرخص للولي أبا كان أو جدا دون تقييد بالإذن في مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضا مثل قبوله الهبة أو الوصية للصغير أو القاصر طالما أنها غير محملة بأية التزامات على عاتق الصغير أو القاصر (م١٢ من قانون الولاية على المال).

كما أنه يرخص للولي أبا كان أو جدا أيضا في مباشرة أعمال الإدارة وله على وجه الخصوص الحق في تأجير عقار الصغير أو القاصر لمدة لا تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

ب- ما لا يرخص للولي أبا كان أو جدا إلا بإذن المحكمة:

إن ثمة تصرفات معينة لا يجوز للولي أبا كان أو جدا مباشرتها إلا بعد استئذان المحكمة في ذلك وإلا كانت هذه التصرفات غير نافذة في حق الصغير أو القاصر، هذه التصرفات تتمثل فيما يلي:

١- لا يجوز للولي - أبا كان أو جداً - أن يتبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبشرط أن تأذن له المحكمة في ذلك (م٥).

٢- لا يجوز للولي - أبا كان أو جداً - أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا إذا أذنت المحكمة له بذلك، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لضمان دين عليه.

٣- لا يجوز للولي -أبا كان أو جداً -إقراض مال القاصر إلى الغير ولا اقتراضه لنفسه إلا بإذن من المحكمة(م٩).

٤- لا يجوز للولي - أبا كان أو جداً - أن يؤجر أموال القاصر لمدة تمتد

لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد إلا بإذن المحكمة(م١٠).

٥- لا يجوز للولي – أبا كان أو جداً – أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن(م١١).

٦- لا يجوز للولي – أبا كان أو جداً – أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة إلا إذا أذنت له المحكمة بذلك (م١٢).

ج- ما يرخص للأب من تصرفات دون الجد:

إنه من منطق الحرص على مراعاة التفاوت الطبيعي والمنطقي بين مقام الأب ومقام الجد الصحيح بالنسبة للصغير أو القاصر، فقد اتجه واضع القانون إلى منح الأب سلطات واسعة على مال صغيره تجاوز حدود سلطات الجد، فرخص للأب مباشرة بعض التصرفات القانونية التي يحظر على الجد أن يجريها في مال حفيده الصغير أو القاصر، نذكر منها ما يلي:

١- يجوز للأب دون الجد أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه الشخصي أم لحساب شخص آخر، هذا ما لم ينص القانون على غير ذلك (م١٤ من قانون الولاية على المال). ويعد هذا النص من قبيل الاستثناء على القاعدة العامة في النيابة في التعاقد والتي تحرم الشخص من التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان هذا التعاقد لحسابه الخاص أم لحساب شخص آخر ما لم يرخص له الأصيل (أي المنوب عنه) في ذلك (م١٠٨ مدني [١]).

٢- يجوز للأب أن يتصرف في عقار مملوك للقاصر أو محله التجاري أو أوراقه المالية إذا لم تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنية(م٧)، في حين أنه ليس للجد حق

---

[١] تنص المادة ١٠٨ من التقنين المدني على ذلك بقولها "لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة " .

في التصرف في مال القاصر أيا كانت قيمته وسواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل إلا بعد استئذان المحكمة، ويتعين عليه الحصول على هذا الإذن في التصالح على مال القاصر أو في التنازل عن تأمينات ضامنة لحقوقه أو إضعافها(م١٥ من قانون الولاية على المال).

٣- يملك الأب ولاية كاملة في التصرف في المال الذي تبرع به لابنه دون تقييد ذلك بالحصول على إذن مسبق من المحكمة أو بتقديم حساب لها عن هذا التصرف، بخلاف الجد الذي لا يملك التصرف في مال القاصر الذي تبرع له به إلا بعد استئذان المحكمة وتقديم حساب لها عن ذلك (م١٣ من قانون الولاية على المال).

٤- لا يسأل الأب في ولايته على أموال الصغير أو القاصر عن أخطائه اليسيرة وإنما يسأل وحسب عن الأخطاء الجسيمة، بخلاف الجد الذي يسأل عن أخطائه جميعها اليسير منها والجسيم، فمسئولية الجد في هذه الولاية تشبه مسئولية الوصي(م٢٤من قانون الولاية على المال).

٥- لا يلتزم الأب بتقديم حساب سنوي عن إدارته لأموال القاصر، في حين يلتزم الجد بتقديم ذلك الحساب (م٢٥،٢٦ من قانون الولاية على المال)[١].

٣- وقف الولاية وسلبها وانتهائها:

لا جرم أنه ما ثبتت الولاية على الصغير أو القاصر إلا رعاية لمصلحته، ولذا فهي تدور مع المصلحة الخاصة به وجوداً وعدماً، ومن ثَمَّ تحكم المحكمة

---

[١] إذ تنص المادة ٢٥ من هذا القانون على أن (".....ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر، ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذي وهبه للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة" وتنص المادة ٢٦ من هذا القانون على أن " تسري على الجد الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب".

بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة (م٢١ من قانون الولاية على المال)، كما أن للمحكمة الحق في سلب ولاية الولي أو الحد منها إذا ترتب على سوء تصرفه أن أصبحت أموال القاصر في خطر (م٢٠ من قانون الولاية على المال) ويمكن أن يعد من قبيل تعريض أموال القاصر للخطر امتناع الولي (أبا كان أو جدا)عن تحرير قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه أو امتناعه عن إيداعها بقلم كتاب المحكمة التي بدائرتها موطنه خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير، متى رأت المحكمة ذلك (م١٦ من قانون الولاية على المال).

وتسقط الولاية متى حكم بسلبها كما توقف بالحكم بوقفها (م٢٢من قانون الولاية على المال)، وإذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها، ولا يقبل طلب استردادها الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض (م٢٣ من قانون الولاية على المال).

وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد وهي واحد وعشرون سنة ميلادية، ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه(م١٨ من قانون الولاية على المال)، وإذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر (م١٩ من قانون الولاية على المال)، وبانتهائها يتسلم القاصر أمواله ببلوغه سن الرشد وصدور قرار المحكمة بانتهاء الولاية عليه.

ولايـــة الوصـي

تعريف الوصي:

الوصي هو كل من تثبت له الولاية على الصغير أو القاصر عدا الأب والجد الصحيح، سواء بطريق الاختيار من الأب أو بالتعيين من جانب المحكمة.

طرق تعيين الوصي:

فولاية الوصي– على خلاف ولاية الولي – لا تثبت بقوة القانون، وإنما تثبت له على مال الصغير أو القاصر بأحد طريقين:

الطريق الأول:طريق الاختيار من قبل الأب:–

إذ يجوز للأب حال حياته أن يختار وصياً على حمله المستكن أو ولده الصغير يتولى إدارة ورعاية أمواله بعد موته، وعندئذ يقدم الوصي المختار من جانب الأب على الجد الصحيح، ويلزم أن يثبت هذا الاختيار في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية مصدق فيها على توقيع الأب أو بورقة مكتوبة بخط يد الأب وموقعة بإمضائه، وأن يعرض الأمر على المحكمة لتثبيت هذا الوصي (م٢٨ من قانون الولاية على المال).

وللوصي الحرية الكاملة في قبول الوصاية أو رفضها كما أن له الحق في طلب الاستقالة بعد قبوله للوصاية على خلاف ولاية الأب أو الجد فهما لا يملكان التنحي عن الولاية أو التنصل من أدائها، هذا إلى جانب انعدام سلطتهما في قبول الولاية أو رفضها، فهي تفرض عليهما فرضا بقوة القانون، ويجوز للأب أن يعدل في أي وقت عن اختياره للوصي (م٢٨ من قانون الولاية على المال).

الطريق الثاني: طريق التعيين من قبل المحكمة:

إذا لم يكن والد الصغير حيا ولم يختر أبوه قبل موته وصيا للولاية عليه، ولم يكن له جد صحيح (وهو أبو الأب) أصدرت المحكمة قراراً بتعيين وصي يتولى إدارة ورعاية أموال القاصر، وتختاره المحكمة من بين أقارب القاصر أو من بين أهل مذهبه أو على الأقل من بين أهل ديانته (م٧/٢٧من قانون الولاية على المال).

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تقيم وصي خصومة لرفع الدعاوى لصالح القاصر ضد الولي أو الوصي أو غيرهما من الأشخاص، حتى وإن لم يكن للقاصر مال (م ٣٣ من القانون سالف الذكر).

ويجوز للمحكمة أن تعين أكثر من وصي إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليهم الاشتراك جميعاً في إدارة شئون القاصر، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بها دون بقية الأوصياء، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا محددا لكل واحد منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق عليه ، فعندئذ يكون له الحق الانفراد به، ومع ذلك يجوز لأي من الأوصياء عند التعدد حق الانفراد بإدارة شئون القاصر في الأمور العاجلة أو الضرورية أو التي تكون نافعةً نفعاً محضاً بالنسبة للقاصر، وعند الاختلاف بين الأوصياء في شأن إدارة أموال القاصر يجب رفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يجب إتباعه تحقيقا لمصلحة الصغير القاصر (م٣٠ من قانون الولاية على المال).

واجبات الوصي:

لقد حرص واضع القانون على فرض بعض الواجبات على عاتق الوصي لضمان حسن أدائه لوظيفته في إدارة أموال القاصر ورعاية مصالحه،والتي يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

١- يجب على الوصي أن يتسلم أموال القاصر لإداراتها ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور (م٣٦ من قانون الولاية على المال)، ومن ثمَّ يجب عليه بذل عناية الشخص المعتاد سواء أكانت وصايته بأجر أم بغير أجر، وذلك خلافاً للقواعد العامة التي تكتفي في الوكالة بغير أجر بأن يبذل الوكيل من العناية ما يبذله في أعماله الخاصة ولو كانت أقل من عناية

الشخص المعتاد (م٧٠٤/١ مدني [١]).

٢- يلتزم الوصي بتقديم التأمينات (سواء كانت عينية أو شخصية) بحسب القيمة التي تراها المحكمة كافية لضمان عدم إهمال الوصي أو تقصيره في إدارة ورعاية أموال القاصر متى رأت المحكمة وجوب ذلك، على أن تكون المصروفات اللازمة لتقديم هذه التأمينات على نفقة القاصر، مثل مصروفات رهن أحد أموال الوصي رهنا رسميا مثلا (م٣٧ من قانون الولاية على المال).

٣- يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى، وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة(م٤٢ من قانون الولاية على المال).

٤- يجب على الوصي أن يودع باسم القاصر كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة على القاصر والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة، لدى إحدى خزائن المحكمة أو مصرفاً من المصارف الذي تحدده المحكمة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه له، ولا يجوز له سحب شيء من هذا المال المودع إلا بإذن من المحكمة(م٤٣ من قانون الولاية على المال)،وعليه أيضاً أن يودع باسم القاصر لدى المصرف الذي تحدده المحكمة ما ترى المحكمة لزوم إيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها له، وليس له أن يسحب شيئاً منها إلا بإذن من المحكمة (م٤٤ من قانون الولاية على المال).

---

[١] تنص المادة ٧٠٤ مدنى على أنه:

١- إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

٢- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد" .

٥- يجب على الوصي أن يقدم إلى المحكمة حسابا عن إدارته مؤيداً بالمستندات قبل أول يناير من كل سنة، متى كانت أموال القاصر تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه أو كانت أقل من هذا وارتأت المحكمة ضرورة ذلك (م٤٥).

٦- يجب على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية، أن يسلم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي الجديد أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال، وعليه أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، وينتقل هذا الواجب إلى ورثة الوصي أو من ينوب عنه حسب الأحوال إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائباً(م ٥٠،٥١ من قانون الولاية على المال).

سلطات الوصي:

إنه على غرار مسلك واضع القانون في مراعاته لمدى التفاوت بين درجة قرابة كل من الجد والأب تجاه الصغير أو القاصر عند رسمه لحدود ولاية كل منهما على مال هذا القاصر أو الصغير، حيث اتجه واضع القانون أيضاً إلى عدم تجاهل صلة الدم أو رابطة القرابة المباشرة بين الصغير ووليه أبا كان أو جدا، فلم يشأ أن يجعل للوصي سلطات تحاكى سلطتيهما .

وهذا أمر منطقي لأنه قد يحدث أن تنتفي صلة القرابة بين الصغير ووصيه (إن كان الوصي المختار أو المعين من غير الأقارب) بل إنه حتى مع وجود هذه الصلة بين الصغير ووصيه (إن كان الوصي المختار أو المعين من الأقارب)، فلن يحاكى أي قريب الأبَ أو الجدَ الصحيح (الولي)في درجة قرابته للصغير أو القاصر، وسنحاول في معرض الحديث عن سلطات الوصي أن نبرز أوجه التفاوت والتشابه بين سلطاته وسلطات الولي أباً كان أو جداً، وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: بالنسبة للتصرفات النافعة نفعا محضا مثل قبول هبة أو وصية للصغير،

فللوصي سلطة كاملة في إبرامها وقبولها عن الصغير ،وفي ذلك يتساوى الوصي في سلطته مع سلطة الولي أبا كان أو جدا.

ثانياً : بالنسبة للتصرفات الضارة ضررا محضا فلا يملك الوصي– مثله في ذلك مثل الولي أبا كان أو جدا –سلطة مباشرة هذه التصرفات إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة [١].

ثالثاً : بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر: فالأصل العام في هذه التصرفات أن الوصي لا يملك مباشرتها إلا بإذن من المحكمة سواء ما كان منها متعلقا بأعمال الإدارة أو بأعمال التصرف، وعلى وجه الخصوص ليس له مباشرة التصرفات الآتية [٢]:

١– جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق المذكورة.

٢– التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.

٣– الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.

٤– حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.

٥– استثمار الأموال وتصفيتها.

٦– اقتراض المال وإقراضه.

---

[١] تنص المادة ٣٨ من قانون الولاية على المال على أنه" لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة" .

[٢] (م٣٩) من قانون الولاية على المال .

٧- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.

٨- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.

٩-قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.

١٠- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.

١١-الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.

١٢- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.

١٣- التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية، والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.

١٤-التنازل عن التأمينات أو إضعافها.

١٥-إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

١٦- ما يصرف في تزويج القاصر.

١٧- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة مهنة معينة.

١٨- قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الإتباع، وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها، ولها في جميع

الأحوال حق رفضها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء القسمة القضائية [1].

الاستثناء :

يخول الوصي سلطة مباشرة بعض أعمال الإدارة قليلة الأهمية على سبيل الاستثناء دون التقيد بشرط الحصول على إذن مسبق من جانب المحكمة في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى:

يجوز للوصي أن يؤجر عقار القاصر لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات[2]، على أن يراعى في ذلك هذين القيدين أولهما ضرورة ألا يمتد الإيجار لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد، وثانيهما ضرورة ألا يكون الإيجار للوصي نفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون نائبا عنه، وإلا وجب عليه استئذان المحكمة في ذلك.

الحـالة الثانيــة:

للوصي سلطة مباشرة الصلح والتحكيم فيما يقل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة [3].

وإذا أردنا أن نجرى مقارنة بين سلطة الوصي وسلطة الولي أبا كان أو جدا تبين لنا الآتي:

١- إن ثمة اختلافاً كبيراً بين سلطة الوصي وسلطة الأب بوصفه ولياً، حيث يملك الأب بصفة عامة سلطة مباشرة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر دون

---

[1] (م٤٠) من قانون الولاية على المال .

[2] يستفاد هذا الاستثناء من مفهوم المخالفة للمادة ٣٩/سابعا من قانون الولايةعلى المال .

[3] هذا مستفاد من مفهوم المخالفة من المادة ٣٩/ ثالثا من قانون الولاية على المال .

استئذان المحكمة، سواء ما كان من هذه التصرفات متعلقا بأعمال الإدارة أو بأعمال التصرف، إلا ما استثني بنصوص خاصة، بخلاف الحال بالنسبة للوصي فهو لا يملك بصفة عامة مباشرة هذه التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة، باستثناء بعض حالات نادرة قليلة الأهمية تتعلق بأعمال الإدارة دون أعمال التصرف فيجوز له فيها فقط مباشرتها دون إذن المحكمة.

٢-إن سلطة الوصي تتشابه مع سلطة الجد الصحيح (بوصفه ولياً) فيما يتعلق بأعمال التصرف، حيث يلزم لكليهما قبل مباشرة هذه التصرفات ضرورة الحصول على إذن مسبق من المحكمة، ويظهر الفارق بين سلطتيهما فقط فيما يتعلق بأعمال الإدارة، فالجد الصحيح بصفة عامة يملك سلطة مباشرة أعمال الإدارة دون حاجة إلى استئذان المحكمة إلا ما استثني بنص خاص، في حين أن الوصي لا يملك بصفة عامة مباشرة هذه الأعمال دون استئذان المحكمة إلا في حالات نادرة قليلة الأهمية على سبيل الاستثناء.

حالات خاصة للوصاية:

يجوز للمحكمة أن تعين وصيا خاصاً أو مؤقتا على الرغم من ثبوت الولاية على مال القاصر للولي أو الوصي، وذلك مراعاة لمصلحة القاصر في إحدى الحالات الآتية:

١-إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي أو مصلحة زوجة أحدهما أو مصلحة أحد فروعهما أو أصولهما أو مصلحة قاصر آخر مشمول بولاية أي منهما، وذلك درءا للشبهة عن الولي أو الوصي إن كان أمينا وصالحاً، وحماية للقاصر من جوره وظلمه إن كان غير ذلك (م٣١/أ ، ب من قانون الولاية على المال).

٢- إذا أريد إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو

إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجة أو أحد الأشخاص المشمولين بولايته.(م٣١/ج من قانون الولاية على المال).

٣- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع ألا يتولى الولي أو الوصي إدارة هذا المال (م٣١/د من قانون الولاية على المال).

٤- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال (م٣١/هـ من قانون الولاية على المال) كما لو كان العمل المراد أداؤه يحتاج إلى دراية وخبرة لا تتوافر في الولي أو الوصي.

٥- إذا كان الولي أو الوصي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية (م٣١/و من قانون الولاية على المال).

٦-إذا حكمت المحكمة بوقف الولاية أو الوصاية بسبب فقد الولي أو الوصي لأهليته لعارض من عوارض الأهلية أو حالت ظروف مؤقتة دون أحدهما ومباشرة مهام ولايته كما لو مرض مرضاً شديداً (م٣٢م نقانون الولاية على المال).

انتهـاء الوصايــة:

تنتهي الوصاية بأحد الأسباب الآتية:

١- بلوغ القاصر سن الرشد وهي واحد وعشرون سنة ميلادية، ما لم يحكم باستمرار الوصاية عليه بعد هذه السن بسبب الحجر عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة، وهذا يمثل الانتهاء الطبيعي للوصاية لأنها ما تقررت على الصغير أو القاصر إلا لصغر سنه وقد زال سبب الوصاية ببلوغ القاصر سن الرشد.

٢- بعودة الولاية للولي سواء كان أبا أو جدا صحيحا، على أساس أن الولي أولى الناس برعاية أموال الصغير أو القاصر.

٣- عزل الوصي أو قبول استقالته . ويحكم بعزل الوصي في إحدى هاتين

الحالتين:

أ-الحالة الأولى:

إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة ٢٧ من قانون الولاية على المال [١].ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.

ب- الحالة الثانية:

إذا أساء الوصي في إدارة أموال القاصر أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

ويلزم صدور قرار من المحكمة بقبول استقالة الوصي إذا رغب في التنحي عن وصايته على مال القاصر.

٤- فقد الوصي أهليته بثبوت جنونه أو عتهه أو الحجر عليه لسفه

---

[١] تنص المادة ٢٧ من قانون الولاية على المال على ذلك بقولها "يجب أن يكون الوصى عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً

١-المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أوالماسة بالشرف أو النزاهة ،ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.

٢-من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.

٣- من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش.

٤-المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره.

٥ -من سبق أن سلبت ولايته أوعزل من الوصاية على قاصر آخر.

٦-من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين، متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدقا على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.

٧-من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.

ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر، فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.

أو غفلة.

٥- موت الوصي أو ثبوت غيبته.

٦- موت القاصر.

وإذا ما انتهت الوصاية لأحد الأسباب سالفة الذكر، وجب على الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن يقوم بتسليم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي الجديد أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال، وأن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال (م٥٠من قانون الولاية على المال)، وينتقل هذا الالتزام إلى ورثة الموصي في حالة وفاته، أو إلى القيم عليه في حالة فقده أهليته، أو إلى الوكيل عنه في حالة ثبوت غيبته (م٥١ من قانون الولاية على المال).

وجدير بالذكر أن واضع القانون قد خرج على حكم القواعد العامة فقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات لسقوط الدعاوى الخاصة بالوصاية إذا ما انتهت، وذلك رغبة في حسم المنازعات التي تثور بصددها وعدم إطالة النزاع فيها، وتحسب بداية هذا التقادم من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد إذا ما انتهت ببلوغ القاصر هذه السن أو من تاريخ موت القاصر إذا كان سبب انتهاء الوصاية يرجع إلى الموت(م١/٥٣)، أو من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية في حالة انتهاء الوصاية بعزل الوصي أو استقالته أو موته(م٢/٥٣).

وإذا ما انتهت الوصاية بعودة الولاية للولي أو عودة الوصاية للوصي الأصلي أو الأسباب الأخرى التي لم يشر القانون إلى بداية حساب التقادم فيها، فإنه يبدأ حساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تحقق سبب انتهاء الوصاية قياسا

على الأسباب المنصوص عليها في المادة (١/٥٣)من قانون الولاية على المال [١].

ويعد قابلا للإبطال –لمصلحة القاصر– كل تعهد أو مخالصة تصدر عنه بعد بلوغه سن الرشد لمصلحة الوصي، متى صدرت عنه هذه المخالصة أو هذا التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم حساب الوصاية من جانب الوصي أو من ينوب عنه (م٥٢)، وقد قصد واضع القانون من هذا النص حماية القاصر من محاولات استغلال الوصي لنفوذه الأدبي على القاصر بعد انتهاء الوصاية عليه، وبذلك تبقى التعهدات أو المخالصات التي تصدر عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد لصالح الوصي خاضعة للقواعد العامة في البطلان متى صدرت بعد انتهاء مدة السنة من تاريخ تقديم الحساب فتكون صحيحة ولا تبطل إلا للأسباب المؤدية إلى البطلان مثل عيب الغلط أو التدليس أو الإكراه [٢].

المطلب الثاني

الولاية على المحجور عليهم

عرفنا مما سبق أن المرء قبل بلوغه سن الرشد يكون خاضعا للولاية على ماله من جانب الولي (أبا كان أو جدا صحيحا) أو الوصي (سواء أكان مختارا من قبل الأب قبل وفاته ثم ثبتته المحكمة أم معينا منذ البداية من جانب المحكمة)، فإذا ما بلغ الصغير أو القاصر سن الرشد واعتراه قبل البلوغ أحد عوارض الأهلية (مثل الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة) فعندئذ تقضي المحكمة باستمرار الولاية أو الوصاية عليه.

أما إذا بلغ القاصر سن الرشد ولم يعتره قبل البلوغ أحد عوارض الأهلية

---

[١] انظرفي نفس المعنى أ.د/حسن كيره–المرجع السابق –ص: ٦٠٩،٦١٠ هامش ،أ.د/إسماعيل غانم" محاضرات في النظرية العامة للحق" ص٢٠٥، طبعة عام ١٩٥٥م .

[٢] انظر في نفس المعنى:أ.د/نعمان جمعة –المرجع السابق –ص:٤٨٢ .

انتهت الولاية عليه التي كانت ثابتة للولي أو الوصي .

ومن ثمَّ فإنه إذا اعتراه بعد البلوغ أحد هذه العوارض فعندئذ تقوم المحكمة بالحجر عليه وتعين قيما له يتولى إدارة أمواله ورعايتها، وفي ذلك تنص المادة ٦٥ من قانون الولاية على المال بقولها" يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم، وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون".

وتثبت القوامة على مال المحجور عليهم بعد سن البلوغ حسب الترتيب الآتي:للابن البالغ ، ثم للأب عند عدم وجود الابن ، ثم للجد الصحيح عند عدم وجود الابن البالغ والأب ، ثم لمن تختاره المحكمة عند عدم هؤلاء الثلاثة (م٦٨ من قانون الولاية على المال).

وتسرى على القوامة وعلى القُوَّام ما يسرى على الوصاية والأوصياء من أحكام (م٧٨من قانون الولاية على المال) ومن ثمَّ تقوم المحكمة بتعيين القيم على المحجور عليه من بين هؤلاء حتى وإن كان من بينهم الأب أو الجد خلافا للولاية على مال القاصر حيث تثبت الولاية للأب أو الجد على مال القاصر بقوة القانون فلا يحتاج أحدهما لتدخل المحكمة لتعيينه أو تثبيته، ويخضع القيم بصفة عامة سواء أكان ابنا بالغا أم أبا أم جدا أو من تختاره المحكمة لنفس أحكام الوصي من حيث واجباته وسلطاته وانتهاء ولايته .

كما يشترط في القيم –بصفة عامة – ما يشترط في الوصي فيلزم أن يكون عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة، وألا يتوافر في حقه أحد أسباب عدم الصلاحية للولاية على مال المحجور عليه والمنصوص عليها في المادة ٢٧ من قانون الولاية على المال الواردة بشأن الوصي.

بيد أنه استثناء من مبدأ خضوع القوامة والقُوَّام لذات أحكام الوصاية والأوصياء

فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في القيم أجاز القانون –على خلاف الحال بالنسبة للوصي – أن تعين المحكمة الابن البالغ أو الأب أو الجد الصحيح قيما رغم الحكم عليه بالإفلاس أو الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة إذا رأت المحكمة في ذلك مصلحة (م٦٩من قانون الولاية على المال)ولم يجعل بذلك بعض أسباب عدم الصلاحية للوصاية على مال القاصر من بين أسباب عدم الصلاحية للقوامة على مال المحجور عليهم.

المطلب الثالث

الولاية على مال ذوي موانع الأهلية

على الرغم من أن الشخص قد يكون بالغا سن الرشد ولم يعتره أحد عوارض الأهلية التي قد تعدمه أهليته (مثل الجنون والعته) أو تنتقص منها (مثل السفه والغفلة) إلا إنه قد لا يستطيع مع ذلك ممارسة نشاطه القانوني ومباشرة أهليته بنفسه أو بمفرده لوجود مانع الأهلية وهي الغيبة بوصفها مانعاً مادياً، والحكم بعقوبة الجناية بوصفه مانعاً قانونياً والعاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد بوصفه مانعاً طبيعياً.

وتحقيقا لمصلحة ذوي موانع الأهلية الذين تعوقهم هذه الظروف الخاصة بهم عن إدارة أموالهم بأنفسهم رغم كمال أهليتهم وتمام رشدهم، وحتى لا تتعطل حركة أعمالهم وتضيع أموالهم تثبت الولاية عليهم من أشخاص آخرين يتولون إدارة أموالهم ورعاية مصالحهم سواء بالانفراد بها دونهم كما في حالة الغيبة أو الحكم بعقوبة الجناية أو بالمعاونة والاشتراك معهم كما هو الحال في العاهة المزدوجة أو العجز الشديد.

وعندئذ تعين المحكمة وكيلا عن الغائب ابتداءً أو تثبت من اختاره الغائب قبل غيبته انتهاءً، وتعين قيماً على المحكوم عليه بعقوبة الجناية، وتعين مساعداً

قضائياً لذي العاهتين أو المصاب بعجز جسماني شديد.

أولا: الوكيل عن الغائب:

إذا غاب الشخص كامل الأهلية ولم يترك وكيلا عاما لإدارة أمواله وتصريف شئونه في غيبته، ومضت سنة فأكثر على غيبته وترتب على ذلك تعطيل مصالحه، تقوم المحكمة بتعيين وكيل عنه لإدارة هذه الأموال متى كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته، أو لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم رغم حياته أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج مصر واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها(م٧٤ من قانون الولاية على المال).

وإذا ثبت أن الشخص قبل غيابه قد ترك وكيلاً عاماً لإدارة أمواله، فعندئذ تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي [١]. وإلا عينت شخصاً آخر غيره (م٧٥ من قانون الولاية على المال).

وتسري على الوكيل عن الغائب الأحكام الخاصة بالوصي سواء من حيث الشروط الواجب توافرها فيه أو من حيث واجباته وسلطاته ومسؤليته (م٨٨،٨٧،٨٥،٨٤،٧٥ من قانون الولاية على المال).

تنتهي مهمة الوكيل عن الغائب بموت الغائب سواء أكان موتا حقيقا أو موتا حكميا، كما تنتهي بعودة الغائب أو بقدرته رغم استمرار غيبته على تصريف شئون نفسه بنفسه أو الإشراف على من أوكله في إدارة هذه الأموال(م ٧٦ من قانون الولاية على المال) [٢].

---

[١] انظر: شروط الوصي في موضعها من هذا الكتاب .

[٢] تنص المادة ٧٦ على أن " تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة محكمة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتاً" .

ثانيا: القيم على المحكوم عليه بعقوبة الجناية:

من المعلوم أن الشخص الذي يحكم عليه بعقوبة الجناية يحرم حتما من مباشرة أعمال الإدارة الخاصة بأمواله وأملاكه طوال مدة الاعتقال، ويكون له الحق في تعيين قيم ليتولى مباشرة أعمال الإدارة نيابة عنه بشرط أن تقر المحكمة هذا التعيين، أو تعين المحكمة هذا القيم إذا لم يختر المحكوم عليه أحدا ليتولى القوامة عليه بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة في ذلك، كما أنه يحرم أيضا من مباشرة أعمال التصرف في أملاكه وأمواله إلا بعد استئذان المحكمة وإلا كانت تصرفاته فيها باطلة بطلانا مطلقاً (م٢٥/ رابعا من تقنين العقوبات)وذلك على الرغم من كمال أهلية هذا الشخص وتمام عقله ورشده . ويمثل هذا نوعاً من العقاب والزجر لمرتكب مثل هذه الجريمة البالغة الخطورة (ألا وهي الجناية)، وحتى لا يستعين بأمواله وممتلكاته على التفلت من العقاب على جريمته بالهرب والفرار من الاعتقال.

وبذلك يتولى القيم مباشرة أعمال الإدارة وحدها دون أعمال التصرف التي تظل ثابتة للمحكوم عليه بعد استئذان المحكمة، بناء على قرار المحكمة التي عينته بداءة أو ثبتته بعد اختيار المحكوم عليه إياه، ويكون تابعا لها في كل ما يتعلق بقوامته.

ويسري على القوامة والقيم ما يسري على الوصاية والوصي من أحكام،سواء من حيث الشروط الواجب توافرها في القيم ومن حيث واجباته وسلطاته ومسئوليته والجزاءات التي توقع عليه(م ٧٨،٨٧ من قانون الولاية على المال).

وتزول القوامة بزوالها سببها وذلك بانتهاء مدة العقوبة أو حتى بالإفراج عن المحكوم عليه ولو إفراجاً شرطياً، وترد – من ثم – إلى الشخص أمواله وأملاكها التي كان يديرها القيم مدة العقوبة ويقدم إليه حساباً عن هذه الإدارة (م٤٥/ رابعا من

قانون العقوبات).

ثالثا:المساعد القضائي لذي العاهتين أو العاجز عجزا جسمانيا شديدا:

عرفنا آنفا –بصدد الحديث عن موانع الأهلية –أن إصابة الشخص بعاهة مزدوجة من ثلاث عاهات (هي الصمم والبكم والعمى) أو بعجز جسماني شديد، يعد مانعا يعوقه عن الانفراد بسلطته على أمواله وأملاكه الخاصة،الأمر الذي قد يستوجب –إذا قدرت المحكمة حاجة الشخص إلى المساعدة القضائية –ضرورة تدخل شخص آخر معه يعاونه ويشاركه في مباشرة أهليته وممارسة نشاطه القانوني (سواء ما تعلق منه بأعمال الإدارة أو بأعمال التصرف)وذلك على الرغم من كمال أهليته وعدم إصابته بأحد عوارض الأهلية، مراعاة لمصلحة ذي العاهة أو المصاب بالعجز الذي قد تعوقه ظروفه الخاصة عن الدراية بأمور التعامل والإحاطة بواقعه أو تحول دونه والتعبير عن إرادته تعبيراً يكشف عن إرادته الحقيقة (الإرادة الباطنة).

ولذلك فقد أجاز القانون لذي العاهتين أو للمصاب بالعجز الجسماني الشديد ولكل ذي مصلحة، أن يتقدم إلى المحكمة الواقع بدائرتها الشخص المصاب بالعاهتين أو العجز بطلب المساعدة القضائية، فإذا ارتأت المحكمة حاجة هذا الشخص للمعاونة تقديراً لظروفه الخاصة عينت له مساعداً قضائياً.

ويلزم تسجيل طلب المساعدة القضائية والقرار الصادر بتقريرها، إذ لا يترتب على المساعدة القضائية أثرها إلا من تاريخ هذا التسجيل فيمتنع على المساعد القضائي وعلى الشخص ذي العاهة المزدوجة أو المصاب بالعجز الجسماني الشديد أن ينفرد أحدهما بأي تصرف من التصرفات، ويتعين اشتراكهما في مباشرته ، وإذا اختلفت وجهتا نظرهما بشأن تصرف معين من التصرفات جاز لهما الاحتكام إلى المحكمة في ذلك ، ويكون للمحكمة أن تأذن لأيهما بالانفراد

بمباشرة التصرف حسبما تراه محققا لمصلحة من تقررت لمصلحته المساعدة القضائية.

ولا يمكن أن نعد المساعد القضائي إلا مجرد معاون في ولايته على ذي العاهة المزدوجة أو العاجز، فلا يمكن أن نعده نائبا عنه إلا في الحالات التي ينفرد فيها بمباشرة ولاية كاملة على أموال وأملاك من تقررت لصالحه المساعدة بعد إذن المحكمة له بذلك.

ويثار التساؤل حول حكم التصرف الصادر من الشخص بعد تقرير المساعدة القضائية لصالحه.

فعندئذ ينبغي أن نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى:

إذا صدر التصرف بعد قرار المساعدة ولكن قبل تسجيل هذا القرار فيتوقف الحكم على مدى حسن نية المتعاقد أو سوء نيته فإن ، كان حسن النية كان التصرف صحيحا ولا يجوز إبطاله حماية للمتعاقد الذي كان يجهل قرار المساعدة لعدم تسجيله، أما إذا كان سيء النية بحيث كان يعلم بصدور القرار فعندئذ يجوز إبطاله لمجرد وقوع التصرف بعد القرار على الرغم من عدم تسجيله [١].

الحالة الثانية:

إذا وقع التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة القضائية كان قابلاً للإبطال (م٢/١١٧ مدني) ما لم يجزه المساعد القضائي أو المحكمة.

---

[١] أ.د/ عبد الحى حجازى –المرجع السابق –ص :١١٥ .

أما إذا صدر التصرف من المساعد القضائي منفرداً دون أن ترخص له المحكمة في الانفراد، مجاوزا بذلك حدود ولايته التي تقتضي اشتراكه لا انفراده في مباشرة الأعمال القانونية لصالح من تقررت المساعدة لصالحه فعندئذ يكون تصرفه صحيحا لصدوره من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة ولكنه يكون غير نافذ في حق ذي العاهة المزدوجة أو العاجز إلا إذا أجازه أو أجازته المحكمة، على أساس أن المحكمة تملك أن تأذن له ابتداءً بالانفراد في مباشرة التصرف دون معاونة ذي العاهة أو العاجز فمن باب أولى تملك الإجازة انتهاءً.

الفصل الثاني

الشخص المعنوي أو الاعتباري

La personne morale

تمهيد :

<u>فكرة الشخص المعنوي وأهميته في المجتمع:</u>

لقد فرضت ظروف الحياة الإنسانية بشتى أنواعها وصورها (أي الظروف السياسية و الاقتصادية والاجتماعية...إلخ) على واضعي القوانين ألا يقصروا الشخصية القانونية (والتي تعني القابلية أو الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات) على الإنسان وحده (أو ما يُسمى بالشخص الطبيعي تمييزاً له عن الشخص المعنوي بوصفه يعبر عن فكرة معنوية يخلعها القانون على بعض الكيانات الأخرى غير الإنسان) وإسباغها من ثم على مجموعات الأشخاص أو مجموعات الأموال التي تنشأ لتحقيق أغراض اجتماعية أو اقتصادية محددة .

فالإنسانُ وحدُه بجهوده القليلة (سواء البدنية منها أو المالية) وحياته القصيرة أعجزُ من أن يحقق لنفسه لا لغيره بعض المصالح الضرورية أو الأساسية اللازمة لاستمرار سير الحياة في المجتمع، لذلك فقد ظهرت الحاجة ملحة إلى تكوين مجموعات من الأشخاص أو مجموعات من الأموال لتتكاتف كل فئة من هذه المجموعات في تحقيق أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها.

غير أن هذه المجموعات أو التكتلات سواء كانت تضمُ أشخاصاً أو أموالاً لن تقدر على الاضطلاع بمهامها أو النهوض بوظائفها التي قامت من أجلها، إلا إذا اعترف لها القانون بوجود قانوني مستقل عن الأشخاص المؤسسين لها أو الأشخاص الذين قدموا لها هذه الأموال، على نحو يسمح بتمتعها بكيان قانوني مستقل عنهم .

من أجل ذلك فقد لجأ واضعو القوانين في كل دول العالم إلى خلق وإيجاد فكرة الشخص المعنوي لتحقيق تلك الغاية، على أساس أنه حينما يجتمع مجموعة من الأشخاص بهدف تحقيق أهداف وغايات معينة يتولد عن اجتماعهم كائن يستقل في وجوده عن وجود كل واحد منهم، كما أنه في حالة رصد مجموعة من الأموال لغايات معينة يتملك هذه الأموال كائن يستقل في وجوده عن وجود من قدموا هذه الأموال، هذا الكائن الجديد في الحالتين ليس شخصاً طبيعياً ولكنه شخصٌ معنوي يدرك بالتصور والافتراض وليس بالواقع والحس .

المبحث الأول

تعريف الشخص المعنوي أو الاعتباري وبيان عناصره

يمكننا تعريف الشخص المعنوي أو الاعتباري La Personne Morale بأنه ذلك الكيان الذي يعتمد في وجوده على مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تستهدف تحقيق أغراض ومصالح معينة، ويعترف له القانون بالشخصية القانونية المستقلة عن الأشخاص المؤسسين له أو الأشخاص المتقدمين بالأموال المكونة له.

ويتضح لنا من التعريف سالف الذكر أنه يلزم لوجود الشخص المعنوي أن يتوافر له عنصران أحدهما موضوعي والآخر شكلي.

أولا: العنصر الموضوعي:

ويقصد به أن يكون ثمة جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تسعى إلى تحقيق هدف أو غرض معين، ويلزم في الغرض في الحالتين أن يكون ممكناً ومشروعاً ومستمراً، فلا يتصور نشأة شخص اعتباري لغرض غير ممكن التنفيذ أو غير مشروع لمخالفته للنظام العام، أو لغرض عرضي يمكن تحقيقه بسهولة دفعة واحدة وبفعل شخص واحد كما لو حدث اتفاق بين بعض الأشخاص على الذهاب إلى رحلة معينة ، إذ يلزم في الغرض أن يكون مستمراً سواء أكان ذلك بصفة دائمة كما في الجمعيات أو لمدة محدودة كما في المؤسسات.

ويستوي بعد ذلك أن يكونَ الغرضُ عاماً (أي يستهدفُ تحقيق مصلحة عامة في المجتمع) أو أن يكون غرضاً خاصا (أي يستهدف مصلحة خاصة ببعض الأفراد)، كما أنه يستوي أن يكون الغرض ماليا كما هو الحال في الشركات ، أو أن يكون الغرض غير مالي كما هو الحال في الجمعيات التي تنشأ لتحقيق أغراض دينية أو علمية أو أدبية.

ويشترط في الكيان المعنوي الذي يعتمد في وجوده على مجموعات الأموال أن تكون أمواله الحالة أو المستقبلة كافية لتحقيق الغايات والأهداف التي أُنشئ من أجلها، كما يلزم ذلك أيضا في جماعات الأشخاص فيكون لها من الأموال ما يفي بالغرض الذي قامت من أجله ، هذا ما لم يثبت أن هذا الغرض لا يلزم لتحقيقه وجود أموال [١] .

ثانيا: العنصر الشكلي :

ويتمثل في اعتراف الدولة بالشخصية القانونية لهذا الكيان المعنوي المتمثل في مجموعة الأموال أو مجموعة الأشخاص ، ويتحقق هذا الاعتراف بأحد طريقين: إما بطريق الاعتراف العام أو بطريق الاعتراف الخاص.

ويتحقق الاعتراف العام بقيام واضع القانون بوضع الشروط العامة اللازمة لاكتساب مجموعات الأشخاص أو مجموعات الأموال للشخصية القانونية، ومن ثمَّ إذا توافرت هذه الشروط في أي مجموعة من هاتين المجموعتين اكتسبت الشخصية القانونية بقوة القانون، دون حاجة إلى ترخيص أو إذن خاص من جانب واضع القانون عند تكوين كل واحدة منهما.

أما صورة الاعتراف الخاص فتستلزم صدور ترخيص أو إذن خاص من جانب واضع القانون يمنح فيه الشخصية القانونية لكل مجموعة على حده من مجموعات الأشخاص أو الأموال [٢].

المبحث الثاني

---

[١] انظر في نفس المعنى إلى: أ.د/ عبد الحي حجازي ص ١٦١، أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٦٤، ص٣٥١ .

[٢] انظر في نفس المعنى إلى: أ.د/ حسن كيره بند ٣٢٣، ص ٦٣٦، ٦٣٧، أ.د/ عبد الحي حجازي ص١٦٢، أ.د/ عبد الناصر العطار بند ١٦٤، ص ٣٥١ .

النطاق الزمني للشخصية المعنوية أو الاعتبارية

أولا: بداية الشخصية المعنوية أو الاعتبارية:

تبدأ الشخصية المعنوية أو الاعتبارية لمجموعة الأموال أو الأشخاص من تاريخ اعتراف الدولة بها سواء أكان هذا الاعترافُ اعترافاً عاماً أو اعترافاً خاصاً.

ويميل القانون المصري إلى ولوج سبيل هذين النوعين من الاعتراف في منح الشخصية المعنوية لتجمعات الأشخاص أو الأموال التي تنشأ لتحقيق أغراض معينة، وإن كان الاعتراف العام يمثل الأصل العام، ويتم اللجوء إلى الاعتراف الخاص على سبيل الاستثناء.

ثانيا: انتهاء الشخصية الاعتبارية أو المعنوية:

لانتهاء الشخصية الاعتبارية أو المعنوية أسباب متعددة، فإذا ما تحقق أحدها ترتب على ذلك زوالها، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:-

١- بانتهاء الأجل أو الزمن المحدد لها، وذلك إذا ما تمَّ تحديده في السند المنشئ لها.

٢- بتحقيق الغرض الذي قامت من أجله أو إذا أصبح تحقيق هذا الغرض أمراً مستحيلاً.

٣- حل الشخصية الاعتبارية سواء أكان هذا الحل حلاً اتفاقياً أي باتفاق الأعضاء أنفسهم على الحل كما هو الحال في الجمعيات، أو كان حلاً قضائياً بصدور حكم قضائي بالحل إذا ما ثبتت مخالفة الشخص الاعتباري للقانون أو النظام العام، أو كان حلاً تشريعياً أي عن طريق المشرع بصدور قانون يتضمن هذا الحل، كما هو الحال في تأميم مشروع ما من المشروعات.

وقد يحدث أن تمتد الشخصية الاعتبارية رغم الحل لمدة معينة حتى يتسنى القيام بأعمال التصفية، فتبقى هذه الشخصية بالقدر اللازم لهذه الأعمال.

وبانتهاء الشخصية الاعتبارية أو المعنوية تُصفَى ذمتُها المالية فتسددُ ديونُها ويوزعُ الباقي بعد سداد الديون وفقا لما يقرره سندُ إنشائها أو وفقا لما يقرره قرارُ الحل [1].

المبحث الثالث

مميزات الشخصية الاعتبارية أو المعنوية

إنه متى اكتملتْ نشأةُ الشخص الاعتباري أو المعنوي بتوافر عنصريه الموضوعي والشكلي، ثبتتْ له شخصيتُه القانونية وأضحى أهلاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي دون أية فوارق إلا تلك الفوارق التي تقتضيها طبيعةُ كل منهما، ولذلك يثبت للشخص الاعتباري أو المعنوي اسم وموطن وحالة مثل الشخص الطبيعي بالقدر الذي يناسب طبيعته وتكوينه [2].

أولا: اسم الشخص المعنوي أو الاعتباري :

ينبغي أن يكون للشخص الاعتباري – مثل الشخص الطبيعي– اسمٌ يميزُه

---

[1] أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٦٧ .

[2] إذ تنص المادة ٥٣/ ١ من التقنين المدني الحالي على أن "الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون"

"٢– ويكون له:–

أ– ذمة مالية مستقلة. ب– أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

ج– حق التقاضي. د– موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية" .

عن غيره من الأشخاص الاعتبارية، ويتمُ عادةً ذكرُ هذا الاسم في سند إنشائه أو نظامه الأساسي، ويغلبُ اختيارُ هذا الاسم واشتقاقه من الغرض الذي أنشئ هذا الشخص الاعتباري لأجله.

ويتمتعُ الشخصُ المعنوي بالحماية القانونية للاسم مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي فتمتنع المنازعةُ فيه كما يحظرُ انتحالُه والاعتداءُ عليه، ويمكن إلى جانب ذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تنجمُ عن المنازعة في الاسم أو انتحاله والاعتداء عليه .

وتجدر الإشارة إلى أن اسم الشخص الاعتباري قد يكون اسماً تجارياً، فيصير أحد عناصر الذمة المالية للشخص الاعتباري مثل المحل التجاري أو الشركة، فيجوز التعامل فيه لصيرورته ذا قيمة مالية، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فلا يكون للشخص الاعتباري على اسمه سوى مجرد حق أدبي لا يجوزُ التعاملُ عليه.

ثانيا: موطن الشخص المعنوي أو الاعتباري:

يتمتع الشخص الاعتباري بموطن خاص مستقل عن موطن أعضائه ومؤسسيه، ويعدُ موطناً له المكانُ الذي يوجدُ به مركزُ إدارته، أي مركز النشاط القانوني والإداري والمالي الذي توجد به الهيئات الرئيسية للشخص الاعتباري [1]، وليس بالضرورة أن يكون هذا المركزُ هو ذاته الذي به مركز الاستغلال (أي مكان النشاط التجاري أو الصناعي أو غيرهما من الأنشطة التي أنشئ الشخص الاعتباري لأجل القيام به) فقد يكون مركز الإدارة الرئيسي ومركز الاستغلال في مكان واحد ، وقد يكون مركز الاستغلال في مكان آخر بعيداً عن مركز الإدارة يتمُ

[1] أ. د/ توفيق حسن فرج ص ١٦٨، أ. د/ حسن كيره بند ٣٣١، ص٦٥٣ .

اختيارُه بحسب ما يحققه لهذا الاستغلال من فوائد وتسهيلات تساعد على حسن الاضطلاع به، فالعبرة إذن بالمكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لإدارة الشخص الاعتباري فهو الذي يعد موطناً له.

بيد أنه في خصوص الشركات التي يوجد مركز إدارتها الرئيسي بالخارج، ولها مركزُ استغلال أو نشاط داخل مصر، ففي هذه الحالة يعد موطنا لها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية (م ٥٣/ ٥ مدني).

وإذا كان للشخص الاعتباري أكثر من فرع داخل الجمهورية في أماكن متفرقة ومتباعدة، فعندئذ يكون المكان الذي يوجد به الفرع موطناً خاصاً به فيما يتعلق بالأعمال الخاصة به، وفي ذلك نص المادة ٥٢/ ٢ من قانون المرافعات بأنه "ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع".

وعادة ما يتم تحديد مركز إدارة الشخص الاعتباري في نظامه الأساسي وقد استوجب القانون ذكر هذا البيان بالنسبة للجمعيات والمؤسسات في نظامها الأساسي [١].

ثالثا: حالة الشخص المعنوي أو الاعتباري:

إنه من غير المتصور أن تكون للشخص الاعتباري حالة عائلية أو حالة دينية، لأنه ليس له أسرةٌ ولا يمكنُ أن يكونَ له دينٌ معينٌ، فهاتان الحالتان لا يتصورُ ثبوتُهما لغير الأشخاص الطبيعيين وكذلك الحال بالنسبة للحالة الطبيعية (أي الجنس)، ولكن يكون للشخص الاعتباري حالة سياسية أو رابطة تبعية أو ولاء

---

[١] أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٦٨ .

بدولة معينة بحيث يخضع لأحكام قانونها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الاعتبارية العامة تخضع لقانون البلد الموجودة فيه، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة فهي تخضع لقانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، على أن يراعى أنه إذا كان للشخص الاعتباري مركز إدارة رئيسي في الخارج في حين أن مركز استغلاله أو نشاطه في مصر، ففي هذه الحالة يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق، حيث تنص المادة ١١/ ٢ مدني على أنه "أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسرى عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري".

المبحث الرابع

أهلية الشخص الاعتباري أو المعنوي

نفرق في هذا المبحث بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء بالنسبة للشخص الاعتباري أو المعنوي.

أولا: أهلية الوجوب:

إنه متى توافر للشخص الاعتباري عنصراه الموضوعي (المتمثل في وجود مجموعة من الأشخاص أو الأموال بهدف تحقيق غرض معين) والشكلي (باعتراف الدولة به اعترافا عاما أو خاصاً) ثبتت له الشخصية القانونية، وأصبح له أهلية وجوب يتحدد مداها ونطاقها بما يتناسب مع طبيعته بوصفه كائناً معنوياً وبالغرض الذي أنشئ من أجل تحقيقه.

١- تقييد أهلية وجوب الشخص المعنوي وفقا لطبيعته:

إن طبيعة الشخص المعنوي – بوصفه كائناً معنوياً يختلف عن الإنسان أو الشخص الطبيعي– تحد من نطاق ومدى أهلية الوجوب التي تثبت له، ومن ثم تثبت للشخص الاعتباري الحقوق والواجبات التي تتفق مع طبيعته مثل حقه في اسم يميزه عن غيره من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وحقه في التملك، وحقه في التقاضي وغيرها من الحقوق التي تناسب طبيعته بوصفه كائناً معنوياً، أما الحقوق الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية مثل حقوق الأسرة والحقوق السياسية فهي بحسب طبيعتها لا تثبت للشخص الاعتباري، وكذلك الحال بالنسبة للواجبات التي لا تُفْرَض إلا على الإنسان، فإنها تخرجُ عن نطاق أهلية الوجوب الخاصة بالشخص المعنوي مثل واجب أداء الخدمة العسكرية .

وتطبيقا لذلك تنص المادة ٥٣/ ١ مدني على أن "الشخص الاعتباري

يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون".

٢- <u>تقييد أهلية وجوب الشخص المعنوي بالغرض من إنشائه:</u>

يتقيدُ حجمُ ونطاق أهلية الوجوب التي تثبت للشخص المعنوي بالغرض من إنشائه والذي يُعين بدقة في سند إنشائه أو يقرره القانون، فليس للشخص المعنوي أن يتجاوز الغرض الذي قام من أجله ويسعى إلى تحقيق غيره من الأغراض، ويكون له أهلية وجوب في حدود هذا الغرض، وهذا ما يسمى في الفقه بمبدأ التخصيص.

وتطبيقا لذلك لا يجوز للشركة بوصفها أحد الأشخاص المعنوية إذا ما قامت لتحقيق غرض معين محدد لها في سند إنشائها أن تباشر أعمالاً وأنشطةً قانونية خارج نطاق هذا الغرض، وكذلك الحال إذا حدد القانونُ للشخص المعنوي مهمةً معينةً كما لو كان جمعيةً أُنشئت لتحقيق أغراض إنسانية أو علمية أو أدبية، فليس لها أن تتجاهل هذه الأغراض وتباشر أعمالاً تجارية سعياً وراء تحقيق الأرباح [١] .

ثانيا: أهلية الأداء:

لا يتصور أن تكون للشخص الاعتباري أهلية أداء، نظرا لأن مناط هذه الأهلية هو الإرادة والتمييز، وهما لا يتحققان في الشخص الاعتباري، ولكنهما يتوافران فقط في الشخص الطبيعي.

لذلك لم يكن هناك بُدٌ من وجود نائب يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري، فيباشر كافة أوجه النشاط القانوني الخاص بهذا الشخص باسمه ولحسابه الخاص

---

[١] انظر في هذا المعنى إلى: أ.د/ توفيق حين فرج ص ٢٧٠، د/ محمد سعد خليفة ص ٢٦٨ .

(وفي ذلك تنص المادة ٥٣/ ٣ مدني " ويكون له – أي للشخص الاعتباري – نائب يعبر عن إرادته).

ولقد ثار خلاف في الفقه حول طبيعة العلاقة بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي الذي يعبر عن إرادته، فقيل بأنها علاقة وكالة، ولكنه قول مردود نظرا لأن الوكالة تفترض توافر إرادة التوكيل لدى الموكل، وهذا ما لا يتوافر بالنسبة للشخص الاعتباري لأنه لا إرادة له، وقيل بأن القائمين على أمر الشخص المعنوي هم أدوات أو أجهزة تعد جزءاً من الشخص المعنوي مثل أعضاء جسم الإنسان تماما، فإن تصرفوا فإنهم يعبرون عن إرادة الشخص المعنوي مباشرة، ويرد على هذا الرأي بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا بأعضاء أو أدوات وإنما هم أشخاصٌ لهم إراداتُهم التي قد تختلفُ وقد تتعارضُ مع مصلحة الشخص المعنوي، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الرأي ليس إلا نوعاً من المجاز والافتراض الذي يتنافى مع الواقع، وذهب رأيٌ ثالثٌ وهو الذي يمثلُ رأيَ جانبٍ كبيرٍ من الفقه –وهو ما نرجحه– إلى أنها نيابةٌ قانونية مصدرها القانون [1]، عملا بنص المادة ٥٣/ ٣ مدني الذي جاء فيه "ويكون له – أي للشخص المعنوي – نائب يعبر عن إرادته".

وينبغي التمييز بين النشاط الذي يباشره النائب القانوني عن الشخص المعنوي بوصفه ممثلا له (والذي يباشره باسم هذا الشخص المعنوي ولحسابه) وبين نشاطه الخاص الذي يباشره باسمه هو ولحسابه الشخصي (مثل شراء مدير الشركة شقة لنفسه أو إبرامه لأحد العقود باسمه ولحسابه الخاص) لما في ذلك من أهمية قصوى في تحديد المسئولية، حيث تقتصر مسئولية الشخص المعنوي على الأخطاء التي تصدر من النائب القانوني بسبب أو بمناسبة نشاطه لحساب الشخص المعنوي وفي حدود اختصاصاته، أما ما عدا ذلك من أخطاء فيتحملها النائب نفسه وفقا

---

[1] انظر في عرض هذا الخلاف إلى: أ.د/ نعمان جمعة ص ٥١٨ .

لقواعد الخطأ الشخصي [1] .

[1] انظر في نفس المعنى: أ. د/ حسن كيره بند ٣٦٦، ص ٦٦١، ٦٦٢، أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٧١.

المبحث الخامس

الذمة المالية للشخص المعنوي أو الاعتباري

يتمتع الشخص الاعتباري أو المعنوي بذمة مالية تضم حقوقه وديونه، وهي ذمة مالية مستقلة تماما عن ذمم الأشخاص المكونين له، ومن ثم ليس لدائني هؤلاء الأشخاص أن يرجعوا بديونهم على ذمة الشخص الاعتباري، وفي نفس الوقت لا يجوز – بصفة عامة – لدائني الشخص الاعتباري أن يرجعوا بديونهم على عناصر الذمة المالية الخاصة لهؤلاء الأشخاص، باستثناء ما يقرره القانون من مسئولية الشركاء في الشركات المدنية وشركات التضامن وشركات التوصية عن ديون الشركة، بحيث يكون لدائني الشركة الرجوع عليهم في أموالهم الخاصة.

ويترتب على استقلال الذمة المالية للشخص الاعتباري عن ذمم الأشخاص المكونين له جواز مقاضاته فترفع عليه الدعاوى، كما يثبت له حق التقاضي فيرفع الدعاوى على الغير، وعندئذ تنصرفُ الآثارُ المترتبةُ على هذه الدعاوى في الحالتين إلى الذمة المالية للشخص الاعتباري إيجاباً أو سلباً [1].

ولعل هذا هو ما أكدته المادة ٥٣ مدني بقولها:

"١– الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق ....." .

"٢– فيكون له:–

أ– ذمة مالية مستقلة. ب– .....جـ– حق التقاضي.

المبحث السادس

أنواع الشخص المعنوي أو الاعتباري

[1] انظر في نفس المعنى: أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٧١ .

تنص المادة ٥٢ من التقنين المدني الحالي على أن "الأشخاص الاعتبارية هي:-

١- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية".

٢- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

٣- الأوقاف.

٤- الشركات التجارية والمدنية.

٥- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التي ستأتي فيما بعد.

٦- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

ويتضح لنا من النص سالف الذكر أنه يميز بين طائفتين من الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية: هما الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

أما الأشخاص الاعتبارية العامة فهي الأشخاص التي تمارس نشاطها بصفتها صاحبة سيادة وسلطان وبوصفها ممثلة للمصلحة العامة، والتي تضم الدولة والمحافظات والمدن والقرى والإدارات والمصالح العامة، وهي تخضع في مباشرة أعمالها وأنشطتها لأحكام القانون العام.

وتجدر الإشارة إلى أن مجال دراسة هذه الأشخاص الاعتبارية العامة في مؤلفات وكتب القانون العام، أي في القانون الدولي العام، والقانون الدستوري والقانون الإداري، ولذلك فإننا لن نتعرض لها بالدراسة.

وأما الأشخاص الاعتبارية الخاصة فهي الأشخاص التي تستهدف تحقيق أو حماية المصالح لمؤسسيها أو للغير، وهي تخضع لأحكام القانون الخاص في مباشرتها لأعمالها وأنشطتها، وتضم نوعين من الأشخاص: مجموعات الأشخاص مثل الشركات والجمعيات، ومجموعات الأموال مثل المؤسسات والأوقاف.

وسنستبعد من نطاق بحثنا دراسة بعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة مثل دراسة الأوقاف نظرا لأن مجال دراستها في الشريعة الإسلامية (ويقصد بالوقف حبس مال أو أموال معينة عن التداول مع تخصيص ريعها لشخص أو أشخاص معينين أو قابلين للتعيين أو لجهة من جهات البر في الحال أو المآل [1])، ودراسة الشركات المدنية والشركات التجارية لأن مجال دراستها في كتب القانون التجاري، ومن ثم سنكتفي بدراسة الجمعيات بوصفها نموذجاً لإحدى جماعات الأشخاص، والمؤسسات بوصفها نموذجاً لإحدى مجموعات الأموال.

المطلب الأول

الجمعـيات Les associations

تنص المادة الأولى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (وهو القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م) على أن " تعتبر جمعية فى تطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لا يقل عددهم فى جميع الاحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي " .

ويظهرُ مما سبق أن الجمعيةَ تتألفُ من مجموعة من الأشخاص ويشترطُ

---

[1] أ.د/ إسماعيل غانم "محاضرات في النظرية العامة للحق" طبعة عام ١٩٦٦م، ص ٢٣٧ .

القانونُ ألا يقلُ عددُهم عن عشرة أشخاص طبيعيين، ويجيز القانون أن ينضمَ إلى هذه الجمعية أشخاصٌ اعتباريون أيا كان عددهم، حيث لم يوجب القانون حداً معيناً لعدد الأشخاص الاعتبارية بعكس موقفه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وتستهدف الجمعيات دائما تحقيق أغراض إنسانية متعددة بعيدة تماما عن نطاق الأغراض والأرباح المادية، فهي تنشأ كما يقول النص القانوني سالف الذكر لغرض غير الحصول على الربح المادي، فهي عادة ما تنشأ بهدف تحقيق أهداف وأغراض ثقافية أو رياضية أو فنية أو سياحية أو دينية، أو الدفاع عن مصالح إحدى طوائف المجتمع وفئاته، وبذلك فهي تختلف عن الشركات المدنية أو التجارية التي تسعى دائما بهدف تحقيق الأرباح لأعضائها.

ولعل من أمثلة هذه الجمعيات نذكر نقابات العمال والنقابات المهنية (مثل نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الأطباء ..... الخ) والنوادي الرياضية وجمعية الشبان المسلمين وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات التي تهدف إلى تنظيم رحلات سياحية لأعضائها [1].

وتنشأ الجمعية لمدة زمنية محددة أو دون تحديد أي مدة لقيامها. غير أنه يتعين لصحة نشأتها أن تكون ذات تنظيم مستمر، وذلك منعا من إنشاء جمعيات مكونة من عدد من الأشخاص بهدف تحقيق هدف عارض أو غاية مؤقته كما لو اجتمع عدد من الأشخاص بقصد تنظيم رحلة واحدة أو سهرة واحدة أو لإقامة مباراة واحدة، فمثل هذا التجمع البشري وإن اكتمل عدده لعشرة أشخاص لا يمكن أن يشكل جمعية لأنه تنظيم عارض يفتقر إلى عنصر الاستمرار المشروط بموجب نص القانون (م ١ من قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م).

---

[1] أ.د/ نعمان جمعة ص ٥٢٥ .

ويلزم لصحة نشأة الجمعية أيضاً ضرورة وضع نظام مكتوب لها موقع عليه من الأعضاء المؤسسين، وأن يكون هذا النظام متضمنا لكافة البيانات المحددة للجمعية مثل اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها جغرافيا ومركز إدارتها –على أن يكون هذا المركز في مصر– وأسماء الأعضاء المؤسسين لها – على أن يذكر اسم ولقب وجنسية وموطن ومهنة كل عضو من هؤلاء الأعضاء – وموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وشروط العضوية (م ٢ ، ٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م)، على أن يراعى أن الكتابة المشروطة في نظام الجمعية هي للإنشاء (أي لصحة نشأتها) وليست للإثبات، ويرتب القانون البطلان جزاءً على تخلف الكتابة.

ولا تثبت الشخصية القانونية للجمعية بمجرد نشأتها، وإنما يتحقق ذلك من تاريخ شهرها، ويتم شهر الجمعية بقيد نظامها في السجل المعد لذلك في وزارة الشئون الاجتماعية ، ولذا تنص المادة ٦ من قانون الجمعيات والمؤسسات الحالي رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م " تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسي للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال الستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشار اليها فى المادة (٥) من هذا القانون فإذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية باجراء هذا القيد او بمضى ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما اقرب " .

وتخضع الجمعية لرقابة الدولة من حيث إنشائها وسير العمل بها وميزانيتها ومستنداتها، نظرا لخطورة مثل هذا التجمع البشري الذي قد يملك طاقة بشرية ومادية ضخمة، والتي يخشى من سوء استغلالها بما يضر بمصالح المجتمع.

وتنقضي الجمعيةُ إما بانتهاء الغرض الذي أُنشئتْ من أجله (كما لو أنشئت

لمواجهة آثار الزلزال أو الفيضان فتنقضي بزوال آثاره مثلا) أو بانتهاء الأجل المحدد لقيامها في نظامها الأساسي المكتوب أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية أو بحكم قضائي. (م ٤١، ٤٢ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م).

المطلب الثاني

المؤسسات الخاصة

المؤسسةُ الخاصةُ هي مجموعةُ من الأموال تخصص لمدة معينة أو غير معينة بهدف تحقيق عمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام، دون السعي إلى تحقيق أرباح مادية (١).

ويظهر مما سبق أن المؤسسةَ لا تنشأُ لتحقيق أرباح مادية ولكنها تقوم بهدف تحقيق أغراض غير مادية (سواء كانت إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو غيرها من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام) وهي بذلك تتفقُ مع الجمعية، وتختلفُ مع الشركة لأن الشركةَ تنشأُ بهدف تحقيق الأرباح المادية سواء كانت شركة مدنية أو تجارية.

كما أن المؤسسة عبارة عن تجمع مالي يرصد لتحقيق أهداف معينة غير مادية بخلاف الجمعية فهي تجمعٌ بشري يستهدفُ تحقيقَ أهداف محددة غير مادية.

---

(١) إذ تنص المادة 56 من قانون الجمعيات والمؤسسات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م على أن " تنشأ المؤسسة الاهلية بتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي وتسري في هذا الخصوص احكام المادة (١١) من هذا القانون " .

وتنشأُ المؤسسةُ الخاصةُ إما بموجب سند رسمي يصدر عن شخص أو عدة أشخاص (كما لو حررَ شخصٌ أو أكثر من شخص سنداً رسمياً كعقد هبة مثلا تبرع أو تبرعوا بمقتضاه ببعض أموالهم لرعاية أيتام مثلا أو لإيواء كبار السن أو لرعاية المكفوفين) وعندئذ تنشأُ المؤسسة فورا، وإما بموجب وصية (كما لو أوصى شخصٌ بثلث أمواله لأحد الأغراض الإنسانية) فعندئذ لا تنشأ المؤسسة إلا بعد وفاة منشئِها.

ويلزم أن يتضمن السند المنشئ للمؤسسة سواء أكان سنداً رسمياً أم وصيةً على عدد معين من البيانات مثل اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاقها الجغرافي والغرض من إنشائها مع بيان الأموال المخصصة لها والأغراض التي ستسعى إلى تحقيقها.

وإذا كانت المؤسسة تنشأ من الناحية الواقعية أو من حيث الوجود المادي بمجرد إتمام السند الرسمي المنشئ لها أو عقب وفاة الموصي –كما سبق أن رأينا– إلا أن وجودها القانوني لا يبدأ إلا اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لذلك بوزارة الشئون الاجتماعية (مادة ٥٩ رقم ٨٤ العام٢٠٠٢م (١)).

ولا تنقضي المؤسسة إلا بالحل الإجباري، وفي هذه الحالة لابد من صدور قرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات ، وذلك في حالة عجز المؤسسة عن تحقيق أغراضها أو تصرفها في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها، أو ارتكابها مخالفة جسيمة

(١) إذ تنص هذه المادة على أن " تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية " .

للقانون أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب(١)، وهي بذلك تختلف عن الجمعية التي يمكن أن تنقضي بالحل الاختياري أيضا إلى جانب الحل الإجباري، ولعل هذا الاختلاف مرده إلى أن المؤسسة تختلف عن الجمعية فهي مجموعة من الأموال وليست مجموعة من الأشخاص [٢].

(١) إذ تنص المادة 63 من هذا القانون على أنه " يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرات دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (١١) من هذا القانون . ويتعين أن يتضمن قراراً لحين تعيين مصفٍ أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما . ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة " .

(٢) انظر في نفس المعنى: أ.د/ حسن كيره بند ٣٦٢، ص ٧٠١ .

الباب الثاني

أنواع الحقوق وتقسيماتها

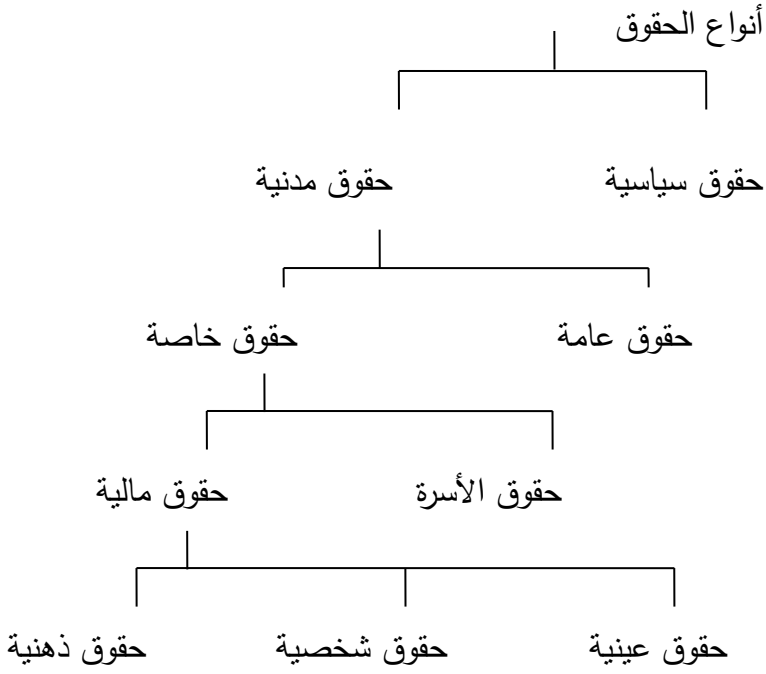
الباب الثاني

أنواع الحقوق وتقسيماتها

تمهيد :

لا جرم أن للأشخاص حقوقاً كثيرةً ومتنوعةً عني بها الفقهاء وأجروا لها تقسيمات عديدة نختار من بينها هذين التقسيمين : أولهما ذلك التقسيم الذي يقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية ، وتنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة وحقوق مالية، ثم تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق ذهنية.

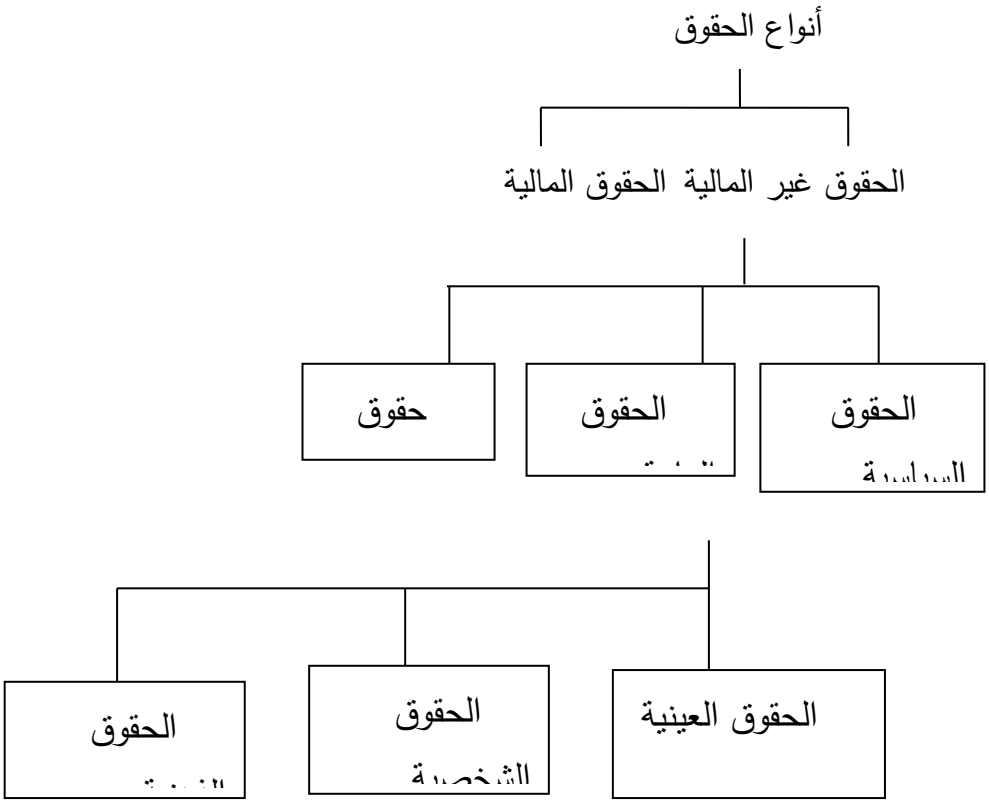
ويمكننا أن نمثل لهذا التقسيم بالرسم الآتي:-



وهناك تقسيمٌ آخرٌ يقسم الحقوق إلى نوعين : حقوقٌ ماليةٌ وحقوقٌ غيرُ مالية ، وتضمُ الحقوقُ الماليةُ : الحقوقَ العينيةَ ، والحقوقَ الشخصيةَ ، والحقوقَ الذهنيةَ ،

في حين تضم الحقوق غير المالية : الحقوق السياسية ، والحقوق العامة ، وحقوق الأسرة ، ولا ينال من هذا التقسيم أن يكون لبعض الحقوق غير المالية آثار مالية مثل حق البنوة الذي يستتبع حق الإرث ، وحق الطلاق الذي يستتبع حق النفقة ، أو يترتب على الاعتداء على الحقوق غير المالية حق المعتدى عليه في التعويض بوصفه حقاً مالياً.

ويمكننا أن نمثل لهذا التقسيم بالرسم الآتي :-



وسنحاول في هذا الباب أن نركز على التقسيم الأخير للحقوق وهو الذي يقسم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية ، مع مراعاة أننا في خصوص (الحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق الذهنية) الحقوق المالية سنذكرها بشيء من التفصيل، في حين نتناول الحقوق الأخرى غير المالية (الحقوق السياسية ، والحقوق العامة ، وحقوق الأسرة) بصورة موجزة . على أساس أنها عادة ما تكون محلا لدراسات متعمقة في كتب القانون العام (مثل القانون الدولي العام والقانون الدستوري أو قانون الأحوال الشخصية).

ولذا سنقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين: نخصص الفصل الأول للتعريف بالحقوق غير المالية، ونخصص الفصل الثاني للحقوق المالية.

الفصل الأول: الحقوق غير المالية.

الفصل الثاني : الحقوق المالية.

الفصل الأول

الحقوق غير المالية

تمهيد :

سنبين في هذا الفصل أنواع الحقوق غير المالية، وهي الحقوق السياسية، والحقوق العامة أو حقوق الشخصية، وحقوق الأسرة، كلٌ في مبحث خاص به.

المبحث الأول

الحقوق السياسية

Les droits Politiques

يقصد بالحقوق السياسية تلك الحقوق التي يقررها قانون الدولة لأشخاصها المنتمين إليها برابطة الجنسية حتى يتسنى لهم المشاركة في شئون الحكم وإقامة النظام السياسي بهذه الدولة.

وتهدف هذه الحقوق إلى حماية المصالح السياسية للأشخاص داخل الدولة مثل حق الانتخاب ، وحق الترشيح ، وحق تولى الوظائف العامة.

ويقصد **بحق الانتخاب** حق الشخص في اختيار من يمثله من النواب في المجالس النيابية لممارسة السلطة التشريعية بوصفها إحدى السلطات العامة الثلاث في الدولة، وذلك عن طريق الإدلاء بصوته لصالح من يختاره نائبا عنه في المجالس النيابية.

ولقد نص الدستورُ صراحةً على ثبوت حق الانتخاب لكل مواطن[1] ويتولى القانون الذي ينظم هذا الحق بيان كيفية إتمام قيد الشخص في جداول الانتخاب

---

[1] راجع المادة ٦٢ من دستور ١٩٧١م ، والمادة ٥٥ من دستور ٢٠١٢م، والمادة ٨٧ من دستور ٢٠١٤م .

وكيفية إدلائه بصوته.

أما **حق الترشيح** فيقصد به حق الشخص في أن ينوب عن الناخبين في تولى السلطة التشريعية بوصفها إحدى السلطات العامة في الدولة، وهو مثل حق الانتخاب مقصور على المواطنين دون الأجانب. وعادة ما يتدخل القانون لوضع شروط معينة يجب توافرها في الناخب أو النائب كأن يشترط سناً معينة لممارسة هذا الحق أو ذاك أو يشترط عدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أما حق **تولى الوظائف** العامة فيقصد به حق الشخص في أن يشغل إحدى الوظائف العامة في الدولة وفقا للشروط الموضوعية المقررة لشغل هذه الوظائف. وهو مثل غيره من الحقوق السياسية الأخرى حقٌ مقصورٌ على المواطنين دون الأجانب بحسب الأصل، حيث يمتنع على الأجانب شغل الوظائف العامة في الدولة تفاديا لاحتمالات التلاعب بمصالح الدولة والإضرار بشئونها العامة بدافع الولاء لبلادهم، هذا ما لم تقتض الظروف استقدام بعض الأجانب لشغل بعض الوظائف العامة للاستفادة من خبراتهم غير المتوافرة لدى المواطنين، على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء وبصفة عارضة ومؤقتة.

وتتميز الحقوق السياسية بأنواعها الثلاثة سالفة الذكر بأنها ليست حقوقاً محضةً أو خالصةً للمواطنين، بحيث يثبت لهم فيها الخيار بين استعمالها أو العزوف عن هذا الاستعمال، ولكنها حقوق تحمل معنى المؤونة والتكليف، ولذا فهي في حقيقتها واجباتٌ وتكاليفٌ إلى جانب كونها حقوقاً، ولذلك يرخص للدولة إجبار المواطنين في بعض الأحوال على شغل بعض الوظائف العامة حينما تقتضي المصالح العامة في الدولة ذلك ، كما يتم توقيع الغرامة على من يتخلف من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين سواسية كأسنان المشط في ممارسة هذه الحقوق السياسية متى توافرت لديهم الشروط المطلوبة قانونا، دون أية تفرقة بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين، وتحرص الدساتير عادة على تقرير هذا المبدأ بوصفه أحد الضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد السياسية.

المبحث الثاني

الحقوق العامة أو حقوق الشخصية

يقصد بالحقوق العامة Les droits publics أو حقوق الشخصية Droits de la personnalité تلك الحقوق التي تستمد أصلها من إنسانية الشخص (أي لكونه إنسانا) فتثبت له منذ ولادته حياً وحتى وفاته، بهدف المحافظة على كيانه المادي والمعنوي، فضلا عن تمكينه من مزاولة نشاطه المشروع بطريقة معتادة.

ويرجع اتصاف هذه الحقوق بوصف العمومية لكونها تثبت للناس كافة دون أدنى تفرقة بينهم في التمتع بها لأي سبب من الأسباب، كما يرجع وصفها بالشخصية لكونها مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً ومتلازماً لشخصية الإنسان [١] .

ولقد كان فلاسفة القانون الطبيعي يطلقون على هذه الحقوق اصطلاح الحقوق الطبيعية Les droits naturels ، على أساس أنها حقوقٌ تثبت للإنسان بحكم الطبيعة بمجرد ولادته حياً دون حاجة إلى قواعد تنشئها أو تقرر وجودَها [٢].

---

[١] وجدير بالذكر أن القانون الرومانى لم يكن يعرف حقوق الشخصية باعتبارها طائفة من الحقوق القائمة بذاتها. إلا أن حماية هذه الحقوق كانت تتأدى عن طريق دعوى قصد بها حماية الشخصية بصفة عامة أي حماية الكيان الجسدى والروحى للإنسان، وكان يطلق على هذه الدعوى اسم دعوى الاعتداء (انظر في ذلك: أ.د/ عبد الحى حجازى ص ٢٤) .

[٢] انظر في نفس المعنى: أ.د/ نعمان جمعة ص ٣٢٤، د/ حمدى عطيفي "نظرية الحق" بدون تاريخ، ص ١٠ انظر في نفس المعنى: أ.د/ نعمان جمعة ص ٣٢٤، د/ حمدى عطيفي "نظرية الحق" بدون تاريخ، ص ١٠ .

وتستهدف هذه الحقوق –كما يبدو من تعريفنا لها– حماية شخصية الإنسان في كافة مقوماتها سواء المادية منها أو المعنوية، هذا فضلا عن عنايتها ورعايتها بتمكين الشخص من مزاولة حرياته بشتى أنواعها وصورها.

ولذلك فهي تنقسم إلى أنواع ثلاثة تبعا للجانب الذي تُعْنَى بالاهتمام به في شخصية الإنسان، وذلك على النحو الآتي:–

أولا: الحقوق التي تستهدف حماية الكيان المادي للإنسان:

مثل حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسمه وأعضائه ، وتتجلى مظاهر الحماية لهذه الحقوق من خلال تجريم أي اعتداء يقع على الإنسان في نفسه (سواء حصل ذلك من غيره في صورة القتل العمد أو القتل الخطأ أو حتى القتل بدافع الشفقة مثل الطبيب الذي يساعد المريض بمرض مزمن على التخلص من حياته لإنهاء آلامه [١]أو حصل حتى من الإنسان نفسه ، حيث تعمد بعض التشريعات إلى معاقبة المرء على الشروع في الانتحار [٢]وإلى تجريم أي اعتداء يمس سلامة جسده من الضرب أو الجرح ، فضلا عن حقه هو أو ورثته في الرجوع على المعتدي بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الناجم عن هذه الاعتداءات وفق الضوابط المقررة قانوناً لذلك.

فالحق في الحياة هو أسمى هذه الحقوق على الإطلاق، لأن الحياة هبة الله

---

[١] فالقتل ولو بدافع الشفقة بالمريض (والذي يسميه الفقه بالقتل الرحيم) ، لا يحول دون قيام جريمة القتل في حق من ساعد المريض على إنهاء حياته ، سواء أكان طبيبا أم غيره (لمزيد من التفصيل حول هذا النوع من القتل راجع بحثنا بعنوان " إرادة المريض في العمل الطبى بين الإطلاق والتقييد" ص ١٢٤ وما بعدها ، طبعة عام ٢٠٠٥ م . دار النهضة العربية .

[٢] ذلك أنه وكما يقول البعض –وبحق– فإن حق " ... الإنسان على جسمه لا يعكس سلطانا للشخص على هذا الجسم بقدر ما يعكس تصميم النظام القانوني على حمايته ضد اعتداء الآخرين – لذلك كانت قدرة الإنسان على التصرف في جسده ، وما زالت وفقا للقوانين الحالية مقيدة إلى أبعد مدى " أ.د/ حمدى عبد الرحمن " مقدمة القانون المدني الحقوق وغيرها من المراكز القانونية ، ص ٥٣ ، طبعة عام ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ م .

لخلقه فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها بغير حق، وإلا عُدَ فعله من كبائر الذنوب شرعاً ومن عظائم الجرائم قانوناً ، وكيف لا والإنسانُ هو صنعةُ الله عز وجل وبنيانُه ملعونٌ من هدمه ، ولذلك تُجرِّمُ الشرائع جميعها الاعتداء على هذا الحق (سواء كانت شرائع سماوية أو شرائع وضعية) وتضع له عقوبات شديدة ومغلظة تناسب شناعته وفظاعته.

غير أني لم أجد وصفاً أو تصويراً يبرز شناعة جرم الاعتداء على حق الإنسان في الحياة كما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى "**أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً** "(١).

كما تحرص الشرائع جميعها على تجريم أي مساس غير مشروع بسلامة جسم الإنسان أو بسلامة أي عضو من أعضائه، فلا يجوز للغير أن يعتدي على جسم الإنسان أو على أحد أعضائه حتى ولو كان ذلك برضاء المعتدي عليه، بل إن الإنسان نفسه لا يملك أن يتصرف في أحد الأعضاء المزدوجة من جسمه (مثل إحدى كُلْيَتيه أو إحدى عينيه) لإنقاذ غيره إلا وفقا لضوابط وقيود معينة (مثل أن يكون ذلك على سبيل التبرع وليس على سبيل البيع تكريماً لهذا الجسم الإنساني ، وألا يلحق ذلك التبرع ضرراً أكبر بالمتبرع ، إلى غير ذلك من القيود التي لا يتسع المجال لذكرها الآن) لضمان المحافظة على كرامة الإنسان وآدميته التي أوجبها له الخالق جلَّ في علاه.

ثانيا: الحقوق التي ترمى إلى حماية الكيان المعنوي للإنسان:

ويتجسد هذا النوع من الحقوق في الحقوق التي تستهدف المحافظة على

---

(١) آية رقم ٣٢ من سورة المائدة.

سمعته الإنسان وشرفه وأسراره، وتتجه كافة التشريعات إلى تجريم المساس بمثل هذه الحقوق وتجعل للشخص حق دفع أي اعتداء يقع عليها، هذا فضلا عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تصيبه من جراء هذا الاعتداء .

ثالثا: الحقوق التي ترمى إلى تمكين الشخص من مزاولة نشاطه المشروع بطريقة عادية:

وهي تضم الحريات الشخصية والرخص العامة التي تثبت للأشخاص كافة مثل حرية التنقل، وحرية التملك، وحرية العمل، وحرية الإقامة وحرية الرأي والعقيدة ..... إلخ.

خصائص الحقوق العامة أو حقوق الشخصية :

يسيطر على خصائص هذه الحقوق فكرة أساسية مؤداها أنها حقوق غير مالية، أي لا تقبل الخضوع للتقييم الاقتصادي أو النقدي، مما يعني خروجها عن دائرة التعامل.

وينبني على وصف هذه الحقوق بأنها حقوق غير مالية الآثار والنتائج الآتية:-

١- عدم جواز التصرف في هذه الحقوق:

فلا يجوز للشخص أن يتصرف في حياته تصرفاً مادياً، أي بالانتحار، بل تحرصُ تشريعاتُ بعض الدول على تجريم الشروع في الانتحار وتقرر عقوبة لمن يقدم عليه، كما لا يجوز للشخص أن يتصرف في أي عضو من أعضائه نظرا لما ينطوي عليه هذا التصرف من مساس بسلامته وصحته إلا في إطار قانوني منظم يحدد ضوابط هذا التصرف (كأن يشترط القانون لصحة التصرف أن يكون بغير

مقابل أي على سبيل التبرع، وأن تكون ثمة ضرورة لمثل هذا التصرف، كما لو كان المتصرف إليه يحتاج إلى العضو المتصرف فيه لإنقاذ حياته من موت محقق، هذا فضلا عن اشتراط كون العضو المتبرع به من الأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان كأن يكون أحد العينين أو إحدى الكليتين، ومن ثمَّ لا يجوز التصرف في عضو تستحيل حياة الإنسان بدونه ولو كان ذلك برضاه، مثل التصرف في القلب أو الكبد)[1].

ولا يجوز للشخص أن يتصرف مثلاً في إحدى حرياته فمثل هذا التصرف يقع باطلا لوروده على محل يخرج عن دائرة التعامل، وتطبيقاً لذلك تنص المادة ٤٩ من التقنين المدني على أنه "ليس لأحد النزول عن حريته" غير أنه ثمة حالات يجوز فيها للشخص أن يتصرف في عناصر تنتج عن جسمه دون أن تمس بسلامة حياته أو جسده، مثال ذلك جواز إرضاع المرأة لأطفال غيرها بأجر، وجواز بيع الدم أو التبرع به.

٢- عدم جواز الحجز على هذه الحقوق :

لأن الحجز يؤدى إلى بيع محل الحجز جبراً عن الشخص، وهذه الحقوق لا يجوز التعامل عليها أصلاً.

٣- عدم انتقال هذه الحقوق بالميراث أو بالوصية:

فلا تنتقل هذه الحقوق بالميراث لأنها حقوق لصيقة بالشخص تظل ثابتة له طيلة حياته وتنقضي وتزول بزوال صاحبها فلا تنتقل إلى غيره.

ولقد أجاز البعض للشخص أن يتصرف في جسمه كله أو بأحد أعضاء

---

[1] راجع في ذلك : حماية الرضاء في عمليات نقل وزرع الأعضاء في بحثنا الموسوم بعنوان " إرادة المريض في العمل الطبي بين الإطلاق والتقييد " ص ١٧٢ وما بعدها .

جسمه بعد موته أي بطريق الوصية لأحد المعاهد العلمية أو الطبية، على أساس أن منع التصرف فيها بوصف عام يكون أثناء الحياة فقط [1].

والذي أعتقده أن جسم الإنسان كله أو بعضه ليس ملكا للإنسان نفسه، ولكن ملكيته خالصة لله سبحانه وتعالى، ومن ثمَّ فليس له أن يتصرف فيه مطلقا سواء كان حياً أو ميتاً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يصح أن يقال بأن المنعَ مقصورٌ على التصرف أثناء حياة الإنسان مما يجوز التصرف فيه بالإيصاء بعد الموت، لأن كرامة الإنسان وآدميته بعد الموت والتي لا يليق معها التصرف في الجسم أو أحد أجزائه، لا تقل تماما عن كرامته وآدميته حيا، لاسيما وأن الشرع الحنيف يجعل الاعتداء على جسم الميت أو أحد أعضائه مماثلا للاعتداء عليه أثناء حياته في الإثم والوزر.

وقد يعترض على قولي معترضٌ فيقول أن هذا الرأي يجافي مقتضيات التقدم والتطور في مجال العلوم الطبية، على أساس أن هذه العلوم تعتمد في تقدمها الذي يخدم الإنسانية جمعاء على البحوث والتجارب التي تُجْرَى على جسم الإنسان وأجزائه بعد موته لاسيما في علوم التشريح، فأردُ عليه بأن إقصاء جسم الإنسان أو بعض أعضائه عن مجال التجارب العلمية والبحوث الطبية لن يشل حركة تقدمها لاسيما مع وجود بدائل أخرى تحقق الكفاية لها في هذا الأمر، سواء أكانت بدائل طبيعية مثل بعض الحيوانات التي تتشابه في كثير من أعضائها مع أعضاء الإنسان، أم بدائل صناعية أيا كانت مواد صنعها، هذا بالإضافة إلى أن أي تقدم طبي أو غير طبي لا يمكن أن يتحقق إلا بمشيئة الله وإرادته، فهو المسبب الأعلى الذي يملك نواصي الأمور كلها، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وإكرامنا للإنسان بعد موته – بوصفه من أكرم وأفضل مخلوقات الله عند الله عز وجل–

---

[1] أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٨٠، ١٨١ .

بدفنه كاملا دون أي مساس به مطلقا يعد إكراما لخالقه وصانعه .

ومن ثَمَّ لن تكون هناك خشية من توقف حركة التقدم الطبي لأن الله عز وجل سيمكن عباده من تحقيق هذا التقدم الذي كانوا ينشدونه من خلال تجاربهم على جثث الموتى من بني الإنسان، بواسطة بدائل أخرى، فمن رحمته سبحانه وتعالى بخلقه ما جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم "تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء الهرم" (١) ، ويحضرني في هذا المقام أثر روى عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جاء فيه أن نبي الله موسى شكي لربه ألما أصابه في بطنه فأرشده ربه جلَّ في علاه إلى الأكل من عشب معين من الأعشاب فأكله سيدنا موسى فَشُفي بإذن الله، فلما عاوده نفس الألم ذهب إلى نفس العشب فأكله ولكنه لم يشف هذه المرة، فرجع إلى ربه وقصَّ عليه القصص، فكان جوابه له شافيا حيث قال له يا موسى في المرة الأولى لجأت إليَّ فخلقت لك السبب أما في المرة الثانية فلجأت إلى السبب وهو لا يفلح إلا بأذني أو كما قال رب العزة سبحانه وتعالى.

فحري بنا أن ندرأ عن أنفسنا عاقبه المساس بأجسام الموتى وجثثهم ولنكرمهم بالدفن استجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ، والله عز وجل قادرٌ على أن يعيننا على أي تقدم ننشده في المجال الطبي أو في غيره، فهو جلت قدرته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا والله أعلى وأعلم.

٤- عدم سقوط هذه الحقوق بالتقادم أو بعدم الاستعمال:

فلا يرد التقادم على هذه الحقوق سواء أكان تقادماً مسقطاَ أم تقادماً مكسباً، ومن ثَمَّ فإن عدم استعمال هذه الحقوق لفترات زمنية طويلة لا يؤدي إلى سقوطها،

---

(١) رواه الترمذي في سننه، جـ٤، رقم الحديث ٣٨٥٥، ص ٣ .

كما أن مرور الزمن لا يكسب الشخص حقاً من هذه الحقوق الخاصة بغيره مهما كانت مدته، فإذا استعمل شخصٌ اسمَ غيره مثلاً ولو لمدة طويلة، فإن ذلك لا يكسبه حقاً على هذا الاسم [١].

٥- يحتج بهذه الحقوق في مواجهة الكافة:

حيث يقع على عاتق الناس كافة واجب عام باحترام هذه الحقوق وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء.

المبحث الثالث

حقوق الأســرة

حقوق الأسرة Droits de la famille هي الحقوق التي تثبت للفرد بوصفه عضواً في أسرة معينة. وهي تتفاوتُ فيما بينها تبعا لمركزه داخل هذه الأسرة، فما يثبت لكل عضو في الأسرة من حقوق يختلف تبعا لكونه زوجاً أو أباً أو ابناً ..... إلخ.

فللزوج على زوجته حقوقٌ يقررها القانون مثل حقه في القوامة عليها [٢] وحقه في طاعته في غير معصية [٣] ، وحقه في تأديبها [٤]،كما أن للزوجة على

---

[١] انظر في نفس المعنى: أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٨١، أ.د/ نعمان جمعة ص ٣٢٩، د/ حمدي عطيفي ص ١٣ .

[٢] حيث يقول الحق تبارك وتعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .... (آية ٣٤ من سورة النساء) .

[٣] فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئت " (أخرجه ابن حبان ، ج ٩ ، ص ٤٧١ ، رقم الحديث ٤١٦٣ ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ، ج ١ ، ص ١٩١ ، رقم الحديث ١٦٦١) .

[٤] وقد أشار القرآن الكريم إلى حق الزوج في تأديب زوجته بالوعظ والتوجيه والإرشاد أو بالهجر في المضجع أو بالضرب غير المبرح في قوله تعالى " ..... واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً " (آية رقم ٣٤ من سورة النساء) .

زوجها حقوقاً مثل حقها في المهر [١]وحقها في النفقة [٢] وحقها في حسن المعاشرة [٣].

وللأب على أولاده حقوق مثل حقه في تأديبهم وتهذيبهم وحقه في طاعتهم له، وفي نفس الوقت للأبناء على أبيهم حقوق مثل حق الأولاد في النفقة ، وحقهم في النسب إليه ، وحقهم في الإرث منه.

وتعد حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم فهي تخضع في تنظيمها للتشريعات الخاصة الصادرة بشأنها ثم لأحكام قواعد الأديان السماوية الثلاثة بحسب ديانة كل أسرة .

ويلاحظ على هذه الحقوق أنها ليست حقوقاً محضة ولكنها حقوقٌ وواجباتٌ في نفس الوقت ، فحقٌ الوالد في تأديب أولاده يمثل في نفس الوقت واجباً على الأب بأن يحقق مصلحة الأولاد فيحسن تأديبهم وتهذيبهم ، كما أن حق الزوج في طاعة زوجته له يعد واجباً في نفس الوقت يملي عليه أن يعينها على هذه الطاعة فيحسن معاشرتها ويوفر لها حياة كريمة وآمنة وألا يأمرها بمعصية.

فهي كما يقول البعض –وبحق– ليست حقوقاً تمنح لأصحابها ابتغاء تحقيق مصالح شخصية لهم، ولكنها تمنح لتحقيق مصلحة الأسرة بصفة عامة، فضلاً عن الرغبة في تحقيق مصلحة الطرف الآخر الذي يخضع لسلطة صاحب

---

[١] حيث يقول الله تعالى " ..... فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة .... " (آية ٢٤ من سورة النساء) .

[٢] حيث يقول الله عز وجل " .... الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ... " (آية رقم ٣٤ من سورة النساء) .

[٣] حيث يقول الله عز وجل " ..... وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . (آية ١٩ من سورة النساء) .

الحق بصفة خاصة [1] .

وتعد حقوق الأسرة –بوصفها حقوقا غير مالية– من أنواع الحقوق التي تخرج عن دائرة التعامل فلا يجوز نقلها إلى الغير بالتنازل عنها أو التصرف فيها.

[1] أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٨٢ .

الفصل الثاني

الحقـوق المـالية

يقصد بالحقوق المالية Les droits pécuniaires تلك الحقوق التي يمكن إخضاعها للتقييم النقدي أو الاقتصادي، فيجري التعامل فيها والحجز عليها ويمكن انتقالها بالإرث. وهي بذلك تدخل في العناصر المكونة للذمة المالية فتمثل الجانب الإيجابي لهذه الذمة.

والحقوق المالية أنواع متعددة، تختلف فيما بينها تبعا للمحل الذي ترد عليه، فقد ترد على أشياء مادية معينة بالذات فتسمى بالحقوق العينية، وقد يكون محلها القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء فتسمى بالحقوق الشخصية، وقد ترد على أشياء غير مادية أي قيم معنوية فتسمى بالحقوق الذهنية أو المعنوية، وبذلك تنقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع هي الحقوق العينية، والحقوق الشخصية والحقوق الذهنية، نتناول كل واحدة منهم في مبحث مستقل، وذلك على التفصيل الآتي:

المبحث الأول

الحقـوق العينـية

تمهيد :

الحق العيني Le droit réel هو سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شيء معين بالذات، بحيث يتمكن هذا الشخص من مباشرة حقوقه على هذا الشيء دون حاجة إلى تدخل شخصي من جانب آخر.

وبذلك يختلف الحق العيني عن الحق الشخصي، حيث لا يتمكن صاحب الحق الشخصي (أي الدائن) من الحصول على حقه إلا إذا تدخل شخصٌ آخر

(أي المدين) ليمكنه من ذلك.

فحينما يكونُ المرءُ مالكاً لشقة مثلاً فإن حق الملكية الثابت له بوصفه حقاً عينياً أصلياً يخول له على هذه الشقة سلطة مباشرة تمكنه من الاستفادة منها دون توقف على تدخل شخص آخر، فيستطيع دون وساطة أحد أن يستعمل هذه الشقة فيسكن فيها أو يستغلها فيؤجرها أو يتصرف فيها بالبيع أو الرهن . بخلاف من له دين (بوصفه حقاً شخصياً) في ذمة شخص معين ، فإن حصوله على هذا الحق يتوقف على قيام المدين بوفاء الدين له، ومن ثَمَّ فهو يحتاج للحصول على حقه إلى تدخل شخص آخر وهو المدين.

وتنقسم الحقوق العينية إلى قسمين: حقوق عينية أصلية، وحقوق عينية تبعية.

المطلب الأول: الحقوق العينية الأصلية.

المطلب الثاني: الحقوق العينية التبعية.

المطلب الأول

الحقوق العينية الأصلية

يقصد بالحقوق العينية الأصلية Les droits réels principaux تلك الحقوق التي تخول لأصحابها سلطات مباشرة على أشياء معينة بالذات تمكنهم من الاستفادة منها في حدود صلاحيات هذه الحقوق. ذلك أن من هذه الحقوق ما يخول صاحبه جميع السلطات على الشيء المعين بالذات محل الحق فيخول له استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وهذا هو حق الملكية، ومنها ما تقصر صلاحيته عند تمكين صاحبه من مجرد الاستعمال والاستغلال فقط دون سلطة التصرف في الشيء محل الحق، وهذا هو حق الانتفاع، ومنها ما تقف صلاحيته عند حد التمكين من الاستعمال فقط دون الاستغلال والتصرف، وهذا هو حق الاستعمال ..... إلخ.

ويرجع تسمية الحقوق العينية الأصلية بهذا الاسم إلى كونها حقوقاً مستقلةً قائمةً بذاتها، فهي تنشأ بصفة أصلية غير مرتبطة في وجودها بوجود غيرها من الحقوق، فهي حقوق تقصد لذاتها بعكس الحقوق العينية التبعية التي لا تنشأ بصفة أصلية وإنما تنشأ بصفة تبعية مرتبطة في وجودها بوجود الحقوق الشخصية التي تضمنها، ولذلك فهي تدور مع هذه الحقوق الشخصية وجودا وعدما، فلا ينشأ الحق العيني التبعي إلا إذا كان ثمة حق شخصي ينشأ لضمان الحصول عليه، كما أنه ينقضي بانقضائه.

وتشمل الحقوق العينية الأصلية حق الملكية (بوصفه أبرز هذه الحقوق وأهمها على الإطلاق نظرا لما يخوله لصاحبه من سلطات واسعة النطاق لا يوفرها غيره من بقية الحقوق العينية الأخرى) وعدداً آخر من الحقوق الأخرى التي تتفرع من حق الملكية وهي حق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الحكر،

وحق الارتفاق.

أولا: حق الملكية :

يقصد بحق الملكية propride Droitété سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شيء معين بالذات بحيث يكون له الحق في استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

ويظهر من التعريف سالف الذكر أن حق الملكية يعد أقوى الحقوق العينية الأصلية وأوسعها مضمونا ونطاقا حيث يخول لمالك الشيء كافة السلطات التي يمكن أن تباشر على الشيء محل الملكية فله سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه (م٨٠٢ مدني).

واستعمال الشيء: يكون بالإفادة منه مباشرة والحصول على ما يمكن أن يؤديه من خدمات فيما عدا الثمار ودون أن يؤدى ذلك إلى المساس بأصله وجوهره، فاستعمال الأرض الزراعية يتحقق من خلال زراعتها، واستعمال المنزل يتحقق بسكناه، واستعمال السيارة يكون بركوبها، واستعمال الأرض الفضاء يكون بالبناء عليها [١].

أما استغلال الشيء فيكون بالإفادة منه بطريق غير مباشر وذلك بالحصول على ثماره، دون أي مساس بأصله أو جوهره.

ويقصد بالثمار كل ما يتولد عن الشئ بصفة دورية ومتجددة دون أن يمس أصله وجوهره. وهذه الثمار نوعان: ثمار مادية، وثمار مدنية.

---

[١] انظر في نفس المعنى إلى: أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٨٥، أ.د/ حسن كيره بند ٢٣٧، ص ٤٦١، أ.د/ العطار بند ٢١٣، ص ٤٣٣، أ.د/ عبد الحي حجازي " نظرية الحق في القانون المدني " ص ٦٠ ،٦١ ، بدون تاريخ نشر ، الناشر مكتبة وهبة ، أ.د/ محمد حسام لطفي – المرجع السابق ص ٣٣ ، د./ حمدي عطيفي ص ٢٠ .

والثمار المادية إما أن تكون بفعل الطبيعة دون أي تدخل من جانب الإنسان مثل نتاج الحيوان، ولذا فهي تُسمى بالثمار الطبيعية، وإما أن تكون بفعل الإنسان مثل المحصولات الزراعية وهي تسمى بالثمار الصناعية أو الثمار المستحدثة نظرا لمساهمة الإنسان في استخراجها واستحداثها.

أما **الثمار المدنية أو القانونية** فهي ما يغله الشيء من ريع أو دخل نقدي في مقابل انتفاع الغير به، مثل الأجرة التي يحصل عليها مالك الشقة نتيجة لتأجيرها لغيره، والفوائد التي يحصل عليها مالك الأسهم أو السندات.

أما **التصرف في الشيء** – والذي يمثل أقوى سلطات المالك على ملكه – فهو يعنى التسلط على رقبته أو على كيانه ووجوده بحيث يملك هو دون غيره التحكم في مصيره واستنفاد سلطاته عليه استنفاداً كلياً أو جزئياً. وهذا التصرف قد يكون تصرفاً مادياً بإفناء الشيء والقضاء على مادته عن طريق استهلاكه أو إتلافه أو بإحداث تغيير جوهري فيه على نحو يؤدي إلى قلب وظيفته والغرض منه، مثل هدم منزل أو تحويله من مسكن عائلي إلى فندق أو تصنيع المواد الأولية إلى منتجات، وقد يكون تصرفاً قانونياً بالنزول عن ملكيته للغير بمقابل (مثل بيعه له) أو بغير مقابل (بالتبرع به بعقد هبة) أو تقرير حق عيني أصلي آخر (مثل تقرير حق انتفاع على هذه الشيء) أو حق عيني تبعي (مثل رهنه رهناً رسمياً إن كان عقاراً أو رهنه رهناً حيازياً سواء كان عقاراً أو منقولاً) [1].

وتجدر الإشارة إلى أن ملكية الشيء قد تكون خالصةً لشخص واحد فينفرد بمباشرة كافة السلطات الثلاث سالفة الذكر (أي سلطه استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه) وعندئذ تعد ملكيته ملكية مفرزة، وقد يشاركه في ملكية هذا الشيء

---

[1] انظر في هذا المعنى إلى: أ.د/ حسن كيره بند ٢٣٧، أ.د/ توفيق حسن فرج ص ١٨٥، د./ محمد سعد خليفة ص ١٦٤، د./ حمدي عطيفي ص ٢٢ .

أشخاصٌ آخرون، بحيث يملك كل واحد منهم حصة شائعة فيه فتسمى الملكية عندئذ بالملكية الشائعة.

ويكون للشريك على الشيوع حق استعمال واستغلال حصته الشائعة وله حق التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في المال الشائع كله أو في جزء مفرز منه، فمثل هذا التصرف من حق جميع الشركاء أو الأغلبية الخاصة المالكة لثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل (م٨٣٢ مدني)، ويرخص القانون للشريك على الشيوع الحق في طلب إنهاء حالة الشيوع بقسمة المال الشائع ، هذا ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق (م٨٣٤ مدني).

خصائص حق الملكية :

يتميزُ حقُ الملكية بعدد من الخصائص أهمها:-

١- حق الملكية حق مقيد ذو وظيفة اجتماعية:

لم يعدْ حقُ الملكية حقاً مطلقاً عن القيد كما كان الوضعُ قديماً في ظل المذهب الفردي، حيث كان للمالك على ملكه سلطاتٌ مطلقة، ولم يكن بمقدور واضع القانون آنذاك أن يتدخلَ لتقييدها أو الحد منها سواء تحقيقا للمصلحة العامة أو الخاصة، بيد أنه مع أفول الفكر الفردي وانتشار الفكر الاشتراكي أضحتْ الملكيةُ ملكيةً موجهةً لخدمة الاقتصاد القومي تؤدى دوراً ذا وظيفة اجتماعية في المجتمع، وأضحى لواضع القانون حق التدخل للحد من غلواء إطلاقها من القيود فيفرضُ عليها عددا من القيود التي تستهدفُ تحقيق المصلحة العامة مثل وضع حد أقصى للملكية الزراعية والأراضي البور والصحراوية أو تلك القيود التي تنشد تحقيق بعض المصالح الخاصة بوصفها هي الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية من غيرها مثل مصلحة الملاك المجاورين التي أملت على واضع القانون تقدير بعض الحقوق لهم على أراضى جيرانهم مثل حق المرور وحق الشرب وحق وضع

العلامات بين الأملاك المجاورة [1].

٢- حق الملكية حق جامع ومانع:

ويرجع وصفه بأنه حقٌ جامعٌ إلى كونه يتيح للمالك كافة السلطات التي يمكن مباشرتُها على الشيء محل الملكية، حيث يكون للمالك حق استعمال الشيء الذي يملكه واستغلاله والتصرف فيه (سواء أكان هذا التصرف تصرفا ماديا أم تصرفا قانونيا)، وهذه السلطات بصورها الثلاثة تمكن المالك من استنفاد كل مزايا الشيء ومنافعه ، أما عن وصف حق الملكية بأنه حق مانع نظرا لأنه يجعل للمالك وحده حق الاستئثار بمنافع الشيء ومزاياه، فله وحده استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه (م٨٠٢ مدني [2])، وإذا اعتدى عليه غيره وحال دونه وممارسة إحدى هذه السلطات الثلاث، كان من حقه أن يدفع هذا الاعتداء ، كما له أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الاعتداء .

٣- حق الملكية حق دائم:

يتميزُ حقُ الملكية بأنه حقٌ دائمٌ، فهو يدومُ بدوام الشيء محل الملكية، ولا ينالُ من ديمومته وبقائه تغيرُ الملاك أو تعاقبهم عليه، إذ أنه لا يزولُ إلا بزوال الشيء محل الملكية وهلاكه. غير أن هذا المعنى لا يصدق إلا على العقار وحده، نظراً لأن المنقول إذا ما تخلَّى عنه صاحبه أضحى بغير مالك حتى يستولي عليه غيرُه.

ويتميزُ حقُ الملكية عن غيره من الحقوق العينية وعن جميع الحقوق الشخصية بأنه حقٌ لا ينتهي بالتقادم المسقط. فلو فرضنا أن شخصاً هجر منزله

---

[1] انظر في نفس المعنى: د./ حمدي عطيفي ص ٢٣ .

[2] تنص المادة ٨٠٢ مدني أن "مالك الشيء وحده، في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".

لفترة زمنية أيا كانت مدتها فإنه لا يترتبُ على ذلك سقوطُ حقه، بل يظلُ مالكاً له.

بيد أنه قد يجري على هذا الحق التقادمُ المكسبُ، فمتى وضعَ شخصٌ يدَه على منزلٍ مملوكٍ لغيره بنية تملكه مدة التقادم المكسب أصبح هو المالكَ لهذا المنزل وزالتْ ملكيةُ المالك الأول، على أساس أن الملكية الجديدة هي الملكية الأولى بالتقدير والتفضيل لأنها تتفقُ مع الوضع الظاهر وتساعدُ على تحقيق الاستقرار الاجتماعي من وجهة نظر كثير من الفقهاء [1] .

والذي أعتقده أن تمكين واضع اليد على العقار مدة معينة من تملكه لهذا العقار المملوك لشخص آخر غيره بحجة أن هذا الأخير قد ترك له ماله وأهمل في حيازته له طوال مدة حيازة واضع اليد لهذا المال ، أمرٌ يصدق عليه وصف الإعانة على الغصب والظلم، ولا يصحُ بحالٍ من الأحوال تبرير هذا الوضع الجائر بأي علل أو مبررات، مثل ذلك الزعم الذي يساق لتبرير التقادم بحجة أنه خيرُ عقاب للمالك المهمل الذي يترك ملكه لغيره ليكسب ملكيته بمضي المدة هو حرمانه من هذا الملك، فهو إدعاءٌ مردودٌ على صاحبه ، ذلك أن العقابَ ليس غايةً في حد ذاته وإنما هو وسيلةٌ وأداةٌ لإصلاح المجتمع وتقويم سلوكيات أفراده، لذا كان من الواجب أن يتناسبَ حجمُ هذا العقاب مع قدر الخطأ والتقصير المرصود له ، ولا أظنُ مطلقاً أن المالك المهمل مهما بلغ إهمالُه وتقصيرُه في الحفاظ على ملكه من ذاك الغصب الحاصل له عن طريق وضع اليد لكسب ملكيته يستحق عقلاً ومنطقاً أن يجري حرمانُه تماماً من خالص حقه وملكه عليه مع إباحة كسبه قانوناً في نفس الوقت ملكاً سائغاً لآخر غصباً، ويكفينا في إبراز شناعة هذا الوضع الجائر ما قاله سيد الخلق سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم " لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرَّم الله عليه الجنة وأوجب له النار" فقال رجلٌ من القوم : يا رسول الله

---

[1] أ. د/ نعمان جمعة ص ٣٤٦ .

وإن كان شيئاً يسيراً ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " وإن كان سواكا من أراك" [١] فهذا حال من غصب شبراً بيمينه (أي بقسمه وحلفه كذباً)من أرض غيره، فكيف بمن غصب الأرض كلها واستحل حق غيره كاملاً (٢) .

وتجدر الإشارة إلى أن أسباب كسب الملكية في القانون المدني المصري هي الميراث، والوصية، والعقد، والشفعة، والالتصاق، والاستيلاء، والحيازة.

ثانياً: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية:

يتفرع عن حق الملكية وفقاً لأحكام القانون المدني المصري حقوق عينيه أصلية كثيرة ومتنوعة، تتفاوت فيما بينها تبعا لمضمون وفحوى كل حق من هذه الحقوق، هذه الحقوق هي:-

١- حق الانتفاع: Droit d`usufruit

يمكننا تعريف هذا الحق بأنه سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شيء معين بالذات مملوك لغيره تمكنه من استعماله واستغلاله دون التصرف فيه. أو هو حقٌ يخولُ للمنتفع سلطة استعمال واستغلال ملك غيره دون التصرف فيه [٣].

وقد عرفنا فيما سبق أن المالكَ لشيء معين له عليه سلطاتٌ ثلاثٌ هي سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فإذا ما قرر لغيره حقَ انتفاع على هذا الشيء كان لهذا الغير حقُ استعمال الشيء واستغلاله فقط، أما حق التصرف

---

[١] رواه الإمام ابن ماجة في سننه ، جـ ٢ ، رقم الحديث ٢٣٢٤ ، ص ٧٧٩ .

(٢) فلا ينكرُ أحدٌ أن أكل أموال الناس بالباطل أيا كانت صورتُه حرامٌ شرعاً ، عملاً بالنهي الوارد في قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (آية رقم ٢٩ من سورة النساء) وتزداد الحرمة لمن يدعم سبيل ذلك بالحلف الكاذب كما جاء في هذا الحديث النبوي الشريف .

[٣] أ.د/ حسن كيرة بند ٢٣٧، ص ٤٦٢ .

فيظل ثابتاً لمالك الشيء بوصفه مالكاً لرقبته.

ويقع على عاتق المنتفع التزام بالمحافظة على الشيء الذي له عليه حق انتفاع، وأن يبذل من العناية في المحافظة عليه ما يبذله الشخص المعتاد (م ١/٩٩٠ مدني)، كما يلتزم برد هذا الشيء بمجرد انتهاء حقه عليه.

ويكتسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصية أو بالشفعة أو بالتقادم ، وينتهي حق الانتفاع بوصفه حقاً عينياً مؤقتاً بانتهاء الأجل المحدد له، فإن لم يعين له أجل انتهى بموت المنتفع أيهما أقرب، كما ينتهي بهلاك الشيء المنتفع به أو بتنازل المنتفع عن حقه في الانتفاع به أو بعدم استعماله هذا الحق خمس عشرة سنة.

٢- حق الاستعمال وحق السكنى:

يقصد بحق الاستعمال Droit d`usage (بوصفه حقاً عينياً أصلياً متفرعاً عن حق الملكية) سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شيء معين بالذات مملوك لغيره تمكنه من استعماله فقط دون استغلاله أو التصرف فيه.

فحقُ الاستعمال أضيقُ نطاقا من حق الانتفاع فهو لا يخول صاحبه سوى سلطة واحدة من سلطات المالك على ملكه، ألا وهي سلطة الاستعمال والتي تمثل أدنى عناصر الملكية وسلطاتها، بخلاف حق الانتفاع الذي يخول صاحبه سلطتين من سلطات المالك ألا وهما سلطتا الاستعمال والاستغلال.

فحقُ الاستعمال يتيح لصاحبه استعمال الشيء فيما أعد له، فإن كان أرضا زراعيه فله زراعتها بنفسه وجني محصولاتها، لكن ليس له استغلالها بتأجيرها لغيره، لأن هذه السلطة تخرج عن نطاق هذا الحق.

أما حق السكنى: Droit d`habitation

فهو سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على دار أو منزل معين بالذات

مملوك لغيره تمكنه من استعماله للسكنى فيه فقط.

فهذا الحق أضيق نطاقاً من حق الاستعمال حيث يقتصر على وجه واحد من وجوه استعمالات الشيء محل الحق، ألا وهو السكنى أو القرار فيه، ومن ثمَّ فليس من حقه أن يستعمله لغرض آخر غير السكنى كأن يستعمله متجرا أو مكتبا يمارس فيه مهنة من المهن (كأن يفتحه مكتبا للمحاماة أو للاستشارات الهندسية... إلخ)، وليس له من باب أولى أن يقوم بتأجيره لغيره.

ولا يجوز لصاحب حق الاستعمال أو حق السكنى أن يتنازل عن حقه للغير إلا بمقتضى شرط صريح بينه وبين مالك الشيء محل الحق أو لمبرر قوى (م ٩٩٧ مدني)، وهما حقان مؤقتان – مثل حق الانتفاع – ينتهيا بانتهاء الأجل المحدد لهما أو بموت صاحبهما قبل انقضاء الأجل أو بعدم الاستعمال لمدة خمسة عشرة سنه أو بهلاك الشيء محل الحق.

٣- حق الحكر:

حق الحكر – بوصفه أحد الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري [١]– هو سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على أرض موقوفة تمكنه من الانتفاع بها بالبناء عليها أو الغراس فيها مقابل أجرة المثل لفترة موقوتة [٢].

ويعد هذا الحق نظاما مستمدا من الشريعة الإسلامية الغراء، يستهدف من ورائه عمارة الأراضي الخربة واستصلاحها، فيتم تسليمها لشخص يسمى المحتكر ليقوم بتعميرها وإعدادها للبناء عليها أو الزراعة فيها، ويكونُ له عليها ولورثته حقُ

---

[١] فقد ثار خلاف في الفقه قبل صدور القانون المدني الحالي حول طبيعة حق الحكر، فذهب البعض إلى اعتباره حقا شخصيا، في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتباره حقا عينيا، فلما صدر القانون المدني الحالي حسم هذا الخلاف وذكره ضمن الحقوق العينية الأصلية (أ.د./ عبد الحي حجازي، ص ٥٨) .

[٢] قرب ذلك تعريف أ.د./ عبد المحي حجازي ص ٥٨ .

انتفاع من بعده مقابل أجرة مماثلة لما يدفع في أرض مثلها.

ويكون للمحتكر إلى جانب حق الانتفاع بهذه الأرض سواء بالبناء عليها أو بالغراس فيها، حقُ ملكية لما يحدثه عليها من بناءٍ أو زراعةٍ، ويكون له أن يتصرف في محل حق الملكية وحده أو أن يتصرف فيه مع حقه في الحكر (م١٠٠٢ مدني).

ولا يجوز الحكر في القانون المدني الحالي إلا على الأراضي الموقوفة (م١٠١٢) ويلزم لنشأة هذا الحق أن تكون ثمة ضرورةٌ أو مصلحةٌ تقتضيه، وأن يتمَ تقريرُه بإذن من المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها الأرض الموقوفة كلها أو أكثرها قيمة ، وأن يصدر به عقدُ على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، هذا فضلا عن ضرورة شهر حق الحكر وفقا لقانون تنظيم الشهر العقاري (م ١٠٠٠ مدني)، ولا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أُعتبرَ الحكرُ معقوداً لمدة ستين سنة (م٩٩٩ مدني).

وينتهي حق الحكر بانتهاء الأجل المعين له وإلا بانتهاء الستين عاما إذا عينت له مدة أطول أو أغفلت مسألة تعيين المدة (م ١/١٠٠٨ مدني)، ولا ينتهي حقُ الحكر بموت المحتكر بل ينتقلُ إلى ورثته وذلك متى كانت الوفاةُ قبل انتهاء مدة الحكر، ومع ذلك ينتهي حق الحكر قبل حلول المدة المعينة له إذا مات المحتكر قبل البناء أو الغراس في الأرض ما لم يطلب جميع الورثة بقاء الحكر (م ٢/١٠٠٨ مدني).

وينتهي حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالتْ عن الأرض المحكرة صفةُ الوقف (على أساس أن التحكيرَ لا يجوز إلا على الأراضي الموقوفة) هذا ما لم يكن زوال هذه الصفة يرجع إلى رجوع الواقف عن وقفه أو إنقاصه لمدته، فعندئذ

يبقى الحكرُ إلى انتهاء مدته (م١٠٠٨/٣ مدني).

٤- حق الارتفاق:Droit de servitude

لقد عرفت المادة ١٠١٥ مدني هذا الحق بأنه "حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.....".

ويظهر من التعريف سالف الذكر أن حقَ الارتفاق يفترضُ وجود عقارين مملوكين لشخصين مختلفين ، ثم يتقررُ هذا الحقُ على أحد العقارين ويسمى بالعقار الخادم لصالح العقار الآخر ويسمى بالعقار المخدوم أو العقار المرتفق (أي المقرر لفائدته الارتفاق).

وحقوق الارتفاق كثيرة ومتنوعة، قد تكتسب بعقد أو بوصية أو بطريق الميراث أو بالحيازة، وقد يكون مصدرها نصاً قانونياً، ومن أمثل هذه الحقوق:-

- **ارتفاق المطل:**

وهو عبارة عن تكليف يكون بمقتضاه لصاحب العقار المخدوم حق فتح مطلات على ملك الجار على أقل من المسافة القانونية.

- **حق المرور:**

وهو تكليف يكون بمقتضاه لصاحب العقار المخدوم حق المرور على أرض جاره ليصل إلى أرضه أو منزله.

- **حق الشرب (بكسر الشين):**

هو تكليف يكون بمقتضاه لصاحب العقار المخدوم حق سقي أرضه من مسقاه في أرض جاره.

-**حق المجرى:**

هو تكليف يكون بمقتضاه لصاحب العقار المخدوم حق المرور بمجرى الماء في أرض غيره إذا سمح صاحب هذه الأرض بمرور مسقاه في أرضه.

ويلاحظ على حقوق الارتقاق أن منها ما هو ظاهر مثل حق المرور وحق المطل وحق المجرى وحق الشرب، ومنها ما هو خفي غير ظاهر فلا تدل عليه علامة ظاهرة مثل الحق في عدم تعلية البناء عن حد معين.

وجدير بالذكر أنه نظرا لأن حق الارتفاق حق يتقرر لمنفعة عقار معين، فإن المنفعة فيه منفعة عينية تتصل بالعقار وليست منفعة شخصية تتصل بمالك هذا العقار، لذلك كان من الطبيعي أن يبقى هذا الحق ويستمر وجوده، رغم تغير ملاك العقار المرتفق (أي العقار المخدوم) وتعاقبهم عليه، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الحق حق أبدي دائم مثل حق الملكية، إذ أنه من الممكن الاتفاق على تأقيته بأجل معين ينقضي بانقضائه ، كما ينتهي بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً أو باجتماع ملكية العقارين لشخص واحد .

ولذلك تنص المادة ١٠٢٦ مدني على أن "تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً، وباجتماع العقارين في يد مالك واحد....."

كما تنتهي أيضا هذه الحقوق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة (م١٠٢٧ مدني).

المطلب الثانى

الحقوق العينية التبعية

تمهيـد:

يقصد بالحقوق العينية التبعية les droits réels accessoires تلك

الحقوق التي يقررها الاتفاق أو القضاء أو القانون على أشياء معينة بالذات مملوكة للمدين لضمان الوفاء بحقوق دائنيه ضماناً خاصا [١] . فهي حقوقٌ عينية لأنها تخول للدائن سلطة مباشرة على مال معين من أموال مدينه فلا ترد على عمل أو امتناع عن عمل، كما أنها حقوق تبعية على أساس أنها تنشأ مرتبطة بحقوق شخصية لضمان الوفاء بها وتأمين حصول الدائنين على هذه الحقوق، فوجودها ليس وجودا مستقلا بنفسه مثل الحق العيني الأصلي، وإنما وجودها تابع لوجود هذه الحقوق الشخصية، ولذلك فهي تدور معها وجوداً وعدماً، فلا تنشأ إلا إذا وجدت حقوق شخصية تضمن هي الوفاء بها، كما أنها تنقضي بانقضاء الحقوق الشخصية لأي سبب من الأسباب، إذ أنه بانقضاء الحق الشخصي تنقضي علة وجود الحق العيني التبعي المقرر لضمان الوفاء به [٢].

ويطلق الفقه على هذه الحقوق العينية التبعية اصطلاح التأمينات أو الضمانات العينية Les assurances ou Les garanties réelles . وسنحاول في هذا المطلب بيان سبب ظهور فكرة التأمينات العينية أو الحقوق العينية التبعية، وأنواع هذه الحقوق أو التأمينات العينة التبعية في القانون المدني المصري.

الفرع الأول

مبررات نشأة فكرة الحقوق العينية التبعية

أولا: عدم كفاية التأمين أو الضمان العام :

لا يتعلق حق الدائن العادي أو صاحب الحق الشخصي أيا كان مصدره

---

[١] قرب ذلك انظر إلى: أ.د./ حسن كيره بند ٢٣٨، ص ٤٦٤، أ.د./ عبد الحي حجازي ص ٥٩ .

[٢] انظر في ذلك إلى: كتابنا في "الوجيز في التأمينات العينية" ص ٢٣ وما بعدها .

بمال معين بالذات من أموال مدينه، وإنما يتعلق حقه مع غيره من الدائنين بجميع عناصر الذمة المالية لهذا المدين [١].

فأموالُ المدين جميعها تمثل الضمان العام المقرر قانوناً لحماية حقوق دائنيه، إذ تنص المادة ١/٢٣٤ مدني مصري على هذا المعنى بقولها إن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه". ومن ثمَّ فمن حق الدائن إذا لم يبادر مدينه بالوفاء بديونه طواعيةً واختياراً، أن يلجأ إلى السلطات العامة لتمكينه من التنفيذ الجبري على جميع أمواله التي تمثل ضماناً عاماً للوفاء بحقوقه وحقوق غيره من الدائنين، وهذا ما قرره واضعُ القانون في المادة ١/١٩٩ مدني مصري الحالي بقوله "ينفذ الالتزام جبراً على المدين [٢].

وقد يبدو لأول وهلة أن في منح الدائن ضماناً عاماً يَرِدُ على جميع أموال مدينه، وإعطائه الحق في التنفيذ عليها جبراً عنه، عند امتناع المدين عن الوفاء بحقوقه أو التأخير في التنفيذ ، حمايةً كافيةً تسمح لهذا الدائن بتأمين حقه في استيفاء ديونه كاملة غير منقوصة، إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك.

فالضمانُ العامُ لا يحققُ عادةً غاية الدائن في تأمين حقوقه وذلك للأسباب الآتية:-

١- إن وجود الضمان العام في ذاته بوصفه تأميناً عاماً يقرره القانونُ ضماناً لحق الدائن فضلاً عن استفادته منه ، مرهونٌ بأن يكون ثمة أموال مملوكة للمدين يمكن أن يرد عليها هذا الضمان، ومن ثمَّ يتصور عدم وجود هذا الضمان أصلا

---

[١] انظر في نفس المعنى: أ.د/ محمود جمال الدين زكي "التأمينات الشخصية والعينية" ص ١٥، الطبعة الثالثة عام ١٩٧٩م، مطبعة دار الشعب بالقاهرة .

[٢] انظر في ذلك: أ.د/ سمير تناغو "التأمينات الشخصية والعينية" ص ٥ طبعة عام ١٩٧٥م، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية .

إذا ما ثبت فراغ الذمة المالية للمدين.

٢- إن هذا الضمان العام- حتى على فرض وجوده فعلاً لثبوت ملاءة الذمة المالية للمدين - نظرا لعدم تعلقه بمال معين من أموال المدين وروده من ثم على جميع أمواله، فإنه لا يغل يد المدين عن التصرف في هذه الأموال تصرفا ينقص هذا الضمان، الأمر الذي يؤدى إلى عدم كفاية أموال المدين في الوفاء بحق الدائن عند اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بشأنها.

وإذا كان القانون قد جعل بين يد الدائن وسائل قانونية متعددة بهدف المحافظة على الضمان العام المقرر له، ودفع محاولات المدين لإنقاص هذا الضمان أو الحد من زيادته عن طريق الدعاوى الثلاث- الدعوى غير المباشرة، الدعوى البوليصية ، ودعوى الصورية- وغيرها من الوسائل الأخرى (مثل وضع الأختام على أمواله أو تحرير محضر جرد بها عند موته أو إفلاسه أو تدخله في إجراءات قسمة المال الشائع المملوك لمدينه أو استعمال الحق في الحبس أو طلب شهر إعسار المدين) ، إلا أن هذه الوسائل قد لا تكفي في المحافظة على الضمان العام للدائنين، ومن ثمَّ قد لا تفلح في منع المدين من التصرف في أمواله بما يضر بمصلحة دائنيه رغم ما تسببه للدائن من مشقة وعناء في سبيل اتخاذها.

٣- إن مثل هذا الضمان يشترك فيه جميع الدائنين، ذلك أن الدائنين العاديين جميعهم متساوون في المرتبة، فليس ثمة أفضلية لأحدهم على غيره بالنظر إلى أسبقية نشوء دينه أو أسبقية تاريخ حلوله، ومن ثمَّ فإنه إذا كانت مكونات ذمة المدين المالية أو عناصر الضمان العام غير كافية للوفاء بمجموع حقوق الدائنين كاملة، اقتسموها فيما بينهم قسمة غرماء أي توزع بينهم بحسب نسبة دين كل واحد منهم، ومن ثم فإن هذا الضمان العام قد يعجز عن تأمين حقوق الدائن للوفاء بها كاملة.

ولعل هذه الأسباب الثلاثة سالفة الذكر (والتي كشفت لنا عن مواطن الضعف وأوجه القصور في التأمين العام أو الضمان المشترك) أبرزت لنا- في المقابل- الحاجة الماسة إلى وجود تأمين أو ضمان خاص (التأمين الشخصي والتأمين العيني) كضمان كافٍ لحماية حق الدائن جنبا إلى جنب مع التأمين أو الضمان العام، حتى يتسنى لكل دائن استيفاء حقوقه كاملة من المال محل الضمان الخاص دون أن يزاحمه فيه أحد من الدائنين العاديين أو التاليين له في المرتبة عند اتخاذه إجراءات التنفيذ الجبري على هذا المال.

ثانياً: فكرة التأمين أو الضمان الخاص وفائدتها:

تتخذ فكرة التأمين أو الضمان الخاص في واقع الحياة إحدى صورتين:

أولاهما: تتمثل في إيجاد أكثر من شخص يستطيع الدائن أن يطالبه بذات الدائن، حتى إذا عجز الدائن عن الحصول على حقه من مدينه، كان له حق في الرجوع على شخص آخر أو أشخاص آخرين للمطالبة بحقه أو بما لم يستوفه من ذلك الحق، وهي ما تعرف بالتأمينات الشخصية Les sûretés personnelles (مثل الكفالة والتضامن بين المدينين ، وعدم انقسام الدين بين المدينين ، والإنابة الناقصة [1] والاشتراط لمصلحة الغير).

وتمثل الكفالة الصورة المثلى للتأمينات الشخصية، إذ يترتب عليها أن تضاف إلى ذمة المدين ذمة شخص الكفيل ، ولذا يمكن للدائن إذا لم يتمكن من اقتضاء حقه من مدينه أن يطالب الكفيل أو الضامن بالوفاء بهذا الحق.

وثانيهما: تتمثل في صورة تخصيص مال معين بالذات مملوك لشخص المدين

---

[1] وتعد الإنابة الناقصة تأمينا شخصيا لمصلحة الدائن، إذ يترتب عليها أن يصير أمام الدائن مدينان بدلا من مدين واحد، بحيث إذا أعسر المنيب وعجز بذلك عن وفاء دينه أمكن للدائن اقتضاء حقه من الشخص المناب (أ.د/ محمود جمال الدين زكي- المرجع السابق- ص ٢٦) .

أو لشخص آخر غيره سواء أكان عقاراً أو منقولاً لضمان الوفاء بحق الدائن بحيث يمكن للدائن إذا لم يوفه المدين حقه طواعيةً واختياراً، أن ينفذ بحقه على هذا المال محل الضمان متتبعاً إياه في يد أي شخص ليستوفي حقه منه أولا متقدماً على سائر الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة، وهي ما تعرف بالتأمينات العينية les sûretés réelles (مثل الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الاختصاص وحق الامتياز).

وللتأمين الخاص فائدة مزدوجة، حيث تتحقق من ورائه مصلحة كل من الدائن والمدين على السواء، وتتجلى مصلحة الدائن ظاهرة في ضمان حصوله على حقه، فيمكنه من استيفاء دينه كاملاً من أي شخص من الأشخاص المسئولين عن الوفاء به إذا كان التأمين شخصيا، أو من حصيلة ثمن بيع المال الضامن أو العين الضامنة (سواء أكانت عقارا أم منقولا) دون أن يزاحمه في ذلك أحد الدائنين العاديين أو الدائنين التاليين له في المرتبة إذا كان التأمين عينيا.

كما تبدو مصلحة المدين نفسه– من التأمين أو الضمان الخاص– واضحة فيما يحققه له من ثقة كبيرة في نفس الدائن فيمنحه ائتمانه، إذ يندر في المجتمع الآن–إلا النزر اليسير– أن يمنح شخص (سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا كبنك أم شركة تمويل) قروضا أو ائتمانات (صغيرة أم كبيرة) لغيره من الأشخاص (سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصا معنوية كشركات أو مؤسسات اقتصادية) لتمويل مشروعاتهم الاستثمارية، دون أن يحصل على كافة التأمينات أو الضمانات الخاصة شخصية كانت أو عينية لضمان سداد هذه القروض والائتمانات في مواعيدها المحددة.وليس بخافٍ علينا ما للائتمان [1]–

[1] شريطة أن يخلو هذا الائتمان من مظان الربا المحرم شرعا . ويا ليت وجود البنوك الإسلامية يكون سببا فاعلا في تنقية التعامل المالي من شوائب الربا ، وليس ذلك على الله بعزيز إذا صدقت النية في البعد عن مواطن الحرام لدى القائمين على هذه البنوك ، وحرص الناس على قصر تعاملهم على البنوك الإسلامية ونبذوا التعامل

الذي تساعد التأمينات أو الضمانات الخاصة على انتشاره– من دور كبير في إثراء الحياة الاقتصادية في المجتمعات ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها.

ثالثا: المفاضلة بين نوعى التأمين أو الضمان الخاص:

لا جرم أن التأمين أو الضمان الخاص بنوعيه الشخصي والعيني يبعث في نفس الدائن الثقة والطمأنينة ضد خطر الخوف من ضياع حقه وعدم استيفائه.

ففي التأمين الشخصي تضاف إلى ذمه المدين المالية بكل مكوناتها، ذمة مالية جديدة بجميع عناصرها لشخص آخر مسئول عن الوفاء بالدين وضامن لهذا الوفاء.

كما أنه في التأمين العيني تُخَصصُ لضمان الوفاء بحق الدائن إحدى الأعيان المملوكة للمدين أو لشخص آخر غيره، بحيث ينشأ للدائن عليها حقٌ خاصٌ يخول له ميزة تتبع هذه العين تحت يد أي شخص فيتقي بذلك خطر محاولة التصرف فيها لإقصائها من ضمانه، كما يخول له أيضا ميزة التقدم على غيره من الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمنها عند بيعها بالمزاد، فيتقي بذلك خطر مزاحمة هؤلاء الدائنين له عند التنفيذ بحقه على العين محل الضمان.

بيد أننا إذا أردنا أن نجري مقارنة بين نوعى التأمين أو الضمان الخاص لنتعرف على أفضلية أي منهما في ضمان وتوكيد حق الدائن وإعانته على استيفاء حقه كاملاً، وجدنا أن التأمين العيني يَفْضُلُ التأمين الشخصي في هذا المقام.

ذلك أن التأمين الشخصي وإن بدا في ظاهره أكثر رحابة وسعة من

مع غيرها من البنوك الربوية التي تردد مقولة المرابين في صدر الإسلام إنما البيع مثل الربا ، فتخلط بذلك الحق بالباطل ، ولكن الحق داحض للباطل فليس البيع كالربا ، فقد أحل الله البيع وحرم الربا .

التأمين العيني في المحل الذي يرد عليه، على أساس أنه يرد على جميع عناصر الذمة المالية لشخص الضامن فيضيف بذلك إلى جوار جميع مكونات الذمة المالية للمدين- والتي تمثل الضمان العام لهذا الدائن ولغيره من الدائنين- ضمانا آخر جديداً يرد على ذمة مالية جديدة لشخص الضامن بكل عناصرها ومكوناتها، فلا يكون مقصوراً على عين محددة بالذات من بين أعيان الضامن كما هو الحال في التأمين العيني، إلا أن الدائن مع وجود هذا التأمين الشخصي قد يتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها في مواجهة مدينه، فقد لا يجد الدائن أموالا في ذمة الكفيل لينفذ عليها بحقه أو يجد أموالا قليلة لا تكفي للوفاء بهذا الحق أو تكفي ولكن يزاحمه فيها دائنو الكفيل، بعكس الحال في التأمين العيني حيث يراعى في البداية قبل ترتيبه على مال معين بالذات أن يكون هذا المال كافيا في الوفاء بحق الدائن، كما أن للدائن الحق في طلب تأمين آخر إذا هبطت قيمة المال الوارد عليه هذا التأمين العيني وإلا سقط أجل الدين والتزم المدين بالوفاء به فورا (م ٢/٢٧٣ مدني مصري).

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن التأمين العيني هو التأمين الأقدر على تحقيق الهدف المقصود من التأمين الخاص وهو ضمان حصول الدائن على حقه كاملا، إلا أن ذلك لا يعنى أن ننكر الدور المتعاظم للتأمين الشخصي- لاسيما الكفالة- في تدعيم الائتمان وتشجيعه، لاسيما وقد أخذت البنوك والمصارف على عاتقها- في العصر الحديث- مهمة الاضطلاع بكفالة المدينين مقابل عمولة تحددها، مما أعاد في نفوس الدائنين (سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا معنوية) الثقة في هذا النوع من التأمين، هذا بالإضافة إلى سهولة إتمام إجراءاته وعدم تطلبه وجود مال معين بالذات مملوك للضامن يرد عليه، حيث يرد على جميع عناصر ذمته المالية دون اشتراط تخصيص مال معين أو عين معينة من أموال الضامن وأعيانه.

الفرع الثاني

أنواع الحقوق العينية التبعية في القانون المصري

لقد قسَّمَ التقنين المدني المصري الحالي التأمينات العينية أو الحقوق العينية التبعية في الكتاب الرابع منه إلى أربعة أنواع في أبواب أربعة، نتناول في كل باب منهم نوعا من هذه الأنواع بحسب ترتيبه في القانون المدني .

على التفصيل الآتي :-

أولا: الرهن الرسمي :

عرفت المادة ١٠٣٠ من التقنين المدني المصري الحالي الرهن الرسمي بأنه "عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون" [١] .

فالرهن الرسمي من التأمينات العينية الاتفاقية، أي أن مصدره هو العقد أو الاتفاق المبرم بين الدائن المرتهن والراهن الذي قد يكون هو نفسه المدين أو شخصا آخر قَّدم هذا الرهن لصالح المدين لضمان حق الدائن الذي في ذمة المدين، ويسمى هذا الشخص بالكفيل العيني، كما يعد من قبيل التأمينات العقارية لأنه لا يرد في الأصل إلا عقار هذا ما لم ينص القانون على غير ذلك (م١٠٣٥ مدني مصري).

وعقدُ الرهن الرسمي كما يبدو ظاهراً من اسمه عقدٌ شكلي يجب إفراغه في

---

[١] انظر في نقد هذا التعريف ص ٤٣ من كتابنا "الوجيز في التأمينات العينية" طبعة عام ١٩٩٨م ، ذلك أن واضع القانون في هذه المادة عرف عقد الرهن الرسمي في حين أنه كان من المفروض عليه تعريف حق الرهن الرسمي الذي يتولد عن العقد .

ورقة رسمية، حيث لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية (م١٠٣١ مدني مصري).

ويعد الرهنُ الرسمي من قبيل التأمينات غير الحيازية أو الطليقة، إذ يظل العقارُ المرهون في حيازة صاحبه يستأثر بمنافعه فيستعمله أو يستغله دون أن ينتقل إلى حيازة الدائن المرتهن على خلاف الحال في الرهن الحيازي.

ويطلق الفقهاء على هذا الرهن اصطلاحات متعددة منها اصطلاح الرهن دون حيازة تمييزاً له عن الرهن الحيازي، كما كان يسميه التقنين المدني المصري القديم باسم الرهن العقاري، وهي تسمية لا تميزه عن غيره مثل الرهن الحيازى ، لأن الأخير كما يرد على المنقول يرد أيضا على العقار، وكان البعض يسميه بالرهن التأميني وهي تسمية معيبة لأنها لا تميزه عن غيره من الرهون الأخرى ، على أساس أن الهدف منه أو من غيره هو التأمين أو الضمان لصالح الدائن .

وجدير بالذكر أن الرهن الرسمي رغم ما يحققه من مزايا لمصلحة المدين، نظرا لما تحققه حيازته للعقار المرهون من قدرة على استعماله واستغلاله، إلا أنه لا يخلو من الإضرار بمصلحة الغير الذي قد يجهل نتيجة لبقاء الحيازة في يد المدين الراهن أن العقار مثقلٌ بالرهون فَيُقْدِمُ على التعامل عليه، لذلك فقد أوجب القانون شهر هذا الرهن عن طريق قيده بأحد مكاتب الشهر العقاري في السجلات المعدة لذلك ليتحقق للأغيار العلم بالحقوق المثقل بها العقار، الأمر الذي يدفع عنهم مضار الجهل بها، فلا يحتج بالرهن الرسمي على الغير إلا إذا تم شهره بالقيد في مكتب الشهر العقاري.

وللدائن المرتهن بمقتضى حقه العيني الوارد على العقار أن يتتبعه في يد أي شخص وأن يستوفي حقه من ثمن هذا العقار متقدماً على سائر الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة ، فيكون له بشأنه ميزتان ميزة التتبع وميزة التقدم .

ثانيا: حق الاختصاص :

تنص المادة ١٠٨٥ من التقنين المدني المصري على أنه "يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين، أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات".

ويبدو واضحا من هذا النص أن الاختصاص لا يكون بموجب عقد أو اتفاق وإنما يتقرر بناء على أمر من القاضي المختص (وهو رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها وفقا للمادة ١٠٨٩ مدني مصري) ومن ثم فهو يعد من قبيل التأمينات القضائية.

ولا يرد هذا الحق (أي حق الاختصاص) إلا على عقار فلا يرد على منقول وفي ذلك تنص المادة ١٠٨٨ مدني مصري على أنه "لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني"، ومن ثمَّ يعد حق الاختصاص من قبيل التأمينات العينية العقارية.

كما يعد حق الاختصاص من قبيل التأمينات غير الحيازية أو الطليقة مثل الرهن الرسمي، فلا يخرج العقار المقرر عليه حق الاختصاص من حيازة المدين بل تظل حيازته ثابتة له.

ولا يسري حق الاختصاص في مواجهة الغير –مثله في ذلك مثل الرهن الرسمي– إلا إذا تم شهره بقيد الأمر القضائي بمكتب الشهر العقاري (حيث تنص المادة ١٠٩٥ مدني مصري على أن..... يسري على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمي من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه.....).

ثالثا: الرهن الحيازي :

عرفت المادة ١٠٩٦ من التقنين المدني المصري الحالي الرهن الحيازى بأنه "عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون".

ويتضح لنا من التعريف السابق أن الرهن الحيازي من قبيل التأمينات الاتفاقية، أي أن مصدره العقد المبرم بين الدائن وشخص الراهن سواء أكان هو نفسه المدين أم شخصاً آخر قدَّمَ المال محل التأمين لضمان حق الدائن في ذمة المدين.

كما أن الرهن الحيازي- على خلاف الرهن الرسمي الذي لا يرد في الأصل إلا على عقار ما لم يوجد نص قانوني يقضى بغير ذلك- قد يرد على المنقول كما يرد على العقار، وهو بذلك قد يكون من قبيل التأمينات المنقولة وذلك متى كان المال محل الرهن منقولاً، أومن قبيل التأمينات العقارية إذا كان المال محل الرهن عقارا.

ويختلف الرهن الحيازي حسبما يبدو ظاهراً من مسماه عن الرهن الرسمي في أنه يقتضى انتقال محل الرهن سواء أكان عقارا أو منقولا من حيازة الراهن- سواء أكان شخص المدين أو شخصاً آخر- إلى حيازة الدائن المرتهن أو الأجنبي الذي يعينه المتعاقدان لهذا الغرض.

ويمثل الرهن الحيازى النموذج الوحيد للتأمينات الحيازية، حيث تعد جميع التأمينات الأخرى (مثل الرهن الرسمي وحق الاختصاص وحق الامتياز) من قبيل التأمينات غير الحيازية أو الطليقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرهن الحيازي مثل غيره من الرهون يُكْسِبُ الدائن المرتهن ميزتي التتبع والتقدم، فله أن يتتبع العقار أو المنقول محل الرهن في يد أي شخص لينفذ عليه بحقه فيستوفي من ثمن بيعه بالمزاد كامل حقه متقدما في ذلك على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة.

بيد أنه لا يحتج بهذا الرهن على الغير إلا اذا تم قيده بأحد مكاتب الشهر العقاري إذا كان المرهون عقارا أو تم تحريره في ورقة ثابتة التاريخ إذا كان المرهون منقولاً.

ونظراً لأن هذا الرهن يجعل للدائن المرتهن حيازة المال المرهون ، فإن ذلك يسمح له باستعمال حقه في حبسه في مواجهة الكافة إلى أن يستوفي حقه كاملاً [1].

رابعا: حقوق الامتياز :

تنص المادة ١١٣٠ من التقنين المدني المصري على أن "الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته، ولا يكون للحق امتيازُ إلا بمقتضى نص في القانون" .

فالامتياز عبارة عن أولوية يمنحها القانون لبعض الحقوق تحقيقا لمصلحة معينة أو مراعاة لاعتبارات العدالة، ومن ثمَّ ينشأ حق الامتياز بموجب نص في القانون فهو من قبيل التأمينات القانونية، بمعنى أن مصدرها هو القانون وليس العقد أو أمر القاضي.

وتتنوع حقوق الامتياز إلى نوعين هما حقوق الامتياز العامة، وحقوق

---

[1] انظر في نفس هذا المعنى : أ.د/ نبيل إبراهيم سعد " المدخل إلى القانون " ، نظرية الحق ، ص ٨٥ ، طبعة عام ٢٠٠١م ، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية .

الامتياز الخاصة.

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع عناصر الذمة المالية للمدين بما فيها من عقارات ومنقولات (حيث تنص المادة ١١٣٢ مدني مصري على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار.....) ومن ثمَّ فهي تعد من قبيل التأمينات المختلطة، أي العقارية والمنقولة في آن واحد لأنها ترد على العقارات والمنقولات معا فتستغرق كل أموال المدين أيا كانت طبيعتها.

أما حقوق الامتياز الخاصة فهي ترد إما على عقار معين من عقارات المدين، وعند ذلك تعد من قبيل التأمينات العقارية أو ترد على منقول معين من منقولاته وفي هذه الحالة تعد من قبيل التأمينات المنقولة (حيث تنص المادة ١١٣٢ مدني مصري على ذلك بقولها ".... أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين").

وتتفق حقوق الامتياز جميعها العامة منها والخاصة في أنها من قبيل التأمينات العينية غير الحيازية أو الطليقة، فالدائن الذي له حق امتياز لا يحوز المال محل الحق بل يبقى في حيازة صاحبه المدين.

وتجدر الإشارة إلى أن حقوق الامتياز العامة (أي التي ترد على جميع أموال المدين سواء أكانت منقولات أو عقارات) وإن كانت تثبت لأصحابها ميزة التقدم ، إلا أنه لا يجب فيها الشهر كما لا يثبت فيها للدائن حق التتبع إذ لا يتصور منحه ميزة التتبع على جميع أموال مدينه في أي يد تكون وذلك عملا بنص المادة ٢/١١٣٤ من التقنين المدني المصري الحالي [١] بعكس الحال بالنسبة

---

[١] حيث تنص المادة ٢/١١٣٤ على أنه "ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للشهر أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.....) .

لحقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقارات فيجب فيها القيد بشهرها في أحد مكاتب الشهر العقاري [1] وتثبت للدائن فيها ميزتي التقدم والتتبع .

المبحث الثانى

الحقوق الشخصية Les drois personnels

تمهيد :

الحق الشخصي Le droit personnel أو حق الدائنية Droit de créance هو رابطة قانونية تنشأ بين شخصين أو أكثر يصير أحدهما بمقتضاها (وهو المدين) ملتزما بأداء معين (سواء كان هذا الأداء عملاً أو امتناعا عن عمل أو التزاما بإعطاء) تجاه شخص آخر وهو الدائن.

والحق الشخصي بهذا المعنى له وجهان أحدهما إيجابي وهو كونه حقاً يعطى صاحبه سلطة اقتضاء أداء معين من المدين، والآخر سلبي وهو كونه التزاما يلقى على عاتق المدين يستوجب التدخل الشخصي لتنفيذ الأداء الواجب عليه في مواجهة الدائن أيا كانت طبيعة هذا الأداء (أي سواء كان عملا أو متناعا عن عمل أو التزاما بإعطاء أي بنقل أو إنشاء حق عيني).

وترجع تسمية الحق الشخصي بهذا الاسم، –إلى جانب كونه يتضمن علاقة أو رابطة بين الأشخاص– إلى أن صاحب هذا الحق لا يتسنى له اقتضاؤه والحصول عليه إلا بناء على التدخل الشخصي من جانب المدين الملتزم بهذا الحق، هذا بخلاف الحق العيني الذي هو سلطة مباشرة على شيء معين تمكن صاحبها من الحصول على حقه دون حاجة إلى تدخل شخصي من جانب أحد.

---

[1] حيث تنص المادة ١/١١٣٤ على أن"تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو" .

ويترجح في نظري استعمال اصطلاح حق الدائنية للتعبير عن الحق الشخصي –كما ذهب البعض وبحق [1] – لما فيه من درء للاختلاط بينه وبين حق الشخصية أو حقوق الشخصية والتي تعبر عن حقوق الإنسان أو الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، هذا فضلا عن كونه يعبر بصدق عن طبيعة الحق من حيث كونه علاقة دين أو علاقة اقتضاء بين الأشخاص إذا نظرنا إليها من حيث الدائن.

ويميل بعض فقهاء القانون إلى إطلاق اصطلاح "الالتزام" على الحق الشخصي، ويعرفون الالتزام على أنه رابطة قانونية بين مدين ودائن تخول الدائن إجبار المدين على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، والواقع أن اصطلاحي الحق الشخصي والالتزام هما وجهان لعملة واحدة أو مترادفان ، وذلك لأن الرابطة القانونية إذا نظرنا إليها من جهة الدائن كانت حقا شخصيا، وإذا نظرنا إليها من جهة المدين كانت التزاما، ومن ثمَّ يعد الالتزام والحق الشخصي وجهين لعملة واحدة ، تأسيساً على أن كلا منهما وصف قانوني يخول الدائن إجبار مدينه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وهذا الوصف القانوني هو نفسه الواجب الملقى على عاتق المدين وهو نفسه السلطة المخولة للدائن، غير أن فريقاً آخر من الفقهاء يرى أن الحق الشخصي غير الالتزام، فالحق الشخصي هو رابطة بين مدين ودائن، أما الالتزام فهو الواجب الملقى على عاتق المدين للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل [2].

المطلب الأول

محاولة التقريب بين الحق الشخصي والحق العيني

على الرغم من استقرار التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني ووضوح

---

[1] أ.د/ حسن كيره بند ٢٣٩، ص ٤٦٧ .

[2] أ.د/ عبد الناصر العطار بند ٢٢٤، ص ٤٤٠ .

عناصرها إلى حد أنها أضحت من المسلمات بين فقهاء القانون، إلا أن جانبا من الفقه حاول إذابة الفوارق بين الحقين وذلك إما عن طريق تقريب الحق العيني من الحق الشخصي، تأسيساً على أن الحق العيني هو في نهاية المطاف مثل الحق الشخصي علاقة أو رابطة بين الأشخاص، وقد عرف هذا الرأي بالاتجاه الشخصي، أو عن طريق تقريب الحق الشخصي من الحق العيني، على أساس أن العبرة ليست بالأشخاص أطراف هذا الحق أو ذاك، وإنما العبرة بقيمة الحق ذاته، والحق العيني والحق الشخصي سواء فكل منهما يعد قيمةً ماليةً يجوز التصرف فيها والحجز عليها، وقد عرف هذا الرأي بالاتجاه المادي أو الموضوعي.

الرأي الأول: الاتجاه الشخصي :

لقد حاول أنصار هذا الاتجاه وعلى رأسهم الفقيه الفرنسي بلانيول "PLANIOL" تقريب الحق العيني من الحق الشخصي، بدعوى أن كلا الحقين ما هما إلا رابطة قانونية بين شخصين أحدهما طرف إيجابي وهو الدائن، والآخر طرف سلبي وهو المدين، كل ما هنالك أن الطرف السلبي أو المدين في الحق الشخصي هو شخص معين بالذات، في حين أنه في الحق العيني شخص غير معين فهو يشمل كافة الأشخاص دون تحديد، هذا فضلا عن أن التزام الطرف السلبي (أي المدين) في الحق العيني التزام سلبي مقصور على الامتناع عن إتيان أي عمل من أعمال التعرض لحق الطرف الإيجابي (أي الدائن) ، في حين أن التزام الطرف السلبي (أي المدين) في الحق الشخصي التزام محدد سواء أكان إيجابيا (مثل الالتزام بعمل أو الالتزام بإعطاء) أم سلبيا (مثل الالتزام بالامتناع عن عمل)، وهذه فروقٌ لا تستأهل التفرقة بين الحقين نظرا لبساطتها، فهي لا تنبئ عن اختلاف بينهما في الطبيعة، ولكنها مجرد فروق في النطاق والمدى [1].

ويؤخذ على هذا الاتجاه الانتقادات الآتية:-

أولا: لقد أخطأ أنصار هذا الاتجاه المادي وهم بصدد محاولة التقريب بين الحقين عندما صوَّروا الحق العيني على أنه رابطة بين شخصين أحدهما مدين والآخر دائن، نظرا لأن مثل هذا التصور لا يصدق إلا على الحق الشخصي وحده بوصفه من روابط الاقتضاء التي تخول لشخص معين سلطة اقتضاء أداء معين (سواء كان عملاً أو امتناعاً عن عمل أو التزاماً بإعطاء) من شخص آخر ملتزم قانونا بتنفيذ هذا الأداء الذي لا يتصور أن يكلف به غير الأشخاص، أما الحق العيني فهو بوصفه رابطةً قانونيةً ليس رابطة بين شخص وشخص وإنما هو رابطة

---

[1] انظر في نفس المعنى: أ.د/ كيره بند ٢٤١، ص ٤٧٠، أ.د/ العطار بند ٢٣٠، ص ٤٤٤ .

بين شخص معين وشيء معين يرد عليه حقه العيني، فهو من روابط التسلط لا يتصور وقوعه على الأشخاص وإنما يرد فقط على الأشياء.

ثانياً: إن الواجب السلبي العام الملقى على عاتق كافة الأشخاص في مواجهة صاحب الحق العيني ليس قصراً على هذا الحق وحده، ولكنه واجبٌ عامٌ في كافة الحقوق أيا كانت أنواعها، فلا مجال للتفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني من هذه الزاوية، إذ يمتنع على الكافة إتيان أي عمل من أعمال التعرض في مواجهة صاحب الحق سواء كان حقه عينياً أو شخصياً.

ثالثا: إن الواجب العام الملقى على عاتق الكافة باحترام الحق (سواء في الحق الشخصي أو في الحق العيني) واجب سلبي لا يشكل عبئاً على الذمة المالية لشخص معين ، فلا ينال من مجموع ما له وما عليه ولا يؤثر في عناصر ذمته المالية لأنه واجب مجرد من القيمة المالية، بخلاف الواجب الخاص في الحق الشخصي فهو في أي صورة من صوره (أي سواء كان عملاً أو امتناعاً عن عمل) يعد عبئاً على المدين يؤثر في ذمته المالية، هذا بالإضافة إلى أن الواجب السلبي العام لا يكون المدين به محدداً ومعيناً وقت نشوئه، نظرا لأنه واجبٌ عامٌ يلقى على عاتق الكافة دون تحديد، بخلاف الواجب الخاص إذ يتحدد فيه شخص من يلتزم بأدائه وتنفيذه وقت نشوئه ويصير قيدا على حريته.

الرأي الثاني: الاتجاه المادي أو الموضوعي:

لقد سعى أنصار هذا الاتجاه إلى تقريب الحق الشخصي من الحق العيني، بوصفهما حقين متماثلين إذا ما عوَّلنا على محل الحق أو موضوعه دون الالتفات إلى أطرافه، حيث لا يعدو كل واحد منهما عن كونه مجرد حق ذى قيمة مالية محددة يجوز التصرف فيها والحجز عليها.

ومن ثمَّ فهم لا ينظرون إلى الحق الشخصي بوصفه رابطة بين شخصين

(دائن ومدين) ، ولكن بوصفه قيمة مالية معينة تشغل مكانا في الذمة المالية لطرفي الحق الشخصي فتمثل عنصراً إيجابياً في ذمة الدائن وعنصراً سلبياً في ذمة المدين.

فالقيمة المالية كمحل أو موضوع للحق تمثل عمادا له سواء كان حقاً عينيا أو حقا شخصيا، وهي التي ينبغي التعويل عليها لتقريب الحق الشخصي من الحق العيني ولإذابة ما بينهما من فوارق أخرى لا تنال من هذه التقريب ككون الحق الشخصي رابطة بين شخصين.

لم يسلم هذا الاتجاه أيضا من سهام النقد من أكثر من زاوية، ذلك أنه باعتداده بموضوع الحق أو محله كقيمة مالية يتماثل أو يتقارب فيها كل من الحق الشخصي والحق العيني، يتجاهل صفة جوهرية في الحق الشخصي تميزه عن الحق العيني ألا وهي كون الحق الشخصي رابطة بين شخصين، بحيث لا يتسنى لصاحب الحق الشخصي الحصول على حقه إلا عن طريق تدخل الطرف الآخر لتمكينه من هذا الاستيفاء ، بخلاف الحق العيني الذي يخول صاحبه سلطة مباشرة تمكنه من التسلط على الشيء محل الحق وجني ثماره دون حاجة إلى تدخل شخص آخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القيمة المالية للحق الشخصي – والتي ركَّز عليها أنصار الاتجاه الموضوعي لتقريبه من الحق العيني – قد تستمد أهميتها في بعض الأحيان من شخصية المدين، كما هو الحال في التزام فنان برسم لوحة فنية أو التزام مطرب بإحياء حفل أو التزام مدرب بتدريب فريق رياضي، ففي مثل هذه الحالات هل يستساغ القول –كما يقول البعض وبحق [1] – بأن العبرة في الحق الشخصي بقيمته المالية فقط؟ أم أن الواقع يشهد بأن شخصية المدين باعتباره فنانا أو مطربا أو مدربا قد تفوق في أهميتها القيمة المالية للحق

[1] د/ حمدي عطيفي ص ٥٢ .

نفسه.

المطلب الثاني

الإبقاء على التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي

لقد ظهر بوضوح من خلال عرض الاتجاهين السابقين أن محاولات بعض الفقهاء في التقريب بين الحق العيني والحق الشخصي قد باءت بالفشل، حيث لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة ما بين هذين الحقين من فوارق جوهرية من حيث الطبيعة أو من حيث المدى والنطاق.

أولاً: اختلاف الحقين من حيث الطبيعة :

فالحق العيني يختلف في طبيعته عن الحق الشخصي، فهو سلطة مباشرة على شيء معين بالذات يخولها القانون لصاحب الحق تمكنه من التسلط على هذا الشيء محل الحق والاستئثار بمنافعه دون حاجة إلى تدخل شخص آخر بالقدر الذي يتيحه له هذا الحق تبعاً لطبيعته (إذ يتفاوت حجم المنافع التي يتيحها الحق العيني الأصلي مثلا تبعاً لما إذا كان حق ملكية أو حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكنى ..... إلخ، وهو في كافة الأحول يجعل لصاحب الحق سلطة مباشرة على الشيء دون وساطة أحد)، بخلاف الحق الشخصي فهو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، ولا يمكن للدائن أن يحصل على حقه الشخصي إلا إذا تدخل المدين اختيارا أو جبراً لتنفيذه وأدائه إليه.

هذا بالإضافة إلى اختلاف المحل الذي يرد عليه الحق العيني عن المحل الذي يرد عليه الحق الشخصي، فمحل الحق العيني هو شيء معين بالذات كملكية منزل معين بالذات أو ارتهان عقار محدد بالذات، في حين أن محل الحق الشخصي هو أداء معين سواء كان عملا معينا أو امتناعا عن عمل محدد (على أن يراعى أنه قد يحدث أن يكون موضوع العمل شيئا من الأشياء، ولكن هذا لا

يقدح في كون هذا العمل لا الشيء هو محل الحق الشخصي، مثال ذلك أن يبيع محمد لأحمد منزلا فيكون لأحمد حق شخصي في ذمة محمد محله القيام بعمل معين هو تسليمه المنزل المبيع ولا يغير من حقيقة هذا المحل ككونه عملا معينا أن يكون موضوع العمل شيئا وهو المنزل).

ثانياً: اختلاف الحقين من حيث المدى أو النطاق :

توجد مظاهر متعددة ودلائل مختلفة تنبئ بصورة واضحة عن اختلاف هذين الحقين من حيث المدى أو النطاق، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:-

١- الحق العيني حق مطلق Droit absolu في حين أن الحق الشخصي حق نسبى Droit relatif : ومرد ذلك إلى أن الحق العيني نظرا لكونه سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات على نحو يمكنه من التسلط عليه والاستئثار بمنافعه منذ وقت إنشائه دون حاجة إلى وساطة أو تدخل من جانب شخص آخر، فإنه يحتج به قبل الكافة وينتج أثره في مواجهتهم جميعاً، بخلاف الحق الشخصي فهو حق نسبى لأنه رابطة قانونية بين شخصين لا يمكن اقتضائه والحصول عليه إلا إذا تدخل المدين لتنفيذه وأدائه، هذا بالإضافة إلى أنه مقصور كالتزام خاص على شخص معين هو المدين وحده دون غيره من الأشخاص.

٢- يخول الحق العيني وحده دون الحق الشخصي ميزتي التتبع والتقدم ، فلصاحب الحق العيني تتبع الشيء محل الحق تحت يد أي شخص وانتزاعه منه، على أساس أن هذا الحق يخلق له رابطة مباشرة بينه وبين الشيء الذي يرد عليه حقه تمكنه من التسلط عليه أينما وجد وتحت يد أي شخص.

وميزة التتبع Driot de suite هذه لا يتصور وجودها في الحق الشخصي لأنه لا يرد على شيء حتى يلازمه ويتتبعه تحت يد أي شخص، وإنما يرد على عمل معين ولا يتصور التتبع في شأن الأعمال حتى وإن كان موضوع العمل شيئا من الأشياء، على أساس أنه سيظل مع ذلك كون محل حق الدائن هو العمل لا الشيء موضوع العمل .

هذا بالإضافة إلى أن الحق العيني يجعل لصاحبه ميزة الأفضلية أو التقدم Droit de préference على من سواه بحيث يستأثر وحده بمنافع الحق دون أن يزاحمه فيه أحد، فالمالك بوصفه صاحب حق عيني أصلى له أن يستأثر وحده دون مزاحمة من أحد باستعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه، وللدائن المرتهن بوصفه صاحب حق عيني تبعي أن يحصل على حقه من ثمن بيع المال المرهون مفضلا على سائر الدائنين العاديين أو الدائنين المرتهنين اللاحقين له في المرتبة .

هذا بخلاف الحق الشخصي فهو لا يكفل لصاحبه مثل هذه الميزة فالدائنون أصحاب الحقوق الشخصية متساوون جميعا فيما بينهم دون أي تفاضل، لذلك فهم يقتسمون أموال المدين قسمة غرماء (أي بنسبة دين كل واحد منهم)، ومن ثمَّ يحرص عادة أي صاحب حق شخصي على الحصول على حق عيني تبعي كرهن أو غيره من الحقوق العينية التبعية لتوفير ضمان خاص لحقه فتكون له بموجبه ميزة التقدم على سائر أصحاب الحقوق الشخصية الذين لا توجد تأمينات عينية تضمن حقوقهم.

٣- الحق العيني قد يكون حقا مؤبدا بخلاف الحق الشخصي الذي لا يكون إلا موقوتا بمدة معينة، ويرجع ذلك إلى أن الحق العيني نظرا لوروده على شيء معين بالذات فإنه قد يتصور بقاؤه ما دام الشيء محله باقيا، ويتجلى ذلك واضحا في حق الملكية بوصفه حقا عينيا أصليا ، فهذا الحق حق دائم ومؤبد

يظل باقيا ودائما بدوام الشيء محل الملكية ولا يزول إلا بهلاكه أو زواله، أما بقية الحقوق العينية الأصلية الأخرى مثل حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر وحق الارتفاق، وجميع الحقوق العينية التبعية (كحق الرهن سواء كان حيازيا أو رسميا، وحق الاختصاص وحق الامتياز) فهي حقوق موقوتة بمدة معينة أما الحق الشخصي فهو لا يكون إلا مؤقتا نظرا لأن محله هو التزام المدين بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين لصالح الدائن، ولا يتصور أن يكون هذا الالتزام مؤبدا وإلا أضحى مظهرا من مظاهر الإذلال والاسترقاق لشخص المدين وقيدا مستمرا على حريته الشخصية وهذا أمر غير جائز قانونا [1].

٤- إن الحق العيني باعتباره ليس رابطة بين شخص وشخص ، وإنما هو رابطة بين شخص وشيء لا ينشأ عنه غير واجب عام يلقى على عاتق كافة الأشخاص باحترام هذا الحق، في حين أنه ينشأ عن الحق الشخصي ، إلى جانب هذا الواجب العام الملقى على عاتق كافة الأشخاص باحترامه واجب أو التزام خاص يلقى على عاتق شخص معين هو المدين يلتزم بمقتضاه بأداء عمل معين أو الامتناع عن عمل معين لصالح الدائن.

٥- الحقوق العينية أوردها القانون المدني المصري على سبيل الحصر والتعيين ولذلك يحظر على إرادة الأفراد ابتداع نماذج أخرى لها غير تلك التي حددها القانون، بخلاف الحقوق الشخصية فقد اكتفي واضع القانون ببيان مصادرها

---

[1] انظر في نفس المعنى إلى: أ.د/ عبد الناصر العطار بند ٢٣١، ص ٤٤٦، د/ حمدي عطيفي ص ٥٣ .

وترك هذه الحقوق دون حصر أو تحديد، لذلك يمكن للأفراد الاتفاق على إنشاء ما يرونه منها وفق إراداتهم، طالما أنهم لا يصطدمون بفكرة النظام العام أو الآداب.

ونخلص مما سبق إلى ضرورة الإبقاء على التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي، لاسيما وهي تفرقة عريقة لها ما يبررها من مظاهر التفاوت والاختلاف بين هذين الحقين على النحو الذي رأيناه آنفا.

المطلب الثالث

محل أو موضوع الحق الشخصي

تتنوع الحقوق الشخصية بتنوع الأداء المكلف به المدين لمصلحة الدائن والذي يمثل محلا أو موضوعا للحق الشخصي، فقد يكون الأداء عملا معينا أو امتناعا عن عمل أو إعطاء شئ، وبذلك تتنوع الحقوق الشخصية إلى أنواع ثلاثة: الالتزام بعمل، والالتزام بالامتناع عن عمل، والالتزام بإعطاء، وذلك على التفصيل الآتي:-

أولا: الالتزام بعمل:

يمثل الالتزام بعمل L'obligation de faire الصورة الإيجابية لمحل أو موضوع الحق الشخصي، حيث يتعين على المدين الذي تعهد بالقيام بعمل معين لصالح الدائن أن يقوم بأدائه وتنفيذه إليه.

والالتزام بعمل قد يكون التزاما بتحقيق غاية وقد يكون التزاما ببذل عناية، فإذا كان التزام المدين التزاما بتحقيق غاية أو نتيجة معينة، فإنه لا يكون موفيا بالتزامه إلا إذا حقق الغاية أو النتيجة المطلوبة، مثال ذلك التزام المقاول ببناء عمارة، فهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية أو نتيجة معينة وهي بناء العمارة وبمن ثمَّ

لا يتحقق وفاء المقاول بالتزامه إلا إذا قام المقاول ببناء العمارة فعلا، أما إذا كان التزام المدين التزاما ببذل عناية فيكفيه أن يبذل عناية الشخص المعتاد في أداء العمل المكلف حتى ولو لم تتحقق النتيجة المطلوبة من وراء هذا العمل، مثال ذلك التزام الطبيب بعلاج المريض، إذ يكفي الطبيب لكي يكون موفيا لالتزامه بالمعالجة أن يبذل عناية طبيب معتاد في نفس تخصصه وظروفه حتى وإن لم يشف المريض [١].

والأصل أن يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه لاسيما إذا كان ثمة اتفاق بينه وبين الدائن على قيام المدين شخصيا بالتنفيذ أو كانت طبيعة الالتزام نفسه تقتضى ذلك، وعندئذ يحق للدائن رفض التنفيذ إذا صدر من غير المدين شخصيا [٢].

بيد أنه في غير هاتين الحالتين يمكن للمدين أن يعهد لغيره بتنفيذ التزامه تجاه الدائن نيابة عنه ، كأن يعهد أحد موردي البضائع لمورد آخر لينوب عنه في توريد البضاعة الملتزم بتوريدها في مواجهة الدائن التاجر [٣].

ثانيا: الالتزام بالامتناع عن عمل :

يمثل الالتزام بالامتناع عن عمل L'obligation de ne pas faire الصورة السلبية لموضوع الحق الشخصي حيث يتعهد المدين بعدم إتيان عمل معين من الأعمال كان بوسعه أن يأتيه لولا هذا الالتزام، ولذلك يحد هذا الالتزام من حرية الشخص في ممارسة بعض الأعمال المباحة بحسب الأصل، مثال ذلك أن يبيع تاجر محله التجاري لتاجر آخر فيشترط عليه التاجر المشترى ألا يفتح محلاً منافساً

---

[١] انظر ذلك تفصيلاً للمؤلف " النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني البحريني " دراسة مقارنة ، مصادر الالتزام ، ص ٨، الطبعة الثانية عام ٢٠٠٢م ، مطبعة جامعة البحرين . " .

[٢] انظر إلى المرجع السابق ص ٨ .

[٣] انظر إلى المرجع السابق ص ٨ وما بعدها .

يمارس فيه نفس العمل في نفس المنطقة أو الحي، حيث يقع على التاجر البائع التزامٌ سلبيٌ بالامتناع عن منافسة التاجر المشتري، وإلا كان من حق الدائن بهذا الالتزام الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من جراء هذه المنافسة [١] .

ثالثاً: الالتزام بإعطاء :

يقصد بالالتزام بإعطاء L'obligotion de donner التزام المدين بنقل حق عيني أو إنشائه سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل ، ويتحققُ هذا الالتزامُ بقيام المدين بالأعمال اللازمة لتنفيذه، مثال ذلك التزام بائع العقار بنقل ملكيته إلى المشترى، حيث لا تنتقل الملكية في العقارات بمجرد إبرام العقد ولكن يلزم لتحقق ذلك إتمام إجراءات التسجيل في مكتب الشهر العقاري الكائن بدائرته العقار، ولذلك يقع على عاتق المدين (أي البائع) التزامٌ بنقل أو إنشاء الحق العيني وهو حق الملكية لصالح المشترى وذلك عن طريق قيامه ببعض الأعمال اللازمة لذلك والتي تتمثل في ذهابه مع المشترى إلى مكتب الشهر العقاري المختص للتوقيع على العقد وإتمام إجراءات التسجيل اللازمة لنقل الملكية [٢].

المبحث الثالث

الحقـوق الذهنــية

النظام القانوني لحماية الملكية الأدبية والفنية :

بادئ ذي بدء يقصد بالحقوق الذهنية Les droits intellectuelsتلك الحقوق التي تردُ على أشياء معنوية غير محسوسة من خلق الذهن ونتاج الفكر،

---

[١] المؤلف المرجع السابق ص ٨ ، ٩ .

[٢] المؤلف المرجع السابق ص ٩ .

فتثبتُ لصاحب الحق الذهني أو الفكري أبوةَ هذا الخلق وتثبت نسبتَه إليه وحده، كما تعطيه صلاحيةَ احتكار استغلاله استغلالاً مالياً يكفلُ له الحصول منفرداً على كل ثمراته [١] .

وجدير بالذكر أن فقه القانون ظل فترةً طويلةً حتى نهاية القرن الثامن عشر يقسمُ الحقوقَ الماليةَ إلى حقوق شخصية وحقوق عينية ظناً منه أن هذا التقسيمَ التقليدي يستوعبُ كافةَ أنواع الحقوق المالية المعروفة في واقع الحياة، إلى أن فوجئ على إثر التطور الإنساني في مستهل القرن التاسع عشر بظهور نوع جديد من الحقوق ترد على نتاج الفكر والذهن يشذ على التقسيم التقليدي المعروف للحقوق المالية، بحيث لا يمكنُ إدراجَه في عداد الحقوق الشخصية لأن الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين توجب على أحدهما وهو المدين القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين لصالح الآخر وهو الدائن، وهذا لا وجود له في الحق الذهني، وفي نفس الوقت لا يمكن إدراجه في الحقوق العينية على أساس أن الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات بعكس الحق الذهني فهو يرد على شيء معنوي غير مادي، الأمر الذي أوجب الاعتراف بهذه الحقوق بوصفها نوعاً جديداً من أنواع الحقوق المالية يضاف إلى التقسيم التقليدي المعروف لها.

ولقد كان يطلق على هذه الحقوق اصطلاح "الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية" ،كما عرفت أيضا باصطلاح "الحقوق المعنوية أو الأدبية" إلى أن استقر الأمر على تسميتها باسم "الحقوق الذهنية" وهي أكثر الاصطلاحات تعبيرا عن جوهر ومضمون تلك الحقوق بوصفها ترد على نتاج ذهني وفكري[٢] .

---

[١] أ.د/ حسن كيره بند ٢٤٤، ص ٤٨١ .

[٢] انظر في نفس المعنى: أ.د/ حسن كيره بند ٢٤٤، ص ٤٨١ .

وتنقسم الحقوق الذهنية إلى نوعين هما:

١- **حقوق الملكية الصناعية والتجارية:** وهي تلك الحقوق التي ترد على المبتكرات الذهنية في المجال الصناعي والتجاري، والتي تكفل للصانع أو التاجر حماية العناصر الأساسية في منشآته الصناعية والتجارية، ولعل من أمثلة هذه الحقوق الحق في براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والاسم التجاري والحق في الاحتفاظ بالعملاء، وهذه الحقوق يجري تدريسها في مؤلفات القانون التجاري، ولذلك نحيل بشأنها إلى كتب هذا الفرع من فروع القانون الخاص [١].

٢- **حقوق الملكية الأدبية والفنية أو ما تسمى بحقوق المؤلف:** وهي الحقوق التي تنصب على ما يتفتق عن الذهن الإنساني من نتاج فكري وذهني في مختلف المجالات سواء في العلوم أو الآداب أو الفنون أو غيرهم. والتي ستكون محلا لدراستنا بقدرٍ من التفصيل على التقسيم الآتي:-

المبحث الأول: المقصود بحق المؤلف.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لحق المؤلف.

المبحث الثالث: مضمون حق المؤلف وخصائصه.

المبحث الرابع : الحماية القانونية لحق المؤلف .

المبحث الأول

[١] د/ حمدي عطيفي ص ٥٧، د/ محمد سعد خليفة ص ١٨٣ .

المقصود بحق المؤلف

يقصد بحق المؤلف Droit d'auteur ذلك الحق الذي يثبت لكل مؤلف على مصنفه الذي تفتق عن فكره أو أفرزه ذهنه أيا كانت طبيعة هذا المصنف (أي سواء كان مصنفا علميا أو أدبيا أو فنيا) أو وسيلة التعبير عنه (أي سواء كان ذلك بطريقة الكتابة أو النحت أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحفر أو غير ذلك من صور التعبير عن نتاج الفكر أو الذهن البشري).

وتنص المادة ١٤٠ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م على أن " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية " .

ويظهر من النص سالف الذكر إسباغ القانون ظلال حمايته لحقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية المبتكرة، وهذا ما يدعونا إلى البحث عن معنى المؤلِف الذي ينشد القانون حمايته، ثم معنى المصنَف أو المؤلَف الذي يلزم أن تتوافر فيه صفة الابتكار كي تشمله حماية القانون وما هي دلالة هذه الصفة فيه، وذلك كله على التفصيل الآتي:-

أولاً: المؤلِف L'auteur

هو كلُ شخصٍ يفرزُ نتاجا ذهنيا أيا كان نوعه، وأيا كانت طريقة التعبير عنه، وأيا كانت أهميته أو الغرض منه مادام أنه يتصف بقدر من الحداثة والابتكار. وقد عرفت المادة ٣/١٣٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م المؤلِف قائلة " المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك " ، " ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه ،



فإذا قام الشكُ اعتبر ناشرُ أو منتجُ المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلِف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف " .

وبذلك لا يقتصر معنى المؤلف على من يؤلف كتاباً، وإنما يمتد إلى كل صور النشاط الذهني مثل تأليف الكتب وكتابة القصص والرسم والغناء والتلحين والتصوير والتمثيل ، كما يفهم من هذا النص أن مؤلف المصنف يبقى صاحباً له ولو جرى نشرُه بغير اسم أو باسم مستعار ، مادام لم ينازعه في ملكيته أحد ، فإذا وجد شكٌ في ملكية مصنفٍ معين فتنازع عليه أكثر من شخص عُدَ ناشره أو منتجه ممثلاً لمؤلِفه في مباشرة حقوقه الأدبية والمالية إلى حين البت قانوناً في نسبة هذا المصنف إلى صاحبه الحقيقي .

ثانياً: المصنَّف (المؤلَف):

يقصد بالمصنَف كلُ عملٍ ذهني أيا كانت طريقةُ التعبير عنه وأيا كان نوعُه أو درجةُ أهميته أو الغرض منه. فهو لا يقتصر على الكتاب وحده، ولكنه يمتد ليشمل أي نتاج ذهني أيا كان نوعه (أي سواء كان مصنفا علميا أو مصنفا أدبيا أو مصنفا فنيا) وأيا كانت طريقة التعبير عنه (أي سواء أكان ذلك بالكتابة أم بالرسم أم بالتصوير أم بالنحت أم بالصوت أم بالحركة أم بالحفر أم بالعمارة أم بغير ذلك من وسائل التعبير عن الإنتاج الذهني للإنسان).

وهذا عين ما نصت عليه المادة ١/١٣٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م بقولها " المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو عملي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

ولا تقتصر الحماية القانونية للمصنَف على مضمونه ومحتواه، بل تمتد أيضاً لتشمل اسمه وعنوانه، مادام أن هذا الاسم أو العنوان ينطوي على قدر من

الابتكار، وهذا عين ما نصت عليه المادة ١٤٠ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري بقولها " وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا " .

أما إذا كان عنوان المصنَف مجرد عنوان شائع ودارج الاستعمال بين المؤلفين يطلقونه على نفس محتوى المصنف من غير أن ينطوي على قدر ما من الحداثة والابتكار فعندئذ لا يعدُ استخدام الغير له اعتداءً على حق المؤلِف [١] .

ثالثاً: الابتكار صفة لازمة في المصنف:

لا يحظى المصنف بالحماية القانونية المقررة إلا إذا كان متصفاً بطابع الحداثة أو الابتكار. وقد عبرت المادة ١٣٨/ ٢ من القانون سالف الذكر عن طابع الابتكار في المؤلَف بقولها " الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنَف ".

غير أن ذلك لا يحتمُ أن يكون المصنفُ مبتدعاً لشيء جديد لم يسبق إليه أحد أو متضمنا لشيء من الأشياء التي تعد من قبيل الخوارق أو الغرائب (وإن كان تحققُ ذلك المعنى يقطع دون أدنى شك في توافر صفة الابتكار في المصنف عند توافره)، وإنما يكفي أن يضيف المصنف شيئا جديدا معبرا عن جهد ذهني حقيقي يحمل بصمة خاصة للمؤلف سواء أكان ذلك في عرضه لجوهر الفكرة التي يتضمنها المصنف أم في أسلوب عرضها وتناولها أم في ترتيبها وتبويبها، على نحو تبرز فيه ذاتيتُه وشخصيته فيصح نسبة ذلك إليه وحده دون غيره من الأشخاص.

وبناء على ذلك يعد مصنفاً متسماً بطابعِ الابتكارِ الكتابُ المترجمُ عن لغة أجنبية، نظرا لأن الترجمة تحتاج إلى جهد ذهني كبير من جانب المترجم في إجراء

---

[١] انظر في نفس المعنى: أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٠٤، أ.د/ نعمان جمعة ص ٣٧٧، د/ حمدي عطيفي ص ٦٣ .

الترجمة لينقل فكرة أو مضمون هذا الكتاب من لغةٍ إلى لغة أخرى ، ثم يجنح إلى ابتكار أسلوب خاص به في العرض وطريقة التعبير عن مضمون فكرة هذا الكتاب الذي قام بترجمته، ومن ثم لا يخلو مثل هذا الكتاب المترجِم لكتاب آخر غيره من الإضافات الجديدة سواء من حيث الموضوع أو من حيث الشكل، ولذلك فهو يصدقُ عليه وصفُ الابتكار بوصفه شرطاً لازماً في المصنَف كي يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمصنفات .

كما يتوافر وصفُ الابتكار أيضا في المصنف الذي يقوم فيه صاحبه بتحويله من لون إلى آخر من ألوان الفنون أو الآداب، كمن يلحن قطعة من الشعر أو من يعد الحوار لمادة فيلمية من تأليف شخص آخر غيره [١].

أما إذا اقتصر دور الشخص على مجرد إعادة الطبع لكتب قديمة دون أن يدخل عليها أية تعديلات أو تعليقات أو تنقيحات، فلا يصدق على جهده وصف المصنف، لانتفاء وصف الابتكار عنه في هذا الجهد، كما لا تعد من قبيل المصنفات المجموعات التي تنشر الوثائق الرسمية مثل طبع نصوص القوانين واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية والفتاوى الرسمية، وكذلك الحال بالنسبة للمختارات الشعرية أو النثرية أو الموسيقية التي تصدر في مجموعات، وذلك ما لم تتضمن إصدارات هذه المختارات قدرا من الابتكار في التعليق أو التبويب أو الشرح غير ذلك من أشكال العمل الذهني الذي يضيف فيه صاحبه جهداً ذهنياً جديداً يعبر عن بصمة واضحة له على هذه المصنفات .

ولقد ذكرت المادة ١٤٠ من القانون سالف الذكر نماذج وأمثلة للمصنفات التي تحظى بالحماية القانونية قائلةً " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:

---

[١] أ.د/ نعمان جمعة ص ٣٧٨ .

١- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة

٢- برامج الحاسب الآلي .

٣- قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو غيره .

٤- المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

٥- المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

٦- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.

٧- الصنفات السمعية والبصرية.

٨- العمارة .

٩- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

١٠- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

١١- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

١٢- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.



١٣- المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

رابعاً: تحديد الشخص صاحب المصنف:

لا تثار أية صعوبة في تحديد الشخص صاحب المؤلف أو المصنف وذلك حينما يكون المؤلف شخصا واحداً، وإنما تدقُ المشكلةُ في بعض الأحوال لمعرفة صاحب المصنف حينما يشترك شخصان أو أكثر في تأليف المصنف الواحد وذلك كما هو الحال في المصنف المشترك والمصنف الجماعي.

١- المصنف الفردي

هو ذلك المصنف الذي يمثلُ نتاجاً ذهنياً لشخصٍ واحدٍ، وذلك تمييزاً له عن المصنفات المشتركة أو الجماعية التي تمثلُ نتاجاً ذهنياً لأكثر من شخص. والأصل العام أن يُنْشَرَ المصنفُ حاملا اسم المؤلف الحقيقي، غير أنه يجوز قانونا نشر المصنف تحت اسم مستعار أو علامة أو رمز معين يدل على نسبة المصنف لصاحبه.

ولقد أقام واضع القانون قرينة قانونية مؤداها أنه إذا تم نشر المصنف منسوبا إلى شخص معين سواء بذكر اسمه عليه أو بأي طريقة أخرى اعتبر هذا الشخص هو صاحب الحق الذهني عليه، غير أن هذه القرينة قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها ، ومن ثم يجوز للمؤلف الحقيقي المستتر أن يقيم الدليل على عدم صحة هذه القرينة مثبتاً بكافة طرق الإثبات أن الشخص الذي تم نشر المصنف باسمه مجرد مؤلف صوري قصد به إخفاء شخصية المؤلف الحقيقي للمصنف لاعتبارات معينة حملته إلى ذلك ، وعندئذ تثبت لهذا المؤلف الحقيقي كافة سلطات وحقوق المؤلف الأدبية والمادية على هذا المصنف.



٢- المصنف المشترك:

هو المصنف الذي يشارك في ابتكاره وإخراجه أكثر من شخص لحسابهم الخاص دون توجيه من أحد غيرهم. ولا جرم أن اشتراك عدة أشخاص في وضع مصنفٍ ما يخول لهم جميعا سلطات وحقوق مشتركة عليه، بيد أن مدى هذه الحقوق التي يتمتع بها المشاركون في ابتكار هذا المصنف يتوقف على قابلية أو عدم قابلية فصل دور كل مشارك عن أدوار غيره من المشاركين، وذلك على النحو الآتي:-

أ- الفرض الأول:

إذا كانَ المصنفُ المشتركُ يمثلُ كياناً واحداً أو مِزَاجاً مختلطاً تذوبُ فيه إسهاماتُ كل مشارك على نحو يصعبُ معه فصلُ دور كل مشارك فيه، فعندئذ يعدُ جميعُ من اشتركوا في ابتكاره وتأليفه أصحابَ حق على هذا المصنف بالتساوي فيما بينهم، بحيث ينبغي توافر إجماعهم على مباشرة الحقوق والسلطات الخاصة بهذا المصنف، هذا كله ما لم يتفقوا فيما بينهم على خلاف ذلك . مثال ذلك أن يجتمع أكثر من شخص على خلق وإنشاء فكرة معينة ثم يصيغونها في أسلوب جماعي، على نحو يصعبُ معه فصلُ إسهام كل واحد منهم عن إسهامات الآخرين في هذا العمل الذهني سواء من حيث الفكرة والموضوع (أي قلبا) أو من حيث الأسلوب والصياغة (أي قالبا).

ب- الفرض الثاني:

أن يكونَ المصنفُ المشتركُ رغم كونه مِزاجاً مختلطاً يَصُبُ إسهاماتِ المشتركين في بوتقةٍ واحدةٍ، إلا أنه مع ذلك يسهلُ فصلُ دور كل واحد منهم على حده، فعندئذ يكون لكل واحد من هؤلاء المشتركين أن ينفرد باستغلال الجزء المتميز الذي يخصه في هذا المصنف المشترك، شريطة ألا يضرَ ذلك بوحدة هذا المصنف

بوصفه عملاً مشتركاً أو يكون من شأنه أن يمس الغاية من وضعه وإخراجه، كل هذا ما لم يتفق المشتركون على خلافه. ولعل من أمثلة هذا المصنف في هذا الفرض أن يشترك أكثر من شخص في كتابة مادية علمية معينة مكونة من أكثر من جزء أو باب، فيقوم كل واحد منهم بكتابة الجزء أو الباب المتميز الذي يخصه، فيخرج المصنف المشترك بوصفه وحدةً واحدةً كاملة البنيان على نحو يسهل معه رغم هذه الوحدة المتجانسة فصل دور كل واحد فيه على حده دون أي ضرر أو مساس بالعمل الذهني المشترك لهذا الجمع من المشاركين في التأليف .

ولعل هذا هو عين ما نصت عليه المادة ١٣٨/٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري بقولها " المصنف المشترك : المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن " .

٣- <u>المصنف الجماعي:</u>

هو ذلك المصنف الذي يشترك في وضعه وإخراجه جماعةٌ من الأشخاص بناء على توجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره باسمه ولحسابه الخاص ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي ابتغاه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحيث يصعب فصل عمل كل واحد من المشتركين فيه وتمييزه على حده.

وهذا هو عين ما نصت عليه المادة ١٣٨/٤ من القانون سالف الذكر بقولها " المصنف الجماعي : المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشرة باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حده " .

ويظهر مما سبق أن المصنف الجماعي يماثل المصنف المشترك في

جانب ويختلف عنه في جانب آخر، أما وجه التماثل بينهما فيرجع إلى كون كل واحد منهما يمثل نتاج عمل ذهني مشترك لعدة مؤلفين ، إذ يساهم في وضع وإخراج كل واحد منهما مجموعة من الأشخاص، وهما بذلك يختلفان عن المصنف الفردي الذي هو نتاج ذهني لشخصٍ واحدٍ، أما وجه التباين والاختلاف بينهما فيظهر في كون المصنف الجماعي لا يقوم الأشخاص المشتركون بوضعه وإخراجه من تلقاء أنفسهم كما هو الحال في المصنف المشترك وإنما بتوجيه شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، هو الذي يوجههم إلى هذا العمل الذهني ، ويجري انتاجه تحت إدارته وباسمه ولحسابه الخاص، بخلاف المصنف المشترك الذي يجري إفرازه بأسماء مؤلفيه ولحسابهم الخاص.

وبناء عليه تثبت حقوق المؤلف في المصنف الجماعي قانونا للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بالتوجيه إلى وضعه وابتكاره وليس للأشخاص الذين قاموا بعملية الابتكار والإخراج وذلك على سبيل الاستثناء لتفادي ما قد ينشأ من صعوبات نتيجة لتدخل المؤلفين الحقيقيين لهذا المصنف على نحو قد يهدد الهدف المقصود من التوجيه لوضع مثل هذا المصنف [1].

وفي اعتقادي أن هذا المسلك التشريعي بشأن المصنف الجماعي مع وجاهته محل نظر، على أساس أنه وإن كان صحيحا أن هذا النوع من المصنفات يصدر لغاية معينة ينشدها شخص من قام بالتوجيه إليه ونشره تحت إدارته ولحسابه الخاص سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا، وأن الاعتراف بحقوق المؤلف المادية والمعنوية للأشخاص الذين اشتركوا في ابتكاره ووضعه ربما قد يهدد الغاية المنشودة من وضعه وابتكاره، إلا أن ذلك لا يبرر بحال من الأحوال ثبوت حقوق المؤلف جميعها للشخص الموجه لابتكار هذا المصنف وحرمان

---

[1] انظر في ذلك إلى: أ.د/ حسن كيره بند ٢٤٦، ص ٤٨٨ .

الأشخاص المؤلفين من هذه الحقوق، لأن المصنف الجماعي – مثل المصنف المشترك– عمل ذهني لجماعة من الأشخاص لذلك كان طبيعيا أن ينسب إليهم هذا المصنف وتثبت لهم أيضا وحدهم باقي حقوق المؤلف الأدبية عليه، على أن يتم تقييد هذه الحقوق لصالح الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجَّه جهودهم لهذا العمل الجماعي وقام بنشره تحت إدارته ولحسابه الخاص لضمان عدم المساس بالغاية المنشودة من وراء ابتكار هذا المصنف وإخراجه، ولا يصح مطلقا جحد حقوق المؤلفين لهذا المصنف عن مؤلفيه لاسيما الحقوق الأدبية منها ، تأسيساً على أن مراعاة هذه الحقوق لمؤلفي العمل الجماعي لا يمكن أن تضر أبدا بالغاية المنشودة من وراء انتاج هذا المصنف .

المبحث الثاني

الطبيعة القانونية لحق المؤلف

لقد ثارَ خلافٌ في الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية لحق المؤلف وتمخضَ الخلافُ عن رأيين اثنين: أحدهما يصور هذا الحق على أنه حقُ ملكية يرد على شيء معنوي أو حقُ ملكية أدبية، والآخرُ ينظرُ إليه بوصفه حقاً من نوع خاص له طبيعة مزدوجة، وذلك على التفصيل الآتي:–

أولا: الرأي الأول:

لقد كان الفقهُ والقضاءُ يميلان في بادئ الأمر إلى تصنيف الحقوق الذهنية على أنها من قبيل الحقوق العينية، وأن حق المؤلف على مصنفه هو حق ملكية، كل ما في الأمر أن هذا الحق يرد على شيء معنوي خروجاً على الأصل العام في محل حق الملكية الذي هو دائما شيءٌ مادي وليس شيئاً معنوياً.

<u>ولقد تعرض هذا الرأي للانتقاد من أكثر من زاوية:–</u>



١- إن وصفه لحق المؤلف بأنه حق ملكية يخرج اصطلاح الملكية عن مدلوله الفني التقليدي المستقر له بوصفه حقاً لا يرد إلا على الأشياء المادية وحدها، وهذا ما يخالف حق المؤلف بوصفه حقاً يرد على شيء معنوي غير ملموس.

٢- إن حق الملكية يخول صاحبه وحده سلطة استعمال الشيء والاستفادة منه عن طريق استغلاله، وهذا ما لا يتوافر في حق المؤلف، فمن غير المتصور أن يُقْصِرَ المؤلِفُ على نفسه حق استعمال نتاجه الذهني أو الفكري، بل إن وسيلته لاستعمال حقه على المؤلَف لا تتحققُ إلا بنشره وتداوله بين الناس، وليس عن طريق الاستعمال الشخصي فقط.

٣- إن حق المؤلف يتضمن عنصراً أدبياً يصعبُ تجاهله إلى جانب العنصر المالي، وهو عنصر مميز له عن الحقوق العينية قاطبة ومنها حق الملكية، فهي لا ترد إلا على الأشياء المادية وحدها، ومن ثم فإن إدراج الحقوق الذهنية ومنها حق المؤلف ضمن الحقوق العينية فيه إهدارٌ وتجاهلٌ للجانب الأدبي في حق المؤلف والذي يمثلُ جوهرَ هذا الحق.

٤- إن حقَ الملكية حقٌ دائمٌ لا يفنى إلا بفناء محله الذي يرد عليه، مما يجعله مختلفا عن حق المؤلِف في جانبه المالي الذي هو حق مؤقت ينتهي بعد مضى مدة معينة ينص عليها القانون، يصير بعدها استعمال النتاج الفكري أو الذهني أو الاستفادة منه مباحاً للأشخاص كافةً .

ثانيا: الرأي الثاني: حق الملكية حق ذو طبيعة مزدوجة:

نظرا لكثرة الانتقادات التي وجهت إلى الرأي الأول – على نحو ما رأينا آنفا



– فقد عدل الفقه المعاصر عن تكييف الحقوق الذهنية على أنها حقوق ملكية، واتجه إلى وصفها بأنها حقوقٌ من نوع خاص ذات طبيعة مزدوجة تضم نوعين مختلفين من الحقوق، فحقُ المؤلِف ينطوي على حق معنوي يعبر عن الرباط الوثيق بين الشخص وبين ما يفرزه ذهنه وفكره من نتاج أو جهد، وهو رباطٌ يبررُ نسبةَ المصنف إليه وحده، وحق مالي يخول له الاستئثار بمنافع استغلال هذا المصنف أو النتاج الذهني أو الفكري استغلالا ماليا.

المبحث الثالث

مضمون حق المؤلف

للمؤلِف على مصنفه نوعان من الحقوق حقٌ معنوي أو أدبي يعبر عن نسبة المصنف إلى صاحبه بوصفه نتاج خلقه وابتكاره، يخوله مجموعة معينة من السلطات التي تؤكد الرباط الوثيق بين المصنف وشخصية مبتكره وواضعه بوصفه ترجمةً صادقةً عن مكنون ثقافته وشخصيته الإبداعية ، وحق مادي أو مالي يتيح له حق الاستئثار بثمار استغلال هذا المصنف استغلالا ماديا.

وها نحن سنتناول بالتفصيل مضمون هذين الحقين على النحو الآتي:–

أولا: مضمون الحق الأدبي لحق المؤلف:

يخول القانون للمؤلِف على مصنفه عددا من السلطات التي تكفل له المحافظة على كيانه الأدبي بوصفه جزءاً لا ينفصل عن ثقافته وشخصيته، والتي تتمثل فيما يلي:–

١– سلطة النشر:

لقد جعل القانون للمؤلف سلطة تقديرية في نشر مصنفه من عدمه، وذلك

على أساس أن المصنف يعبر عن جانب من جوانب شخصيته ألا وهو الجانب الذهني أو الجانب الفكري، فكان طبيعيا أن يترك له أمر تقدير نشر هذا المصنف أو عدم نشره حسبما يتراءى له، لأنه قد يُقدَّرُ المؤلِفُ أن في نشر مصنفه مساساً بسمعته الأدبية أو الفنية أو العلمية فيكون له سلطة الامتناع عن النشر.

ولا غرابة في منح المؤلِف مثل هذه السلطة فالأمر يتصل بجانب حيوي من جوانب شخصيته ألا وهو الجانب الذهني أو الفكري، فلا ينبغي أن يكون لغير صاحبه سلطانٌ بشأنه وإلا كان هناك اعتداءٌ على حق من حقوقه اللصيقة بشخصيته.

كما أن للمؤلف الحق في تعيين طريقة النشر، فله أن ينشره مثلا في الجرائد أو داخل إحدى الموسوعات العلمية أو الأدبية أو الفنية بحسب طبيعته أو أن ينشره في مؤلف مستقل عن طريق إحدى دور النشر أو بعرضه في إحدى دور العرض كما لو كان لوحة فنية أو عملا فنيا يعرضه على المسرح أو في السينما، فهو وحده الذي يستقل بتحديد الطريقة التي يطمئن إليها بما يتناسب مع طبيعة مصنفه.

ويبقى للمؤلِف سلطة الامتناع عن النشر حتى وإن كان قد سبق له التعاقد مع إحدى دور النشر على نشر هذا المصنف متى قدَّر أن مصلحته تقتضي عدم النشر ، شريطة أن يلتزم المؤلف بتعويض الناشر عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي تلحقه من جراء مباشرة المؤلف لحقه الأدبي في عدم نشر مؤلَفِه رغم سبق تعاقده على نشره [1] .

٢- سلطة نسبة المصنف إليه:

---

[1] أ. د/ محمد سعد خليفة ص ١٩١ .

لا غرو أن يكون من حق المؤلف نسبة مصنفه إليه فهو نتاجُ فكره وجزءٌ من ثقافته وميوله وشخصيته وثمرةٌ لمجهوده وعطائه الذهني، ومن ثم فله كامل الحق عند نشر مصنفه أو عرضه أو تقديمه للجمهور أن يكون منسوباً إليه فيصدر حاملاً اسمه الحقيقي أو اسمَ مستعارٍ له إذا كان قدر هو ما يبرر له إخفاء اسمه الحقيقى، بل إن له الحق في نشر مصنفه دون أن يحمل اسما معينا.

ويكون من حق المؤلِف أن يدفع أي اعتداء يقع على حقه في نسبة مصنفه إليه، وإثبات أبوته لفكره فهو حقٌ وثيقُ الرباط بشخصيته فلا يسقط بالنزول عنه أو بعدم استعماله لأي مدة وإن طالت.

٣- سلطة تعديل أو تحوير المصنف:

إن من حق المؤلف أن يدخل على مصنفه ما يراه من تعديلات أو تغييرات لازمة ليواكبَ بها تغيرَ الزمان وتقدمَ العلوم وتطورَ الفكر، وليس لأحد سواه أن يمارسَ هذه السلطةَ إلا بإذن منه أو ممن يخلفه من ورثته .

بيد أنه يجبُ مراعاةُ عند ثبوت حق الاستغلال المالي على المصنف للغير ألا يسمح لصاحبه المؤلِف بإجراء أي تعديل عليه إلا بعد استئذان المحكمة الابتدائية في ذلك واقتناع هذه المحكمة بوجود أسباب لدى المؤلف تبرر له إجراء هذه التعديلات ، مع التزامه بتعويض الناشر تعويضاً عادلاً عن كامل الأضرار التي تلحقه من جراء هذه التعديلات خلال أجل معين تحدده له المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم الصادر له بإجراء هذه التعديلات إذا جاوز الأجل المضروب له دون تعويض الناشر عن هذه الأضرار .

وهذا هو عين ما نصت عليه المادة ١٤٤ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري بقولها " للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول **أو**

بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم " ..

كما أن له الحق في تحوير مصنفه بتحويله من لون إلى آخر، كأن يحوله من قصة مكتوبة إلى عمل درامي مسرحي أو فيلمي مثلا ، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه فيه من ورثته .

٤- سلطة سحب المصنف من التداول:

يثبت للمؤلف بمقتضى حقه الأدبي على نتاجه الفكري أو الذهني، سلطة تقرير سحب مصنفه من التداول بوقف نشره أو عرضه أو إذاعته.

ذلك أن المصنفَ جزءٌ من شخصية مؤلِفه وترجمةٌ لميوله وثقافته وفكره، لذا فإن من حقه وحده إذا ما عرضت له بعد طرحه إياه للتداول، ظروفٌ وملابساتٌ تقتضي تدخلَه لسحب مصنفه من التداول ، أن يباشر هذه السلطة، لما في حرمانه منها وجحد حقه فيها من مساسٍ بسمعته العلمية أو الأدبية أو الفنية.

فقد يكون هذا المصنف قد صدر عن مؤلفه في أولى مراحل حياته العلمية أو الأدبية أو الفنية وارتأي بعد مرور فترة من الزمن أن مضمون المصنف أو محتواه لم يعد متناسباً مع مكانته العلمية الرفيعة أو أضحى متعارضاً مع تطور الأحداث العلمية أو السياسية أو مخالفاً للقيم الاجتماعية في المجتمع، الأمر الذي يحتم عليه بحسب تقديره الخاص سحب تداوله بوقف عرضه أو نشره أو إذاعته.

بيد أنه يجب مراعاة عند ثبوت حق الاستغلال المالي على المصنف لغير صاحبه ألا يسمح لصاحبه بسحبه من التداول إلا بعد استئذان المحكمة الابتدائية في ذلك واقتناع هذه المحكمة بوجود أسباب لدى المؤلف تبرر له إجراء هذا

السحب ، مع التزامه بتعويض الناشر تعويضاً عادلاً عن كامل الأضرار التي تلحقه من جراء هذا السحب خلال أجل معين تحدده له المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم الصادر له بإجراء هذا السحب عند إخلاله بحق الناشر في التعويض خلال الأجل المضروب له .

وهذا هو عين ما نصت عليه المادة ١٤٤ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري بقولها " للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو **بسحبه من التداول** أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم " .

خصائص الحق الأدبي للمؤلف:

نظرا لأن الحق الأدبي أو المعنوي في حق المؤلف يعدُ حقاً لصيقاً بشخصيته، فإنه يخرجُ عن دائرة التعامل فلا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه، كما أنه لا يسقطُ بالتقادم .بيد أن هذا الحقوق من اللصيقة بالشخصية فإن القانونَ يقررُ انتقالَه رغم ذلك إلى ورثة المؤلِف ، وذلك من أجل المحافظة على حقوق المؤلِف على مؤلَفه حتى بعد موته ، ومن أجل تأكيد هذا المعنى الحمائي المقصود من تقرير هذا الانتقال فقد قصرَ القانونُ سلطة الورثة عند مباشرتهم لبعض مظاهر سلطات الحق الأدبي على مؤلَف مورثهم على السماح لهم بكل ما يسهم في تأكيد نسبة المؤلَف إلى مؤلِفه ومنع كل ما من شأنه أن يمس كرامة المؤلِف أو سمعته بوصفهم حراساً قانونيين على التراث الفكري لمورثهم [١].

---

[١] د/ حمدي محمد عطيفي ص ٦٨ .

ثانيا: مضمون الحق المالي في حق المؤلف:

يعبر الحق المالي في حق المؤلف عن الرباط أو الصلة المالية القائمة بين المؤلف ونتاج ذهنه أو فكره، فيكون من حقه الاستئثار بالمنافع المالية التي يسفرُ عنها استغلالُ هذا النتاج استغلالاً مالياً.

ولا جرمَ أن الاعترافَ للمؤلف بحقه المالي على مصنفاته أيا كانت طبيعتُها (سواء كانت مصنفات علمية أو أدبية أو فنية) يعدُ أمراً بدهياً وطبيعياً بوصفها ثمارَ جهوده الذهنية والفكرية وهو وحده الذي له الحق في جني قطافها وثمارها المادية أو المالية، ولقد حرصَ القانونُ على التأكيد على هذا الحق .

ويتخذُ المؤلِفُ في استغلال مصنفه استغلالاً مالياً أحد طريقين: إما أن يقوم بنفسه بمباشرة هذا الاستغلال أو يقوم به غيرُه الذي يتنازل له المؤلِف عن هذا الحق مقابل مبلغ معين أو مقابل نسبة تُحَدَدُ بينهما اتفاقاً من ناتج هذا الاستغلال.

وللمؤلف الحقُ في اختيار الطريقة التي يجري من خلالها هذا الاستغلالُ بحسب ما يراه محققاً لمصلحته، فقد يرى عرضَ مصنفِه على الجمهور مباشرة بتلاوته علانية أو بالتوزيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للتكلم أو للصوت أو للصور، أو غيرها من طرق العرض المباشر على الجمهور ويسمى هذا الحق "بحق الأداء العلني"، وقد يقررُ عرضَ مصنفِه على الجمهور بطريق غير مباشر وذلك عن طريق نسخ المصنف بواسطة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الصب في قوالب أو التسجيل أو النسخ أو التثبيت على أسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي، ويسمى هذا الحق "بحق النشر" .

ونشرُ المؤلِف لمصنَفِه قد يتمُ على نفقته هو ولحسابه هو ليجني من بعد وحده

ثمارَ نشرِه ، وقد يتعاقدُ مع آخر فيعطيه حقَ استغلال مصنفه ماليا فينشره ذلك الآخر لحسابه هو لا لحساب مؤلفه سواء أعطاه المؤلف حق استغلاله ماليا بمقابل أو بغير مقابل حسب مضمون الاتفاق بينهما ، وأخيراً قد يتفقُ المؤلفُ مع الناشر على أن يتولى الناشرُ عملية النشر كاملة على نفقته وحسابه ثم يكون لهما من بعد الاشتراك في توزيع عائد استغلاله ماليا بحسب نسب معينة يتفقان عليها .

وتجدر الإشارة إلى أن ترجمة المؤلف لمصنفه من لغة إلى أخرى يعد إحدى صور استغلاله استغلالا ماليا، وليس لغيره حق الترجمة إلا بعد الحصول على إذن كتابي منه أو ممن يخلفه هذا ما لم تكن الترجمة بقصد الاستعمال الشخصي للمترجم ، ودون أن يجني من ورائها أي ثمار مادية ، هذا فضلا عن ضرورة ذكر مصدر ذلك المصنَف واسم ومؤلِفه .

<u>خصائص الحق المالي للمؤلف</u>:

يتسم الحق المالي للمؤلف على مصنَفه بالخصائص الآتية:-

١- قابلية هذا الحق للتصرف فيه أو للتنازل عنه للغير سواء أكان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، لمدة محددة أم بدون تحديد مدة، بموجب تصرف منجز حال حياته أم كان التصرفُ مضافاً إلى ما بعد الموت أي بطريقة الإيصاء.

٢- قابلية الحق للانتقال إلى الورثة تأسيساً على أنه يمثل أحد عناصر الذمة المالية للمؤلف فينتقل مع غيره من أموال التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة.

٣- قابلية هذا الحق للحجز عليه متى تمَّ استغلالُه بطريق النشر فيحجز على نسخ النشر بوصفها أشياء ذات قيمة مالية فتدخل ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للمدين المؤلف فتمثل إذن محلا للضمان العام المقرر لدائنيه .

٤- الحقُ المالي للمؤلف حقٌ مؤقتٌ بمدة معينة : إذ ينصُ القانونُ على سقوط الحق المالي للمؤلف بعد مضى خمسين عاما من تاريخ وفاة المؤلف إذا كان المصنَفُ منفرداً أو من تاريخ وفاة آخر شخص من المؤلفين المشتركين في مصنفٍ واحدٍ أو بمضي خمسين عاماً على تاريخ النشر إذا كان صاحبُ المصنَف شخصاً معنوياً كما هو الحال في المصنف الجماعي أو كان المصنفُ غيرَ منسوبٍ لصاحبه أو كان قد نُشرَ تحت اسم مستعار ولم يكشفْ المؤلِف عن شخصيته الحقيقية خلال تلك المدة .

ويراعى أنه في حالة إذا كان المصنفُ مجزءاً إلى أجزاء مختلفة نشرت منفصلة وعلى فترات ، أن يعاملَ كلُ جزءٍ منها معاملة المصنف المستقل بالنسبة لحساب مدة الحماية القانونية المقررة لها .

وهذا عينُ ما نصت عليه المادة ١٦٠ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف الذكر بقولها " تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف " .

وتنص المادة ١٦١ على أن " تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنف المشترك مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً منهم " .

كما تنص المادة ١٦٢ من القانون سالف الذكر على أن " تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين

(١٦٠)،(١٦١) من هذا القانون" .

" وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد " .

كما تنص المادة ١٦٣ على أن " تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة (١٦٠) من هذا القانون " .

كما تنص المادة ١٦٤ على أن " تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد " .

كما تنص المادة ١٦٥ على أنه " في الأحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديدا. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلا عند حساب مدة الحماية " .

ويراعى أنه في خصوص المصنفات الأجنبية فإن مدى حماية حق مؤلف المصنف الأجنبي وحق من يقوم بترجمته إلى لغة أجنبية أخرى أو إلى اللغة العربية تنقضي بمضي خمسين عاما من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو

المصنف المترجَم .

ولا جرم في أن هذا النص وإن كان له ما يبرره في إعطائه حق الترجمة إلى اللغة العربية للمصنفات الأجنبية لأي شخص دون حاجة إلى إذن مؤلفها إذا لم تترجم إلى اللغة العربية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ النشر، رغبة في إثراء الثقافة المصرية بالثقافات الأجنبية والاستفادة من ثمار التقدم في العلوم المختلفة في العالم كله، إلا أنه لا ينبغي جحد حق المؤلف ماليا في هذه المصنفات الأجنبية ، إذ ينبغي للإنصاف والعدل إعطاؤه الحق في تعويض عادل يترك لتقدير القضاء إذا ما نازع مطالباً بحقه في التعويض بشأن ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو عارض في ذلك ولم يسمح إلا بمقابل مالي [1].

المبحث الرابع

الحماية القانونية لحق المؤلف

لقد أحاط واضع القانون حق المؤلف على مؤلفه (سواء في الجانب الأدبي أو الجانب المالي لهذا الحق) بكل أشكال الحماية القانونية اللازمة لرعاية هذا الحق وحمايته من أي مظهر من مظاهر الاعتداء ، فجعل له ابتداء أن يتخذ من الإجراءات الوقتية والتحفظية ما يلزم لإثبات هذا الاعتداء ووقفه ، كما أتاح له أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية ضد المعتدي لإسباغ الحماية المدنية والجنائية المقررة لهذا الحق انتهاءً ، وذلك كله على التفصيل الآتي :-

أولاً : الإجراءات الوقتية والتحفظية

---

[1] انظر في نفس المعنى: أ.د/ حمدي عبد الرحمن "فكرة الحق" ص ١٠٩، ١١٠، طبعة ١٩٧٩، دار الفكر العربي، أ. د/ محمد سعد خليفة ص ١٩٣ هامش .

لقد كفل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م اتخاذ كافة الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة لإثبات الاعتداء الذي يمس حق المؤلف ولوقف استمرار هذا الاعتداء الحاصل ، وذلك بناء على طلب يقدم من المؤلف أو ممن يخلفه إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة .

إذ تنص المادة ١٧٩ من هذا القانون على أن " لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب :-

١-إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي .

٢-وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته .

٣-توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه ، وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي .

٤-إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .

٥-حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .

ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة ، ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .

ثانياً : الحماية المدنية لحق المؤلف

لا جرم أن أي اعتداء من أي شخص على الجانب الأدبي أو الجانب المالي لحق المؤلف على مؤَلَفِه يمثل وفقا للقواعد العامة في المسئولية المدنية خطأ عقديا أو خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية مرتكبه مسئولية عقدية أو تقصيرية حسب الطبيعة القانونية للخطأ [١].

وبناء عليه يتسنى للمؤلف الالتجاء إلى القضاء لوقف الاعتداء الحاصل وطلب التعويض عن جملة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا الاعتداء .

ولا غرو أن يكلف المؤلف بإثبات الضرر الذي يدعيه سواء أكان ضرراً مادياً أو ضرراً أدبياً إعمالا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب على المدعي إثبات ما يدعيه ، بيد أن اتجاها في الفقه والقضاء [٢] نرجحه يميل إلى التفرقة في

---

[١] ذلك أنه إذا كانت ثمة علاقة عقدية بين المعتدي والمؤلِف ، وكان اعتداؤه يمثلُ إخلالاً بالتزامة العقدي فعندئذ تنعقد مسئوليته العقدية مثل إخلال الناشر بالتزاماته العقدية الناتجة عن عقد النشر ، إذ يمكن للمؤلف الرجوع عليه بالتعويض وفقا لقواعد المسئولية العقدية ، في حين أنه إذا انتفت العلاقة العقدية بين المعتدى والمؤلف أو كان الاعتداء منبت الصلة عن العلاقة العقدية القائمة بينهما ، فعندئذ يكون المعتدى مسئولا في مواجهة المؤلف وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية .

[٢] انظر في ذلك إلى : أ.د/ عبد الرشيد مأمون " الحق الأدبي للمؤلف" ، ص ٤٥٠ ، وما بعدها طبعة عام ١٩٧٨ م دار النهضة العربية ، أ.د/ عبد الله مبروك النجار " الحماية القانونية ، لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون ، ص ١٢٨ ، الطبعة الأولى عام ١٩٩٠ م ، دار النهضة العربية ، د/ شحاته غريب شلقامى "الملكية الفكرية في القوانين العربية" ، ص ٢٣٣ ، طبعة عام ٢٠٠٨ م ، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية .

خصوص إثبات الضرر الحاصل للمؤلف على مؤلفه بين الضرر المادي والضرر الأدبي ، فالضرر المادي يتعين إثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات ، بخلاف الضرر الأدبي فهو مفترضٌ على إثر حصول الاعتداء على الحق الأدبي للمؤلف دون أن يحتاج إلى إثبات ، إذ لا يمكن مطالبة المؤلف بإثبات الضرر الذي عانى منه شخصياً في نفسه بسبب الاعتداء الحاصل على حقه الأدبي ، ولذا ينبغي أن يترك للمؤلف تقدير ما إذا كان الاعتداءُ الحاصلُ على حقه الأدبي قد ألحق به أضراراً أدبية أم لا ، وتطبيقا لذلك ذهب القضاءُ الفرنسي إلى أنه يكفي المؤلف أن يذكر عدم رضائه عن التعديلات التي أجراها الناشر على مصنفه دون إذنه لإثبات حصول الضرر الأدبي له وحصوله على التعويض الجابر لهذا الضرر [1].

ثالثاً : الحماية الجنائية لحق المؤلف

لقد حرصَ واضعُ القانون على توفير الحماية الجنائية لحق المؤلف رغبةً منه في توفير أقصى قدر من الحماية القانونية المأمولة لهذا الحق ، لاسيما وأن للجزاء الجنائي رهبته الكبيرة في نفوس الأشخاص ، الأمر الذي يرهبهم من مقارفة أي مظهر من مظاهر الاعتداء على حق المؤلف .

إذ تنص المادة ١٨١ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :-

١- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون ، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من

---

[1] حكم محكمة النقض الفرنسية ١٨٦٧/٨/٢١ مشار إليه لدى أ.د/عبد الرشيد مأمون – المرجع السابق – بند رقم ٤٥٠ ، ص ٤٥٨ .

المؤلف أو صاحب الحق المجاور . تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده .

٢- التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج مع العلم بتقليده .

٣- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .

٤- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .

٥- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .

٦- الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي

لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها ، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في هذه الجرائم المنصوص .

وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

الباب الثالث

محـل الحـق

الباب الثالث

محـل الحـق

تمهيد :

إذا كان الشخصُ يمثلُ صاحبا للحق فإن للحق محلاً يرد عليه سواء أكان شيئاً أم عملاً تبعا لطبيعة هذا الحق، فالحقُ العينى يرد على شى مادى معينبالذات باعتباره سلطة مباشرة تخول صاحبه مباشرة حقوقه على هذا الشئ دون حاجة إلى تدخل شخصى من جانب أحد ، كما يرد الحق الذهنى على شى معنوى وهو النتاج الذهنى أو الفكرى للمؤلف ، في حين يرد الحق الشخصى أو ما يسمى بحق الدائنية على عمل معين من الأعمال سواء أكان عملا إيجابيا (أي أداء عمل معين لمصلحة الدائن) أم كان عملا سلبيا (أي الامتناع عن عمل معين لمصلحة الدائن).

وبناء على ماسبق فإن محل الحق إما أن يكون شيئا أو عملا بحسب نوع الحق أو طبيعته. وينبغى التحرز في هذا المقام بين مضمون الحق ومحل الحق، فمضون الحق ما يثبته الحق لصاحبه من سلطات وصلاحيات ،في حين أن محل الحق هو ما يرد عليه الحق بمضمونه سالف الذكر من شئ أو عمل تبعا لطبيعة الحق، فإن كان الحق ذهنيا أو عينيا كان محله شيئا (على أن يراعى أنه يكون شيئا ماديا في الحق العينى وشيئا معنويا في الحق الذهنى) أما إن كان الحق شخصيا أو من حقوق الدائنية كان محله عملا من الأعمال.

فمثلا نجد أن مضمون حق الملكية هو ما يثبته حق الملكية للمالك من سلطات تتمثل في سلطة الاستعمال و الاستغلال و التصرف، في حين أن الشئ الذي تنصب عليه سلطات المالك الثلاث سالفة الذكر يمثل محلا لحق الملكية.

وسوف نقسم دراسة محل الحق إلى فصلين اثنين على النحو الآتى :-



الفصل الأول: الأشياء.

الفصل الثانى: الأعمال.

الفصل الأول

الأشيـــاء

ماهية الشئ وتمييزه عن المال:

يقصد بالشيء في اصطلاح فقهاء القانون : كل ما لا يعد شخصا، ويكون له كيان ذاتى منفصل عن الإنسان سواء كان هذا الكيان كيانا ماديا يدرك بالحس (مثل العقارات والمنقولات) أو كيانا معنويا لا يدرك إلا بالتصور عن طريق العقل (مثل المصنفات الذهنية أو الفكرية) [1].

وإذا كان الشى بهذا المعنى يمثل محلاً للحق، إلا أنه لا يصلح محلاً لكافة أنواع الحقوق ، ولكنه يصلح بالنسبة لبعض أنواع الحقوق مثل الحقوق العينية والحقوق الذهنية وبعض حقوق الشخصية (مثل الحق في الاسم)، أما الحقوق الشخصية أو حقوق الدائنية فمحالُها الأعمال لا الأشياء، وقد يكون الشئ موضوعاً للعمل محل الحق الشخصي أو حق الدائنين فيصير بذلك محلاً غير مباشر للحق الشخصي، لكن لا يمثلُ محلاً مباشرا له.

والشئ بهذا المعنى يختلفُ عن المال، ذلك أن المالَ هو الحق ذو القيمة المالية أي الذي يقبل تقييمه بالنقود أيا كان نوعه (أي سواء كان محله شيئا من الأشياء أو عملا من الأعمال).

وقد جرى فقه القانون على تقسيم الأشياء إلى قسمين رئيسين فهناك الأشياء المادية أي التي تدرك بالحس مثل المنقولات والعقارات وغيرهما من الأشياء المادية الأخرى، وهناك الأشياء المعنوية أي الأشياء التي لا تدرك بالحس ولكنها تدرك

---

[1] أ.د / حسن كيره بند ٣٦٤،ص ٧٠٤ ، أ.د/ توفيق حسن فرج ، ص ٨٠٣ ، أ.د/ حمدي عبد الرحمن " مقدمة القانون المدني ، الحقوق وغيرها من المراكز القانونية ، ص ٤٣٣ ، أ.د/ محمد شكري سرور " النظرية العامة للحق " ، ٢٥٧ ، الطبعة الأولى عام ١٩٧٩ م .

بالتصور عن طريق العقل مثل المصنفات الفكرية والمخترعات مثلا.

كما يتجه هذا الفقه أيضا إلى تقسيم الأشياء المادية إلى تقسيمات عدة، منها تقسيمها إلى أشياء قابلة للتعامل وأخرى خارجة عن دائرة التعامل، وتقسيمها إلى منقولات وعقارات،وتقسيمها إلى أشياء مثلية وأخرى قيمية، وأخيرا تقسيمها إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأخرى غير قابلة للاستهلاك ،الأمر الذي يستوجب علينا تقسيم هذا الفصل إلى مباحث خمسة على التفصيل الآتي :-

المبحث الأول: الأشياء المادية والأشياء المعنوية.

المبحث الثاني:الأشياء القابلة للتعامل والأشياء الخارجة عن دائرة التعامل.

المبحث الثالث: العقارات والمنقولات.

المبحث الرابع: الأشياء المثلية والأشياء القيمية.

المبحث الخامس: الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك.

المبحث الأول

الأشياء المادية والأشياء المعنوية

يقصد بالأشياء المادية Les choses ou biens materiaux الأشياء التي يمكن إدراكها بالحس مثل الحيوان والجماد والنبات .....إلخ، أما الأشياء غير المحسوسة أي التي لا يمكن إدراكها بالحس ولكن يمكن إدراكها بالعقل فقط مثل محل الحقوق الذهنية أو المعنوية كحق المؤلف فهو يرد على الفكرة الذهنية التي ابتكرها.

وتبدو أهمية التفرقة بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية من حيث الحيازة، ذلك أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لا تنطبق إلا على المنقولات المادية دون المنقولات المعنوية، هذا بالإضافة إلى أنه في حالة الرهن الحيازي تختلف حيازة المنقول المادي عن حيازة المنقول المعنوي [١].

المبحث الثاني

الأشياء القابلة للتعامل والأشياء الخارجة عن دائرة التعامل

لقد قرر واضع التقنين المدني قاعدة عامة بشأن قابلية أو عدم قابلية الأشياء للتعامل مؤداها أن جميع الأشياء أيا كانت طبيعتُها أو نوعُها (أي سواء أكانت أشياء مادية أم معنوية ،مثلية أم قيمية، منقولات أم عقارات)-كأصل عام – تصلح لأن تكون محلا للحقوق المالية فيتعاملُ عليها الأشخاصُ فيما بينهم بحيث لا يخرجُ عن ذلك سوى الأشياء التي يعجزُ الأشخاصُ عن التعامل عليها بحكم طبيعتها، هذا بالإضافة إلى الأشياء التي يخرجُها القانونُ بنص صريح عن دائرة التعامل على الرغم من صلاحيتها للتعامل عليها بطبيعتها.

---

[١] أ.د / توفيق حسن فرج ص ٢٨٥ .

إذ تنص المادة ٨١ من التقنين المدني على ذلك بقولها "١-كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا المالية".

"٢-والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية ".

ويتضح من النص سالف الذكر أن الأشياء لا تخرج عن دائرة التعامل إلا في حالتين:

أولهما: أن تكون من الأشياء التي تستعصي على التعامل بحكم طبيعتها بحيث يعجزُ الأفرادُ عن الاستئثار بحيازتها، مثل أشعة الشمس والهواء ومياه البحار والأنهار، فمثل هذه الأشياء ينتفعُ بها جميعُ الأشخاص من غير أن يحول انتفاعُ البعض بها دون انتفاع البعض الآخر.

ونظرا لأن العلة من استبعاد هذه الأشياء من دائرة التعامل يرجع كما أشار النص القانوني السابق إلى استحالة الاستئثار بها من قبل آحاد الناس، لذلك فإنه إذا انتفت هذه العلة وأمكن للأشخاص أن يستأثروا ببعض هذه الأشياء فعندئذ يجوزُ لهم التعاملُ عليها، كما يحدثُ الآن من قيام الأفراد بتعبئة المياه المعدنية في زجاجات لبيعها أو تعبئة الهواء في أنابيب الأكسجين لاستخدامها في الأغراض الطبية، أو تجميع الحرارة المنبعثة من أشعة الشمس لاستعمالها في تسخين المياه أو للتدفئة أو لغيرهما من الأغراض الأخرى [١] .

وثانيهما: أن تكون من الأشياء التي يخرجها القانون عن نطاق التعامل

---

[١] انظر في نفس المعنى : أ.د/ إسماعيل غانم " محاضرات في النظرية العامة للحق "، ص ٨٢ ، طبعة عام ١٩٦٦ م ، أ.د/ حسام الدين كامل الأهواني " أصول القانون " ص ٦١١، طبعة عام ١٩٨٨ م ، محمود جمال الدين زكي " دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، ص ٢٩٢ ، ط ٢ ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .

بنصوص خاصة،وهذه الأشياء بحكم طبيعتها قابلة للتعامل ولكن يتدخل القانون بنصوص خاصة ليخرجها عن دائرة التعامل إما حفاظا على النظام العام والأداب أو مراعاة للمصلحة العامة في المجتمع.

وبذلك تنطوي هذه الحالة على صورتين أو مثالين لهذه الأشياء هما:

***الصورة الأولى:** وهي تتعلق بالأشياء التي يحظرُ القانونُ على الأشخاص التعاملَ عليها (على الرغم من كونها صالحةً للتعامل بحكم طبيعتها) بوصفها مخلةً ببعض جوانب فكرة النظام العام في المجتمع(ففكرة النظام العام فكرة عامة تتسع للتعبير عن كافة المصالح الأساسية أو القيم الرئيسة في المجتمع أيا كانت طبيعتها أي سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية) كما لو كانت مخلة بالأخلاق مثل حظر التعامل على المخدرات أو الأفلام التي تخدش الحياء والذوق أو الكتب الجنسية أو الصور الخليعة.

بيد أنه من المتصور أن يرخص القانون في استعمال بعض هذه الأشياء على سبيل الاستثناء لتحقيق أغراض معينة لخدمة المجتمع ، مثال ذلك أن يرخص القانون باستعمال بعض المواد المخدرة في مجال الأعمال الطبية.

***الصورة الثانية:**وهي تتعلق بالأشياء التي يحظر القانون التعامل عليها بوصفها مخصصة للمنفعة العامة ، مثال ذلك الأشياء المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها المعنوية العامة وتكون مخصصة للمنفعة العامة ، والتي يطلق عليها اصطلاح الأموال العامة ، مثال ذلك الميادين والشوارع والطرق والكباري وشواطئ البحار والأنهار، وكافة المرافق العامة مثل أبنية التعليم والصحة والكهرباء وغيرها من الأشياء التي تعد من ممتلكات الدولة داخل هذه المرافق العامة.

ووفقا لصريح نص القانون (م ٨٧ مدني) تعد من قبيل الأموال العامة كافة العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، مادامت أنها

مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهي أموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لأن الأموال بصورها المختلفة–على نحو ما رأينا سلفا– هي في حقيقتها أموال قابلة للتعامل عليها بحكم طبيعتها، فإن حظر التعامل عليها قانونا ينبغي أن يراعى فيه هذان الأمران:–

الأمر الأول: أن تظل هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة،وإلا فقدت هذه الأموال صفتها كأموال عامة، وأمكن – من ثمَّ– التعامل عليها بكل صور هذا التعامل.

وتفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة والذي ينتهي بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة(م ٨٨ مدني).

الأمر الثاني: أن حظر التعامل على هذه الأموال العامة مقصور على الحدود التي قررها القانون، فهو ليس حظراً عاماً وشاملاً لكل صور التعامل بحيث يمتنع عليها مطلقا إجراء أي نوع من أنواع التعامل المنصوص عليها قانونا والتي أشارت إليها المادة ٢/٨٧ مدني بقولها "وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم " ومن ثمَّ يجوز للدولة إجراء بعض صور التعامل على هذه الأموال غير أعمال التصرف ،كما لو قامت الدولة باستغلال بعض الأموال العامة بتأجيرها للأفراد مثلا.

المبحث الثالث

العقارات والمنقولات

المطلب الأول

أساس التقسيم وأهميته

يجري تقسيمُ الأشياء من زاوية ثباتها وعدم ثباتها إلى عقارات ومنقولات، فالعقارات Les immeubles هي أشياء ثابتة القرار في مواضعها وإمكانها على نحو يتعذر معه نقلها أو تحريكها منه بغير تلف ،بخلاف المنقولات Les meubles فهي أشياء غير ثابتة القرار تقبل النقل أو الحركة دون ضرر أو تلف.

ولعل هذه المغايرة في الطبيعة المادية بين العقارات والمنقولات أملت أن يكون ثمة نوعٌ من التباين والاختلاف في القواعد والنظم التي تحكم كلا منهما، وذلك على التفصيل الآتي:-

١- بالنظر إلى ما يلزم من إجراءات لانتقال الملكية:

فإنه نظرا لطابع الثبات والاستقرار الذي تتسم به العقارات فقد رُؤيَ إخضاع التصرفات القانونية، التي من شأنها إنشاء أو نقل أو زوال حقوق عينية عليها أو الاحتجاج بها على الغير، لإجراءات شهر معينة، على نحو لا يسمح معها بالاحتجاج بهذه الحقوق العينية الأصلية الواردة على تلك العقارات إلا بالتسجيل، كما لا يحتج بالحقوق العينية التبعية الواردة على هذه العقارات في مواجهة الغير إلا بالقيد ،بعكس الحال بالنسبة للمنقولات إذ لا يتصورُ إخضاعُ مثل هذه التصرفات عند ورودها عليها لإجراءات شهر مماثلة لما يجري في العقارات نظراً لفقدان هذه المنقولات لطابع الثبات والاستقرار وسرعة تداولها بين الأفراد [١].

لذلك كله نجد أن ملكية العقارات لا تنتقل بمجرد إبرام العقد بل يلزم إلى جانب ذلك إجراء التسجيل ، بخلاف المنقولات تنتقل ملكيتها فور إبرام العقد (هذا إذا كان المنقولُ شيئاً قيمياً ، أي كان شيئاً معيناً أما إذا كان شيئاً مثلياً ، أي كان

---

[١] انظر في نفس المعنى:أ.د / كيره بند ٣٦٦ ، ص٧٠٧ ،أ.د/ توفيق حسن فرج ص٢٨٨ وما بعدها .

شيئاً معينا بالنوع ، فيلزم إلى جانب ذلك الإفراز) دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة .

٢- بالنظر إلى ورود الحقوق العينية عليها:

إن ثمة حقوقا عينية لا ترد على المنقولات ولكن ترد فقط على العقارات، فحق السكنى وحق الحكر وحق الارتفاق بوصفهم حقوقاً عينية أصلية لا ترد إلا على العقارات، كما أن حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص بوصفهما حقين من الحقوق العينية التبعية لا يردان إلا على العقارات وحدها(فحقُ الرهن الرسمي يرد كأصل عام على العقار ولا يرد على المنقولات إلا على سبيل الاستثناء وبموجب نص في القانون،أما حق الاختصاص فلا يرد مطلقا على المنقولات وإنما يرد فقط على العقارات).

٣- مدى دور الحيازة في كل منهما:

لقد كان من شأن المغايرة في الطبيعة المادية للعقارات والمنقولات أن يختلفَ حجمُ الدور الذي تلعبه الحيازةُ في إثبات ملكية الحائز لهما، ففي المنقولات نظرا لصعوبة إخضاعها لنظام الشهر فلا يتاح للكافة العلم بما يرد عليها من حقوق عينية، هذا بالإضافة إلى سرعة تداولها وانتقالها من شخص إلى آخر، فلم يكن هناك بد من اعتبار الحيازة بمجردها سنداً للحائز فيما يدعيه من حق على المنقول وقرينة قانونية في نفس الوقت على توافر السبب الصحيح لهذه الحيازة .

هذا بعكس العقارات التي أتاحت طبيعتها المادية بوصفها أشياء ثابتة ومستقرة إخضاعها لنظام الشهر مما يتيح للكافة العلم بما يرد عليها من حقوق عينية عن طريق الإطلاع على دفاتر التسجيل إن كانت حقوق عينية أصلية أو دفاتر القيد إن كانت حقوقا عينية تبعية، الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم دور الحيازة في تملك العقارات بعكس المنقولات ، ومن ثمَّ لا تكفي الحيازة بمجردها

لتملك العقار، وإنما يلزم استمرارها لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى خمس سنوات [١] أو خمس عشرة سنة [٢] بحسب الأحوال.

هذا فضلا عن أن واضع القانون قد قرر لحائز العقار دعاوى ثلاث لحماية حيازته هي دعوى استرداد الحيازة ، ودعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، (وتسمى هذه الدعاوى بدعاوى الحيازة ، وقد جاءت في المواد من ٩٥٨ :٩٦٢ مدني) ولم يقرر ذلك لحائز المنقول .

٤- بالنظر إلى جواز التملك بطريق الشفعة:

لا يتصورُ في ظل القانون المدني الحالي تملك الأشياء بطريق الشفعة إلا في العقارات فقط ، فلا مجال لوجود الشفعة بالنسبة للمنقولات.

٥- بالنظر إلى الاختصاص القضائي:

يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات للمحكمة التي تقع في دائرتها هذه العقارات ،في حين يكون الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالمنقولات للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

٦- مدى بساطة أو تعقيد إجراءات التنفيذ في كل منهما:

تختلف إجراءات التنفيذ على العقارات عن إجراءات التنفيذ على المنقولات ، إذ يغلب على الأولى طابع البطء والتعقيد في حين يغلب على الثانية طابع السرعة والتبسيط في إتمامها.

---

[١] تنص المادة ١/٩٦٩ مدني على أنه "إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة االتقادم المكسب تكون عشرة سنوات" .

[٢] تنص المادة ٩٦٨ مدني على أنه "من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس سنوات" .



٧- بالنظر إلى القيود الواردة على تملك كل منهما:

تتجه تشريعات الدول عادة إلى وضع بعض القيود على تملك الأشخاص للعقارات ،نذكر من ذلك على سبيل المثال أنه بالنسبة للشخص الطبيعي يوجد حد أقصى لملكيته العقارية فلا يجوز أن تزيد عن خمسين فدانا بالنسبة للفرد ولا عن مائة فدانا بالنسبة للأسرة ،أما بالنسبة للشخص الاعتباري نجد أن القانون يقيد من أهلية الجمعيات في تملك العقارات على نحو لا يسمح بمجاوزة ملكيتها العقارية للقدر اللازم لتحقيق الغرض من إنشائها ،هذا بالإضافة إلى أن تشريعات الدول قد درجت في معظمها -كأصل عام -على حظر تملك الأجانب للعقارات بصفة عامة وللأراضي الزراعية بصفة خاصة.

هذا بخلاف الحال بالنسبة لتملك المنقولات إذ لا توجد مثل هذه القيود، فلا يوجد حد أقصى لملكية المنقولات سواء بالنسبة للشخص الطبيعي (فردا كان أو أسرة) أو الشخص الاعتباري، كما أنه لا تميل قوانين الدول إلى تقييد تملك الأجانب للمنقولات بأية قيود.

المطلب الثاني

العقارات Les immeubles

تمهيد :

تنص المادة ٨٢ من التقنين المدني المصري الحالي على أن:

"١- كل شي مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ،وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول".

"٢-ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله".

ويظهر واضحا من هذا النص أن لفظ العقار ذو دلالة واسعة ورحبة ،إذ أنه لا يقتصر مدلوله على الأشياء التي تتوافر فيها أوصاف العقار حقيقة وفعلا، والتي يطلق عليها اصطلاح العقارات بالطبيعة Les immeubles par natureوإنما يمتد ليشمل إلى جانب ذلك الأشياء المنقولة بحكم طبيعتها أصلا والتي تكتسب رغم ذلك وصف العقار حكما لا حقيقة نظرا لرصدها لخدمة هذا العقار أو استغلاله ،ويطلق عليها الفقه اصطلاح العقارات بالتخصيص Les immeubles par destination.

أولا :العقارات بالطبيعة :

يعد عقارا بطبيعته كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف (م ١/٨٢مدني)، ومن ثم ينطبق وصف العقار بحكم الطبيعة على الأراضي سواء أكانت أرض فضاء أم أرض زراعة ، كما ينطبق على ما يكون بجوف الأرض من معادن وأحجار، وما يوجد على سطحها من أشجار ونباتات ذات جذور غائرة وممتدة فيها (أي بداخل الأرض)، أما النباتات التي تزرع في أوعية خاصة فلا يصدق عليها وصف العقار لعدم اتصالها بالأرض، فضلا عن سهولة نقلها من مكان لآخر دون أي تلف ،كما يصدق هذا الوصف (أي وصف العقار بحكم الطبيعة) أيضا على المباني والمنشآت المتصلة بالأرض اتصال قرار مثل العمارات والكباري والسدود مثلا، أيا كانت مواد بنائها، وبصرف النظر عن الأغراض المقصودة من هذه المباني والمنشآت أو المدد المقررة لبقائها متصلة بالأرض.

فالمنشآت المؤقتة لإقامة المعارض أو المؤتمرات تعد عقارات مادامت مثبتة بالأرض ولا يمكن نقلها من مكانها دون تلف،بعكس الحال بالنسبة للمباني أو المساكن التي لا تتصل بالأرض اتصال قرار أو التي تتصل بالأرض اتصال قرار ولكن يمكن نقلها منها دون تلف فهي لا تعد من قبيل العقارات، مثال ذلك المساكن

المتحركة مثل عربات النوم داخل القطارات أو عربات الإقامة المتصلة بالسيارات (إذ يعمد الأشخاص في الدول الأجنبية إلى شراء عربات مجهزة تستعمل للنوم أثناء السفر وخلال الرحلات) فهي لا تعد عقارات لأنها غير متصلة بالأرض اتصال قرار، وكذلك الحال بالنسبة للخيام والأكشاك التي يستعملها البدو أو المسافرون خلال رحلاتهم للسياحة أو العمل فهي لا تعد عقارات لأنها وإن اتصلت بالأرض اتصال قرار إلا أنه يمكن نقلها من مكان لآخر دون أي تلف.

ونخلص مما سبق أن الشيء لا يعد عقارا حقيقة وفعلا (أي بحكم الطبيعة) إلا إذا توافر فيه شرطان : أحدهما أن يكون هذا الشيء متصلا بالأرض اتصال قرار (أي أن يكون ثابتا بالأرض مستقرا في حيزه)، وثانيهما ألا يمكن نقله من مكانه دون تلف.

ثانيا :العقارات بالتخصيص :

يُعَدُ عقاراً بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه صاحبُه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله (م٢/٨٢ مدني).

إذن فالعقارُ بالتخصيص هو في حقيقته منقولٌ يضفي عليه واضعُ القانون وصفَ العقارَ حكماً على سبيل الحيلة والافتراض [١] ليجري عليه أحكام العقار الحقيقي الذي رصد هذا المنقول لخدمته أو استغلاله من جانب مالك العقار ، فيضمنُ بذلك بقاءَه مرصوداً لخدمة هذا العقار أو لاستغلاله، ويتجنب مخاطر إقصائه عن هذا الغرض نتيجة لتطبيق أحكام المنقول عليه، الأمر الذي يؤدي إلى فصله عن هذا العقار فيعطل الغرض الذي قصد من رصده له.

---

[١] انظر في نفس المعنى أ.د / حسن كيره إذ يقول سيادته "إن فكرة العقار بالتخصيص هي مجرد افتراض أو حيلة قانونية يقيمها المشروع للتوصل إلى ترتيب أحكام العقار على ما يتبعه من منقولات مرصودة على خدمته أو استغلاله" بند ٣٦٩، ص ٧١٠ .

ولعل من أمثلة العقارات بالتخصيص المواشي المخصصة لزراعة الأرض وآلات الزراعة والحرث ،والأثاث اللازم لتشغيل الفندق، والأجهزة والآلات اللازمة لتشغيل المصنع ،والأرفف والأخشاب المخصصة لعرض البضائع والسلع في المحلات التجارية.

ويظهر مما سبق أنه يلزم لكي يكتسب المنقول الوصف الحكمي للعقار (أي لكي يعد عقارا حكما وافتراضا لا حقيقة وفعلا) أن يتوافر فيه هذان الشرطان:-

١-الشرط الأول :وجود منقولات طبيعية مخصصة لخدمة العقار أو استغلاله:

لا جرم أن إضفاء الوصف الحكمي للعقار على شيء ما يقتضي حتماً أن يكون هذا الشيء في ذاته أو أصله منقولاً بطبيعته ، هذا فضلا عن ضرورة رصده أو تخصيصه لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته .

ومن ثمَّ فإنه إذا رصد المنقول لخدمة عقار بالتخصيص أو لخدمة منقول بحسب المآل فلا يعدُ عقاراً بالتخصيص، فأدواتُ السيارة المخصصة لإصلاح السيارة لا تعدُ عقاراتٍ بالتخصيص لأنها منقولاتٌ مخصصةٌ لخدمة منقول آخر، كما أن الزيوت التي تخصص لشحم آلات المصنع لا تعد عقاراً بالتخصيص لأنها منقول رصد لخدمة عقار بالتخصيص ولم يرصد لخدمة عقار بطبيعته، كما أن رصد آلات وأدوات مثل الفأس والمنشار لاستخلاص منقولات منزل جرى بيعه أنقاضاً بقصد هدمه لا يكسبها وصف العقارات بالتخصيص لأنها منقولات رصدت لخدمة منقول بحسب المآل وليس لخدمة عقار بطبيعته [١].

---

[١] أ.د عبد الناصر العطار بند ٢٥٠،ص٤٨٨ .

ويلزم في تخصيص المنقول أن يكون تخصيصا عينياً لا شخصياً بمعنى أن يكون هذا التخصيصُ لخدمة العقار وليس لخدمة مالك العقار، ومن ثَمَّ لا يصدقُ وصفُ العقار بالتخصيص على الدابة التي يستعملها مالك الأرض للانتقال عليها شخصياً من أرضه إلى منزله أو الماشية التي يربيها مالك الأرض للتسمين أو للاستفادة من انتاجها من اللبن وغيره، في حين يصدق وصف العقار بالتخصيص على الماشية أو الدواب التي ترصد لخدمة العقار أو استغلاله [١].

ولا يلزم في التخصيص أن يكون مؤبداً أو دائماً، ولكن يكفي أن يكون متسماً بطابع الثبات والاستقرار ،فلا يكون عارضاً فيجري رصدُه لخدمة العقار واستغلاله لفترة مؤقتة أو لمدة قصيرة وإلا زالت عنه صفتُه بوصفه عقاراً بالتخصيص بزوال أو انقطاع رصده أو تخصيصه لخدمة هذا العقار أو استغلاله.

ولا يلزم أن يكون المنقولُ ضرورياً (أي لا غناء عنه) لخدمة العقار أو استغلاله ،وإنما يكفي أن يعود على هذا العقار قدرٌ من النفع أو الفائدة نتيجة لرصد المنقول لخدمته أو استغلاله ،هذا مع مراعاة تجنب الإسراف في إضفاء وصف العقار بالتخصيص على كل ما يوجد بالعقار من منقولات طبيعية ترصد له رغم انعدام فائدتها أو نفعها بالنسبة له، ومن ثَمَّ إذا قام صاحب مصنع بوضع العديد من الآلات بمصنعه فلا يعد عقاراً بالتخصيص منها إلا تلك الآلات التي تفيد فعلاً في خدمة المصنع أو استغلاله (سواء عظمت أو صغرت قيمة ومقدار هذه الفائدة التي تعود على المصنع منها) أما التي تنعدم أو تكاد تتلاشى فائدتها عن خدمة المصنع أو استغلاله فلا تعد عقارا بالتخصيص [٢].

---

[١] وكذلك الحال إذا خصص صاحب المصنع أو الفندق سيارة لخدمته وليس لخدمة المصنع أو الفندق فلا يصدق عليها وصف العقار بالتخصيص ، بخلاف الحال لو تم رصدها لخدمة المصنع أو الفندق فعندئذ يصدق عليها وصف العقار بالتخصيص باعتبارها منقولا مرصودا لخدمة عقار بطبيعته .

[٢] انظر في نفس المعنى :أ.د / عبد الناصر العطار بند ٢٥٠،ص ٤٨٩ .

ويستوي بعد ذلك أن يجري تخصيصُ المنقول بطبيعته لأجل خدمة العقار أو لأجل استغلاله ، إذ يثبتُ له في كلتا الحالتين الوصفُ الحكمي للعقار فيعدُ عقاراً بالتخصيص ،ولعل من أمثلة المنقولات التي ترصد لخدمة العقار ما يوضع في دور العبادة لخدمتها من سجاد ومقاعد وكتب ،ومن أمثلة المنقولات التي تخصص لاستغلال العقار ما يوضع في الفندق من أثاث ومفروشات ،وما يوضع في المصنع من آلات ومعدات وسيارات مخصصة لنقل المواد الأولية أو المواد المصنوعة [1].

الشرط الثاني :أن يكون مالك المنقول هو نفسه مالك العقار:

لا يكفي لإضفاء وصف العقار بالتخصيص على المنقولات الموجودة بالعقار مجرد تخصيصها لخدمة أو استغلاله، وإنما يلزم إلى جانب ذلك أيضا أن يكون مالك هذه المنقولات هو نفسه مالك العقار ، وذلك حتى يصح صدور التخصيص من جانبه، إذ لا يصدق وصف العقار بالتخصيص على المنقولات التي توضع بالعقار لخدمته أو استغلاله إذا كان مالك هذه المنقولات غير مالك للعقار ، ومن ثمَّ لا يصدق وصف العقار بالتخصيص على المنقولات المملوكة للمستأجر أو صاحب حق الانتفاع أو الدائن المرتهن رهن حيازة رغم رصدها لخدمة العقار ، نظرا لأن مالك هذه المنقولات ليس مالكا للعقار، فمالك العقار هو المؤجر أو صاحب حق الرقبة أو الراهن (مدينا كان أو كفيلا عينيا) وهو شخص آخر غير مالك المنقولات .

ويكفي ثبوت ملكية العقار لمالك المنقول أيا كانت طبيعة ملكيته لهذا العقار، إذ يستوي بعد ذلك أن تكون ملكيته ملكية تامة أو ملكية ناقصة (كما لو كان مالكا لحق الرقبة وحده) كما يستوي أن تكون هذه الملكية ملكية مفرزة أو

---

[1] انظر في نفس المعنى :أ.د / حسن كيره بند ٣٦٩، ص ٧١٢ .

ملكية شائعة، وأخيراً يستوي أن تكون ملكية مؤكدة أو ملكية مهددة بالزوال بقابلية السند الناقل لها للبطلان أو الفسخ [١].ويتم تخصيص المنقولات لخدمة العقار أو استغلاله عن طريق المالك شخصيا أو عن طريق نائبه الذي يعمل لحسابه مثل وكيله أو وصيه أو القيم عليه.

ومتى توافر الشرطان السابقان اكتسبت المنقولات المرصودة لخدمة العقار أو استغلاله وصف العقار حكما وجرت عليها على إثر ذلك أحكام العقار فتعامل معاملة العقار الأصلي المخصصة لخدمته أو استغلاله، ومن ثم لا يجوز الحجز عليها استقلالاً عن العقار المرصودة لخدمته أو استغلاله، وإذا تم بيع العقار أو رهنه امتد البيع أو الرهن ليشمل إلى جانب هذا العقار ما يعد من ملحقاته من عقارات بالتخصيص دون حاجة إلى اتفاق أو نص [٢].

المطلب الثالث

المنقولات Les meubles

تمهيد :

---

(١) انظر في نفس المعنى :أ.د / عبد الناصر العطار بند ٥٠،ص ٤٨٧، ومع ذلك يرى جانب من الفقه أنه إذا ألحق مالك العقار على الشيوع المنقول بالعقار أضحى المنقول عقارا بالتخصص تحت شرط فاسخ ، فاذا وقع العقار بعد القسمة في نصيب هذا المالك تخلف الشرط الفاسخ و بقى المنقول عقارا بالتخصيص على وجه بات ،أما إذا وقع العقار في نصيب مالك آخر فإن الشرط الفاسخ يتحقق فينتهي الإلحاق وينفصل المنقول عن العقار ويعود المنقول لصاحبه، وينطبق نفس الحكم على مالك العقار تحت شرط فاسخ، فإذا تخلف انفسخ الإلحاق وانفصل المنقول عن العقار وعاد لصاحبه، وإذا كان مالك المنقول مالكا تحت شرط واقف فإن المنقول لا يصبح عقارا بالتخصيص إلا عند تحقق الشرط (أ.د/ السنهورى ص٤٤ وما بعد، مشار إليه لدى د/ محمد سعد خليفة ص ٢٨٥) .

(٢) حيث تنص المادة ١٠٣٦ مدنى على أن "يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصص...."، كما تنص المادة ٤٣٢ مدنى على أن يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين " وبالتالى فإن بيع العقار يشمل إلى جانب العقار ذاته ما يعد من ملحقاته من المنقولات المرصودة لخدمته أو استغلاله أيضا .

لم يضع واضع التقنين المدني المصري تعريفاً للمنقول –بعكس موقفه من العقار –غير أنه بعد أن عرف العقار اعتبر كل ما عدا العقار من قبيل المنقولات، ومن ثَمَّ يمكننا تعريف المنقول بأنه "كل شيء غير متصل بالأرض اتصال قرار ويمكن نقله من مكانه دون تلف"، أو "هو كل شيء غير مستقر وغير ثابت في حيزه فيسهل –من ثم–نقله من مكان لآخر دون تلف" .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المدني المصري لم يقصر وصف المنقول على الأشياء التي تعد منقولات بحكم طبيعتها وحقيقتها، ولكنه مد ظلال هذا الوصف ليضم –إلى جانب المنقول بطبيعته – أشياء أُخر، هي في ذاتها وأصلها من قبيل العقارات بطبيتعها ، خالعاً عليها وصف المنقول على خلاف طبيعتها – أي على الرغم من عدم توافر مقومات المنقول وأوصافه فيها– كما هو الحال في المنقولات بحسب المآل والمنقولات المعنوية.

أولا: المنقولات بالطبيعة:

يقصد بالمنقول بحكم الطبيعة Meuble par nature ذلك الشيء المادي غير المتصل بالأرض اتصال قرار والذي يمكن نقله من مكانه دون تلف أو هو الشيء المادي غير المستقر وغير الثابت في حيزه بصورة تسمح بنقله من مكان لآخر دون تلف.

ولا يلزم كما يرى البعض –وبحق– لإضفاء وصف المنقول الطبيعي أو الفعلي على الشيء ضرورة تحقق الانتقال الفعلي فيه، وإنما يكفي مجرد قابلية الشيء للحركة والنقل من مكانه دون تلف، حتى ولو لم ينقل منه بأن كان معدا للبقاء في مكان معين كما هو الحال بالنسبة للعائمات الراسية على ضفاف الأنهار، وأكشاك الأسواق والمعارض، فالعبرة ليست بانتقال الشيء حقيقة وفعلا من مكان لآخر لاكتسابه وصف المنقول الطبيعي أو الفعلي، ولكن العبرة بقابليته للانتقال

والحركة حتى وإن كان ثابتا في مكان معين [1] .

ولعل من أمثلة المنقولات بحكم الطبيعة الحيوانات، والسيارات، والقطارات، والسفن، والطائرات، والمأكولات، والمشروبات، والبضائع، والكتب، والنقود، والمحاصيل والثمار بعد جنيها من الأرض أو فصلها منها، وخيام البدو الرحل، وخيام الكشافة، والغاز والكهرباء..... إلخ.

ثانيا: المنقولات بحسب المآل:

يقصد بالمنقولات بحكم المآل Meubles par anticipation الأشياء التي تنطبق عليها أوصاف العقارات حقيقة وفعلا – أي بحكم طبيعتها– ولكن يتدخل القانون على سبيل الحيلة والافتراض فيخلع عليها وصف المنقول بحكم مصيرها المحتوم الذي ستؤول إليه في القريب العاجل .

فالمنقولات بحكم المآل هي في حقيقتها عقارات بحكم طبيعتها، وكان من مقتضى منطق الأمور أن يعدها القانون من قبيل العقارات بالطبيعة ويجرى عليها– من ثم–أحكام هذه العقارات مراعاة لحقيقتها الحاضرة وطبيعتها الحالية .

غير أن القانون رغبة منه في التيسير على الأفراد(لاسيما وأنه عادة ما يغلب على الإجراءات المتبعة بشأن العقارات طابع البطء، إلى جانب طابع الصعوبة والتعقيد سواء عند التصرف فيها بأي صورة من صور التصرف أو عند الحجز عليها، بعكس الإجراءات المتبعة في المنقولات إذ يغلب عليها طابع السرعة فضلا عن السهولة واليسر في مباشرتها سواء عند التصرف فيها أو التنفيذ عليها) تجاهل الطبيعة العقارية الحاضرة الثابتة لهذه الأشياء وأخذ بطبيعتها المنقولة المستقبلة التي ستؤول إليها في القريب العاجل .

---

[1] انظر في ذلك إلى: أ.د/ حسن كيره بند ٣٧١، ص ٧١٤ هامش ٢، وفي نفس المعنى: أ.د/ عبد الرزاق السنهوري ص ٧٩، د/ محمد سعد خليفة، ص ٢٨٩ .

ولعل من أمثلة هذه المنقولات بحسب المآل الأشجار أو النخيل المعدة للقطع ، والمباني المعدة للهدم، والثمار والمحاصيل المعدة للجني أو القطف، والمعادن والأحجار المعدة للاستخراج أو الاقتطاع من المناجم أو المحاجر إلى غير ذلك من الأشياء التي ستتحول بحكم طبيعتها أو باتفاق الأفراد من أشياء ثابتة ومستقرة بالأرض لا يمكن نقلها من مكانها دون تلف (أي بوصفها أشياء عقارية بحكم الطبيعة) إلى أشياء غير ثابتة في الأرض ويمكن نقلها وتحريكها من مكان لآخر دون تلف في القريب العاجل، فتأخذ وصف المنقول ويجري عليها حكمه مراعاة لمآلها الذي ستنتهي إليه.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن واضع التقنين المدني المصري لم يضع قاعدة عامة يمكن التعويل عليها في إضفاء وصف المنقول بحكم المآل على بعض العقارات، إلا أن الفقه والقضاء استخلصا ، من بعض النصوص القانونية الخاصة (عامل فيها القانون بعض العقارات المعدة للانفصال عن أصل ثباتها واستقرارها معاملة المنقول [1] ، مراعيا في ذلك طبيعتها المستقبلة التي ستؤول إليها لا طبيعتها الحاضرة التي هي عليها)، نظرية عامة مؤداها أن بعض العقارات تعد من قبيل المنقولات بحكم المآل إذا كانت إرادة المتعاقدين تنظر إليها بحسب ما ستؤول إليه في المستقبل القريب الذي تتحول فيه إلى منقولات بالطبيعة نتيجة

---

(1) فمثلا نجد أن واضع تقنين المرافعات المدنية والتجارية الجديد ينص على إتباع إجراءات حجز المنقول بالنسبة للثمار المتصلة وبالنسبة للمزروعات القائمة على الرغم من كونها عقارات بطبيعتها مراعيا في ذلك طبيعتها المستقبلة التي ستؤول إليها بعد فصلها ومتجاهلا طبيعتها العقارية الحاضرة، حيث وردت المادة ٣٥٤ مرافعات في الفصل الأول تحت عنوان "التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه" من الباب الثالث الخاص بالحجوز التنفيذية" حيث تنص هذه المادة على أنه"لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما" .

هذا بالإضافة إلى أن واضع القانون المدني الجديد قد نص في المادة ١/١١٤٢ مدني على أن يعتبر من قبيل الامتيازات الخاصة الواقعة على المنقول "امتياز المبالغ المنصرفة في البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ،ويكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة" على الرغم من أن المحصول قبل فصله عن الأرض يعد عقارا بطبيعته .

لفصلها من أصل ثباتها.

وبناء عليه يلزم لاعتبار الشيء منقولاً بحكم المآل توافر هذين الشرطين:-

١-الشرط الأول:

وجوب انصراف إرادة العاقدين بطريقة جدية إلى فصل الشئ من أصل ثباته واستقراره ، ومن ثمَّ تنصرف النية المشتركة للعاقدين يقيناً إلى إعداد وتهيئة هذا الشيء المتصرف فيه ليتحول في القريب العاجل من طبيعته العقارية إلى طبيعته المنقولة بفصله فعلا عن أصل ثباته واستقراره فإنه لا يعد منقولا بحكم المآل ، بل يبقى على وصفه باعتباره عقاراً بحسب طبيعته ، ولذلك فإن مجرد بيع البناء المقام على أرض استقلالاً عن هذه الأرض لا يعد قرينة على انصراف الإرادة إلى تصيير هذا البناء وتحويله إلى منقول بالطبيعة، ما لم تكن نية البائع والمشترى قد انصرفت فعلاً إلى بيعه بوصفه بناءً معداً للهدم أي باعتباره أنقاضاً بحسب المآل.

٢-الشرط الثاني:

إن يكون انفصالُ هذا الشيء العقاري عن أصل ثباته واستقراره محققَ الوقوع في وقت قريب، وإلا انتفت الحكمة من إضفاء وصف المنقول بحكم المآل عليه رغم طبيعته العقارية.

فالمصيرُ المستقبلي المحتومُ الذي ستؤول إليه بعضُ العقارات الحقيقية أو الفعلية (أي العقارات بحكم الطبيعة) في القريب العاجل والذي ستصير بعده منقولات بحكم الطبيعة، هو الذي حدا بواضع القانون إلى إجراء أحكام المنقول عليها(والتي يغلب عليها طابعُ السرعة واليسر) بدلاً من أحكام العقار (التي يغلبُ عليها طابعُ البطء والتعقيد) رغبةً في التيسير على الأفراد، أما إذا كان انفصالُ الشيء العقاري عن أصله وتحوله إلى الطبيعة المنقولة في المستقبل أمراً احتمالياً أو لا يمكنُ تحققُه إلا بعد زمن طويل، فعندئذ لا يمكنُ أن نعده منقولاً بحكم المآل

ويظلُ محتفظاً بوصفه عقاراً بحكم الطبيعة.

وعلى أية حال فإن قُرْبَ أو بُعْدَ الوقت المستقبلي الذي سيتحقق الانفصالُ عن أصل الشيء خلاله ليصيرَ بعده منقولاً بحكم الطبيعة يُعَدُ مسألةً من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع فيقضي فيها بحسب ظروف هذا الواقع وملابساته [١].

فإذا توافرَ هذان الشرطان خضعَ الشيء العقاري بحكم الطبيعة لأحكام المنقول رغم طبيعته العقارية باعتباره منقولاً بحسب المآل منذ إبرام العقد بشأنه،فلا يلزم لنقل ملكيته ضرورة تسجيل التصرف، كما يجري إتباع إجراءات حجز المنقول بشأنه وليس إجراءات التنفيذ على العقار، كما ينعقد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة موطن المدعى عليه.

ثالثا: المنقولات المعنوية:

يرى البعض–وبحق–أن الأشياء المعنوية لا يمكن إدراجها ضمن المنقولات أو العقارات كأصل عام، على أساس أن تقسيم الأشياء إلى منقولات وعقارات يعتمد على مدى قابلية الأشياء للنقل والحركة أو عدم قابليتها لذلك واتسامها – من ثم – بعنصر الثبات والاستقرار، وهو ما لا يتصور إلا في الأشياء المادية وحدها، بيد أنه خروجا على هذا الأصل يجري اعتبار الأشياء المعنوية من قبيل المنقولات حكماً فتخضع لأحكام المنقول، بحجة أن واضع القانون قد اعتبر كل ما ليس بعقار من قبيل المنقول، والأشياء المعنوية لا تعد من قبيل العقارات قطعا، لذلك فهي تعد بمفهوم المخالفة من قبيل المنقول [٢].

---

[١] انظر في نفس المعنى:أ.د/ نعمان جمعة ص ٥٤٠ .

[٢] انظر في ذلك: أ.د/ حسن كيره بند٣٧٣، ص ٧١٨ .

المبحث الرابع

الأشياء المثلية والأشياء القيمية

يقصد بالأشياء المثلية Choses ou biens fongibles تلك الأشياء التي لها في الأسواق أشباهٌ ونظائرٌ بحيث يقومُ بعضُها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن [1].

أو هي الأشياء التي لا يختلف فيه آحادها عن بقيتها اختلافا يعتد به عند الوفاء ، بحيث يقوم بعضه مقام بعض في الوفاء وإن اختلفا .

فالأشياءُ المثليةُ حسبما يبدو من ظاهر مسماها أشياءٌ متماثلةٌ لا تتفاوتُ في آحادها تفاوتاً يعتدُ به عند التعامل، وهي تقدرُ عادةً عند التعامل بالعد مثل النقود والبيض من نوع واحد، وقد تقدرُ بالمقاس مثل أمتار القماش من ثوب واحد، وقد تقدرُ بالكيل مثل القمح وغيره من الحبوب من نفس الصنف أو الجودة، وقد تقدرُ بالوزن مثل البرتقال من صنف واحد.

أما الأشياءُ القيميةُ Choses ou biens non fongibles فهي تلك الأشياءُ التي لا تتماثلُ فيما بينها وإن تشابهتْ بحيث تتفاوتُ في آحادها تفاوتاً يعتدُ به عند الوفاء ، ومن ثمَّ لا يقومُ بعضُها مقام بعض عند التعامل.

فالشئ القيمي شئٌ معينٌ بذاته لا يماثلُه شيءٌ آخرٌ، نظرا لتفاوتهما رغم التشابه على نحو يعتدُ به عند التعامل بحيث لا يصلحُ أن يقومَ أحدُهما مقام الآخر عند الوفاء، مثال ذلك الأرض، والمنازل، والسيارت المستعملة، والحيوانات، واللوحة

---

[1] إذ تنص المادة ٨٥ مدني على أن "الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن" .

الفنية المرسومة ،والثوب من القماش الذي تمت حياكته لشخص معين، فعندما يتعاملُ الشخصُ على شراء أحد هذه الأشياء القيمية فلا يمكنُ أن يقومَ أحدُهما مقام الآخر عند الوفاء، فلا يجزئ غير الشيء المعين بذاته كشيء قيمي عند الوفاء .

فمن يشتري مثلاً شقةً معينةً في مدينة معينة وشارع محدد وعمارة تحملُ رقماً معيناً لا يمكنُ أن تقومَ مقامَها شقةٌ أخرى مختلفة عنها حتى وإن كانت متشابهة معها في نفس مواصفاتها وتشطيباتها، وكذلك الحال إذا باع شخصٌ لآخر سيارةً معينةً بالذات لم يجزئه الوفاء بسيارة أخرى غيرها حتى وإن كانت مشابهة لها بل يتعين تسليمه ذات السيارة المتفق عليها في العقد.

فالمحك أو المعول عليه في وصف الشيء بأنه شيء مثلي أو شيء قيمي يكمن في مدى جواز قيام شيء آخر من جنسه ونوعه مقامه عند الوفاء به بحسب طبيعة هذا الشيء وقصد العاقدين أو عدم جواز ذلك [١].

وتطبيقاً لذلك فقد قُضى بأن الأشياء المثلية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلا منها، والأشياء القيمية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هي عينها. وقد يكون الشيء بعينه مثليا في أحوال وقيميا في أحوال أخرى، والفصل في كونه مثليا أو قيميا يرجع إلى طبيعة هذا الشيء ونية ذوي الشأن وظروف الأحوال، فعلى أي وجه اعتبره قاضي الموضوع وبني اعتباره على أسباب مؤيدة لوجهة رأيه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك [٢] .

---

[١] مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، جـ١، ص ٤٧٤، أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٨٧ حيث يقول سيادته" ويراعى في هذا الصدد أن العبرة بقصد ذوي الشأن فقد تتجه إراداتهم إلى شيء معين بذاته فلا يتم الوفاء إلا به حتى ولو كان من المثليات. وفي هذه الحالة يكون الشيء قيميا ومعينا بذاته . كما لو اشترى شخص كل القمح الموجود في مخزن من المخازن. فهنا لا تبرأ ذمة البائع إلا بالوفاء بما التزم به، وهو القمح الموجود بالمخازن" .

[٢] نقض مدني مصري ١٩٣٣/١١/٢٣ م، مجموعة المكتب الفني في ٢٥ عام، ج١، ص ٣٠٠ .

وتتجلى أهمية التفرقة بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية في الأمور الآتية:-

أولا: من حيث انتقال الملكية:

تنتقل ملكيةُ المنقول القيمي بوصفه شيئاً معيناً بالذات بمجرد التعاقد طالما أنه مملوكٌ للمتصرف [1]، في حين أن ملكية المنقول المثلي لا تنتقل بمجرد العقد وإنما يلزم إلى جانب ذلك إفرازها سواء بالكيل أو الوزن أو المقاس أو العدد تبعا لطبيعة هذا المنقول المثلي.

ثانيا: من حيث الوفاء:

إذا كان محل الالتزام أن يسلم المدين لدائنه شيئا مثليا، صح الوفاء منه بتسليمه أي شيء من نفس نوع هذا الشيء بالمقدار المتفق عليه في العقد، فمثلا إذا التزم شخص بأن يسلم آخر مائة أردب من القمح المصري أجزأه في ذلك أن يقدم أي مائة أردب من هذا القمح المصري.

بعكس الحال إذا كان الشيء قيميا إذ لا يصح الوفاء إلا بذات الشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول شئ آخر غيره ولو كان مساويا له في القيمة أو مشابها له في المواصفات أو حتى أفضل منه، فمثلا لو أن شخصا اشترى من آخر شقة معينة في دور معين من أدوار عمارة معينة، يتعين عليه تسليمه هذه الشقة بعينها ولا يجبر هذا المشتري على قبول شقة أخرى غيرها ولو كانت مماثلة لها أو حتى أفضل منها.

ثالثا : من حيث المقاصة:

---

[1] وتطبيقا لذلك تنص المادة ٢٠٤ من التقنين المدني الحالي على أن "الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل" .

لا تجوزُ المقاصةُ إلا في الأشياء المثلية المتحدة من حيث النوع والجودة، فعندما يكون الشخص مدينا بنقود أو بشيء آخر مثلي لآخر ،يكون من حقه أن يجري مقاصة بين ما عليه تجاهه وما هو مستحق له عنده من نقود أو مثليات من ذات النوع والجودة، وبناء على ذلك لا تجري المقاصة في الأشياء القيمية.

رابعا:من حيث الهلاك:

إذا كان محلُ الالتزام شيئاً قيمياً ثم هلك هذا الشيء القيمي، انقضى التزامُ المدين بتسليمه للدائن وبرأت ذمتُه لاستحالة تنفيذ الالتزام به، كما لو التزام البائع بتسليم المشتري منزلاً معيناً فتهدم هذا المنزل قبل تسليمه لسبب أجنبي عنه ، فعندئذ تبرأ ذمةُ البائع من الالتزام بتسليمه لاستحالة تنفيذه، بخلاف الحال لو كان محلُ الالتزام شيئاً مثلياً فإن هلاك هذا الشيء المثلي لا يؤدي إلى انقضاء الالتزام به ولا تبرأ ذمة المدين إلا بتقديم شيء آخر مثله كبديل عنه، نظرا لأن الأشياء المثلية تقوم مقام بعضها البعض عن الوفاء فلا يستحيل تنفيذ الالتزام بشأنها بسبب الهلاك .

وبناء عليه إذا التزمَ شخصٌ بتسليم كمية من الفاكهة إلى آخر من نوع معين كمائة كيلو من التفاح الفرنسي فإن هلاكها عنده قبل أن يسلمها إلى الدائن لا يؤدي إلى انقضاء التزامه بها في مواجهته وإنما يتعين عليه تقديم غيرها من نفس النوع والصنف بدلاً من الكمية التي هلكت لأن التفاح الفرنسي كشئ مثلي يمكن أن يقوم مقام بعضه البعض عند الوفاء.

المبحث الخامس

الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك

يقصد بالأشياء القابلة للاستهلاك Choses ou biens consomptibles تلك الأشياء التي لا يتحقق استعمالها والانتفاع بها إلا عن

طريق استهلاكها وإفنائها أو هي الأشياء التي تستهلك من أول استعمال يرد عليها، بحيث لا يتصور أن تكون محلا للاستعمال المتكرر [١] .

ولعل هذا المعنى هو الذي أشارت إليه المادة ١/٨٤ مدني بقولها" الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها".

وجدير بالذكر أن استهلاك الشيء بوصفه أثراً حتمياً لاستعماله والانتفاع به قد يكون استهلاكا حقيقيا وفعليا سواء أكان ذلك عن طريق اختفاء مادة هذا الشيء والقضاء عليها كأكل الطعام (ذلك إن استعماله والانتفاع به يؤدي إلى فنائه والقضاء عليه) أم عن طريق تغيير صورتها مثل تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنوعة مثل المنسوجات والسجاد وغيرهما، وقد يكون استهلاكاً حكمياً أو افتراضياً لا تفنىَ فيه مادةُ الشيء ولا تتغير صورتُها ولكن يفترض حكما هذا الاستهلاك نتيجة لانتقال ملكية الشيء من صاحبه إلى شخص آخر غيره فيفنى حكما وافتراضا بالنسبة له لخروجه من ملكه وإن بقي موجودا بالنسبة لغيره [٢] مثال ذلك النقود .

أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك Choses ou biens non consomptibles فهي تلك الأشياء التي لا تفنى من أول استعمال لها (وإنما تقبل ورود الاستعمال المتكرر عليها) حتى وإن ترتب على تكرار الاستعمال أو طول

---

[١] انظر في نفس هذا المعنى إلى:أ.د/ حسن كيره بند ٣٧٤، ص ٧١٨، أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٨٥، أ.د/ عبد الناصر العطار بند ٢٥٦، ص ٤٩٥، أ.د/ نعمان جمعة ص ٥٤٣، د/ محمد سعد خليفة ٢٩٦، د/ حمدى محمد عطيفي ص ١٨٥ .

[٢] انظر في نفس المعنى إلى : أ.د/ حسن كيره بند ٣٧٤، ص ٧١٨، أ.د/ توفيق حسن فرج ص ٢٨٥، أ.د/ عبد الناصر العطار بند ٢٥٦، ص ٤٥٩، أ.د/ نعمان جمعة ص ٥٤٣، د/محمد سعد خليفة ٢٩٦، د/ حمدي محمد عطيفي ص ١٨٥ .

مدته إضعافه أو إنقاص قيمتها مثل السيارات والمنازل والملابس [١].

وينبغي التنويه إلى أنه وإن كان الأصل العام أن طبيعة الشيء هي التي تحدد مدى قابلية أو عدم قابلية هذا الشيء للاستهلاك، إلا أنه من المتصور أن يكون لإرادة الأفراد أو واضع القانون دخل في تحديد مدى قابلية أو عدم قابلية هذا الشيء للاستهلاك خلافا لما أعد له أصلا بحسب طبيعته، مثال ذلك أن النقود كما سبق أن عرفنا تعد من الأشياء القابلة للاستهلاك وذلك نظراً لأنها تهلك حكماً بالنسبة لصاحبها بمجرد انتقال ملكيتها إلى غيره وخروجها من حوزته، إلا أنه من الممكن أن تتحول إلى شيء غير قابل للاستهلاك بناء على إرادة الفرد إذا ما أعدها للعرض في معرض أو معارض متتالية [٢] .

كما أن البضائع المعدة في المتاجر للبيع منها ما لا يهلك بالاستعمال لأول مرة مثل الثلاجات والأفران والأجهزة الكهربائية والملابس ومن ثمَّ فهي بحسب طبيعتها أشياء غير قابلة للاستهلاك، ٨٤/ ٢ مدني [٣]، على أساس أنها وإن كانت لا تفنى حقيقة وفعلا ببيعها إلا أنها تفنى حكما وافتراضا بخروجها من ملك صاحبها وانتقال ملكيتها إلى غيره.

وتبدو أهمية التفرقة بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك في الأمور الآتية:.

أولاً: إن بعض الحقوق لا يتصور ورودها إلا على أشياء غير قابلة للاستهلاك مثل حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الارتفاق، وذلك نظرا لما تقتضيه طبيعة هذه الحقوق من ضرورة رد الشيء الوارد عليه الحق إلى صاحبه بعد انتهاء مدته.

---

[١] انظر في نفس المعنى : أ.د/ نبيل إبراهيم سعد –المرجع السابق–ص ٢٦٠ .

[٢] انظر في ذلك إلى: مجموعة الأعمال التحضيرية ج١ ص ٤٧٢ .

[٣] إذ تنص المادة ٨٤/ ٢ مدني على أن "فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع" .

ثانيا: إن بعض العقود لا يمكن أن تبرم إلا بشأن أشياء غير قابلة للاستهلاك مثل عقد الإيجار وعقد العارية، فهما عقدان لا يتصور إبرام أي منهما إلا على شيء غير قابل للاستهلاك، نظرا لأن المستأجر أو المستعير– بحسب طبيعة أي من هذين العقدين– يلتزم برد الشيء بعد انتهاء مدة الإيجار أو العارية إلى مالكه، لذلك وجب أن يكون من الأشياء غير القابلة للاستهلاك.

الفصل الثاني

الأعمــال Les actions

لا جرم أن محل الحق قد يكون شيئا وقد يكون عملا وذلك تبعا لطبيعة هذا الحق ونوعه.

وإذا كانت الحقوق العينية أو الحقوق الذهنية ترد على الأشياء (إذ ترد الحقوق العينية –سواء أكانت حقوقا عينية أصلية مثل حق الملكية أم حقوقا عينية تبعية مثل حق الرهن الرسمي – على أشياء مادية معينة بالذات، وترد الحقوق الذهنية على أشياء معنوية لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالعقل فقط) فإن الحقوق الشخصية هي وحدها التي ترد على الأعمال.

فالحق الشخصي يرد عادة على أداء معين يلتزم به المدين في مواجهة دائنه، هذا الأداء يتخذ دائما أحد هذه المظاهر الثلاثة الآتية:فقد يكون هذا الأداء عبارة عن عمل معين يتعهد المدين بالقيام به وتنفيذه لصالح شخص معين، مثل التزام المقاول ببناء عمارة سكنية معينة لصالح شخص معين أو التزام المحامي برفع دعوى معينة لصالح موكله، ويطلق على مثل هذا الالتزام وأمثاله في اصطلاح الفقهاء اسم الالتزام بعمل L’obligation de faire ،وقد يكون هذا الأداء في صورة امتناع عن عمل معين، وعندئذ يتعهد المدين بعدم القيام بعمل معين في مواجهة دائنيه، مثل التزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل مماثل في ذات المنطقة الكائن بها المحل المباع، والذي يطلق عليه في الفقه اصطلاح الالتزام بالامتناع عن عمل L’oligation de ne pas faire.

وأخيرا قد يكون هذا الأداء في صورة التزام بإعطاء أي أن يلتزم المدين بنقل أو إنشاء حق عيني لصالح دائنه، مثال ذلك أن يلتزم بائع العقار بالقيام بكل ما هو ضروري لنقل ملكية العقارات للمشترى (نظرا لأن ملكية العقارات لا تنتقل

بمجرد التراضي وإنما يلزم إلى جانب ذلك إجراء التسجيل ، لهذا العقد) كأن يقدم المستندات التي تثبت ملكيته لهذا العقار ويقوم بالتوقيع على العقد النهائي أمام الموظف المختص، ويطلق الفقه على هذا الالتزام اصطلاح الالتزام بإعطاء.L'obligation de donner [1].

وينبغي في العمل الذي يمثل محلا للحق الشخصي سواء أكان عملاً إيجابياً (أي في صورة التعهد أو الالتزام بعمل) أم عملاً سلبياً (أي في صورة التعهد أو الامتناع عن عمل) أن يكون ممكناً، وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون عملاً مشروعاً أي غيرَ مخالف للنظام العام أو الآداب، وذلك على التفصيل الآتي:-

أولا :الشرط الأول: أن يكون العمل ممكناً.

لا شك أنه يلزم لصحة الالتزام أن يكون العملُ محلُ الالتزام ممكنَ التنفيذ، ولذا إذا كان الالتزامُ وارداً على عمل يستحيل تنفيذه،كان التعهدُ أو الالتزام به باطلا، وتطبيقا لذلك تنص المادة ١٣٢ مدني على أنه"إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا".

بيد أنه يلزم في الاستحالة التي تبطل الالتزام أن تكون استحالة مطلقة Impossibilité absoblue أي راجعة إلى ذات الأداء المكلف به المدين سواء أكان عملا أم امتناعا عن عمل على نحو يستحيل معها على المدين أو على غيره من الناس القيام بتنفيذه، مثال ذلك أن يلتزم مقاول بهدم عمارة قد تهدمت فعلا أو أن يلتزم شخص بتسليم سيارة باعها لغيره رغم هلاكها قبل إبرام العقد معه، أو

---

[1] ويرى جانب من الفقه-وبحق- أن الالتزام بإعطاء يعد في حقيقته التزاما بعمل، ومن ثم فإن الأداء الذي يلتزم به المدين كمحل للحق الشخصي إما أن يكون التزاما بعمل أو التزاما بالامتناع عن عمل(انظر في ذلك إلى: أ.د/ أنور سلطان"النظرية العامة للالتزام" ج١ مصادر الالتزام، ص ١٩١، طبعة عام ١٩٦٥ دار المعارف .

أن يلتزم المحامي باستئناف حكم نهائي بعد فوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف.

أما إذا كانت الاستحالة نسبية أي يستحيل معها على المدين وحده فقط دون غيره من الناس تنفيذ العمل المكلف به ، فعندئذ يكون العملُ محلُ الالتزام ممكناً، ولا يكون ثمة أثرٌ لهذه الاستحالة النسبية L'impossibilité relative على صحة الالتزام بهذا العمل، مثال ذلك أن يتعهدَ شخصٌ برسم لوحة فنية وهو لا يحسنُ الرسمَ، فمثل هذا العمل وإن كان مستحيلاً بالنسبة للمدين إلا أنه عملٌ غيرُ مستحيل في ذاته إذ يمكنُ تنفيذُه وأداؤه عن طريق أشخاص آخرين غير المدين ممن يحسنون الرسم،ومن ثمَّ يصحُ التزامُ المدين به،لأنه من الممكن عن طريق استعانة المدين بذوي الخبرة تنفيذ عين ما التزام به في العقد، وإلا كان للدائن بهذا الالتزام الحق في طلب فسخ العقد فقط أو مع التعويض إن كان لذلك مقتضى.

ثانيا: الشرط الثاني: أن يكون العمل معينا أو قابلا للتعيين.

ينبغي لصحة الالتزام أن يكون وارداً على عمل معين أو قابل للتعيين، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل أو فندق أو مدرسة، فيجب أن يتم تحديد مواصفات المنزل أو الفندق أو المدرسة على نحو يكفل تعيينه كأن يذكر إلى جانب موقع المنزل أو الفندق أو المدرسة مساحة كل واحد منهم وعدد طوابق المنزل أو الفندق أو المدرسة هذا فضلا عن ضرورة بيان عدد شقق المنزل أو الفندق وعدد غرف كل شقة فيهما، وعدد فصول المدرسة، فإن لم يكن البناء في أي منهم معينا وجب على الأقل أن يكون قابلا للتعيين من خلال ظروف التعاقد وملابساته (مثل الغرض من البناء وما يلزمه من سعة) كما لو تعهد المقاول ببناء منزل يكفي لأسرة مكونة من عشرة أفراد مثلا بواقع غرفة لكل فرد أو بناء فندق يستوعب عدد محدد من النزلاء بواقع غرفة لكل اثنين من النزلاء أو أن يتعهد ببناء مدرسة تتسع لعدد معين من التلاميذ.



وإذا كان مضمون العمل بوصفه محلا للالتزام يتمثل في التزام بإعطاء شئ معين ، فينبغي إذا كان الشيء قيميا أن يكون معينا بالذات فيتم تحديده على نحو كاف وناف للجهالة بالقدر الذي يميزه عن غيره، بحيث إذا إذا كان الشئ عمارةً سكنيةً وجبَ ذكرُ موقعها ومساحتها وأوصافها ورقم الشارع الذي توجد به، وإذا كان أرضاً زراعيةً تعينَ ذكرُ موقعها ومساحتها وحدودها واسم الحوض الذي توجد به ورقمه.... إلخ أما إن كان شيئا مثليا وجب تعيينه ببيان نوعه ومقداره فإن كان قمحا فينبغي بيان نوعه ومقداره فيقال أنه قمح أمريكي مقداره١٠٠ أردبا مثلا، ويكفي في تعيين الشيء المثلي بيان نوعه ومقداره دون حاجة إلى بيان درجة جودته، على أساس أنه إذا لم يتفق الطرفان على درجة معينة من الجودة، ولم يكن من الممكن استخلاصها من العرف أو من ظرف آخر وجب على المدين تسليم دائنه شيئاً من صنف وسط(م ١٣٣/ ٢ مدني).

ثالثا: الشرط الثالث: أن يكون العمل مشروعا.

لا يكفي لصحة الالتزام أن يكون العملُ ممكناً، إلى جانب كونه معيناً أو قابلاً للتعيين، ولكن يلزم أيضا أن يكون هذا العملُ مشروعاً، ويتحققُ له هذا الوصفُ حينما لا يصطدمُ بالقواعد القانونية الآمرة، ولا يتعارضُ مع فكرة النظام العام أو الآداب العامة، وإلا كان الالتزامُ باطلاً .

وبناء عليه فإنه إذا تعهد المدينُ بعملٍ مخالفٍ للنظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع القواعد القانونية الآمرة، لم يصح التزامُه وكان باطلاً بطلاناً مطلقاً (فيجوز–من ثمَّ– لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان هذا الالتزام،بل للمحكمة أن تقضي وجوبا بهذا البطلان من تلقاء نفسها) مثال ذلك بطلان تعهد المرء بارتكاب جريمة قتل آخر مقابل مبلغ من المال أو حتى بدون مقابل أو بطلان تعهده بعدم ارتكاب جريمة قتل لقاء مبلغ معين من المال أو أن يتعهد

شخصٌ بدفع مبلغ من المال مقابل إنشاء علاقة غير مشروعة مع امرأة لا تحل له أو مقابل استمرار تلك العلاقة.



المراجـــــع

المراجـــــع

١ – أبو داود: "سنن أبي داود"، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، ضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية.

٢ – أحمد بن حنبل: "مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، بدون تاريخ نشر.

٣ – ابن حجر العسقلاني: "فتح البارى بشرح صحيح البخاري"، الطبعة الثانية عام ١٩٨٧م، دار الريان للتراث بالقاهرة.

٤ – ابن ماجة: "سنن ابن ماجة"، للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث بالقاهرة.

٥ – ابن منظور: "لسان العرب"، تحقيق عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، الناشر دار المعارف، بدون تاريخ نشر.

٦ – البيهقي: "شعب الإيمان" للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) ، الطبعة الأولى عام ١٤١٠ هـ – ١٩٩٠م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٧ – الترمذي: "سنن الترمذي"، للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى عام ١٩٨٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٨ – الدارمي: "سنن الدارمي"، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهران بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون تاريخ نشر.

٩ – الطبري: "تفسير الطبري"، الطبعة الأولى، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.

١٠– المنذري: "الترغيب والترهيب"، للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق مصطفي محمد عمارة، الطبعة الثالثة، عام ١٣٨٨ هـ – ١٩٦٨م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

١١– د/ أحمد سلامة: "المدخل لدراسة القانون"، الكتاب الأول "نظرية القاعدة القانونية"، طبعة عام ١٩٧٤م، دار النهضة العربية.

١٢– د/ أحمد كمال أبو المجد: "الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصرى"، رسالة دكتوراه، عام ١٩٦٠م، القاهرة.

١٣– د/ إسماعيل غانم: "محاضرات في النظرية العامة للحق"، طبعة عام ١٩٦٦م.

١٤– د/ توفيق حسن فرج: "المدخل للعلوم القانونية"، الطبعة الثانية، عام ١٩٨١م، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية.

١٥- د/ جميل الشرقاوي: "دروس في أصول القانون"، طبعة عام ١٩٧١م، دار النهضة العربية.

١٦- د/ حسام الدين كامل الأهوانى: "أصول القانون"، الجزء الأول، نظرية القانون، طبعة عام ١٩٨٨م.

١٧- د/ حسن كيرة: "المدخل إلى القانون"، الطعبة السادسة عام ١٩٩٣م، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية.

١٨- د/ حمدى عبد الرحمن: "مبادئ القانون"، الطبعة الأولى، عام ١٩٧٥م، دار الفكر العربى.

١٩- د/ حمدى محمد عطيفي: "دروس في مبادئ القانون"، الجزء الأول، نظرية القانون، طبعة عام ١٩٩٥م.

٢٠- د/ خالد جمال أحمد: "الوجيز في التأمينات العينية"، طبعة عام ١٩٩٨م، الناشر مكتبة ياسر بأسيوط.

٢١- د/ خالد جمال أحمد حسن : "النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني البحريني " ، طبعة ٢٠٠١م .

٢٢- د / خالد جمال أحمد حسن : " ماهية الحقوق المدنية للجنين " ، طبعة ٢٠٠٥م .

٢٣- د/ خالد جمال أحمد حسن : " مركز المفقود في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية بين الواقع والمأمول " ، طبعة عام ٢٠١١م .

٢٤- د/ خميس خضر: "المدخل للدراسات القانونية"، الجزء الأول، نظرية القانون، الطبعة الثانية، عام ١٩٨٦م، دار النهضة العربية.

٢٥- د/ رمزي الشاعر: "النظرية العامة للقانون الدستوري"، الطبعة الثالثة، ١٩٨٣م، دار النهضة العربية.

٢٦- د/ رمضان أبو السعود: "الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني"، الطبعة الثانية عام ١٩٨١م، الإسكندرية.

٢٧- د/ سعاد الشرقاوي: "النظم السياسية في العالم المعاصر"، طبعة عام ١٩٧٤ - ١٩٧٥م، دار النهضة العربية.

٢٨- د/ سعيد جبر: "المدخل لدراسة القانون"، الجزء الأول، "نظرية القانون"، طبعة عام ١٩٩٩م، دار النهضة العربية.

٢٩- د/ سليمان مرقس: "الوافي في شرح القانون المدني"، الجزء الأول، (المدخل للعلوم القانونية)، الطبعة السادسة، ١٩٨٧م، مطبعة السلام.

٣٠- د/ سمير عالية: "علم القانون والفقه الإسلامي"، نظرية القانون والمعاملات الشرعية، دراسة مقارنة، طبعة ١٩٩٢م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت.

٣١- د/ سمير عبد السيد تناغو: "النظرية العامة للقانون"، طبعة عام ١٩٧٤م، منشأة المعارف بالإسكندرية.

٣٢شحاته غريب شلقامي : " الملكية الفكرية في القوانين العربية " طبعة عام ٢٠٠٨م ، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية .

٣٣-: "التأمينات الشخصية والعينية"، طبعة عام ١٩٧٥م، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية.

٣٤- د/ شاب توما منصور: "شرح قانون العمل"، الطبعة السادسة، عام ١٩٧٧م، دار الحرية للطباعة، بغداد.

٣٥- د/ شمس الدين الوكيل: "مبادئ القانون"، الطبعة الأولى، عام ١٩٦٨م، منشأة المعارف بالإسكندرية.

٣٦- د/ عبد الباقي البكري، د/ على محمد بدير، د/ زهير البشير: "المدخل لدراسة القانون، طبعة ١٩٨٢م، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

٣٧- د/ عبد الحى حجازي: "مذكرات في نظرية الحق"، طبعة عام ١٩٥١م، مطبعة دار الكتاب العربي.

٣٨- د/ عبد الرازق يس: "المدخل لدراسة القانون"، جـ١، نظرية القانون، طبعة عام ١٩٨٩ - ١٩٩٠م.

٣٩- د/ عبد الرزاق السنهوري، أ.د/ أحمد حشمت أبو ستيت: "أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون".

٤٠- د/ عبد الرشيد مأمون : " الحق الأدبي للمؤلف " طبعة عام ١٩٧٨م ، دار النهضة العربية بالقاهرة .

٤١- د/ عبد الفتاح عبد الباقي: "نظرية القانون"، الطبعة الرابعة عام ١٩٦٥م، دار الكتاب العربى بمصر.

٤٢- د/ عبد القادر أحمد حفني: "النسخ عند الأصوليين وأثره في الأحكام الشرعية"، رسالة دكتوراه، عام ١٩٩٦م، كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف.

٤٣- د/ عبد الله مبروك النجار : " الحماية القانونية لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون " ، ط١ ، عام ١٩٩٠م ، دار النهضة العربية بالقاهرة .

٤٤- د/ عبد المنعم البدراوي: "المدخل للعلوم القانونية"، طبعة عام ١٩٦٦م، دار النهضة العربية.

٤٥- د/ عبد المنعم فرج الصدة: "أصول القانون"، طبعة عام ١٩٦٥م.

٤٦- : "نظرية الحق في القانون المدنى الجديد"، طبعة عام ١٩٥٠م.

٤٧- د/ عبد الناصر توفيق العطار: "مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية، طبعة عام ١٩٧٩م، مطبعة السعادة بالقاهرة.

٤٨- د/ عبد الودود يحيى: "المدخل لدراسة القانون"، طبعة عام ١٩٧٥م، دار النهضة العربية.

٤٩- د/ عثمان خليل: "النظام الدستوري المصرى"، طبعة عام ١٩٤٢م.

٥٠- د/ عز الدين عبد الله: "القانون الدولي الخاص"، الطبعة الحادية عشر، عام ١٩٨٦م، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب.

٥١- د/ عصام أنور سليم، د/ محمد حسن قاسم: "مبادئ القانون"، المدخل إلى القانون، طبعة عام ١٩٩٣م، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية.

٥٢- د/ على حسين نجيدة: "المدخل لدراسة القانون"، نظرية القانون، طبعة عام ١٩٨٤م، دار الفكر العربي.

٥٣- د/ على سيد حسن: "المدخل إلى علم القانون"، الكتاب الأول، نظرية القانون، طبعة عام ١٩٨٣م، دار النهضة العربية.

٥٤- د/ محسن خليل: "النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة"، طبعة عام ١٩٥٩ - ١٩٦٠م.

٥٥- د/ محمد إبراهيم دسوقي: "النظرية العامة للقانون والحق"، طبعة عام ١٩٩٣م.

٥٦- د/ محمد حسام لطفي: "المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء"، نظرية القانون، طبعة عام ١٩٩٣/ ١٩٩٤م.

٥٧- د/ محمد حسنين عبد العال: "القانون الدستوري"، طبعة عام ١٩٧٥م، دار النهضة العربية.

٥٨- د/ محمد حسين عبد العال: "مبادئ القانون"، الجزء الأول، "النظرية العامة للقانون"، طبعة عام ١٩٩٥م، دار النهضة العربية.

٥٩- د/ محمد سامى مدكور: "مبادئ القانون"، طبعة عام ١٩٦٠م، مطبعة الرسالة.

٦٠- د/ محمد سعد خليفة: "محاضرات في المدخل لدراسة القانون"، الجزء الأول، نظرية القانون، طبعة عام ١٩٩٠م.

٦١- د/ محمد على عرفة: "مبادئ العلوم القانونية"، طبعة عام ١٩٥١م، مطبعة السعادة بالقاهرة.

٦٢- د/ محمد كامل ليلة: "القانون الدستورى"، طبعة ١٩٦٣م.

٦٣- د/ محمد لبيب شنب: "مذكرات في المدخل لدراسة القانون"، طبعة عام ١٩٧٥ - ١٩٧٦م، دار النهضة العربية.

٦٤- د/ محمود جمال الدين زكي: "دروس في مقدمة الدراسات القانونية"، الطبعة الثانية، عام ١٩٦٩م، القاهرة.

٦٥- : "الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، طبعة عام ١٩٧٨م.

٦٦- : "التأمينات الشخصية والعينية"، الطبعة الثالثة عام ١٩٧٩م، مطبعة دار الشعب بالقاهرة.

٦٧- د/ محمود محمد حافظ: "القضاء الإداري"، الطبعة السادسة، بدون تاريخ نشر.

٦٨- د/ مصطفي أبو زيد فهمي: "النظام الدستورى للجمهورية العربية المتحدة"، طبعة عام ١٩٦٦م.

٦٩- د/ مصطفي محمد الجمال، أ.د/ جلال على العدوى: "أصول المعاملات"، بدون تاريخ نشر، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية.

٧٠- د/ مفيد شهاب: "القانون الدولى العام"، طبعة ١٩٩٥م، دار النهضة العربية.

٧١- د/ منصور مصطفي منصور: "المدخل لدراسة العلوم القانونية"، طبعة عام ١٩٧٢م، دار النهضة العربية.

٧٢- د/ نزيه محمد الصادق المهدي: "المدخل لدراسة القانون"، نظرية القانون، الطبعة الثالثة عام ١٩٨١م، دار النهضة العربية.

٧٣- د/ نعمان جمعة: "المدخل للعلوم القانونية"، طبعة عام ١٩٧٧م.

- د/ همام محمد محمود، د/ محمد حسين منصور: "مبادئ القانون"، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية.



فهرس الكتاب

فهرس الكتاب

الموضوع **الصفحة**

الجزء الثانى: نظرية الحق.....

مبحث تمهيدى: في التعريف بالحق.....

المطلب الأول: معنى الحق.....

المطلب الثانى: تمييز الحق عن غيره.....

أولا: الفرق بين الحق والمصلحة.....

ثانيا: الفرق بين الحق والسلطة.....

ثالثا: الفرق بين الحق والمكنة.....

رابعا: الفرق بين الحق والحالة الشخصية.....

خامسا: الفرق بين الحق ومجرد الأمل.....

الباب الأول: الشخصية القانونية.....

الفصل الأول: الشخص الطبيعي.....

المبحث الأول: النطاق الزمنى للشخصية الطبيعية....

أولا: بداية الشخصية الطبيعية:.....

الشرط الأول: تمام ولادته.....

الشرط الثاني: ثبوت الحياة.....

- ثبوت الشخصية القانونية للجنين على سبيل الاستثناء....

ثانيا: انتهاء الشخصية القانونية:.....

الوضع القانوني للمفقود:.....

١- متى يحكم بموت المفقود:.....

- **الحالة الأولى:** حالة غلبة الهلاك.....

- **الحالة الثانية:** حالة عدم غلبة الهلاك.....

٢- أثر الحكم أو القرار باعتبار المفقود ميتا:.....

أ- **الأصل العام:** اعتبار المفقود ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار.....

ب- الاستثناء: اعتبار المفقود ميتا من تاريخ الفقد.....

٣- أثر هور المفقود بعد الحكم بموته.....

المبحث الثاني: مميزات الشخص الطبيعي.....

المطلب الأول: اسم الشخص الطبيعي.....

أولا: تحديد الاسم وأهميته.....

ثانيا: التكييف القانوني للاسم.....

ثالثا: أنواع الاسم:.....

١- اسم الشهرة.....

٢- الاسم المستعار.....

٣- الاسم التجاري.....

رابعا: الحماية القانونية للإسم.....

المطلب الثاني: الحالة.....

أولا: الحالة الطبيعية أو الجنس.....

ثانيا: الحالة السياسية أو الجنسية.....

ثالثا: الحالة العائلية:.....

أ- قرابة النسب:.....

القرابة المباشرة.....

القرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي.....

ب- قرابة المصاهرة.....

آثار القرابة .....

المطلب الثالث: الموطن.....

أولا: تعريف الموطن وأهميته وتقسيماته.....

١- الموطن العام:.....

أ- الموطن الإرادي أو الاختياري:.....

ب- الموطن الإلزامي أو القانوني.....

٢- الموطن الخاص:.....

أ- موطن الأعمال.....

ب- موطن القاصر بالنسبة لما يعتبر أهلا لمباشرته من تصرفات.....

جـ- الموطن المختار.....

المبحث الثالث: أهلية الشخص الطبيعي.....

المطلب الأول: أهلية الوجوب.....

أولا: أهلية الوجوب الناقصة.....

ثانيا: أهلية الوجوب الكاملة.....

١- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعا للحالة الطبيعية....

٢- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعا للحالة السياسية....

٣- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعا للحالة العائلية.....

٤- تفاوت مدى أهلية الوجوب تبعا للحالة الدينية.....

المطلب الثاني: أهلية الأداء.....

الفرع الأول: مراحل أهلية الأداء.....

أولا: المرحلة الأولى: مرحلة انعدام الأهلية.....

ثانيا: المرحلة الثانية: مرحلة نقص الأهلية.....

ثانيا: السفه والغفلة.....

الفرع الثاني : عوارض الأهلية .....

الفرع الثالث: موانع الأهلية.....

أولا: الغيبة.....

ثانيا: الحكم بعقوبة جنائية.....

ثالثا: العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني.....

المبحث الرابع: الذمة المالية للشخص الطبيعي.....

المبحث الخامس: أحكام الولاية على المال.....

أولا: الفرق بين أهلية الأداء والولاية على المال.....

ثانيا: القانون المنظم لأحكام الولاية على المال.....

ثالثا: أنواع الولاية على المال.....

المطلب الأول: الولاية على مال القصر.....

المطلب الثاني: الولاية على المحجور عليهم.....

المطلب الثالث: الولاية على مال ذوي الأهلية.....

الفصل الثاني: الشخص المعنوي أو الاعتباري.....

المبحث الأول: تعريف الشخص المعنوي أو الاعتباري وبيان عناصره.....

المبحث الثاني: النطاق الزمني للشخصية المعنوية أو الاعتبارية.....

المبحث الثالث: مميزات الشخصية الاعتبارية أو المعنوية...

أولا: اسم الشخص المعنوي أو الاعتباري.....

ثانيا: موطن الشخص المعنوي أو الاعتباري.....

ثالثا: حالة الشخص المعنوي أو الاعتباري.....

المبحث الرابع: أهلية الشخص الاعتباري أو المعنوي...

أولا: أهلية الوجوب.....

ثانيا: أهلية الأداء.....

المبحث الخامس: الذمة المالية للشخص المعنوي أو الاعتبار.....

المبحث السادس: انواع الشخص المعنوي أو الاعتباري.....

المطلب الأول: الجمعيات.....

المطلب الثاني: المؤسسات الخاصة.....

الباب الثاني: أنواع الحقوق وتقسيماتها.....

الفصل الأول: الحقوق غير المالية.....

المبحث الأول: الحقوق السياسية.....

المبحث الثاني: الحقوق العامة أو حقوق الشخصية...

المبحث الثالث: حقوق الأسرة.....

الفصل الثاني: الحقوق المالية.....

المبحث الأول: الحقوق العينية.....

المطلب الأول: الحقوق العينية الأصلية.....

أولا: حق الملكية.....

ثانيا: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.....

١- حق الانتفاع.....

٢- حق الاستعمال وحق السكنى.....

٣- حق الحكر.....

٤- حق الارتفاق:.....

المطلب الثاني: الحقوق العينية التبعية.....

الفرع الأول: مبررات نشأة فكرة الحقوق العينية التبعية.....

الفرع الثاني: أنواع الحقوق العينية والتبعية في القانون المصري.....

أولا: الرهن الرسمي.....

ثانيا: حق الاختصاص.....

ثالثا: الرهن الحيازي.....

رابعا: حقوق الامتياز.....

المبحث الثاني: الحقوق الشخصية.....

المطلب الأول: محاولة التقريب بين الحق الشخصي والحق العيني.....

المطلب الثاني: الإبقاء على التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي:.....

المطلب الثالث: محل أو موضوع الحق الشخصي..

أولا: الالتزام بعمل.....

ثانيا: الالتزام بالامتناع عن عمل.....

ثالثا: الالتزام بإعطاء.....

المبحث الثالث: الحقوق الذهنية.....

الفرع الأول: المقصود بحق المؤلف.....

أولا: المؤلف.....

ثانيا: المصنف.....

١- المصنف الفردي.....

٢- المصنف المشترك.....

٣- المصنف الجماعي.....

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحق المؤلف.....

الفرع الثالث: مضمون حق المؤلف.....

أولا: مضمون الحق الأدبي للمؤلف .....

خصائص الحق الأدبي للمؤلف.....

ثانيا: مضمون الحق المالي في حق المؤلف.....

خصائص الحق المالي للمؤلف.....

الباب الثالث: محل الحق.....

الفصل الأول: الأشياء.....

المبحث الأول: الأشياء المادية والأشياء المعنوية....

المبحث الثاني: الأشياء القابلة للتعامل والأشياء الخارجية عن دائرة التعامل.....

المبحث الثالث: العقارات والمنقولات.....

المطلب الأول: أساس التقسيم وأهميته:.....

المطلب الثاني: العقارات.....

أولا: العقارات بالطبيعة.....

ثانيا: العقارات بالتخصيص.....

المطلب الثالث: المنقولات.....

أولا: المنقولات بالطبيعة.....

ثانيا: المنقولات بحسب المال.....

ثالثا: المنقولات المعنوية.....

المبحث الرابع: الأشياء المثلية والأشياء القيمية.....

المبحث الخامس: الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك..... .....

الفصل الثاني : الأعمال .....

المراجع .....

الفهرس: .....